

2026 대비 스터디파이터 2차 보상법규 행정법 기본서

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
필수 기본서

제1판

01

PART

행정법 개관

제1장 행정과 행정법

제1절	행정법 개념 및 분류	001
제2절	행정법의 법원	002
제3절	법치행정의 원칙	004
제4절	법령의 개정과 적용	006

제2장 일반원칙

제1절	헌법에서 도출되는 일반원칙	009
제2절	모든 법의 일반원칙	016

제3장 행정법관계

제1절	공법관계와 사법관계	019
제2절	행정법 관계의 당사자	020
제3절	공권	021

02

PART

행정작용법

제1장 행정입법

제1절	법규명령	025
제2절	행정규칙	030
제3절	형식과 실질의 불일치	034

제2장 행정행위

제1절	행정행위의 개념	039
제2절	행정행위의 분류	042
제3절	기속행위와 재량행위	052
제4절	행정행위의 요건	056
제5절	행정행위의 효력	058
제6절	구성요건적 효력과 선결문제	061
제7절	행정행위의 하자	065
제8절	행정행위의 취소·철회·실효	077
제9절	행정행위의 부관	081

제3장 그 밖의 행정의 주요 행위형식

제1절	단계적 행정결정	087
제2절	행정계획	092
제3절	인허가의제 제도	098
제4절	공법상 계약	101
제5절	행정상 사실행위	104
제6절	행정지도	106

03

PART

행정절차와 실효성 확보수단

제1장 행정절차

제1절	행정절차 일반론	109
제2절	처분의 공통절차	110
제3절	수익적 처분의 절차	113
제4절	침익적 처분의 절차	114
제5절	절차상 하자	120

제2장 행정의 실효성 확보수단

제1절	행정강제	121
제2절	대집행	125
제3절	행정벌	133
제4절	새로운 실효성 확보수단	135
제5절	행정조사	141

04

PART

행정쟁송

제1장 행정심판

제1절	행정구제의 체계	145
제2절	행정심판의 개요	146
제3절	행정심판의 종류	150
제4절	청구요건	152
제5절	가구제	155
제6절	행정심판의 심리·재결	157

제2장 취소소송

제1절	행정소송의 개요	161
제2절	취소소송의 소송요건	164
제3절	대상적격	167
제4절	원고적격	180
제5절	협약의 소익	184
제6절	가구제	188
제7절	처분사유의 추가·변경	193
제8절	취소소송의 심리와 판결	197

제3장 무효등확인소송 219**제4장 부작위위법확인소송** 223**제5장 당사자소송** 227**05
PART****행정상 손해전보****제1장 행정상 손해배상**

제1절	행정상 손해배상(국가배상)	231
제2절	국가배상책임의 요건	234
제3절	국가배상과 관련된 논점	237

PART 01

행정법 개관

Chapter 01 행정과 행정법

Chapter 02 일반원칙

Chapter 03 행정법관계

제1절 행정법의 개념 및 분류

01 개요

- ① 행정법이란 행정의 조직, 작용 및 행정구제에 관한 국내공법이다.
- ② 여기서 행정이란 정부가 하는 모든 작용을 말하는데, 행정법은 이러한 행정을 대상으로 한 법이다.
- ③ 행정법은 다양하게 분류할 수 있는데, 적용분야와 그 내용을 기준으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

02 일반행정법과 특별행정법

- ① 일반행정법은 모든 행정분야에 공통적으로 적용되는 표준적인 법규와 법 원칙을 말한다.
(예 행정기본법, 행정절차법 등)
- ② 특별행정법은 공행정의 개별적인 분야에 적용되는 법을 말한다.(예 공무원법, 도로법 등)

03 행정조직법, 행정작용법, 행정구제법

- ① 행정조직법은 행정을 위한 전제로 필요한 행정의 조직 구성과 조직의 권한을 정하는 법을 말한다.
- ② 행정작용법은 행정주체가 행정의 상대방에게 행정작용을 함에 있어 필요한 권리와 의무를 정하는 법을 말한다.
- ③ 행정구제법은 행정작용으로 인한 개인의 권리침해에 대한 구제에 관한 법을 말한다.

행정법총론	행정법총칙	법치행정, 행정법의 법원, 개인의 주관적 공권 등	
	광의의 행정작용법	협의의 행정작용법 (행정의 행위형식론)	행정행위, 행정입법, 행정계획, 행정상 사실행위, 행정지도, 행정계약, 확약 등
		행정절차	행정절차법
		정보공개	공공기관의 정보공개에 관한 법률
		행정강제	행정대집행법 등 개별 법률(행정기본법 제30조 내지 제33조)
	행정구제법	국가책임법	국가배상제도 : 국가배상법
			손실보상제도 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률
		행정쟁송법	행정심판제도 : 행정심판법
			행정소송제도 : 행정소송법
행정법각론	행정조직법, 공무원법, 지방자치법, 공물법 등		

01 법원의 개념과 체계

1) 개요

- ① 법원(法源)이란 법의 존재형식을 말한다.
- ② 법원은 조문의 형태로 존재하는 성문법원과 그렇지 않은 불문법원으로 구분된다.
- ③ 원칙적으로 행정은 국민의 예측가능성과 법적 안정성이 중요하므로 성문법으로 규율하는 것이 원칙이나 행정의 규율대상이 복잡·다양하여 내용상 불문법에 의해 보완된다.

2) 법원의 체계

- ① 행정법의 성문법원에는 헌법, 법률, 명령, 자치법규 등이 있으며, 이들은 헌법을 최고 정점으로 하여 통일적, 단계적 구조를 이루고 있다.
- ② 하위법은 상위법에 맞게 해석하여야 하며, 법령 사이에 상호 모순이 있을 때는 상위법이 우선한다.
- ③ 불문법에는 행정관습법, 조리 등을 들 수 있으며, 이는 중요한 보충적 법원이 된다.

02 성문법원

1) 헌법

국가의 최고규범으로 헌법 내용 중 행정조직과 행정작용 및 행정구제에 관한 규정, 특히 기본권에 관한 규정은 행정법의 법원 중 가장 기본적 법원이 된다.

2) 법률

국회가 제정한 법률로서, 법률이 충돌할 경우 특별법이 일반법에 우선하고, 신법이 구법에 우선한다.

3) 명령

- ① 행정권에 의해 제정된 규범으로 행정법의 법원이 된다.
- ② 행정입법은 대외적 구속력(법규성) 유무에 따라 법규성이 있는 법규명령과 법규성이 없는 행정규칙으로 구분된다.
- ③ 이 중 행정규칙이 법원에 포함되는지에 대해 이견이 있으나 법규성을 지닌 행정규칙은 예외적으로 법원성이 인정된다.(예) 법령보충적 행정규칙)

4) 자치법규

지방자치단체가 법령안에서 제정하는 법규로서, 지방의회가 제정하는 조례와 지방자치단체 장이 정하는 규칙이 있다.

1) 행정관습법

(1) 개념

관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말한다.

(2) 종류

a. 행정선례법

행정청의 선례가 반복되어 성립된 것이다. [행정절차법], [국세기본법]에 명문조항이 있다.

[행정절차법] 제4조 (신의성실 및 신뢰보호)

- ② 행정청은 법령등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여졌을 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 따라 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니 된다.

b. 민중적 관습법

행정법관계에 대한 국민의 관행에 의해 성립된 것이다. (예) 수산업법상 관행입어자)

[수산업법] 제2조 (정의)

입어자(入漁者)란 제48조에 따라 어업신고를 한 자로서 마을어업권이 설정되기 전부터 해당 수면에서 계속하여 수산동식물을 포획·채취하여 온 사실이 대다수 사람들에게 인정되는 자 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 어업권원부에 등록된 자를 말한다.

2) 조리

조리란 사회에서 일반적으로 인정되는 정의·형평을 말하는 것으로 행정법의 불문법원이 된다.

3) 판례법에 대한 논의

- ① 대법원 판례 : 대륙법계 국가인 우리나라에서는 판례의 법원성이 인정되지 않는다.
 ② 헌법재판소 판례 : [헌법재판소법]에서 현재의 위헌결정에 기속력을 부여하고 있다.

4) 일반원칙

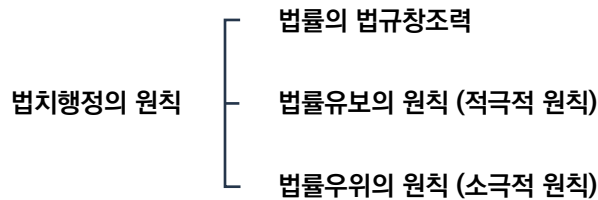
- ① 비례원칙, 평등원칙, 신뢰보호원칙 등의 일반원칙은 헌법에 근거한 것으로서 헌법적 효력을 갖는다.
 ② 따라서 성문법원의 흠결시 보충적으로 적용되는 관습법, 조리 등과 달리 오히려 법률보다 우위에서 다른 성문법이나 그에 따른 처분의 적법성을 판정하는 기준이 된다.

01 개요

- ① 법치행정의 원칙이란 행정도 법에 따라서 행하여져야 한다는 원칙이다.
- ② 만일 행정권에 의하여 국민의 권익이 침해된 경우에는 이의 구제를 위한 제도를 위한 제도가 보장되어야 한다는 것을 의미한다.
- ③ 법치행정의 목적은 행정의 예견가능성을 보장하는데 있다.

[행정기본법] 제8조 (법치행정의 원칙)

행정작용은 법률에 위반되어서는 아니 되며, 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 경우와 그 밖에 국민생활에 중요한 영향을 미치는 경우에는 법률에 근거하여야 한다.



02 법률의 법규창조력

- ① 국민의 권리·의무에 구속력을 가지는 법규는 의회가 제정한 법률에 의해서만 창조되어야 한다는 원칙이다.
- ② 다만, 오늘날 다양화·전문화된 사회에서 모든 사항을 법률로 제정하는 것은 불가능하므로, 법률에서 수권을 받는 전제로 행정입법이 폭넓게 인정되고 있다.

03 법률유보의 원칙

CASE

국도교통부장관이 법률에 명시된 사유없이 감정평가사 甲에게 업무정지 처분을 내린 경우, 이러한 처분이 적법한지 검토하시오.

1) 의의

행정작용이 행하여지기 위해서는 법률의 근거가 있어야 한다는 원칙을 말한다.

2) 법률의 범위

- ① 원칙적으로 국회에서 법률제정의 절차에 따라 만들어진 형식적 의미의 법률을 의미한다.
- ② 따라서 국회의 의결을 거치지 않은 불문법은 포함되지 않는다.
- ③ 이 원칙은 행정작용이 법률에 근거하여 이루어져야 한다는 것을 의미하므로, 법률에 근거가 있으면 그 법률의 위임을 받은 하위 법령(법규명령)에 의해서도 행정작용이 가능하다.

3) 학설

법률에 근거가 있어야 하는 행정의 범위가 어디까지인가에 대하여 학설의 대립이 있다.

(1) 침해행정유보설

국민의 자유·재산 등에 침해적인 행정에는 법률적 근거가 필요하나 그 외의 행위에는 필요없다고 본다.

(2) 급부행정유보설

침해행정 뿐만 아니라 급부행정에도 법률적 근거가 필요하다는 견해이다.

(3) 전부유보설

모든 행정작용이 법률에 근거해야 한다는 견해이다.

(4) 권력행정유보설

행정작용이 권력작용이면 법적근거가 필요하나, 비권력적 작용이면 필요없다는 견해이다.

(5) 중요사항유보설(본질사항유보설)

중요사항은 반드시 법률의 근거를 요하지만, 비중요사항에 대해서는 법률의 근거를 요하지 않는다는 견해이다.

4) 판례

대법원과 헌법재판소는 모두 중요사항유보설의 견해를 취하고 있다.

관련 판례

오늘날 법률유보원칙은 단순히 행정작용이 법률에 근거를 두기만 하면 충분한 것이 아니라, 국가공동체와 그 구성원에게 기본적으로 중요한 의미를 갖는 영역, 특히 국민의 기본권실현과 관련된 영역에 있어서는 국민의 대표자인 입법자가 그 본질적인 사항에 대해서 스스로 결정한다는 요구까지 내포하고 있다.(헌재)

04 법률우위의 원칙

1) 의의

- ① 모든 행정작용은 법률에 위반되어서는 안 된다는 것을 의미한다.
- ② 행정은 법률 뿐만 아니라 헌법, 법률, 명령, 자치법규, 법의 일반원칙 등 모든 법을 위반하여서는 안된다.
(불문법 포함, 행정규칙은 제외)

2) 내용

법률의 우위의 원칙은 행정의 모든 영역에 적용된다. 수익적 행위인가, 침익적 행위인가를 가리지 않는다.

01 처분시법 적용원칙 [★]

1) 원칙과 제한

- ① 행정처분은 처분시법에 의함이 원칙이다.
- ② 다만 처분시법 원칙은 소급금지원칙에 따른 제한을 받는다.
- ③ 또한 신법에 경과규정이 마련된 경우 경과규정에 따르면 된다.
- ④ 경과규정이란 법령의 제정이나 개폐시 종전 규정과 새 규정의 적용범위를 설정해 둔 규정을 말하며 보통 법령의 부칙에 규정된다.

2) 신청에 따른 처분

- ① 신청에 따른 처분은 특별한 사정이 없는 한 처분시 법령에 따른다.
- ② 다만 행정청이 별다른 이유 없이 신청에 대한 처리를 지연하였는데 그 사이 법령이 불리하게 바뀌어 국민이 불이익을 입게 된 경우라면 신청시법을 적용해야 한다.

[행정기본법] 제14조 (법 적용의 기준)

- ② 당사자의 신청에 따른 처분은 법령등에 특별한 규정이 있거나 처분 당시의 법령등을 적용하기 곤란한 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 처분 당시의 법령등에 따른다.

3) 제재처분의 경우

- ① 위반행위에 대한 제재처분은 처분시법의 원칙이 적용되지 않고 위반행위시법에 따른다.
- ② 다만 처분시법을 적용하는 것이 위반행위시법을 적용하는 것보다 국민에게 유리한 경우 처분시법을 적용한다.

[행정기본법] 제14조 (법 적용의 기준)

- ③ 법령등을 위반한 행위의 성립과 이에 대한 제재처분은 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법령등을 위반한 행위 당시의 법령등에 따른다. 다만, 법령등을 위반한 행위 후 법령등의 변경에 의하여 그 행위가 법령등을 위반한 행위에 해당하지 아니하거나 제재처분 기준이 가버워진 경우로서 해당 법령등에 특별한 규정이 없는 경우에는 변경된 법령등을 적용한다.

02 소급적용금지의 원칙 [★]

1) 의의 및 취지 (행정기본법 제14조)

- ① 법령은 그 효력이 생긴 때를 기준으로 하여 그 이후에 발생한 사실에 대하여서만 적용된다는 원칙을 말한다.
- ② 이는 법치국가원칙의 내용인 법적 안정성에서 비롯된 원칙이다.

[행정기본법] 제14조 (법 적용의 기준)

- ① 새로운 법령등은 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 법령등의 효력 발생 전에 완성되거나 종결된 사실관계 또는 법률관계에 대해서는 적용되지 아니한다.

2) 진정소급과 부진정소급

- ① 법령의 소급이란 새로운 법령을 그 시행 후 사안뿐만 아니라, 그 시행 전 사안에까지 적용시키는 것을 의미한다.
- ② 진정소급 : 이미 종료된 사안에까지 신법령을 적용시키는 것(원칙적으로 금지)
- ③ 부진정소급 : 아직 진행 중인 사안에 신법령을 적용시키는 것(허용되나 일부 제한)

3) 예외

- ① 판례는 진정소급을 원칙적으로 허용하지 않는다.
- ② 다만 신뢰이익이 적거나, 공익이 중대한 경우, 국민과 직접 이해관계가 없거나 오히려 유리한 경우 등 예외적인 경우에만 진정소급을 허용한다.

03 소급입법금지의 원칙 [★]

CASE

공익사업에 따라 농업손실보상 대상자인 甲의 농지가 사업인정고시 이후 수용될 예정인 상황에서, 영농손실보상의 산정기준 중 실제소득 보상의 한도를 변경하는 내용의 시행규칙이 개정되었다. 개정된 시행규칙 제48조 제2항 단서 제1호는, 규칙 시행일 이전에 사업인정고시가 이루어진 경우에도 같은 조항 적용을 명시하고 있다. 이러한 규정 적용이 진정소급입법에 해당하는지 여부를 관련 법리 및 판례에 따라 논하시오.

1) 의의 및 취지

- ① 이미 종결된 사실관계 또는 법률관계에 적용하는 것을 내용으로 하는 법을 제정하는 것을 금지하는 원칙을 말한다.
- ② 이는 법적 안정성을 내용으로 하는 법치국가원리에 근거한 헌법적 효력을 갖는 원칙이다.

2) 적용 범위

(1) 진정소급입법

- ① 진정소급입법은 법적 안정성에 비추어 볼 때 원칙적으로 금지된다.
- ② 다만, 헌법재판소는 국민이 소급입법을 예상할 수 있었거나, 법적 상태가 불확실하고 혼란스러워 보호할만한 신뢰이익이 적은 경우에는 예외적으로 허용된다고 한 바 있다.

(2) 부진정소급입법

- ① 부진정소급입법은 엄밀한 의미에서 소급입법이 아니므로 원칙적으로 이러한 입법을 하는 것은 허용된다.
- ② 그러나 이 경우에도 소급효를 요구하는 공익상의 사유와 신뢰보호의 요청 사이의 이익형량과정에서 신뢰보호의 관점이 입법형성권에 제한을 가하게 된다는 것이 판례의 입장이다.

사업인정고시일 전부터 해당 토지를 소유하거나 사용권원을 확보하여 적법하게 농업에 종사해 온 농민은 사업인정고시일 이후에도 수용개시일 전날까지는 해당 토지에서 그간 해온 농업을 계속할 수 있다. 그러나 사업인정고시일 이후에 수용개시일 전날까지 농민이 해당 공익사업의 시행과 무관한 어떤 다른 사유로 경작을 중단한 경우에는 손실보상의 대상에서 제외될 수 있다. 사업인정고시가 이루어졌다는 점만으로 농민이 구체적인 영농보상금 청구권을 확정적으로 취득하였다고는 볼 수 없으며, 보상협의 또는 재결절차를 거쳐 협의성립 당시 또는 수용재결 당시의 사정을 기준으로 구체적으로 산정되는 것이다.

또한 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제48조에 따른 영농보상은 수용개시일 이후 편입농지에서 더 이상 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실에 대하여 장래의 2년간 일실소득을 예측하여 보상하는 것이므로, 수용재결 당시를 기준으로 영농보상은 아직 발생하지 않은 장래의 손실에 대하여 보상하는 것이다.

따라서 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 부칙(2013. 4. 25.) 제4조 제1항이 영농보상 금액의 구체적인 산정방법·기준에 관한 2013. 4. 25. 국토교통부령 제5호로 개정된 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 '개정 시행규칙'이라 한다) 제48조 제2항 단서 제1호를 개정 시행규칙 시행일 전에 사업인정고시가 이루어졌으나 개정 시행규칙 시행 후 보상계획의 공고·통지가 이루어진 공익사업에 대해서도 적용하도록 규정한 것은 진정소급입법에 해당하지 않는다.

제1절

헌법에서 도출되는 일반원칙

01 신뢰보호 원칙 [★★★]

CASE

【문제 1】甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2002년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린 공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

- 1) 甲은 乙이 2010년 3월 그의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정한 것은 신뢰보호의 원칙에 위배된다고 주장한다. 甲주장의 타당성에 대해 논하시오. (24회 1번 변형)

1) 의의 및 근거

- ① 신뢰보호원칙이란 행정기관의 적극적, 소극적 언동에 대한 국민의 보호가치 있는 신뢰는 보호해주어야 한다는 원칙을 말한다.
- ② 행정기본법 제12조, 행정절차법 제4조 제2항에 근거를 둔다.

[행정기본법] 제12조 (신뢰보호의 원칙)

- ① 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.

[행정절차법] 제4조 (신의성실 및 신뢰보호)

- ② 행정청은 법령등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여졌을 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 따라 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니 된다.

2) 요건 [선보조인반]

(1) 행정기관의 선행조치

- ① 행정기관의 상대방인 국민에 대한 신뢰를 주는 어떠한 선행조치가 있어야 한다.
- ② 선행조치는 법령, 행정행위, 확약, 행정계획, 행정지도 등 국민이 신뢰를 가질 수 있는 일체의 조치를 말하는데, 적극적인 행위뿐만 아니라 소극적인 행위와 묵시적인 행위도 포함된다

(2) 보호가치 있는 신뢰(상대방의 무귀책)

- ① 선행조치에 대한 상대방의 신뢰가 보호가치 있는 것이어야 한다.
- ② 즉, 상대방 등에게 귀책사유(책임있는 사유)가 있어서는 안된다.

- ③ 상대방의 귀책사유란 행정청의 선행조치의 하자가 상대방의 부정행위에 기인한 것이거나, 행정청의 견해표명에 하자가 있음을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우까지 포함한다.
- ④ 귀책사유가 없는 한 위법한 행정조치에 대한 신뢰도 보호된다.

(3) 상대방의 조치

- ① 상대방인 국민이 행정기관의 선행조치에 대한 신뢰에 입각하여 어떠한 조치를 취하여야 한다.
- ② 신뢰보호의 원칙의 목적은 선행조치를 믿고 어떠한 행위를 한 사인을 보호하기 위한 것이므로 단순히 선행조치를 신뢰한 것만으로는 부족하고, 사인의 후행 조치(자본투자, 업무수행 등)가 필요하다.

(4) 인과관계

행정기관의 선행조치와 이를 신뢰하고 행한 국민의 조치 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다.

(5) 선행조치에 반하는 후행행위

- ① 행정기관이 선행조치를 하였고 이를 신뢰한 상대방이 일정한 조치를 하였는데, 행정기관이 상대방의 신뢰에 반하는 행정권의 행사를 하여 상대방의 권익이 침해되어야 한다.
- ② 즉, 선행조치에 반하는 후행행위로 인해 구체적인 사인의 권익 침해가 있을 것을 요건으로 한다.

3) 한계

(1) 법률적합성과 충돌

- ① 행정의 법률적합성의 원칙(공익추구)과 신뢰보호의 원칙(사익추구)은 서로 충돌할 수 있다.
- ② 이 경우 판례는 적법 상태의 실현에 의해 달성되는 공익과 행정작용의 존속에 대한 상대방의 신뢰보호를 이익형량하여 결정하여야 한다는 입장이다.

(2) 공익 또는 제3자의 이익과 이익형량

- ① 신뢰보호의 원칙에 대한 요건이 충족되더라도 선행조치대로 하는 것이 공익 또는 제3자의 이익을 해할 수 있다.
- ② 이 경우 신뢰보호이익(사익)과 공익 또는 제3자의 이익을 이익형량하여야 하며, 공익 또는 제3자의 이익이 더 큰 경우 신뢰보호원칙 적용은 제한된다.

(3) 사정변경

공적견해표명이 있는 후에 그 전제로 된 사실적·법률적 상태가 변경되었다면 그러한 견해표명은 효력을 잃게 되어 상대방은 신뢰보호원칙을 주장할 수 없게 된다.

4) 위반의 효과

신뢰보호원칙에 위반한 행정작용은 위헌·위법한 행정작용이 되며 행정쟁송 및 국가배상을 청구할 수 있다.

대법원 2005. 3. 10. 선고 2002두5474 판결 [도시계획변경결정취소청구]

행정청이 용도지역을 자연녹지지역으로 지정결정하였다가 그보다 규제가 엄한 보전녹지지역으로 지정결정하는 내용으로 도시계획을 변경한 경우, 행정청이 용도지역을 자연녹지지역으로 결정한 것만으로는 그 결정 후 그 토지의 소유권을 취득한 자에게 용도지역을 종래와 같이 자연녹지지역으로 유지하거나 보전녹지지역으로 변경하지 않겠다는 취지의 공적인 견해표명을 한 것이라고 볼 수 없고, 토지소유자가 당해 토지 지상에 물류창고를 건축하기 위한 준비 행위를 하였더라도 그와 같은 사정만으로는 용도지역을 자연녹지지역에서 보전녹지지역으로 변경하는 내용의 도시계획 변경결정이 행정청의 공적인 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래된 것이라고도 볼 수 없다는 등의 이유로, 신뢰보호의 원칙이 적용되지 않는다.

02 실권의 법리

CASE

감정평가사 甲이 시험을 합격 후 국토교통부장관에게 등록을 신청하였고 2010년 자격증을 교부받았다. 그러나 갑은 평가업무를 하던 중 허위감정평가로 구속되어 징역 2년의 집행유예 5년을 선고받은 경우, 이에 국토교통부장관은 2011년경 보고를 받았으나 갑의 등록을 취소하지 않다가 2015년에 이르러서야 등록을 취소하려고 한다. 국토교통부장관의 갑의 등록취소는 타당한가?

1) 의의 및 근거

- ① 행정청이 취소권, 철회권 등을 장기간 권리 행사를 하지 않아 이에 대한 신뢰가 형성된 경우 권리행사를 할 수 없다는 법리를 말한다.
- ② 행정기본법 제12조 제2항에 근거한다.(신뢰보호원칙에 기초)

[행정기본법] 제12조 (신뢰보호의 원칙)

- ② 행정청은 권한 행사의 기회가 있음에도 불구하고 장기간 권한을 행사하지 아니하여 국민이 그 권한이 행사되지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 그 권한을 행사해서는 아니 된다.
다만, 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우는 예외로 한다.

2) 요건 [권장신]

- ① 행정청이 취소권, 철회권 등 **권**리행사를 할 수 있었으나(몰랐던 경우에는 적용안됨.)
- ② **장**기간 권리를 불행사하여
- ③ 상대방인 국민에게 행정청이 더는 권리를 행사하지 않을 것으로 귀책사유 없는 **신**뢰가 형성되어야 한다.

3) 효과

행정청은 더 이상 그 권리를 행사하지 못하게 된다.

4) 신뢰보호원칙과의 관계

- ① 실권의 법리는 신뢰보호의 원칙의 파생법리이므로 실권의 법리가 성립되면 신뢰보호원칙보다 우선 적용된다.
- ② 실권의 법리가 성립하지 않는 경우에 신뢰보호의 원칙의 적용요건이 충족되면 신뢰보호의 원칙이 적용된다.

03 평등의 원칙 [★]

CASE

甲과 乙은 불법형질변경토지이다. 따라서 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라서 갑은 종전 이용상황인 전으로 보상한 반면, 을은 1995.1.7 이전에 공익사업시행지구에 편입되어 현황인 대지로 보상받는다. 이에 甲은 합리적인 이유없이 차별하였다고 주장한다. 甲 주장의 타당성을 검토하시오.

1) 평등의 원칙 의의 및 근거

- ① 평등의 원칙은 불합리한 차별을 하여서는 안된다는 원칙이다.
- ② 헌법 제11조로부터 도출되는 불문법 원칙으로서 행정기본법 제9조에 이를 명문화하고 있다.

[헌법] 제11조

- ① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

[행정기본법] 제9조 (평등의 원칙)

행정청은 합리적 이유 없이 국민을 차별하여서는 아니 된다.

2) 요건 및 한계

- ① 합리적인 이유 없이 동일한 사항을 다르게 취급하는 것은 평등의 원칙에 위반된다.
- ② 단, 불법 앞의 평등 요구는 인정되지 않는다.

04 자기구속의 원칙 [★]

CASE

국토교통부장관은 내부규칙을 통해, 10년간 징계 기록 없이 업무를 수행한 감정평가법인 등에 대해 업무정지 처분이 내려질 경우 해당 정지 기간을 1/2로 감경하는 기준을 마련하고, 이를 수년간 반복적으로 적용하여 왔다.

A법인은 수수료 요율을 1회 위반하여 업무정지 1개월의 징계를 받았으나, 10년간 무사고 감정평가법인에 해당함에도 불구하고 위 감경 기준이 적용되지 않았다. 이에 대해 A법인은 해당 처분이 국토교통부장관이 스스로 설정하고 일관되게 적용해 온 내부 기준을 일탈한 것으로, 자기구속의 원칙에 위배된다고 주장하고 있다.

1) 의의 및 근거

- ① 행정관행이 성립된 경우 행정청은 특별한 사정이 없는 한 같은 사안에서 행정관행과 같은 결정을 하여야 한다는 원칙을 말한다.
- ② 기속행위의 경우 행정청에게 인정되는 선택의 자유가 없으므로 자기구속의 원칙이 적용되지 않으며, 행정청의 재량이 인정되는 경우에 한하여 적용된다.
- ③ 평등의 원칙에 근거하며, 자기구속의 원칙에 반하는 행정권 행사는 위법한 것이 된다(행정기본법에 조문 없음).

2) 요건

- ① 재량행위의 영역일 것
- ② 행정관행과 동일한 사안일 것
- ③ 행정선례가 존재할 것

3) 선례필요여부에 대한 견해의 대립

(1) 학설

- ① 반복적인 행정선례가 필요하다는 견해(선례필요설)
- ② 1회의 행정선례로 족하다는 견해(1회 선례 충분설)
- ③ 재량준칙의 존재만으로 자기구속을 인정할 수 있다는 견해(선례불요설)가 있다.

(2) 판례

재량준칙이 되풀이 시행되어 행정관행이 이루어진 경우 자기구속의 원칙이 적용된다고 보고 있다.(선례필요설)

(3) 검토

- ① <1회 선례 충분설>은 행정을 경직화시킬 우려가 있고,
- ② <선례 불요설>은 행정규칙의 법규성을 인정하는 결과를 초래한다는 점에서 문제가 있다.
- ③ 반복적인 선례가 되풀이되어 행정관행이 있어야 한다고 보는 판례의 입장과 같이 <행정관행설>이 타당하다.

4) 적용한계

- ① 위법한 처분에 대하여는 인정되지 않는다.
- ② 새로운 사정변경이 있는 경우에는 행정관행과 다른 처분을 할 공익상 필요가 심히 큰 경우에 한하여 행정관행과 다른 처분을 하는 것이 가능하다.

대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두13132

위법한 행정처분이 수차례에 걸쳐 반복적으로 행하여졌다 하더라도 그러한 처분이 위법한 것인 때에는 행정청에 대하여 자기구속력을 갖게 된다고 할 수 없다.

5) 재량준칙과의 관계

- ① 재량준칙(행정규칙)은 대외적 구속력이 없어, 행정규칙을 위반하였다고 해서 위법한 행정행위가 되는 것은 아니다.
- ② 그러나 행정청이 재량준칙(행정규칙)을 마련하여 이에 따라 반복하여 행정작용을 하였을 경우, 자기구속의 원칙에 의해 그 재량준칙은 간접적으로 대외적 구속력을 갖게 된다.

05 비례의 원칙 [★★★]

CASE

콘크리트 제조 공장 부지가 수용되면 공장 운영의 차질 및 콘크리트 공급 감소로 인한 건설현장의 대혼란을 야기할 수 있으므로 문화유산 보호의 이유로는 비례의 원칙에 따라서 수용할 수 없다고 주장한다.
주장의 타당성 여부를 검토하십시오. (36회 문1번 변형)

1) 의의 및 근거

- ① 과잉조치금지의 원칙이라고도 하는데, 행정작용에 있어서 행정목적과 행정수단 사이에는 합리적인 비례관계가 있어야 한다는 원칙을 말한다.
- ② 헌법 제37조 제2항으로 도출되는 불문법 원칙으로서 행정기본법 제10조에서 이를 명문화하고 있다.

[헌법] 제37조

- ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

[행정기본법] 제10조 (비례의 원칙)

행정작용은 다음 각 호의 원칙에 따라야 한다.

1. 행정목적의 달성하는 데 유효하고 적절할 것
2. 행정목적의 달성하는 데 필요한 최소한도에 그칠 것
3. 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것

2) 내용 [적필상]

(1) 적합성의 원칙 (행정기본법 제10조 제1호)

행정은 추구하는 행정목적의 달성에 적합한(유용한) 수단을 선택하여야 한다는 원칙을 말한다.

(2) 필요성의 원칙 (행정기본법 제10조 제2호)

적합한 수단이 여러 가지인 경우에 국민의 권리를 최소한으로 침해하는 수단을 선택하여야 한다는 원칙이다.

(3) 상당성의 원칙 (행정기본법 제10조 제3호)

- ① 행정작용을 함에 있어 달성되는 공익보다 침해되는 국민의 권익이 더 크다면 그러한 행정조치를 취해서는 안 된다는 원칙을 말한다.
- ② 이는 협의의 비례원칙이라고도 하며, 공익과 사익 간의 이익형량을 통해 판단한다.

(4) 3원칙의 상호관계

- ① 적합의 원칙부터 상당성의 원칙까지 단계적으로 심사를 하여 비례의 원칙의 위반 여부를 판단한다.
- ② 즉 적합한 여러 개의 수단 중에서 최소한의 침해를 가져오는 수단을 선택하여야 하고 그러한 행정조치로 인해 달성되는 공익이 침해되는 사익보다 더 커야 한다.

3) 관련 판례

대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051 판결

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 사업으로 결정하는 것으로서 공익사업의 시행자에게 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 일정한 내용의 수용권을 설정하여 주는 형성행위이므로, 해당 사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당한다고 하더라도 사업인정기관으로서 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부와 공익성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 관하여 사업인정에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다.

CASE

국토교통부장관이 폐기물처리시설 사업시행자 甲에게 사업인정을 하면서 폐기물 처리시설부지의 50%를 녹지공간으로 조성하여 기부채납하도록 조건을 붙인 경우 부당결부금지의 원칙에 반하는지 검토하시오.

1) 의의 및 근거

- ① 행정기관이 행정작용을 함에 있어 상대방에게 그것과 실질적인 관련이 없는 반대급부를 결부시켜서는 안 된다는 원칙을 말한다.
- ② 부당결부금지의 원칙은 행정행위의 부관에서 주로 적용된다.
- ③ 행정기본법 제13조에 그 근거를 둔다.

[행정기본법] 제13조 (부당결부금지의 원칙)

행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다.

2) 요건 [공반실]

- ① 행정청의 공권력 행사가 있을 것
- ② 공권력의 행사가 상대방의 반대급부와 결부되어 있을 것
- ③ 공권력의 행사와 반대급부 사이에 실질적 관련성이 없을 것

3) 실질적 관련성의 판단

- ① 실질적 관련성은 <원인적 관련성>과 <목적적 관련성>을 그 내용으로 한다.
- ② 원인적 관련성 : 행정작용과 반대급부 사이에 직접적인 인과관계가 있어야 함을 말한다.
- ③ 목적적 관련성 : 행정작용과 반대급부가 동일한 행정목적에 추구하여야 함을 말한다.

대법원 1997. 3. 11. 선고 96다49650 판결 [소유권이전등기말소]

지방자치단체장이 사업자에게 주택사업계획승인을 하면서 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지를 기부채납 하도록 하는 부관을 주택사업계획승인에 붙인 경우, 그 부관은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하지만, 지방자치단체장이 승인한 사업자의 주택사업계획은 상당히 큰 규모의 사업임에 반하여, 사업자가 기부채납한 토지 가액은 그 100분의 1 상당의 금액에 불과한 데다가, 사업자가 그 동안 그 부관에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니하다가 지방자치단체장이 업무착오로 기부채납한 토지에 대하여 보상협조요청서를 보내자 그 때서야 비로소 부관의 하자를 들고 나온 사정에 비추어 볼 때 부관의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고는 볼 수 없다.

01 성실의무의 원칙 [★]

CASE

국토교통부장관이 사업자 선정에서 A가 더 기술우위에 있음에도 제출된 서류를 제대로 확인하지 않아서 B를 선정한 경우 성실의무의 원칙에 위반되는지 검토하시오.

1) 의의 및 근거

- ① 성실의무의 원칙이란 행정청은 법령등에 따른 의무를 성실히 수행하여야 한다는 원칙을 말한다.
- ② 행정기본법 제11조 제1항에 근거한다.

[행정기본법] 제11조 (성실의무 및 권한남용금지의 원칙)

- ① 행정청은 법령등에 따른 의무를 성실히 수행하여야 한다.

2) 적용범위 및 위반시 효과

- ① 성실의무의 원칙은 모든 행정작용에 적용된다.
- ② 이에 반하는 행정작용은 무효 또는 취소할 수 있는 행위가 된다.

02 권한남용금지의 원칙 [★★]

CASE

토지소유자 甲은 수용재결 취소소송을 제기하면서, 사업시행자 乙이 사업인정 후 재정상황이 악화되어 해당 공익사업을 수행할 능력을 상실한 상태가 되었음에도 수용재결을 한 위법이 있다고 주장한다. (28회 문1 변형)

1) 의의 및 근거

- ① 행정청이 주어진 행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 안된다는 원칙을 말한다.
- ② 권한남용이란 행정기관의 권한을 법상 정해진 공익 목적에 반하여 행사하는 것을 말한다.
- ③ 행정기본법 제11조 제2항에 규정되어 있다.

[행정기본법] 제11조 (성실의무 및 권한남용금지의 원칙)

- ② 행정청은 행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 아니된다.

2) 적용범위 및 위반시 효과

- ① 성실의무 및 권한남용금지의 원칙은 모든 행정작용에 적용된다.
- ② 이에 반하는 행정작용은 무효 또는 취소할 수 있는 행위가 된다.

사업시행자가 사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 **수용권의 남용에 해당**하여 허용되지 않는다.

제1절

공법관계와 사법관계

01 개념

- ① 법률관계란 법에 의해 규율되는 권리, 의무 관계를 의미한다.
- ② 법률관계는 크게 공법관계와 사법관계로 구분할 수 있으며 소송, 관할법원, 공정력 인정 여부 등에 차이가 있어 구분의 실익이 있다.

구 분	공법관계	사법관계
적용 법원리	공법원리의 적용	사법원리의 적용
소 송	행정소송	민사소송
공정력	권력관계에서는 공정력이 인정	공정력 불인정

02 구별기준

1) 제1차적 기준 : 관련법 규정

- ① 우선 문제의 법률관계를 규율하는 관련 법규정이 제1차적 기준이 된다.
- ② 관련법규가 문제의 법률관계가 공법관계라는 것을 전제로 하고 있는 법규정인 경우에는 그 법률관계는 공법관계이다.
- ③ 즉, 공법에 의해 규율되는 법률관계는 공법관계이다.

2) 제2차적 기준 : 법률관계(또는 행위)의 성질

- ① 관련법규에 의해 공법관계와 사법관계가 명확하게 구별되지 못하는 경우가 있는데 이 경우에는 관련 법규정과 함께 법률관계의 성질을 기준으로 구별하여야 한다.
- ② 법률관계의 성질을 기준으로 한 공법관계와 사법관계의 구별에 관하여 아래의 학설들이 있다.
 - 주체설 : 국가 등 행정주체를 일방 당사자로 하는 법률관계인지
 - 권력설 : 지배복종관계인지 대등한 관계인지
 - 이익설 : 공익의 보호목적인지 사익상호간의 이익조정목적인지
 - 귀속설 : 공권력의 담당자의 지위를 갖는 자에게만 권리 또는 의무를 귀속시키는 법률관계인지 누구에게나 권리 또는 의무를 귀속시키는 법률관계인지
- ③ 판례는 **복수기준설**(상기 이론을 종합 고려하여 개별적으로 판단)에 따라 판단하는 입장이다.

01 행정의 주체 [★]

1) 개념

- ① 행정주체란 행정을 행하는 법주체를 말한다.
- ② 행정주체에는 국가, 지방자치단체, 공공조합과 공무원사인 등이 있다.
- ③ 행정을 실제로 행하는 것은 행정주체가 아닌 행정주체의 기관(대통령, 국토교통부장관, 서울특별시장 등)이다.
- ④ 그러나 이들 기관들이 행한 행위의 법적 효과는 법인격체인 행정주체에게 귀속된다.

2) 공무원사인

- ① 행정주체 중 공무원사인이란 공행정사무를 위탁받아 자신의 이름으로 처리하는 권한을 갖고 있는 행정주체인 사인을 말한다. (예 「토지보상법」상 사업인정을 받은 사업시행자)
- ② 공무원사인은 행정주체로부터 공행정사무를 위탁받아 처리하는 한도내에서는 행정주체의 지위를 갖는다.
- ③ 또한 행정소송법, 행정심판법, 행정기본법, 행정절차법에서 행정청으로서 공무원사인을 규정하고 있으므로, 행정청의 지위도 갖는다. (행정주체이면서 행정청)
- ④ 따라서 행정청의 임무수행으로 침해를 받은 국민은 공무원사인을 직접 피청구인 또는 피고로 하여 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있다. (국가배상이나 손실보상청구도 가능)

구 분	행정기관	행정주체
개 념	행정을 실제로 수행하는 자	행정법관계에서 행정권을 행사하고 그 행위의 법적 효과가 궁극적으로 귀속되는 당사자
법인격성	법인격 없음 (직무수행은 권한 있으나, 독자적인 권리는 없음)	법인격 있음 (행정기관이 한 행위의 법적 효과의 귀속주체는 행정주체임)
종 류	행정청, 의결기관(징계위원회)	국가, 지방자치단체, 공공단체, 공무원사인

02 행정의 상대방(행정의 객체)

- ① 행정의 상대방이란 행정법 관계에서 행정주체의 상대방을 말한다.
- ② 행정의 상대방에는 사인, 공공단체, 지방자치단체등이 있다. 공공단체 및 지방자치단체는 국가와 관계에서 행정객체가 될 수 있다.

01 공권

- ① 공권이란 공법관계에서 직접 자기를 위하여 일정한 이익을 주장할 수 있는 법률상의 힘을 말한다.
- ② 공권에는 국가적 공권과 개인적 공권으로 구분된다.
- ③ 국가적 공권 : 행정주체가 우월한 의사의 주체로서 행정객체에 대하여 가지는 권리를 말한다.(경찰권, 조세권 등)
- ④ 개인적 공권 : 개인이 행정주체에 대하여 가지는 공권을 말한다. 따라서 행정법에서는 통상 공권이라 함은 개인적 공권을 말한다.

02 개인적 공권 [★]**1) 의의**

개인이 직접 자기의 이익을 위하여 행정주체에게 일정한 행위를 할 것을 요구할 수 있는 법적인 힘을 말한다.

2) 성립요건 [강사]**(1) 강행법규의 존재**

- ① 강행법규에 의해 행정주체에게 일정한 행위(작위, 부작위, 급부, 수인)를 하여야 할 의무가 부과되어야 한다 (강행법규성).
- ② 행정주체의 의무에는 기속행위에서 특정행위를 할 의무 뿐만 아니라 재량행위에서 하자 없이 행정권을 행사할 의무도 포함된다.
- ③ 즉, 재량행위에서도 공권이 성립될 수 있다.

(2) 사익보호성

- ① 관련법규가 사익보호를 목적으로 하여야 한다.
- ② 사익보호의 판단기준은 처분의 근거법규 및 관련 법규의 목적, 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. (반사적 이익과 구별필요)

3) 반사적 이익과 개인적 공권의 구별**(1) 반사적 이익의 개념**

행정법규가 사익이 아닌 공익만을 위하여 행정주체 또는 사인에게 일정한 의무를 부과한 결과, 그에 따른 반사적 효과로서 이와 관련된 개인이 얻게 되는 이익(또는 행정주체가 어떠한 공공시설을 운영함으로써 결과적으로 개인이 반사적으로 얻게 되는 이익)을 말한다.

(2) 공권과 반사적 이익의 구별실익

공권은 법적으로 보호되는 이익이므로 공권이 침해된 경우에는 법적인 구제를 받을 수 있지만, 반사적 이익은 법적으로 보호받지 못한다는 차이가 있다.

(3) 공권과 반사적 이익 구별기준

- ① 공권은 처분의 근거법규 및 관계 법규에 의해 보호되는 개인의 이익이므로 처분의 근거법규 및 관계 법규가 공익뿐만 아니라 개인의 이익도 아울러 보호하고 있는 경우에 성립될 수 있다.
- ② 그러나 행정법규가 공익의 보호만을 목적으로 하고 있고 개인의 이익은 보호하지 않는 경우 그 법규로부터 개인이 이익을 누리더라도 그러한 이익은 반사적 이익에 불과하다.
- ③ 예를 들어, 근거법규 내지 관련법규에서 어떤 시설의 설치로 인하여 환경상 침해가 예상되는 영역을 구체적으로 정하는 경우(예 환경영향평가대상지역), 이때 인근주민의 환경상 이익은 단순한 반사적 이익이 아닌 법률상 보호되는 이익으로 인정된다.

03 무하자재량행사청구권

1) 의의

행정청에게 재량권이 부여된 경우에 행정청에 대하여 재량권을 하자 없이 행사하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 말한다.

2) 법적성질 (형식적 권리, 실체적 권리)

- ① 무하자재량행사청구권은 특정한 내용의 처분을 하여 줄 것을 청구하는 권리가 아니고 재량권을 하자 없이 행사하여 어떠한 처분을 하여 줄 것을 청구하는 권리인 점에서 형식적 권리이다. (실질적 권리X)
- ② 동시에 자신의 권익을 위하여 일정한 행정결정을 청구하는 권리이므로 실체적 권리로 보는 것이 타당하다. (절차적 권리X)

3) 독자성 인정여부

- ① 무하자재량행사청구권을 독자적 권리로 인정할 필요가 있는가에 관하여 견해의 대립이 있다.
- ② 재량행위에서도 공권이 인정될 수 있다는 것과 재량행위에서 인정되는 공권의 내용과 의미를 분명히 하기 위하여 인정할 필요가 있다는 점, 무하자재량행사청구권은 사익보호성이 있는 경우에만 인정되므로 민중소송화할 위험이 없다는 점
- ③ 또한 의무이행심판에서 적법재량행사를 명하는 재결의 실체법적 근거가 된다는 점에서 그 인정 실익이 있다.

대법원 1991. 2. 12. 선고 90누5825 판결

(검사임용을 받지 못한 사법연수원 수료생이 이를 다투는 사건에서) 행정청에는 적어도 재량권의 한계일탈이나 남용이 없는 위법하지 않은 응답을 할 의무가 있고, 이에 대하여 임용신청자로서도 재량권의 한계일탈이나 남용이 없는 적법한 응답을 요구할 권리가 있다.

4) 성립요건

- ① 강행법규성 : 행정청에 재량권을 행사하여 어떤 처분을 하여야 할 의무가 부과되어야 하며, 그 의무는 법령상 또는 조리상 인정될 수 있다.
- ② 사익보호성 : 근거 법규는 공익실현이라는 목적 이외에 사익을 보호하려는 목적도 있어야 개인적 공권이 성립하여 무하자재량행사청구권이 인정될 수 있다.

5) 재량권이 영으로 수축

(1) 의미

재량권이 영(0)으로 수축이라 함은 일정한 경우에는 재량권이 있는 행정청에게 선택의 여지가 없어지고 **특정한 내용의 처분을 하여야 할 의무**가 생기는 것을 말한다.

(2) 판단기준

- ① 사람의 생명, 신체 및 재산에 중요한 법익에 중대한 위험이 존재하고
- ② 그러한 위험이 행정권의 발동에 의하여 제거될 수 있으며
- ③ 피해자의 개인적인 노력으로는 권익침해의 방지가 충분하게 이루어질 수 없는 경우 그러하다.

(3) 효과

재량권이 영으로 수축하는 경우에는 무하자재량행사청구권은 특정한 내용의 처분을 하여 줄 것을 청구할 수 있는 <행정개입청구권>으로 전환된다.

04 행정개입청구권 [★]

CASE

관할 시장 甲이 개발행위를 허가한 기업 A가 공장을 가동하면서 유해한 폐수를 배출하는 경우 주민 乙이 관할 시장 甲에게 개발행위허가(재량행위)를 취소, 변경해달라고 요구할 수 있는지 검토하시오.

1) 의의

- ① 개인이 자기의 이익을 위하여 자기나 제3자에게 특정한 내용의 행정권을 발동하여 줄 것을 행정청에 요구할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 무하자재량행사청구권이 형식적 권리인 것과 달리, 행정개입청구권은 특정한 내용의 처분을 해줄 것을 요구할 수 있는 권리라는 점에서 실질적 권리이다.

2) 성립요건

- ① 강행법규성 : 행정개입의 의무를 부과하는 강행법규의 존재가 필요하다. 기속행위의 경우 행정개입청구권을 인정함에 있어 어려움이 없지만, 재량행위의 경우 재량이 영(0)으로 수축되어 행정권을 발동할 의무가 생긴 경우여야 한다.
- ② 사익보호성 : 근거 법규는 공익실현이라는 목적 이외에 사익을 보호하려는 목적도 있어야 개인적 공권이 성립하여 행정개입청구권이 인정될 수 있다.

3) 권리실현 수단

- ① 개인의 행정개입청구권에 근거한 행정개입의 요구에 대하여 행정청의 거부나 부작위가 있는 경우, 행정심판으로는 의무이행심판, 행정소송으로는 거부처분취소소송이나 부작위위법확인소송을 제기할 수 있다.
- ② 다만, 가장 적절한 소송수단인 의무이행소송은 현행법상 인정되지 않는다.
- ③ 개인의 행정개입청구권에 근거한 행정개입의 요구에 대하여 공무원의 거부나 부작위로 인하여 손해가 발생한 경우, 국가배상청구소송의 제기도 가능하다.

PART 02

행정작용법

Chapter 01 행정입법

Chapter 02 행정행위

Chapter 03 그 밖의 행정의 주요 행위형식

제1절

법규명령 [★★]

01 개념

법규명령이란 행정권이 정립하는 일반적·추상적 법규범으로서 대외적으로 구속력을 가지는 것을 말한다.

02 종류

1) 법적근거 기준 분류

(1) 위임명령

- ① 위임명령은 법률 또는 상위명령에 의하여 위임된 사항에 관하여 발하는 명령이다.
- ② 위임된 범위 내에서 국민의 권리·의무에 관한 새로운 사항을 정할 수 있다.

[토지보상법 시행령] 제1조 (목적)

이 영은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[토지보상법 시행규칙] 제1조 (목적)

이 규칙은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 동법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

(2) 집행명령

- ① 상위법령의 집행을 위하여 필요한 사항(신고서 양식 등)을 법령의 위임 없이 직권으로 발하는 명령을 말한다.
- ② 위임명령과 달리 새로운 입법사항을 정할 수는 없다.

[토지보상법 시행령] 제10조 (사업인정의 신청)

- ① 법 제20조제1항에 따른 사업인정(이하 “사업인정”이라 한다)을 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 사업인정 신청서에 다음 각 호의 사항을 적어 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사를 거쳐 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 사업시행자의 성명 또는 명칭 및 주소
2. 사업의 종류 및 명칭
3. 사업예정지
4. 사업인정을 신청하는 사유

2) 제정권자 기준 분류

- ① 법규명령을 제정권자를 기준으로 분류하면 크게 시행령과 시행규칙으로 구분할 수 있다.
- ② 시행령은 대통령이 제정하는 명령인 대통령령을 말하고, 시행규칙은 총리가 제정하는 명령인 총리령과 행정각부의 장이 발하는 명령인 부령을 말한다.

[헌법] 제75조

대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다.

[헌법] 제95조

국무총리 또는 행정각부의 장은 소관사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다.

03 법규명령의 한계 [★★]

1) 위임명령의 한계

(1) 수권상의 한계

- ① 헌법 제75조는 법률에서 대통령령에 위임할 경우 구체적으로 범위를 정하여 위임하도록 하여 위임입법의 범위와 한계를 제시하고 있다.
- ② 따라서 법률에서 위임명령에 규정할 사항을 위임함에 있어서 일반적·포괄적 위임은 허용되지 않는다.
- ③ 판례는 구체적 위임의 판단기준에 대해서 <누구라도 당해 법률이나 상위법령으로부터 위임명령에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있어야 한다>고 보았다.
- ④ 이러한 예측가능성 유무는 당해 위임조항만 가지고 판단하는 것이 아니라, 관련 법조항 전체를 유기적·체계적으로 종합 판단하여야 한다.

(2) 내용상 한계

- ① 위임명령은 상위 법령의 수권 범위 내에서 제정되어야 한다.
- ② 수권의 범위를 일탈한 위임명령은 위법한 명령이 된다.

2) 집행명령의 한계

- ① 법률이나 상위명령의 개별·구체적인 수권 없이 직권으로 제정할 수 있다.
- ② 그러나 집행명령은 상위법령을 집행하기 위하여 필요한 사항(헌법 제75조)만을 규정할 수 있고, 국민의 권리와 의무에 영향을 주는 새로운 법규사항을 규정할 수는 없다.

04 하자 있는 법규명령의 효력

1) 하자 있는 법규명령의 효력

- ① 법규명령이 적법요건을 갖추지 못하면 위법한 법규명령이 된다.
- ② 위법한 법규명령은 그것이 법령에 근거가 있다 하더라도 대외적 구속력이 인정될 수 없다.
- ③ 통설·판례는 법규명령에는 행정행위와 달리 공정력이 부여되지 않기 때문에 **하자의 정도와 상관없이 무효**가 된다고 본다.(공정력 인정X)

2) 하자 있는 법규명령에 따른 행정행위의 효력

- ① 하자 있는 법규명령에 따른 행정행위는 당연히 하자 있는 행정행위가 된다.
- ② 이러한 행정행위의 하자는 **중대한 하자**이므로, 중대명백성설에 따라 근거가 된 법규명령의 하자가 외관상 명백하다면 무효가 되고, 외관상 명백하지 않다면 취소사유가 될 것이다.
- ③ 다만, 법규명령에 하자가 있다 하더라도 법원의 판결이 선고되기 전에는 그 법규명령의 위법 여부가 객관적으로 명백한 것이라고 할 수 없으므로 **취소사유**에 해당한다고 보는 것이 판례의 입장이다.

05 법규명령의 사법적 통제 [★★]

CASE

甲은 자신의 과수원이 자신의 토지에 대한 수용재결에서 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호(사실상의 사도의 부지에 대한 평가는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 한다)에 따른 가격으로 평가받았다.

이에 불복하여 甲은 동 규정은 헌법 제23조상의 재산권보장 및 정당보상원칙을 위배하여 위헌적인 것이라고 주장한다. 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단을 설명하시오. (15점) (기출22회 1-3)

1) 법원에 의한 통제

법원에 의한 행정입법의 통제로는 <항고소송에 의한 직접적 통제>와 <간접적 통제>가 있다.

2) 처분적 명령에 대한 통제 (직접적 통제)

- ① 행정입법은 일반적·추상적 규범이므로 원칙상 처분이 아니고 따라서 항고소송의 대상이 될 수 없다.
(통설과 판례)
- ② 그러나 행정청의 별도의 집행행위 없이도 국민의 권리·의무를 직접적으로 규율하는 **처분적 법규명령**은 **그 실질이 처분**이므로 예외적으로 항고소송의 대상이 될 수 있다고 본다.(통설과 판례)

대법원 1996. 9. 20. 선고 95누8003 판결(두밀분교조례 사건)

조례의 집행행위가 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리·의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 행정처분에 해당한다고 하여 두밀분교폐지조례의 처분성을 긍정한 바 있다

3) 구체적 규범통제 (간접적 통제) [의대주효]

(1) 의의 및 근거 (헌법 제107조 제2항)

구체적 규범통제란 구체적인 처분을 소송으로 다투면서 위법성의 근거로, 처분의 근거가 된 법규명령의 위헌·위법을 주장하는 것을 말한다.

[헌법] 제107조

- ① 법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다.
- ② 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.

(2) 통제의 대상

- ① 구체적 규범통제의 대상은 명령과 규칙이 된다.
- ② 명령은 법규명령을 의미하고, 규칙은 대법원규칙, 국회규칙 등과 같이 법규명령인 규칙과 지방자치단체의 조례와 규칙을 의미한다.

(3) 통제의 주체

- ① 명령·규칙이 헌법이나 법률에 위반되는지 여부에 관한 심사권은 원칙적으로 각급 법원의 관할이다.
- ② 다만 대법원이 최종적으로 심사할 권한을 갖는다.

(4) 효력

① 개별적 효력설

구체적 규범통제는 재판의 전제가 된 경우에만 가능하고, 법원은 구체적 사건의 심사를 목적으로 하며 법령의 심사를 목적으로 하지 않으므로 해당 사건에 한하여 적용되지 않는다고 본다.

② 일반적 효력설

대법원의 판결이 있는 경우에 당해 명령은 일반적으로 효력을 상실한다고 본다.

③ 판례

구체적 규범통제를 통해 위법한 것으로 판결된 법령에 대해서는, 당해 법령의 효력이 일반적으로 상실되는 것은 아니고 문제가 된 당해 사건에 한하여 적용되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

④ 검토

법률의 위헌판결과 달리 법규명령에 관하여는 일반적 효력 상실의 명문 규정이 없고, 법원은 구체적 사건의 심사가 목적이니 법규명령 그 자체의 심사를 목적으로 하는 것은 아니므로 개별적 효력설이 타당하다. 다만, 행정소송법 제6조에서 명령·규칙의 위헌판결 공고를 규정하고 있어 사실상 대세효를 확보하고 있다.

[행정소송법] 제6조 (명령·규칙의 위헌판결등 공고)

- ① 행정소송에 대한 대법원판결에 의하여 명령·규칙이 헌법 또는 법률에 위반된다는 것이 확정된 경우에는 대법원은 지체없이 그 사유를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 통보를 받은 행정안전부장관은 지체없이 이를 관보에 게재하여야 한다.

4) 헌법재판소에 의한 통제

(1) 문제점

법규명령(명령·규칙)이 재판의 전제성이 없는 경우에 헌법소원의 대상적격이 있는지에 대하여 대법원과 헌법재판소의 견해가 나뉜다.

(2) 대법원의 태도

법률에 대한 위헌심사권은 헌법 제107조 제1항에서 헌법재판소에 부여하고 있는 반면, 명령·규칙에 대한 심사권은 동조 제2항에서 법원에 부여하고 있으므로, 헌법재판소는 법규명령에 대한 위헌심판권을 갖지 않는다고 한다.

(3) 헌법재판소의 태도

〈법무사법 시행규칙〉에 대한 결정례에서 재판의 전제가 되는 경우가 아닌 명령·규칙이 그 자체에 의하여 직접 국민의 기본권을 침해하는 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 본다.

(4) 검토 [직보]

- ① 헌법소원제도의 기본권보장제도로서의 기능을 보장하기 위하여 명령·규칙에 대한 헌법소원을 인정하는 것이 타당하다.
- ② 권리구제형 헌법소원을 제기하기 위해서는 법규명령으로 인해 국민의 기본권이 현재 직접적으로 침해되고, 다른 법률이 정한 구제절차를 모두 거친 뒤에도 구제되지 않은 경우에만(보충성) 헌법소원을 청구할 수 있다.
- ③ 다만, 법령 자체에 의하여 직접 기본권을 침해받은 경우에는 별도의 구제절차가 있는 것이 아니므로 그 법령을 대상으로 곧바로 헌법소원을 청구할 수 있다.

※ 보충자료

1. 권리구제형 헌법소원

1) 의의

공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자가 법원의 재판을 제외하고는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구하는 것을 말한다.(헌법재판소법 제68조 제1항)

2) 요건

(1) 공권력의 행사 또는 불행사

대통령령, 부령, 조례, 행정부작위, 권력적사실행위 등이 해당한다. 다만 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 대한 헌법소원은 받아들여지지 않는다.

(2) 기본권의 침해

헌법이 보장하고 있는 기본권을 현재 그리고 직접 침해당한 사람은 헌법소원을 청구할 수 있다.

(3) 다른 구제절차의 경우

다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 헌법소원을 청구하기 전에 그 절차를 모두 거쳐야 한다. 그러나 법령 자체에 의하여 직접 기본권을 침해받은 경우에는 구제절차가 있는 경우가 아니므로 그 법령을 대상으로 곧바로 헌법소원을 청구할 수 있다.

2. 위헌심사형 헌법소원

법률의 위헌 여부 심판의 제청신청이 기각된 때에는 그 신청을 한 당사자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다. 이 경우 그 당사자는 당해 사건의 소송절차에서 동일한 사유를 이유로 다시 위헌 여부 심판의 제청을 신청할 수 없다.(헌법재판소법 제68조 제2항)

01 의미

- ① 행정규칙이란 행정조직내부에서 행정의 사무처리기준으로서 제정된 일반적*추상적 규범을 말한다.
- ② 행정규칙은 내부적으로만 효력을 갖고 대외적 구속력 즉, 법규성은 없다.

※ 보충자료

- ① 고시 : 행정사무의 처리기준이 되는 일반적, 추상적 규범의 성질을 갖는 경우 행정규칙이다.
- ② 훈령 : 상급기관이 하급기관에 대하여 상당히 장기간에 걸쳐서 그 권한의 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 발하는 명령을 말한다.
- ③ 지시 : 상급기관이 직권 또는 하급기관의 문익에 의하여 개별적, 구체적으로 발하는 명령을 말한다.
- ④ 예규 : 법규문서 이외의 문서로서 반복 행정사무의 기준을 제시하는 것을 말한다.
- ⑤ 일일명령 : 당직, 출장, 시간외 근무 등 일일업무에 관한 명령을 말한다.

02 행정규칙의 한계

- ① 행정규칙은 상위법률이나 규칙, 행정법 일반원칙에 위배 되어서는 안 되며, 대외적 구속력이 없으므로 국민의 권리·의무에 관한 사항을 새로이 규정할 수 없다.
- ② 행정의 조직과 활동에 관한 규율로서 그 목적상 필요한 범위를 벗어나서는 안 되고 그 내용은 실현가능한 것이어야 한다.

CASE

B시의 시장은 공익사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 'B시 이주민지원규정'을 마련하였다. 위 지원규정에서는 이주대책대상자 선정과 관련하여 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 시행령이 정하고 있는 이주대책대상자 요건 외에 '전세대원이 사업구역 내 주택 외 무주택'이라는 요건을 추가적으로 규정하였다.

甲은 'B시 이주민지원규정'에서 정한 추가적 요건을 이유로 자신을 이주대책 대상자에서 배제한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (28회 문2 변형)

03 행정규칙의 종류

1) 재량준칙

- ① 재량준칙은 재량권 행사의 기준을 정하는 행정규칙을 말하며 그 자체로서는 국민에게 직접적인 법적 효과를 미치지 않는다.
- ② 재량준칙은 국민에게 법적 안정성을 보장하고 재량권의 자의적인 행사를 방지하기 위해 제정된다.

2) 규범해석규칙 (법령해석규칙)

- ① 불확정적인 법개념(예 공익, 질서유지, 미풍양속 등)의 통일적·단일적인 적용을 가능하게 하기 위해 규범해석의 지침을 정하는 행정규칙을 말한다.
- ② 법령을 해석하는 권한은 법원이 가지므로 행정기관이 제정한 규범해석규칙은 대외적 구속력을 가지지 않는다.

3) 규범구체화행정규칙

- ① 규범구체화행정규칙이란 과학기술이나 환경분야와 같은 전문영역에서 관계법령이 전혀 없거나 있어도 지나치게 포괄적으로 규정되어 있는 경우 그 관계법령의 내용을 구체화하는 행정규칙을 의미한다.
- ② 인정영역 : 원자력행정이나 환경행정과 같이 고도의 전문적이고 기술적인 분야이다.

4) 기타

- ① 조직규칙 : 행정조직 내부에서의 행정기관의 설치 및 조직, 내부적 권한배분 등을 정한 것
- ② 근무규칙 : 상급행정기관이 하급행정기관 및 구성원의 근무에 대한 사항을 규율하기 위한 것
- ③ 영조물규칙 : 영조물(예 도서관)의 관리청이 그 조직·권리·이용관계 등을 규율하는 것
- ④ 법률대위규칙 : 법률이 따로 존재하지 않는 경우 법률을 대신하여 행정작용의 기준과 방법을 정하는 행정규칙을 말한다.

04 행정규칙의 법규성 인정여부

1) 일반적인 행정규칙인 경우

(1) 학설 [비법준]

- ① 행정규칙은 원칙적으로 행정조직 내부를 규율하는 것으로 대내적 구속력만 있고, 대외적 구속력(법규성)이 없다는 견해(비법규설)
- ② 행정권은 권한범위 내에서 고유한 입법권을 가지므로 행정규칙도 대외적 효력을 가진다고 보는 견해(법규설)
- ③ 행정규칙 중 재량준칙은 평등의 원칙 및 자기구속의 원칙에 의해 법규로 전환되어 법규성이 인정될 수 있다고 보는 견해(준법규설) 등 다양한 견해가 있다.

(2) 판례

판례는 일관되게 행정규칙의 대외적 구속력 즉, 법규성을 부정하는 입장을 취하고 있다.

(3) 검토

- ① 행정규칙의 법규성을 인정하는 것은 법률의 법규창조력에 반하며
- ② 평등의 원칙이나 자기구속의 법리를 매개로 하는 경우에도 규칙 자체에는 법규성이 없다고 보는 것이 타당하므로 <비법규설>이 타당하다.

2) 재량준칙인 경우 [★★]

(1) 학설

- ① 전통적 견해는 재량준칙은 행정조직 내부에서의 재량권 행사의 기준을 정한 행정규칙이므로 외부적 구속력이 없다고 본다.(부정설)
- ② 재량준칙은 평등원칙을 매개로 하여 간접적으로 대외적 구속력을 갖는다고 보는 견해이다.(평등원칙설)
- ③ 행정의 자기구속의 법리에 근거하여 재량준칙의 대외적 구속력을 인정하는 견해이다.(자기구속설)

(2) 판례 [객합타특존]

판례는 원칙상 행정규칙에 대해 대외적 구속력을 인정하지 않지만, 재량준칙이 객관적으로 보아 합리적이 아니거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 행정청의 의사는 가능한 한 존중되어야 한다고 하고, 이러한 재량준칙에 따른 처분은 적법한 것으로 본다.

(3) 검토

재량준칙 그 자체가 법규성을 가지는 것은 아니나, 재량준칙이 반복적으로 시행되어 행정관행이 성립된 경우 자기구속력이 인정되므로 이 경우 자기구속의 원칙이나 평등의 원칙을 매개로 하여 법규성을 가진다고 보는 것이 타당하다.

05 행정규칙의 하자

- ① 행정규칙이 적법요건을 갖추지 못하면 위법한 행정규칙이 된다.
- ② 위법한 행정규칙은 효력을 발생시키지 못하고 행정행위의 하자과 달리 취소인 경우가 없고 무효인 경우만이 있다.

06 행정규칙의 사법적 통제

1) 법원에 의한 통제

(1) 구체적 규범통제

- ① 헌법 제107조 제2항에서 말하는 명령과 규칙은 법규성이 인정되는 것을 의미한다. 따라서 행정규칙은 법규성이 없어 원칙적으로 구체적 규범통제의 대상이 될 수 없다.
- ② 그러나 법령보충적 행정규칙이나 평등의 원칙이나 자기구속의 원칙에 의해 간접적으로 대외적 구속력을 가지게 되는 행정규칙의 경우 구체적 규범통제의 대상이 될 수 있다.

(2) 항고소송의 대상

원칙적으로 행정규칙은 그 자체로 처분성이 없으므로 항고소송의 대상이 되지 않으나, 예외적으로 행정청의 별도의 집행행위 없이도 국민의 권리·의무를 직접적으로 규율하는 처분성을 가지는 경우 항고소송의 대상이 될 수 있다.

2) 헌법재판소에 의한 통제

- ① 행정규칙은 일반적으로 행정조직 내부의 행위와 관련된 것으로서 공권력의 행사에 해당하지 아니하여 헌법소원의 대상이 될 수 없다.
- ② 다만 법령보충적 행정규칙처럼 국민에게 효력이 있는 경우에 이로 인해 직접 국민의 기본권이 침해된다면 헌법소원의 대상이 될 수 있다.
- ③ 또한 행정규칙이 자기구속의 원칙을 매개로 대외적인 구속력을 갖게 되는 경우 헌법소원의 대상이 될 수 있다.

01 법규명령형식의 행정규칙

CASE

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령 제29조 별표3(감정평가법인등의 설립인가취소와 업무정지의 기준)의 재판규범성 인정여부에 대해 설명하시오. (제20회 3번 기출)

1) 의의

법규명령의 형식을 취하고 있지만 그 내용이 행정규칙의 실질을 가지는 것을 법규명령 형식의 행정규칙이라 한다.

※ 보충자료

「감정평가법」 시행령 제29조 [별표3] : 감정평가법인등의 인가취소와 업무정지에 관한 규정(일부 발췌)

다. 국토교통부장관은 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등을 고려하여 처분기준의 2분의 1 범위에서 그 기간을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 총 업무정지기간은 2년을 넘을 수 없다.(가중규정)

라. 국토교통부장관은 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음의 사유를 고려하여 처분기준의 2분의 1 범위에서 그 처분기간을 줄일 수 있다. 이 경우 법을 위반한 자가 천재지변 등 부득이한 사유로 법에 따른 의무를 이행할 수 없었음을 입증한 경우에는 업무정지처분을 하지 않을 수 있다.(감경규정)

위반행위	근거	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
감정평가서의 발급을 정당한 이유 없이 지연한 경우	법 제32조 제1항 제6호	업무정지 15일	업무정지 1개월	업무정지 2개월
감정평가서의 기재사항에 중대한 하자가 있는 경우		업무정지 1개월	업무정지 2개월	업무정지 4개월

※ 보충자료

「감정평가법」 시행령 제43조 : 감정평가법인등의 과징금 부과기준 등에 관한 규정(일부 발췌)

제43조 (과징금의 부과기준 등)

① 법 제41조에 따른 과징금의 부과기준은 다음 각 호와 같다.

1. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 1년 이상인 경우 : 법 제41조제1항에 따른 과징금최고액(이하 이 조에서 “과징금최고액”이라 한다)의 100분의 70 이상을 과징금으로 부과
2. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 이상 1년 미만인 경우 : 과징금최고액의 100분의 50 이상 100분의 70 미만을 과징금으로 부과
3. 위반행위로 인한 별표 3 제2호의 개별기준에 따른 업무정지 기간이 6개월 미만인 경우 : 과징금최고액의 100분의 20 이상 100분의 50 미만을 과징금으로 부과

② 제1항에 따라 산정한 과징금의 금액은 법 제41조제2항 각 호의 사항을 고려하여 그 금액의 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 과징금최고액을 초과할 수 없다.

2) 법적성질

(1) 문제점

법규명령 형식의 행정규칙이 법규명령으로 대외적 구속력이 있는지 여부가 문제된다.

(2) 학설 [법행수]

- ① **법규명령설(형식설)** : 규범의 형식을 중시하고 법적 안정성 확보를 위해 법규명령으로 보는 견해를 말한다.
- ② **행정규칙설(실질설)** : 규범의 실질을 중시하고 구체적 타당성을 중시하여 행정규칙을 보는 견해를 말한다.
- ③ **수권여부기준설** : 수권여부를 기준으로 판단하는 견해로서, 상위법령의 수권에 근거하여 제정되었다면 법규명령으로 보고 위임이 없이 제정되었다면 행정규칙으로 본다.

(3) 판례

a. 제재적 처분기준인 경우

가. 시행규칙의 형식인 경우

- ① 판례는 부령형식으로 정해진 제재적 처분기준은 그 성질과 내용이 **행정규칙**의 성질을 가지는 것에 불과하다고 보았다.
- ② 다만, 판례는 제재적 처분기준이 부령의 형식으로 규정되어 있는 경우 당해 제재적 처분기준을 존중해야 한다고 본다.

나. 시행령의 형식인 경우

- ① 그러나 판례는 대통령령의 형식으로 규정된 경우 부령의 경우와는 달리 당해 기준을 **법규명령**으로 보았다.
- ② 다만 대통령령 형식의 제재적 처분기준을 법규명령으로 보면서도 일부 판례에서는 재량권 행사의 여지를 인정하기 위하여 처분기준을 정액이 아닌 처분의 **최고한도액**이라고 보았다.
- ③ 그러나 법령상 기속행위로 규정된 처분의 기준은 상한이 아니라 절대적 구속력을 갖는다고 본 판례도 있다.

b. 수익적 처분기준인 경우

판례는 [여객자동차운수사업법 시행규칙] 조문들에 대해 **법규명령**이라고 판시함으로써, 수익적 처분기준인 경우 시행규칙에 규정되어 있어도 법규명령으로 본 예가 있다.

(4) 검토

- ① 대통령령과 부령의 형식적 차이에 따라 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 구분하는 것은 합리적인 이유가 없어 타당하지 않다.
- ② 대통령령과 부령 모두 헌법 제75조 및 제95조에 근거한 형식이며 법규명령으로서 절차적 정당성이 부여되어 있으므로 국민의 예측가능성을 보장하는 측면에서 형식을 기준하여 법규명령으로 보는 <법규명령설>이 타당하다.

CASE

甲은 A시장이 자신의 소유 토지에 대한 개별공시지가를 결정함에 있어서 부동산 가격공시에 관한 법률에 의하여 국토교통부장관이 작성한 토지가격비준표를 고려하지 않았다고 주장한다. 이에, A시장은 토지가격비준표를 고려하지 않은 것은 사실이나, 같은 법에 따른 산정지가검증이 적정하게 행해졌으므로, 甲 소유의 토지에 대한 개별공시지가결정은 적법하다고 주장한다. A시장 주장의 타당성에 대해 검토하시오, (20점) (기출19회 2번 변형)

1) 의의 및 근거

- ① 법령보충적 행정규칙이란 법률의 위임에 의해 법령을 보충하는 법규사항을 정하는 행정규칙을 말한다.
- ② 행정기본법 제2조 법령에서도 이를 명문화 하고 있다.

[행정기본법] 제2조 (정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “법령등”이란 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 법령 : 다음의 어느 하나에 해당하는 것

- 1) 법률 및 대통령령 · 총리령 · 부령
- 2) 국회규칙 · 대법원규칙 · 헌법재판소규칙 · 중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙
- 3) 1) 또는 2)의 위임을 받아 중앙행정기관(「정부조직법」 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 중앙행정기관을 말한다. 이하 같다)의 장, 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장, 중앙선거관리위원회위원장, 감사원장 등이 정한 훈령 · 예규 및 고시 등 행정규칙

나. 자치법규 : 지방자치단체의 조례 및 규칙

2) 사례

(1) 토지가격비준표

국토교통부장관이 한국부동산원에 업무를 위탁하며, 「부동산공시법」 제3조 제8항에 위임 규정이 있다.

(2) 표준지공시지가 조사평가기준

국토교통부 훈령 형식으로 제정되었으며, 「부동산공시법」 시행령 제6조 제3항에 위임 규정이 있다.

3) 법적성질 (대외적 구속력 인정논의)

(1) 학설 [법행수규]

a. 법규명령설 (실질설)

법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.

b. 행정규칙설 (형식설)

법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다.

c. 수권여부기준설

상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.

d. 규범구체화 행정규칙설

대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다.

(2) 판례

a. 대법원

① 행정규칙의 형식으로 제정된 것이라도 상위법령의 위임이 있고, 위임의 한계를 벗어나지 않으며, 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 가지는 경우에는 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령이라고 보았다.

② 다만 법률의 위임을 받은 것이기는 하나 행정적 편의를 도모하기 위한 절차적 규정은 법률보충적 행정규칙이 아니라 단순한 행정규칙이라고 보았다.

※ 보충자료

〈감정평가 실무기준〉이나 한국감정평가사협회가 제정한 〈토지보상평가지침〉은 일반 국민을 기속하지 않는다고 판시한 바 있다.

b. 헌법재판소

헌법이 인정하고 있는 위임입법의 형식은 예시적인 것이라 하면서 대법원의 입장과 마찬가지로 법령보충적 행정규칙의 대외적 구속력을 인정한다.

(3) 검토

① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 법규성을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다.

② 다만, 일반적인 법규명령절차를 거치지 않기 때문에 국민의 예측가능성을 고려하여 고도의 전문적 영역에 한정되어 최소한도로 인정해야 할 것이다.

4) 위법한 법령보충적 행정규칙의 효력

판례는 법령보충적 행정규칙이 법령의 위임범위를 벗어난 경우에는 위법한 법규명령이 되는 것이 아니라 법규명령으로서의 대외적 구속력이 인정되지 않으므로 **행정규칙에 불과한 것**이 된다고 한다.

5) 법령보충적 행정규칙의 사법적 통제

(1) 법원에 의한 통제 (구체적 규범통제)

법령보충적 행정규칙은 상위법령과 결합하여 법규명령의 효력을 가지므로 법규명령과 같이 재판의 전제가 된 경우에는 법원이 간접적으로 통제하고, 처분성을 갖는 경우 직접 항고소송의 대상이 된다.

(2) 헌법재판소에 의한 통제

- ① 행정규칙은 대외적 구속력이 없으므로 원칙적으로 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사가 아니다.
- ② 그러나 행정규칙이 사실상의 구속력을 갖고 있어 국민의 기본권을 현재 직접적으로 침해하는 경우 헌법소원의 대상이 될 수 있다.
- ③ 현재는 국립대학의 대합입학교사 주요요강을 항고소송의 대상인 처분으로 보지 않으면서도 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사로 보았다.

제1절

행정행위의 개념

01 행정행위의 의미

- ① 행정청이 구체적인 사실에 대한 법집행으로서 행하는 권력적 단독행위인 공법적 행위를 말한다.
- ② 행정행위는 실정법상의 용어가 아니라 학문상의 용어이다.
- ③ 실정법상으로는 허가, 인가, 면허, 특허, 확인, 면제 등의 용어가 사용된다. 학문상 이들을 포괄하는 개념으로 사용하는 것이 바로 행정행위이다.

02 행정행위의 개념요소

1) 행정청의 행위

- ① 행정행위란 행정청의 행위일 것을 요건으로 한다.
- ② 「행정기본법」등은 행정청의 범주가 본래의 행정청(국가, 지방자치단체의 기관)뿐만 아니라 법령등에 따라 그 권한을 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인도 포함하고 있다.
- ③ 따라서, 공무원수탁사인의 공권력 행사도 처분에 해당한다.

[행정기본법] 제2조 (정의)

2. “행정청”이란 다음 각 목의 자를 말한다.

- 가. 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관
- 나. 그 밖에 법령등에 따라 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 권한을 가지고 있거나 그 권한을 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인

2) 구체적 사실에 대한 행위

- ① 통상의 행정행위나 처분은 개별적(특정인), 구체적(특정사안)이다.
- ② 반면 행정입법은 일반적(불특정인) 및 추상적(불특정사안)을 대상으로 하므로 처분성이 없다.
- ③ 그러나 행정입법 중 구체적 사안을 대상으로 하는 것은 처분성을 갖고 항고소송의 대상이 될 수 있다.
이를 처분적 명령(예) 두밀분교폐지 조례)이라고 한다.

3) 법적행위

- ① 외부에(국민에) 직접 법적 효과를 발생시키는 것이어야 한다.
- ② 따라서 법적 효과를 발생시키지 않는 내부적 행위(예) 직무 명령)이나 사실행위(예) 도로보수행위)는 행정행위가 아니다.

4) 권력적 단독행위

- ① 행정행위는 국민에 대해 우월한 지위에서 일방적으로 행사하는 권력적 단독행위여야 한다.
- ② 따라서 비권력적 행위인 공법상 계약등은 행정행위가 아니다.

03 행정행위와 처분의 관계

1) 처분의 의의

- ① <처분>이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다.
- ② 처분은 「행정기본법」, 「행정절차법」, 「행정심판법」, 「행정소송법」 등에 규정된 개념이다.
- ③ 특히, 「행정소송법」은 취소소송의 대상을 처분으로 삼고 있어 어떠한 행정작용이 <처분>에 해당하는지 여부가 중요하다.

[행정소송법] 제2조 (정의) 제1항 제1호

“처분등”이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

[행정소송법] 제19조 (취소소송의 대상)

취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

2) 처분과 행정행위의 관계

(1) 문제점

행정소송법상의 처분 개념이 학문상의 행정행위 개념과 동일한 것인지에 관하여 학설이 대립하고 있다.

(2) 학설

① 일원설 (실체법적 개념설)

행정소송법상 처분 개념을 학문상 행정행위와 동일한 것으로 보는 견해이다.

② 이원설 (쟁송법적 개념설)

행정행위는 사실행위를 제외한 법적 행위만을 대상으로 하나, 처분은 행정행위 개념 뿐만 아니라 <그 밖의 이에 준하는 행정작용>에 권력적 사실행위, 비권력적 사실행위 중 국민의 권익에 사실상 지배력을 미치는 행위 등도 포함된다고 본다.

(3) 판례

판례는 처분의 개념을 <국민의 권리, 의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위>로 넓게 정의하여 <이원설>의 태도로 평가된다. 이에 판례는 권력적 사실행위(예) 교도소 수형자 이송조치, 단수 처분 등)나 처분적 명령(예) 두밀분교폐지조례) 등의 처분성을 인정한 바 있다.

(4) 검토

- ① 처분의 개념에는 <그 밖의 이에 준하는 행정작용>이 포함되어 행정행위 뿐만 아니라 권력적 사실행위 등도 포함되는 것이 타당하다는 점
- ② 현행 행정소송제도가 취소소송 중심으로 되어 있고 기타의 소송제도는 실효적인 권리구제에 불충분하기 때문에 항고소송의 대상을 확대하는 것이 국민의 권익구제에 유리하다는 점 등을 고려하여 이원설이 타당하다고 본다.

※ 보충자료 - 사실행위

1. 비권력적 사실행위

공권력 행사의 실재를 갖지 않는 사실행위를 말한다.(예 행정지도, 폐기물수거, 여론조사 등)

2. 권력적 사실행위

- ① 의의 : 행정주체가 우월적 지위를 가지고 하는 사실행위로 공권력 행사의 실재를 가지는 사실행위를 말한다.
- ② 사례 : 대집행의 실행(예 불법건축물 철거), 행정상 즉시강제(예 전염병환자의 강제격리) 등
- ③ 처분성 : 권력적 사실행위는 사실행위의 요소와 하명적 요소가 결합된 합성적 행위이기 때문에 공권력 행사 및 법적 행위의 요건을 충족하여 항고소송의 대상인 처분이라고 보는 것이 일반적인 견해이다.

04 일반처분

1) 의의

- ① 관련자의 범위는 일반적(불특정)이나 규율하는 대상은 구체적인(시간적·공간적으로 특정) 행정의 행위형식을 말한다.(불특정 다수인에 대한 처분)
- ② 일반처분은 일반적·구체적 규율이라는 점에서 일반적·추상적 규율인 법규명령과는 구별된다.

2) 처분성 여부

- ① 통설과 판례는 일반적·구체적 규율의 성격을 가지는 일반처분도 행정행위의 한 유형으로 본다.
- ② 따라서 일반처분에 의해 법률상 이익이 침해된 자는 항고소송을 제기할 수 있다.

3) 일반처분의 종류

(1) 대인적 일반처분

- ① 의의 : 일정한 기준에 의해 결정되는 불특정 다수인을 대상으로 하는 행정행위를 말한다.
- ② 사례 : 일정한 장소에서의 집회행위 금지처분, 통행금지처분, 입산금지 등이 있다.

(2) 대물적 일반처분

- ① 의의 : 행정행위의 직접적인 규율대상은 물건이고, 사람에 대해서는 물건과의 관계를 통하여 간접적으로 규율하는 행정행위를 말한다.
- ② 사례 : 국계법상 용도지역·지구의 지정행위, 개별공시지가의 결정 등

01 법률행위적 행정행위와 준법률적 행정행위

1) 개념

(1) 법률행위적 행정행위 의의

〈행정청의 의사표시를 구성요소〉로 하고 그 법적 효과가 그 행위자의 의사에 따른 효과가 발생하는 행정행위이다.

(2) 준법률행위적 행정행위 의의

행정청의 의사표시(효과적사) 이외의 정신작용(판단, 인식 등)을 구성요소로 하고 행정청의 의사와는 무관하게 〈법규가 정한 바에 따라 법적 효과가 발생하는 행위〉를 의미한다.

(3) 구별실익

- ① 종래 통설은 법률행위적 행정행위에는 **부관**을 붙일 수 있으나 준법률행위적 행정행위에는 부관을 붙일 수 없다고 보아 구별실익이 있었다.
- ② 최근에는 법률행위적 행정행위라도 귀화허가 등의 경우에는 부관을 붙일 수 없고, 준법률행위적 행정행위인 공증에는 기한 등과 같은 부관을 붙일 수 있다고 보아 그 〈구분에 실익이 없다〉고 본다.

2) 법률행위적 행정행위의 구분

(1) 명령적 행정행위 의의

질서유지를 위해 국민에 대하여 일정한 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 명하거나 해제하는 행정행위를 말한다.

(2) 형성적 행정행위

사인에게 새로운 권리·능력·법률상의 지위 또는 포괄적 법률관계, 기타 법률상의 힘을 발생, 변경, 소멸시키는 행정행위를 말한다.

3) 준법률행위적 행정행위의 구분

법률효과가 행정청의 의사가 아닌 법률 규정에 의해 발생하는 행위를 말하며, 확인, 공증, 통지 및 수리가 이에 해당한다.

02 법률행위적 행정행위 - 명령적 행정행위

1) 하명

(1) 의의

인간이 본래 가지는 자유로운 행동에 대하여 행정청이 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 명하는 행위를 말한다.

(2) 하명의 효과

① 하명의 내용에 따라 상대방에게 일정한 공법상 의무가 발생한다.(하명 → 의무발생)

② 작위하명 : 상대방이 일정한 행위를 적극적으로 행하여야 할 의무가 발생한다.

(철거명령, 해산명령, 예방접종의무부과 등)

[토지보상법] 43조 (토지 또는 물건의 인도 등)

토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다.

③ 부작위하명 : 일정한 행위를 하지 않을 의무가 발생한다.(금지, 통행금지 등)

[토지보상법] 제25조 (토지등의 보전)

① 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 제3조제2호 또는 제4호에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다.

④ 급부하명 : 일정한 급부를 해야 할 의무가 발생한다.(조세부과처분, 과징금부과처분 등)

[감정평가법] 제41조 (과징금의 부과)

① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

⑤ 수인하명 : 행정청에 의한 강제를 감수하고 이를 수인할 의무가 발생한다.(강제입원명령, 인용의무 등)

[토지보상법] 제11조 (토지점유자의 인용의무)

토지점유자는 정당한 사유 없이 사업시행자가 제10조에 따라 통지하고 출입·측량 또는 조사하는 행위를 방해하지 못한다.

(3) 하명위반의 효과

- ① 하명에 의해 부과된 의무를 이행하지 않는 자에 대해서는 행정상 강제집행이 행해지고, 하명에 의해 부과된 의무를 위반한 때에는 행정벌이 과하여진다.
- ② 그러나 원칙상 하명에 위반하여 행해진 행위의 사법상 효력이 부인되지는 않는다.

2) 허가

(1) 의의

- ① 허가란 법령에 의한 자연적 자유에 대한 일반적·상대적·잠정적 금지를 일정한 요건을 갖춘 경우에 해제하여 **본래의 자유권을 회복**시켜주는 것을 말한다.
- ② 사례 : 영업허가, 건축허가, 운전면허, 어업허가 등이 대표적인 예이다.

(2) 기속행위인지 여부

- ① 허가란 인간의 자유권을 공익목적상 금지하였다가 법률상 일정한 요건을 갖춘 경우에 그 제한을 해제함으로써 본래의 자유를 회복시켜 주는 행정행위이므로, 법령에 특별한 규정이 없는 한 기속행위로 보아야 한다.

대판 2006.11.09, 2006두1227

건축허가권자는 건축허가신청이 건축법 등 관계 법규에서 정하는 어떠한 제한에 배치되지 않는 이상 당연히 같은 법조에서 정하는 건축허가를 받아야 하고, 중대한 공익상의 필요가 없음에도 불구하고, 요건을 갖춘 자에 대한 허가를 관계법령에서 정하는 제한사유 이외의 사유를 들어 거부할 수 없다.

- ② 다만, 허가의 요건이 불확정개념으로 규정되어 있어 행정청에게 판단여지가 인정될 수 있는 경우나, 명문의 규정이 없더라도 중대한 공익의 고려가 필요하여 이익형량이 요구되는 경우, 법령에서 재량행위로 규정한 경우에는 재량행위가 된다.

대판 2013.10.31., 2013두9625 [건축불허가처분취소]

[국토의 계획 및 이용에 관한 법률]에 따른 토지의 형질변경허가는 그 금지요건이 불확정개념으로 규정되어 있어 그 금지요건에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 행정청에 재량권이 부여되어 있다고 할 것이므로, 국토계획법에 따른 토지의 형질변경행위를 수반하는 건축허가는 재량행위에 속한다.

(3) 허가의 신청

- ① 통상 허가는 신청을 전제로 하여 주어진다. (예 건축허가)
- ② 그러나 반드시 신청을 전제로 하지는 않는다. 따라서 신청을 전제로 하지 않는 허가도 있다.
(예 통행금지의 해제 등)

(4) 허가의 이익

- ① 원칙(반사적 이익) : 허가제도를 설정하는 법규정은 질서유지 등 공익의 달성을 목적으로 하고 있을 뿐 허가를 받은 자의 경제적인 영업상 이익을 보호하지 않으므로, 허가로 인하여 누리는 영업상 이익은 반사적 이익에 불과한 것이 일반적이다.

한 의사 면허는 경찰금지를 해제하는 명령적 행위(강학상 허가)에 해당하고, 한약조제시험을 통하여 약사에게 한약 조제권을 인정함으로써 한의사들의 영업상 이익이 감소되었다고 하더라도 이러한 이익은 사실상의 이익에 불과하다.

- ② 예외(법률상 이익) : 허가요건규정이 공익 뿐만 아니라 개인의 이익도 보호하고 있다고 해석되는 경우에는 허가로 인한 영업상 이익은 법률상 이익이 된다.

(예) 허가요건 중 거리제한 또는 영업구역제한 규정이 있는 경우)

(5) 무허가행위의 효과

무허가행위는 위법한 행위가 되고 통상 법률에서 그에 대하여 행정벌을 부과한다. 그러나 당해 무허가행위의 사법상 효력이 부인되는 것은 아니다.

(6) 예외적 승인(허가)와의 구별

① 의의

예외적 허가란 사회적으로 바람직하지 않은 일정행위를 법령상 원칙적으로 금지하고 예외적인 경우에 이러한 금지를 해제하여 당해 행위를 적법하게 할 수 있게 하여 주는 행위를 말한다.

(예) 토지보상법상 타인토지출입허가, 개발제한구역 내의 건축허가나 용도변경 등)

② 허가와의 구별

구 분	허가	예외적 승인(허가)
내용	① 원칙적 허가를 전제로 금지 ② 일반적·상대적·잠정적 금지 ③ 자연적 자유의 회복	① 원칙적 금지를 전제로 예외적 허가 ② 억제적 금지의 해제 ③ 권리범위의 확대
재량여부	원칙적으로 기속행위	원칙적으로 재량행위

3) 면제

- ① 법령에 의해 부과된 작위·급부·수인의 의무를 특정한 경우에 해제해 주는 행정행위를 말한다.(예) 조세감면 등)
② 허가는 부작위의무의 해제이나, 면제는 작위·급부·수인의무의 해제라는 점에서 서로 구별된다.

03 법률행위적 행정행위 - 형성적 행정행위

1) 특허

(1) 의의

- ① 특정인에 대하여 새로운 권리, 능력 또는 포괄적 법률관계를 설정하는 행위를 말한다.
- ② 본래부터 있던 자연적 자유가 아닌 새로운 권리 등이므로 <설권행위>라고 부르기도 한다.(상대방의 신청필요)

(2) 사례

- ① 권리설정 사례 : 특허기업의 특허(버스운송사업면허 등), 광업허가, 도로점용허가, 어업면허 등
- ② 능력을 설정하는 사례 : 재건축정비조합설립인가 등
- ③ 포괄적 법률관계를 설정하는 사례 : 공무원임명, 귀화허가 등

※ 보충자료 - [도시정비법] 조합의 설립인가의 법적 성질 (25회 기출)

- ① <구 판례>는 조합설립결의는 기본행위로, 조합 설립인가는 이를 보충하는 행위(인가)로 판시하였다.
- ② <최근 판례>는 조합설립인가처분은 법령상 요건을 갖추 경우 도시정비법상 주택재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체(공법인)로서의 지위를 부여하는 일종의 <설권적 처분>의 성격을 갖는다고 판시한 바 있다.

(3) 특허의 성질

- ① 형성적 행위 : 상대방이 본래 가지고 있지 않았던 권리 등을 새롭게 설정하는 행위이다.
- ② 원칙상 재량행위 : 특허에 있어서는 공익목적의 효과적인 달성을 고려하여야 하므로 원칙상 재량행위로 본다.(다만 법령상 기속행위로 규정하는 등 예외있음.)

(4) 특허와 허가구별

① 전통적 견해

구 분	허가	특허
법적성질	명령적 행위	형성적 행위
재량여부	원칙상 기속행위	원칙상 재량행위
법적이익 여부	반사적 이익	법률상 이익

② 새로운 견해

오늘날 허가과 특허의 구별은 상대화하고 있고 양자는 상호 접근하는 경향이 있다고 본다.

2) 인가

(1) 의의

- ① 행정청이 제3자의 법률행위를 동의로써 보충하여 그 행위의 효력을 완성시키는 행정행위를 말한다.
- ② 제3자의 행위를 보충한다는 점에서 보충행위라고도 한다.(인가의 보충성)

(2) 사례

토지거래허가구역내의 토지거래계약허가, 주택재건축정비사업조합의 사업시행인가, 비영리법인 설립인가, 재단법인의 정관변경허가, 공공단체의 정관변경승인 등이 있다.

[감정평가법] 제29조에 의한 감정평가법인 설립등

- ⑤ 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 다음 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 신고할 수 있다.

대판 2010.12.9, 2010두1248, 2009두4913

(구) 도시 및 주거환경정비법(이하 도정법)에 기초하여 도시환경정비사업조합이 수립한 사업시행계획은 그것이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립된 행정처분에 해당하므로, 사업시행계획을 인가하는 행정청의 행위는 주택재건축(재개발)정비사업조합의 사업시행계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위에 해당한다.

대판 2012.8.30., 2010두24951

도시 및 주거환경정비법상 재건축조합이 수립하는 관리처분계획에 대한 행정청의 인가는 관리처분계획의 법률상 효력을 완성시키는 보충행위로서의 성질을 갖는다.

(3) 인가의 법적성질

- ① 형성적 행정행위 : 인가의 대상이 되는 기본행위의 효력을 완성시켜 주는 행위이다.
- ② 재량행위 여부 : 인가가 기속행위인지 재량행위인지 여부는 일률적으로 판단할 수 없고, 법문언에 따라 개별적으로 판단해야 한다.(인가가 재량행위인 경우 부관을 붙일 수 있다.)

(4) 인가와 기본행위의 관계

CASE

A 등은 감정평가법인을 설립하여 국토교통부장관의 설립인가를 받았다. 설립인가 자체의 하자는 없지만, 감정평가법인의 사원에 관한 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」의 요건을 충족하지 못하여 설립행위에 문제가 있음을 확인한 경쟁업체의 감정평가사 甲은 소송을 통하여 이를 다투고자 한다. 이러한 감정평가법인의 설립행위와 인가행위의 관계를 설명하고, 甲은 어떠한 소송에서 어떠한 하자를 다퉴 수 있는지 검토하시오. (36회 문4)

- ① 인가는 기본행위의 효력을 완성시켜 주는 보충적 행위이므로 인가의 효력은 **기본행위의 유무 및 하자에 의해 영향을 받는다.**
- ② 따라서 기본행위가 소멸되면 인가는 별도의 무효선언이나 처분청의 직권취소 없이도 실효된다.
- ③ 하자있는 기본행위와 인가의 관계

기본행위	인가	내 용
불성립 또는 무효	적법	① 인가는 무효일 뿐이고 인가로 인해 기본행위가 유효하게 되는 것은 아니다. ② 인가는 기본행위의 하자를 치유하지 않는다.
취소사유	적법	① 기본행위가 취소되지 않는 한 인가의 효력에는 영향이 없다. ② 다만, 기본행위가 취소되거나 실효되면 인가도 실효된다.

- ④ 적법한 기본행위와 하자있는 인가의 관계

기본행위	인가	내 용
적법	무효	① 기본행위는 무인가행위가 되므로 아무런 효력도 발생하지 않는다. ② 적법한 인가가 있으면 그때부터 효력발생
적법	취소사유	① 인가행위가 취소되기 전까지는 기본행위는 유효 ② 나중에 인가가 취소되면 기본행위는 무인가행위가 되어 효력상실

- ⑤ 쟁송방법

기본행위	인가	내 용
하자	적법	기본행위의 하자를 다투어야 하며, 기본행위의 하자를 이유로 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익은 없다.
적법	하자	인가를 대상으로 무효확인이나 그 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

3) 대리

(1) 의의

제3자가 해야 할 일을 행정청이 대신하여 행함으로써 제3자가 스스로 행한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. (예 압류재산 공매처분 등)

(2) 토지보상법 제34조 토지수용위원회의 재결(사례)

- ① 의의 : 사업시행자와 토지소유자등간 협의 불성립시 조정적 입장에서 토지수용위원회가 행하는 최종적 판단절차(수용 또는 사용할 토지 구역 및 사용방법, 손실의 보상액 등)를 말한다.
- ② 성격 : 재결은 토지수용위원회가 제3자(사업시행자, 토지소유자등)가 할 협의를 조정적 입장에서 대신하고 그 효과를 귀속하게 하는 대리의 성격을 가진다.

04 준법률행위적 행정행위

1) 확인

(1) 의의

특정한 사실 또는 법률관계의 존부 또는 정부에 관하여 의문이 있거나 다툼이 있는 경우 행정청이 이를 공권적으로 확인하는 행위를 말한다.

(2) 사례

행정심판의 재결, 이의신청의 재결, 국가시험합격자결정, 도로구역·하천구역의 결정 등

※ 보충자료 - [토지보상법] 제29조 협의성립확인행위의 법적성질

- ① 협의성립확인이란, 협의가 성립한 경우 사업시행자가 수용재결의 신청기간 이내에 당해 토지소유자 및 관계인의 동의를 얻어 관할 토지수용위원회의 확인을 받는 것을 말한다. 이는 협의(계약)를 재결(처분)로 변경하여 계약불이행을 방지하고자 하는 취지이다.
- ② 협의성립확인에 대하여 특정한 사실 또는 법률관계의 존부를 공적 권위로 증명하는 <공증>으로 보는 견해가 있으나,
- ③ 특정한 사실관계 또는 법률관계에 대해 의문이 있는 경우 공권력으로 그 존부 또는 정부를 판단하는 행위로 <확인행위>로 보는 것이 일반적이다.

(3) 법적성질

확인행위는 사실 또는 법률관계를 확인하는 행위이므로 원칙상 행정청에게 재량권이 인정될 수 없고 기속행위이다. 다만 판단여지가 인정될 수는 있다.

대판 1992.04.10., 91누5358

준공검사처분은 건축허가를 받아 건축한 건물이 건축허가상태대로 건축행정목적에 적합한가의 여부를 확인하고, 준공검사필증을 교부하여 줌으로써 허가받은 자로 하여금 건축한 건물을 사용*수익할 수 있게 하는 법률효과를 발생시키는 것이므로 허가관청은 특단의 사정이 없는 한 건축허가내용대로 완공된 건축물의 준공을 거부할 수 없다.

(4) 확인의 효과

행정심판의 재결이나 이의신청의 재결과 같은 준사법적 행위에는 불가변력이 발생하고, 그 이외의 확인행위는 취소권 또는 철회권이 제한된다.

2) 공증

(1) 의의

진위가 확실한 특정한 사실 또는 법률관계의 존재 여부를 공적으로 증명하는 행위를 말한다.
각종의 등기·등록·증명서의 발급 등이 이에 해당한다.

(2) 사례

부동산등기, 선거인명부예의 등록, 광업원부예의 등록 등

[토지보상법] 제29조 제3항

사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 〈공증〉을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다.

(3) 효과

- ① 공증행위의 효력은 사실 또는 법률관계의 존재에 대하여 공적 증거력을 부여하는 것이다.
- ② 따라서 공증에 의한 공적 증거력은 반증에 의하지 아니하고는 전복될 수 없다.

3) 통지

(1) 의의

- ① 행정청이 특정인 또는 불특정 다수인에 대해 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다.
- ② 특정한 사실 또는 의사를 알리는 행위를 말하는 것으로서 일정한 법적 효과를 발생시키는 것을 의미한다.

(2) 사례

토지수용에 있어서 사업인정의 고시, 대집행의 계고, 대집행 영장에 의한 통지 등

[토지보상법] 제22조 (사업인정의 고시)

- ① 국토교통부장관은 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다.
- ③ 사업인정은 제1항에 따라 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

4) 수리

(1) 의의

수리란 법상 행정청에게 수리의무가 있는 경우에, 행정청이 타인의 행위를 유효한 행위로서 받아들이는 인식의 표시행위를 말한다.

(2) 자기완결적 신고의 수리와 구별

- ① 수리를 요하는 신고에서 수리 : 준법률행위적 행정행위인 수리로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.
- ② 자기완결적 신고에서 수리 : 행정청에게 별도의 수리를 요하지 않으므로 단순한 사실행위이다.

(3) 사례

※ 보충자료 - 감정평가법인등의 사무직원의 고용

- ① 「감정평가법」 제21조의2에 따라서 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ② 이때 국토교통부장관은 신고서를 제출받은 경우 그 사무직원이 법 제24조제1항에 따른 결격사유에 해당하는지 여부를 확인해야 하므로, 이 신고는 수리를 요하는 신고로 본다.

05 수익적·침익적·복효적 행정행위 (법적 효과의 성질 기준)

1) 수익적 행정행위

상대방에게 권리·이익을 부여하거나 권리의 제한을 해제해 유리한 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

(예 영업허가 등)

2) 침익적 행정행위

상대방에게 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 등 불이익한 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

(예 과징금 부과, 업무정지 등)

3) 복효적 행정행위

(1) 의의

하나의 행정행위가 이익과 불이익이라는 복수의 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

(2) 혼합효 행정행위

복수의 효과가 동일인에게 발생되면 <혼합효 행정행위>라 한다. (예 부관부 허가 등)

(3) 제3자효 행정행위

상대방에게는 이익을 주고 제3자에게는 불이익을 주는 경우(혹은 그 반대)는 <제3자효 행정행위>라고 한다.

(예 「토지보상법」 제20조 사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정하여 수익을, 피수용자에게는 불이익을 주는 제3자효 행정행위이다.)

CASE

「감정평가법 제41조」에서는 “국토교통부장관은 감정평가법인이 동법 제32조에 따라서 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다”고 규정한다.
과징금 부과처분의 법적 성질을 검토하시오.

01 의미

- ① 기속행위란 행정권 행사의 요건 내지 효과가 법에 일의적·확정적으로 규정되어 행정청이 법에 정해진 행위를 할 의무를 지게 되는 행위를 뜻한다.
- ② 재량행위는 행위의 요건이나 효과의 선택에 있어 행정권에 재량이 인정되는 경우를 말한다.

02 구별실익 (사법심사 방식)

- ① 기속행위와 재량행위는 사법심사 방식에 차이가 있어 그 구별에 실익이 있다.
- ② 기속행위는 법령상 요건 충족시 반드시 일정한 행위를 하여야 하는 법규에 대한 기속성이 있으므로 그 행위의 위법여부를 법원이 독자적으로 심사할 수 있다.
- ③ 반면에 재량행위는 공익과 관련하여 행정청에 재량권이 있으므로 법원이 독자적 결론을 도출함이 없이 행정청의 행위에 대해 재량권의 일탈·남용이 있는지만을 심사한다.

03 구별기준

1) 법문언기준설 (통설 및 판례)

- ① 법령에서 〈~하여야 한다〉고 표현하면 기속행위로 보고,
- ② 〈~할 수 있다〉고 표현하면 재량행위로 본다.

[감정평가법] 제19조 (등록의 취소)

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따라 등록한 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.
 1. 제12조각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 2. 사망한 경우
 3. 등록취소를 신청한 경우
 4. 제39조 제2항 제2호에 해당하는 징계를 받은 경우

[감정평가법] 제32조 (인가취소 등)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소(제29조에 따른 감정평가법인에 한정한다)하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다.
다만, 제2호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소하여야 한다.
2. 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우
7. 감정평가법인등이 제21조 제3항이나 제29조 제4항에 따른 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우

2) 법문언의 표현이 불분명한 경우 (통설)

- ① 당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, 당해 행위 자체의 개별적 성질과 유형 등을 <종합 고려>하여 판단하여야 한다.

[토지보상법] 제20조 (사업인정)

- ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.
- ② <판례>는 해당사업이 토지를 수용할 수 있는 공익사업에 해당된다 하더라도 행정청으로서의 그 사업이 공용수용을 할 만한 <공익성이 있는지의 여부를 모든 사항을 참작하여 구체적으로 판단>하여야 하는 <재량행위>라고 판시한 바 있다.

04 재량의 일탈·남용

1) 개념

구 분	내 용
재량권 일탈	법령에 따라 부여된 재량의 한계를 벗어난 것으로, 재량권의 외적 한계(법적·객관적 한계)를 벗어난 것을 말한다. (예) 「감정평가법」 제39조에 2년 이하의 업무정지를 할 수 있다고 규정하고 있으나, 3년을 업무정지 처분한 경우)
재량권 남용	관련 이익을 정당하게 형량하지 않은 것으로, 재량권의 내적 한계를 벗어난 것을 말한다. (예) 3개월 정도의 위반사유에 대해서 2년의 업무정지를 처분한 경우)

2) 재량권의 일탈과 남용 구별 여부

- ① 판례는 재량권의 일탈과 재량권의 남용을 명확히 구분하지 않고 재량권의 행사에 <재량권의 일탈 또는 남용>이 없는지를 판단한다.
- ② 실질적으로 재량권 일탈과 남용을 구분할 실익이 없고, 재량권의 한계를 위반한 재량권 행사는 위법하게 된다.

3) 관련 개념

(1) 사실오인

사실의 존부에 대한 판단에는 재량권이 인정될 수 없으므로 사실을 오인하여 재량권을 행사한 경우에 그 처분은 위법하다. (예) 비위를 저지르지 않은 감정평가사를 비위를 저지른 것으로 오인하여 징계처분한 경우)

(2) 재량권의 불행사 또는 해태

부주의로 또는 재량행위를 기속행위로 오인하여 재량권을 행사하지 않거나, 재량권을 해태한 경우에는 위법한 처분이 된다.

(3) 목적 위반

재량권의 행사가 법률에서 정한 목적과 다르게 행사된 경우에 재량처분은 위법하게 된다.

(예) 사적 재산 증식 목적으로 본인 소유 부동산 인근에 개발허가)

05 불확정개념과 판단여지

CASE

甲은 자기 소유 임야에 태양광 발전시설을 설치하기 위하여 B군수에게 국토계획법에 따른 개발행위허가를 신청하였다. B군수는 「국토계획법」 제58조에서 개발행위 허가시 주변환경이나 경관과 조화를 이룰 것이라는 규정에 근거하여 “토지형질변경을 허가할 경우 주변 환경이나 경관과 조화를 이루지 못하기 때문에 개발행위허가기준을 충족하지 못한다.”고 거부하였다. 이 사건 거부처분의 거부 사유(불확정개념에 대한 행정청의 판단)에 대한 법원의 사법심사 방식과 한계에 관하여 설명하시오. [2024년 변호사 시험 변형]

1) 개념

(1) 불확정개념

- ① 공공복리, 주변환경과 조화, 환경의 보전 등의 용어와 같이, 그 의미내용이 일의적인 것이 아니라 다의적인 것이어서 진정한 의미내용이 구체적 상황에 따라 판단되는 개념을 말한다.
- ② 불확정개념의 해석·적용은 어떠한 사실이 법이 정한 요건에 해당하는지 여부에 대한 인식의 문제로서 법적문제가기 때문에 원칙적으로 사법심사의 대상이 된다.

(2) 판단여지

- ① 불확정개념에 대한 행정청의 평가 및 결정에 대하여 사법부가 그 정당성을 판단하는 것이 불가능하거나 합당하지 않아서 행정청의 판단을 존중해 줄 수밖에 없는 영역이 있는데, 이런 영역을 판단여지라고 부른다.
- ② 판단여지가 인정되는 영역 내에서 행정청이 내린 판단은 법원에 의한 통제의 대상이 되지 않는다.
- ③ 즉, 법률요건에 불확정개념의 해석에 있어 사법심사가 배제되는 행정청의 전문적인 판단영역을 말한다.

2) 재량과 판단여지 구별 여부

(1) 학설

- ① 사법심사가 제한된다는 점에서 양자를 구별할 실익이 없다는 <부정설>
- ② 판단여지는 법인식 문제이고, 재량은 법률효과 선택의 문제라고 보아 양자를 구별하여 판단여지를 독자적 개념으로 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>이 있다.

(2) 판례

판례는 판단여지설의 논리를 일부 수용하면서도 재량행위와 판단여지를 구분하지 않고, 긍정설이 판단여지의 영역이라 보는 문제에 대해서도 모두 재량의 문제로 보고 있다.

대법원 1996. 9. 20. 선고 96누6882 판결

감정평가사시험의 합격기준으로 절대평가제 방식을 원칙으로 하되, 행정청이 감정평가사의 수급상 필요하다고 인정할 때에는 상대평가제 방식으로 할 수 있다고 규정하고 있으므로, 감정평가사시험을 실시함에 있어 어떠한 합격기준을 선택할 것인가는 시험실시기관인 행정청의 고유한 정책적인 판단에 맡겨진 것으로서 자유재량에 속한다.

(3) 검토

재량과 판단여지는 그 개념, 필요성, 인정근거, 내용, 인정기준 및 범위 등에서 차이가 있으므로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

3) 인정영역

- ① 비대체적 결정 영역(전문적, 학문적 평가에 관계되는 시험성적의 평가 등)
- ② 고도의 전문가로 구성된 구속적 가치평가 영역(직무상 독립성을 가지는 위원회의 결정 등)
- ③ 형성적·정책적 결정 영역 등(외국인의 체류기간 연장 등)에서 인정될 수 있다.

4) 판단여지의 한계

판단여지가 존재하는 경우에도 판단기관이 적법하게 구성되었는지 여부, 절차 규정의 준수 여부, 정당한 사실관계에서 출발하였는지 여부, 일반적으로 승인된 평가 척도의 침해 여부 등은 사법심사의 대상이 된다.

01 개설

- ① 행정행위의 요건은 성립요건, 적법요건, 효력발생요건으로 구분할 수 있다.
- ② 행정행위가 성립하더라도 적법요건과 효력발생요건을 충족하여야 적법·유효한 행정행위가 된다.

02 행정행위의 성립요건

- ① 행정행위가 존재하기 위한 최소한의 요건을 말하며, 내부적 성립요건과 외부적 성립요건을 모두 충족해야 한다.
- ② 내부적 성립 : 행정기관에 의해 행정의사가 내부적으로 결정되어야 한다.
- ③ 외부적 성립 : 내부적 의사결정이 행정기관 밖으로 표시되어야 한다.
- ④ 성립요건을 불충족한 경우 행정행위는 <부존재>하는 것이 되어, 부존재확인청구소송의 대상이 된다.

03 행정행위의 적법요건

1) 적법요건의 구분

(1) 주체에 관한 요건

행정행위는 법령상 정당한 권한을 가진 행정청에 의하여 그 권한의 범위 내에서 정상적인 의사에 의하여 발하여져야 한다.

(2) 절차에 관한 요건

- ① 행정행위에 대하여 일정한 절차가 요구되는 경우 그에 관한 절차를 거쳐야 한다.
- ② 특히 행정절차법에서는 행정청이 상대방에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 행정행위를 하는 경우에는 사전통지, 청문, 공청회, 의견제출 등의 절차를 거치도록 하고 있으므로, 이를 준수해야 한다.
- ③ 또한 각 개별법에서 행정행위를 하기 전에 타 기관의 자문이나 협의, 동의 등을 거치도록 규정한 경우가 있다면, 이러한 절차도 준수해야 한다.

(3) 형식에 관한 요건

행정절차법에서는 행정청이 처분을 하는 때에는 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 문서로 하도록 하고 있다.

(4) 내용에 관한 요건

- ① 적법성 : 법률유위원칙에 따라 관련 법규범에 위반되어서는 안되고, 법률유보원칙이 적용되는 범위에서는 법률의 근거가 있어야 한다.
- ② 실현가능성 : 법률상이나 사실상으로 실현가능한 것이어야 한다.
- ③ 명확성 : 객관적으로 그 내용이 명확해야 한다.
- ④ 확정성 : 그 내용이 확정되어야 한다.

2) 적법요건의 판단시점

- ① 행정행위의 **발급시**를 기준으로 적법요건의 충족여부를 판단한다.
- ② 만약 행정행위의 기초가 되는 사실관계나 법령이 행정행위 발급 이후에 변경된다면 이는 행정행위의 위법성 판단에 영향을 미치지 않고, 단지 행정행위의 철회사유가 될 뿐이다.

3) 적법요건을 결여한 행정행위의 효력

- ① 행정행위가 적법요건을 결여하면 <하자 있는 위법한 행정행위>가 된다.
- ② 하자있는 행정행위의 효력은 무효 및 취소할 수 있는 행정행위가 된다.
- ③ 하자의 정도가 무효사유인 경우 행정행위의 효력이 발생하지 않는다.
- ④ 그러나 하자의 정도가 취소사유인 경우 **공정력**에 의해 일단 효력을 발하게 된다.

※ 보충자료 - 행정행위의 하자(홍정선 저)

외부효를 갖는 법령에서 요구되는 적법요건을 완전하게 구비한 것이 아닌 행정행위를 위법행위라 하고, 적법요건을 구비하였다고 하여도 비합목적적인 재량행사가 있는 행정행위를 부당한 행정행위라고 부른다. 여기서 위법과 부당을 하자라 하고, 위법한 행정행위와 부당한 행정행위를 합하여 하자 있는 행정행위라 부른다.

04 행정행위의 효력발생요건

1) 개설

- ① 효력발생요건이란 행정행위가 상대방에 대하여 효력을 발생하기 위한 요건을 말한다.
- ② 효력발생요건이 충족되지 않으면 해당 행정행위는 상대방에 대하여 효력을 발생하지 못하므로 무효이다.

2) 도달주의

- ① 상대방이 있는 행정행위는 상대방에게 **통지(고지)**되어 **도달**됨으로써 효력을 발생한다

[행정절차법] 제14조 (송달)

- ① 송달은 우편, 교부 또는 정보통신망 이용 등의 방법으로 하되, 송달받을 자(대표자 또는 대리인을 포함한다. 이하 같다)의 주소·거소(居所)·영업소·사무소 또는 전자우편주소(이하 “주소등”이라 한다)로 한다. 다만, 송달받을 자가 동의하는 경우에는 그를 만나는 장소에서 송달할 수 있다.

[행정절차법] 제15조 (송달의 효력 발생)

- ① 송달은 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 문서가 송달받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다.

- ② 여기서 <도달>이라 함은 반드시 상대방이 행정행위를 현실적으로 수령하여 그 내용을 알았을 것을 의미하는 것은 아니고, 상대방이 알 수 있는 상태에 놓여진 것을 의미한다.

3) 통지의 방식

- ① 통지의 방식으로는 송달과 고시 또는 공고가 있다.
- ② 상대방이 특정되어 있는 경우에 통지는 송달(예 우편송달, 교부송달 등)의 방법에 의하고, 상대방이 불특정 다수인이거나 상대방의 주거 또는 거소가 불분명하여 송달이 불분명한 경우 등에는 고시 또는 공고에 의한다.

01 구속력

행정행위가 성립·효력발생요건을 갖추면 행정청의 효과의사의 내용이나(법률행위적 행정행위), 법령이 정하는 바에 따라(준법률행위적 행정행위) 일정한 법적효과를 발생시키고 <행정주체와 관계인을 구속하는 힘>을 말한다.

02 존속력

1) 불가변력

(1) 의의

- ① 일부 행정행위는 처분청 스스로도 당해 행위의 내용에 구속되어 직권으로 이를 취소·변경하거나 철회할 수 없는데 행정행위가 갖는 이러한 힘을 불가변력이라고 한다.
- ② 불가변력은 행정행위의 취소·변경·철회를 허용하지 않음으로써 법적 안정성을 도모하고자 하는데 그 의미를 갖는다.
- ③ 무효인 행정행위에는 불가변력이 인정되지 않는다.

(2) 인정범위

- ① 준사법적 행정행위 : 행정심판의 재결, 토지수용 재결 등과 같이 일정한 쟁송절차를 거쳐 행해지는 준사법적 행정행위에는 불가변력이 인정된다.
- ② 확인행위 : 확인행위에 대해서 불가변력이 발생한다고 보는 견해와 취소·철회권이 제한된다고 보는 견해가 있다.

2) 불가쟁력

(1) 의의

- ① 하자 있는 행정행위라 하더라도 쟁송제기기간이 경과하거나 쟁송수단을 다 거친 경우(쟁송절차가 종료된 경우)에는 상대방 또는 이해관계인은 더 이상 그 행정행위의 효력을 다툴 수 없게 하는 효력을 말한다.
- ② 다만 무효인 행정행위에는 불가쟁력이 발생하지 않는다.
- ③ 불가쟁력은 행정법관계의 안정과 능률적인 행정목적의 수행을 위하여 그 효력에 관한 다툼을 제한된 시간 내에서만 허용한다는 목적에서 인정되는 것이다.

(2) 효력

- ① 상대방 또는 이해관계인 : 취소사유의 행정행위에 대해 행정쟁송의 제기는 부적법한 것으로 각하된다.
- ② 행정청 : 처분청은 불가쟁력이 발생한 이후에도 사실적 또는 법적 상황을 다시 심사하여 위법함이 발견되면 행정행위를 취소·철회하거나 새로운 행정행위로 변경할 수 있다.

(3) 국가배상청구소송의 가능여부

a. 문제점

위법한 처분에 불가쟁력이 발생한 후에, 처분의 상대방이 위법한 처분으로 인한 손해에 대해서 국가배상을 청구할 수 있는지가 문제된다.

b. 학설

- ① 처분의 효력을 다투는 취소소송과 피해의 배상을 구하는 국가배상은 그 제도의 취지를 달리하므로 취소판결이 없이도 국가배상을 청구할 수 있다는 적극설
- ② 국가배상을 인정하면 불가쟁력이 발생한 처분에 대한 취소소송을 인정하는 효과가 나타날 수 있으므로 불가하다는 소극설

c. 판례(적극설)

국가배상청구소송은 처분의 효력을 다투는 것이 아니므로 불가쟁력이 발생한 행정행위로 손해를 입은 국민은 손해배상청구권이 시효로 소멸하지 않은 한 국가배상청구소송을 제기할 수 있다.

3) 불가변력과 불가쟁력의 관계

- ① 불가쟁력이 발생한 행정행위도 불가변력이 발생하지 않는 한 행정청은 직권으로 취소·변경·철회할 수 있다.
- ② 불가변력이 발생한 행정행위도 불가쟁력이 발생하지 않는 한 상대방 및 이해관계인은 행정쟁송을 제기하여 다툴 수 있다.

03 강제력(자력집행력·제재력)

1) 자력집행력

- ① 자력집행력은 행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 행정청이 스스로 강제력을 발동하여 그 내용을 실현시키는 힘을 말한다.
- ② 행정행위 중 하명행위만 자력집행력을 가진다.

2) 제재력

행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 그에 대한 제재로서 행정벌(행정형벌과 행정질서벌)을 부과하는 힘을 말한다.

04 공정력

1) 의의

행정행위가 당연무효가 아닌 한 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지 상대방 및 이해관계인에 대하여 일단 유효한 것으로 통용되는 힘을 말한다.

2) 근거

(1) 이론적 근거

행정목적의 신속한 달성, 행정법관계의 안정성 유지, 상대방의 신뢰보호 등과 같은 정책적 고려에서 구하는 법적 안정성설이 통설이다.

(2) 실정법적 근거

행정기본법 제15조에 근거가 있다.

[행정기본법] 제15조 (처분의 효력)

처분은 권한이 있는 기관이 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 유효한 것으로 통용된다. 다만, 무효인 처분은 처음부터 그 효력이 발생하지 아니한다.

3) 구성요건적 효력과의 구별논의

(1) 구성요건적 효력의 의의

유효한 행정행위가 존재하는 이상 처분청 이외 다른 국가기관은 그의 존재를 존중하여 스스로의 판단기초 내지는 구성요건으로 삼아야 한다는 구속력을 말한다.

(2) 근거

실정법상 근거는 없으나, 국가기관 상호간의 권한 존중의 원칙을 이론적 근거로 본다.

(3) 공정력과 구별

- ① 공정력을 넓게 이해하여 구성요건적 효력을 공정력의 한 내용으로 보는 비구별설(판례)
- ② 공정력은 행정행위의 상대방 또는 이해관계인에 대한 구속력이고, 구성요건적효력은 처분청 이외 다른 국가기관에 대한 구속력으로서 양자는 차이가 있다고 보는 구별설(다수설)이 있다.
- ③ 구별설에 따르면 선결문제는 구성요건적 효력과 관련된 문제가 된다.(이하에서 선결문제는 구성요건적 효력으로 서술한다.)

CASE

乙의 토지에 관한 수용재결에 취소사유에 해당하는 하자가 있어, 乙이 수용재결의 하자를 이유로 자신의 소유권 회복을 위한 소유권이전등기말소청구소송을 제기한 경우, 그 승소여부를 검토하시오. (35회 문1번 변형)

01 문제점

- ① 행정소송법 제11조 제1항에서는 행정행위가 당연무효인 경우에는 민사법원은 처분 등의 효력 유무 및 존재 여부를 심사할 수 있다고 규정하고 있다.
- ② 다만, 단순위법(취소사유)인 경우에 대해서는 규정하고 있지 않으므로 민사법원, 형사법원이 행정행위의 효력 유무나 위법 여부에 관한 판단을 할 수 있는지가 문제되며, 이를 소위 선결문제라고 한다.
- ③ 선결문제란 항고소송의 수소법원 이외의 민사법원이나 형사법원에서 본안판단의 전제로서 <행정행위의 위법 여부나 효력유무에 관한 판단>을 할 수 있는가의 문제를 의미한다.

[행정소송법] 제11조 (선결문제)

- ① 처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되어 당해 민사소송의 수소법원이 이를 심리·판단 하는 경우에는 제17조, 제25조, 제26조 및 제33조의 규정을 준용한다.

대법원 2010. 4. 8. 선고 2009다90092 판결

민사소송에 있어서 어느 행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 판단하여 당연무효임을 전제로 판결할 수 있고 반드시 행정소송 등의 절차에 의하여 그 취소나 무효확인을 받아야 하는 것은 아니다.

02 민사사건의 경우

1) 행정행위의 무효확인이 선결문제인 경우

[민법] 제741조 (부당이득의 내용)

법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.

- ① 행정행위가 무효인 경우 구성요건적 효력은 인정되지 않는다.
- ② 따라서 누구든지 행정행위의 무효를 주장할 수 있으므로, 어느 법원도 행정행위의 무효를 확인할 수 있다.
- ③ 또한 행정소송법 제11조 제1항도 <처분등의 효력 유무>가 민사소송의 선결문제인 경우 민사법원이 이를 심리·판단할 수 있다고 규정하고 있다.
- ④ 예를 들어, 과세처분의 무효를 이유로 이미 납부한 세금의 반환을 청구하는 경우, 과세처분이 무효라면 민사법원은 과세처분의 무효를 확인할 수 있다.

2) 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우

(1) 문제점

행정청의 철거명령으로 건물을 철거당해 손해를 입은 자가 그 철거명령의 위법을 이유로 국가배상청구소송을 제기한 경우, 철거명령이 위법한지 여부가 국가배상청구소송의 선결문제가 된다.

[국가배상법] 제2조 (배상책임)

- ① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 “공무원”이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다.

(2) 학설

a. 긍정설

- ① 구성요건적 효력은 행정행위의 적법성 추정이 아니라, 유효성이 잠정적으로 통용되는 효력에 불과하고
- ② 행정소송법 제11조 제1항은 선결문제심사권에 대한 예시적 규정에 불과하므로,
- ③ 민사법원이 행정행위의 위법성 여부를 심사하는 것은 구성요건적 효력에 반하지 않는다는 견해이다.

b. 부정설

- ① 구성요건적 효력은 행정행위의 적법성 추정을 의미한다는 점
- ② 행정행위의 위법성 판단은 항고소송을 제기받은 행정법원만이 배타적 관할을 가진다는 점
- ③ 행정소송법 제11조 제1항은 <처분의 효력 유무 또는 존재 여부>에 대해서는 심리할 수 있다고 규정하고 있으나, <위법여부>는 규정이 없는 바, 민사법원이 위법성 판단에 대한 심사권을 가질 수 없다는 입장이다.

(3) 판례

계고처분이 위법임을 이유로 손해배상을 청구한 사안에서 행정처분의 취소판결이 있어야만 손해배상을 청구할 수 있는 것은 아니라고 보아 긍정설의 입장을 취하고 있다.

대법원 1972. 4. 28. 선고 72다337 판결

위법한 행정대집행이 완료되면 그 처분의 무효확인 또는 취소를 구할 소의 이익은 없다 하더라도, 미리 그 행정처분의 취소판결이 있어야만, 그 행정처분의 위법임을 이유로 한 손해배상청구를 할 수 있는 것은 아니다.

(4) 검토

구성요건적 효력은 행정행위의 적법성을 추정하는 효력은 아니고 행정행위의 위법여부를 묻지 않고 취소되기 전까지 잠정적으로 유효한 것으로 처분청 이외 다른 국가기관을 구속하는 효력이므로 긍정설이 타당하다.

3) 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제인 경우

- ① 민사법원이 당해 행정행위를 취소하여 위법한 행정행위의 효력을 상실시키는 것은 행정행위의 구성요건적 효력에 반한다.
- ② 판례는 행정처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 인정될 경우 이를 전제로 판단 할 수 있으나, 그 하자가 단순한 취소사유에 그칠 때에는 법원은 그 효력을 부인할 수 없다고 판시하였다.

대법원 2001. 1. 16. 선고 98다58511 판결

수용재결이 있는 후에 수용 대상 토지에 숨은 하자가 발견되는 때에는 불복기간이 경과되지 아니한 경우라면 공평의 견지에서 기업자는 그 하자를 이유로 재결에 대한 이의를 거쳐 손실보상금의 감액을 내세워 행정소송을 제기할 수 있다고 보는 것이 상당하나, 이러한 불복절차를 취하지 않음으로써 그 재결에 대하여 더 이상 다툴 수 없게 된 경우에는 기업자는 그 재결이 당연무효이거나 취소되지 않는 한 재결에서 정한 손실보상금의 산정에 있어서 위 하자가 반영되지 않았다는 이유로 민사소송절차로 토지소유자에게 부당이득의 반환을 구할 수는 없다.

03 형사사건의 경우

1) 행정행위의 무효확인이 선결문제인 경우

구성요건적 효력은 행정행위가 무효인 경우에는 인정되지 않으므로 형사법원은 행정행위의 무효를 확인하여 무죄를 선고할 수 있다.

2) 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우

(1) 문제점

행정행위의 위법여부가 형사소송의 범죄구성요건 판단의 선결문제가 된 경우, 형사법원이 행정행위의 위법여부를 심사할 수 있는지에 대해 별도의 규정이 없어서 문제가 된다.

(2) 학설

형사법원에서 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 경우는 민사법원의 경우와 마찬가지로 형사법원이 위법 여부를 심리·판단할 수 있다고 보는 것이 통설·판례의 입장이다.

(3) 판례

개발제한구역법 제30조 제1항에 의하여 행정청으로부터 시정명령을 받은 자가 이를 위반한 경우, 그로 인하여 개발제한구역법 제32조 제2호에 정한 처벌을 하기 위하여는 시정명령이 적법한 것이라야 하고, 시정명령이 당연무효가 아니더라도 위법한 것으로 인정되는 한 개발제한구역법 제32조 제2호 위반죄가 성립될 수 없다고 하여 <긍정설>을 취하고 있다.

대법원 2017. 9. 21. 선고 2017도7321 판결

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법(이하 '개발제한구역법'이라 한다) 제30조 제1항에 의하여 행정청으로부터 시정명령을 받은 자가 이를 위반한 경우, 그로 인하여 개발제한구역법 제32조 제2호에 정한 처벌을 하기 위하여는 시정명령이 적법한 것이라야 하고, 시정명령이 당연무효가 아니더라도 위법한 것으로 인정되는 한 개발제한구역법 제32조 제2호 위반죄가 성립될 수 없다.

(4) 검토

행정소송법 제11조 제1항을 반드시 제한적 열거규정으로 해석하여야 하는 것은 아니라는 점, 구성요건적 효력은 행정행위의 효력과 관련된 것이므로 행정행위의 위법성 판단이 곧 효력을 부인하는 것은 아니라는 점등을 비추어 볼 때, <긍정설>이 타당하다.

3) 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제인 경우

(1) 학설

a. 긍정설

형사법원은 범죄구성요건에 대한 독자적인 판단권이 있다는 점 등을 근거로 형사소송에서는 구성요건적 효력이 미치지 않으므로 형사법원은 행정행위의 효력을 부인할 수 있다고 보는 견해이다.

b. 부정설

- ① 형사법원이 행정행위의 효력을 부인하면 구성요건적 효력에 반할 뿐만 아니라
- ② 현행법상 취소소송의 배타적 관할권 규정에 위반되기 때문에 형사법원은 행정행위의 효력을 부인할 수 없다는 견해이다.

(2) 판례

미성년자(연령미달의 결격자)인 피고인이 소외인의 이름으로 운전면허시험에 응시, 합격하여 교부받은 운전면허는 취소되지 않는 한 유효하므로 피고인의 운전행위는 무면허운전에 해당하지 않는다고 하여 <부정설>의 입장이다.

(3) 검토

- ① 행정행위에는 구성요건적 효력이 있고,
- ② 행정행위가 당연무효가 아닌 한, 현행법상 취소소송의 배타적 관할권 규정에 위반되기 때문에 형사법원은 행정행위의 효력을 부인할 수 없다.

I

행정행위의 무효와 취소

01 의미

1) 무효인 행정행위

- ① 행정행위의 외형은 갖추고 있으나 처음부터 아무런 효력을 발생시키지 않는 행정행위를 말한다.
- ② 한편 행정행위의 일부에 무효사유인 하자가 있는 경우 무효부분이 본질적이지 않고 가분적인 경우 무효부분만이 무효가 된다.

2) 취소할 수 있는 행정행위

- ① 행정행위의 성립에 하자가 있어 권한 있는 기관이 그 법률상의 효력을 소멸시킬 수 있는 행정행위를 말한다.
- ② 취소할 수 있는 행정행위는 일단 유효하게 성립되어 효력을 발생시키고 있으므로 취소하기 전까지는 유효한 행위로 통용된다.

02 무효와 취소의 구별실익

구 분	무효인 행정행위	취소할 수 있는 행정행위
효력 발생 여부	처음부터 아무런 효력 발생하지 않음	취소될 때까지 유효함
선결문제 관련	민·형사법원은 무효 여부가 선결문제가 될 경우 무효 확인 가능	민·형사법원은 행정행위의 효력을 부인할 수 없고, 행정행위의 위법 여부의 판단은 가능
하자의 치유	불인정	인정
하자의 승계	무효인 선행행위 하자는 후행행위에 승계됨	결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 선행행위의 하자가 승계됨(하자승계론)
쟁송형태	무효확인심판 무효확인소송	취소심판 취소소송
쟁송기간	제한 없음(불가쟁력 X)	제한 있음
사정판결	불인정	인정

03 무효와 취소의 구별기준

1) 학설

(1) 중대설

하자의 중대성을 기준으로 하자가 중대하면 그 하자가 명백하지 않더라도 무효라는 견해이다.

(2) 중대명백설

- ① 하자의 중대성과 명백성 모두를 기준으로 하자의 내용이 중대하고, 그 하자가 외관상 객관적으로 명백하면 무효인 행정행위이고 중대성과 명백성 중 어느 하나라도 갖추지 못한 경우에는 취소사유라고 보는 견해이다.
- ② 여기에서 중대성이란 행정행위가 중대한 법률요건을 위반하고 그 위반 정도가 상대적으로 심한 경우를 말하며,
- ③ 명백성이란 일반인의 판단에 의해서도 하자가 있음이 객관적으로 외관상 분명한 것을 말한다.

(3) 명백성 보충요건설

하자의 중대성을 기준으로 하자가 중대하기만 하면 무효가 되는 것이 원칙이지만, 제3자나 공공의 신뢰보호가 필요한 경우에는 보충적으로 명백성을 요구하는 견해이다.

2) 판례

판례는 하자 있는 행정처분이 당연무효가 되기 위하여는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것이어야 한다고 하여 **중대명백설**을 취하고 있다.

대법원 1985. 7. 23. 선고 84누419 판결

행정처분이 당연무효라고 하기 위하여는 그 처분에 위법사유가 있다는 것만으로는 부족하고 그 하자가 중요한 법규에 위반한 것이고 객관적으로 명백한 것이어야 하며 하자가 중대하고도 명백한 것인가의 여부를 판별함에 있어서는 그 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰함을 요한다.

3) 검토

행정의 법적 안정성과 국민의 권리구제의 요청을 적절히 조화시키는 측면에서 통설·판례와 같이 무효와 취소에 대한 객관적인 기준을 정립하여 판별하는 중대·명백설이 타당하다.

II 하자의 유형

01 하자의 유형

- ① 행정행위의 하자의 유형에는 주체, 내용, 절차, 형식의 하자가 있으며, 내용상 하자를 제외한 주체, 절차, 형식상의 하자를 넓은 의미의 형식적 하자라고 부르기도 한다.
- ② 취소소송에서 행정행위가 형식상 하자로 인하여 취소된 경우 행정청은 동일한 내용의 처분을 다시 내릴 수 있다.
- ③ 그러나 내용상 하자를 이유로 취소된 경우, 판결의 기속력으로 인하여 행정청은 동일한 내용의 처분을 다시 내리지 못한다.

02 주체상 하자

- ① 행정행위는 정당한 권한을 가진 행정청이 법령에 의하여 부여된 권한의 범위 내에서 정상적인 의사에 따라 행해져야 한다.
- ② 사례

- 정당한 권한을 가진 행정기관이 아닌 자의 행위
- 행정기관의 권한 외의 행위
- 행정기관의 의사에 결함이 있는 행위 등

03 내용상 하자

- ① 행정행위는 법령을 위반하지 않아야 하고 실현가능하며 명확하여야 한다.
- ② 사례

- | | |
|---------------------|------------------|
| - 내용의 실현 불가능 | - 공서양속 위반 |
| - 내용의 불명확 | - 공익위반 |
| - 법 또는 행정법의 일반원칙 위반 | - 위헌인 법률에 근거한 처분 |

※ 보충자료 - 위헌인 법률에 근거한 처분의 효력

- ① 행정처분의 근거법률이 헌법재판소에 의하여 위헌결정을 받은 경우, 그 행정처분은 위헌인 법률에 근거한 처분이므로 당연히 위법하다.
- ② 문제는 위헌인 법률에 근거한 처분의 효력인데, 대법원은 처분의 근거가 되는 법률이 헌법에 위반된다는 점은 결과적으로 법률에 근거없이 처분이 행하여진 것과 마찬가지이므로 하자의 중대성이 인정되나,
- ③ 그것이 헌법재판소에 의하여 확정되기 전까지는 일반인에게 명백한 것이라 할 수 없으므로 취소사유에 해당한다고 보고 있다.

04 절차상 하자

① 법률에서 규정된 절차 중 어느 하나를 거치지 않거나 거쳤으나 절차상 하자가 있는 행정행위는 위법한 행정행위가 된다. 다만, 절차하자가 경미한 경우에는 처분의 효력에 영향을 주지 않는다.

② 사례

- 법령상 필요한 상대방의 신청 또는 동의를 결한 행위
- 타 기관과의 협의 등을 거치지 않은 행위
- 필요한 공고·통지·열람 등을 거치지 아니한 행위
- 필요한 이해관계인의 참여 또는 협의를 결한 행위
- 필요한 청문 또는 의견진술의 기회를 주지 않은 행위
- 환경영향평가의 실시대상사업에서 환경영향평가를 거치지 않고 행한 처분
- 이유제시 등을 결한 행위

05 형식상 하자

① 법령상 문서나 기타 형식을 요구하는 경우에 그에 의하지 않으면 형식상 하자있는 행정행위가 된다.

② 사례

- 문서에 의하지 않은 행위
- 서명·날인을 결한 행위

CASE

국토교통부장관이 감정평가사 甲에게 자격취소 전 청문기일을 5일 전에 통지하였다.

甲이 청문에 출석해 충분히 방어 기회를 가졌을 때 이 절차 하자가 치유될 수 있는지 검토하시오.

[행정절차법] 제21조 (처분의 사전 통지)

② 행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 10일 전까지 제1항 각 호의 사항을 당사자등에게 통지하여야 한다.

01 의의 및 취지

- ① 하자의 치유란 성립당시에 하자가 있는 행정행위가 사후에 하자의 원인이 되는 법률요건을 충족하였거나 또는 그 하자가 취소사유가 되지 않을 정도로 경미해진 경우에 그의 성립당시의 하자에도 불구하고 하자 없는 적법한 것으로 다루는 것을 말한다.
- ② 하자의 치유는 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 인정될 수 있다.

02 인정 여부

1) 학설

- ① 행정의 능률성 측면에서 하자의 치유를 인정하는 <긍정설>
- ② 행정결정의 신중성 확보 측면에서 부정하는 <부정설>
- ③ 국민의 방어권 보장을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용해야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2) 판례

판례는 원칙적으로 하자 치유는 허용될 수 없으나, 예외적으로 국민의 권리나 이익을 침해하지 않는 범위 내에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정해야 한다고 판시한 바 있다.

대판 2014.2.27. 2011두11570

하자 있는 행정행위의 치유는 행정행위의 성질이나 법치주의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이고, 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피함으로써 행정경제를 도모하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 아니하는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정하여야 할 것이다.

3) 검토

하자 치유는 하자의 종류에 따라서, 하자의 치유를 인정함으로써 달성되는 이익과 그로 인하여 발생하는 불이익을 비교형량하여 개별적으로 결정하여야 한다.

03 인정 범위

통설과 판례는 하자의 치유는 취소할 수 있는 행정행위에서만 인정되고, 무효인 행정행위에 대해서는 인정되지 않는다고 본다.

04 하자치유의 사유

- ① 하자치유가 인정되는 사유로는 흠결된 요건의 사후보완(예 필요한 청문이나 이유부기의 사후보완, 요식행위의 형식보완 등)을 드는 것이 일반적이다.
- ② 판례는 형식·절차상의 하자의 경우에만 인정하고, 내용상 하자에 대해서는 치유를 인정하지 않는다.

대법원 1992. 10. 23. 선고 92누2844 판결

행정청이 식품위생법상의 청문절차를 이행함에 있어 청문서 도달기간을 다소 어겼지만 영업자가 이의하지 아니한 채 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 변명하는 등 방어 기회의 기회를 충분히 가진 경우 하자는 치유되었다고 봄이 상당하다.

대법원 2001.3.27. 99두8039

과세관청이 과세처분에 앞서 납세의무자에게 보낸 과세예고통지서 등에 납세고지서의 필요적 기재사항이 제대로 기재되어 있어 납세의무자가 그 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 전혀 지장을 받지 않았음이 명백하다면, 이로써 납세고지서의 하자가 보완되거나 치유될 수 있다.

05 하자치유의 한계

1) 실체적 한계

- ① 행정행위의 하자의 치유는 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위 내에서만 허용된다.
- ② 특히 경원자관계의 경우 위법한 수익적 행정행위에 대해 치유를 인정한다면 타방 당사자의 이익을 침해할 수 있으므로 하자치유를 허용할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.(경원자가 충전소 설치허가 시 건물주 동의를 위조하여 허가를 받은 후에 건물주의 동의를 받은 경우 치유 불가, 91누13274)

대법원 2001.6.26. 선고 99두11592

선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다.

2) 시간적 한계

(1) 학설

- ① 국민의 신뢰보호와 예측 가능성을 위해 하자의 치유는 쟁송제기 이전까지만 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>,
② 행정심판의 내부통제 기능을 고려하여 소송제기 이전까지 가능하다고 보는 <소송제기이전시설>
③ 국민의 권리구제의 침해가 없는 경우에 쟁송종결이전까지 허용된다고 보는 <쟁송종결이전시설>이 있다.

(2) 판례

판례는 이유제시(부기)가 결여된 과세처분의 하자치유와 관련하여 늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 하여야 한다고 하여, **쟁송제기이전시설**을 취하고 있다.

대법원 1983. 7. 26. 선고 82누420 판결

피고의 이 사건 과세처분의 하자가 치유되었다는 주장에 대하여 행정행위의 취소원인인 하자의 보완, 관계 행정청의 추인, 행정처분을 장기간 방치함으로 인한 행정목적의 달성, 또는 법률관계의 확정 등으로 행정처분의 하자가 치유되는 것이 보통이지만, 위 세율 과세표준등 산출근거 등을 아울러 고지하도록 규정한 취지가 조세행정의 공정성의 확보와 납세의무자에게 그 부과처분에 대한 불복여부의 결정과 그 불복신청에 편의를 주려는데 있다고 봐야하므로, 그렇다면 피고 주장과 같은 위 뒤늦은 납세고지서의 송달이나 오랜기간(4년)의 경과로 위 각 과세처분의 하자가 치유되었다고 보기 어렵다.

(3) 검토

- ① 소송 중 치유가 가능하다고 보는 쟁송종결이전시설은 행정의 효율성을 일방적으로 강조하여 행정절차가 갖는 사전권리구제의 기능과 공정한 행정의 보장을 본질적으로 훼손시킬 우려가 있다.
- ② 따라서 행정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기능 등을 종합 고려하여 쟁송제기 전까지 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.

06 효과

하자의 치유는 **소급효**가 있다. 즉, 행정행위의 하자가 치유되면 당해 행정행위는 치유시가 아니라 처음부터 하자가 없는 적법한 행정행위로서 그 효력이 발생한다.

IV 하자있는 행정행위의 전환

01 의미

- ① 하자있는 행정행위의 전환이란 하자가 있는 행정행위가 본래의 행정행위로서는 무효이나 다른 행정행위로 보면 그 요건이 충족되는 경우에 하자 있는 행정행위를 하자 없는 다른 행정행위로 인정하는 것을 말한다.
(예) 사망자에 대한 과세처분을 상속인에 대한 처분으로 전환하는 경우 등)
- ② 전환이 이루어지면 전환 후의 행정행위가 처음부터 적법한 것으로 간주된다.

CASE

이 사건 토지는 [국토의 계획 및 이용에 관한 법률]에 따른 도시계획시설인 공원 부지로 토지수용의 대상이 되었다.
 2024.11.15. 이 사건 토지에 대하여 관할 토지수용위원회의 수용재결이 이루어졌다.
 이에 甲은 2024.12.2. 수용보상금증액청구소송을 제기하면서 표준지공시지가결정의 위법을 주장하고 있다.
 甲의 주장이 인용될 수 있는지를 검토하시오.(36회 문2 변형)

01 의의 및 논의 배경

- ① 하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우에, 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다룰 수 있는지에 대한 문제를 말한다.
- ② 이는 법적 안정성의 요청과(불가쟁력) 국민의 권리구제의 조화의 문제이다.

02 전제조건 [처치불적]

1) 선행행위와 후행행위 모두 처분일 것

선행행위와 후행행위 모두 항고소송의 대상이 되는 처분이어야 한다.

2) 선행행위에 취소사유의 하자가 존재할 것

- ① 선행행위에는 취소사유의 하자가 존재하여야 한다.
- ② 선행행위가 무효인 경우에 당사자는 선행행위의 무효를 언제나 주장할 수 있고 또한 선행행위의 무효는 당연히 후행 행정행위에 승계되어 후행행위도 무효가 되므로 하자의 승계를 논의할 실익이 없다.

대법원 1999. 4. 27. 선고 97누6780 판결

적법한 건축물에 대한 철거명령은 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 할 것이고, 그 후행행위인 건축물철거 대집행계고처분 역시 당연무효라고 할 것이다.

3) 선행행위에 불가쟁력이 발생할 것

선행행위에 대한 제소기간이 경과하지 않은 경우에는 선행행위의 위법 여부를 직접 다룰 수 있으므로 하자의 승계가 논의되기 위해서는 선행행위에 불가쟁력이 발생하여야 한다.

4) 후행행위는 적법할 것

후행행위에 고유한 위법 사유가 있으면 굳이 하자의 승계를 논의하지 않고 후행행위를 직접 다룬다면 되므로 하자의 승계가 논의되기 위해서는 후행행위가 적법하여야 한다.

1) 학설

(1) 하자승계론 (전통적 견해)

- ① 선행행위와 후행행위가 **결합**하여 **하나**의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하고
- ② 양 행위가 서로 **독립**하여 **별개**의 법적 효과를 발생시키는 경우에는 하자가 승계되지 않는다고 본다.

(2) 구속력론 (새로운 견해)

- ① 선행행위가 후행행위에 대하여 **구속력**이 미치는 범위(한계)내에서는 하자의 승계를 부정하는 견해이다.
- ② 선행행위의 구속력이 미치기 위해서는
 - (ㄱ) 선행행위와 후행행위는 동일한 목적을 추구하며 법적효과가 기본적으로 일치할 것(객관적 한계),
 - (ㄴ) 선행행위와 후행행위의 수범자(상대방)가 일치할 것(주관적 한계),
 - (ㄷ) 선행행위의 사실적·법적 상태가 동일하게 유지될 것(시간적 한계)이 요구된다.
- ③ 선행행위의 구속력이 미치는 범위내에서는 하자승계가 부정되지만, 예외적으로 이것이 당사자에게 **수인한도**를 넘는 가혹함을 가져오며 그 결과가 당사자에게 **예측가능**한 것이 아닌 경우에는 구속력이 차단되어 하자가 승계된다고 본다.

2) 판례

(1) 원칙

- ① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다.
- ② (ㄱ) 대집행절차상 계고·영장에 의한 통지·대집행의 실행·비용징수의 각 행위,
(ㄴ) 강제징수절차상 독촉·압류·매각·청산의 각 행위 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
- ③ 반면
 - (ㄱ) 표준지공시지가결정과 개별공시지가결정
 - (ㄴ) 표준지공시지가의 조세부과처분
 - (ㄷ) 건물철거명령과 대집행 계고
 - (ㄹ) 사업인정과 수용재결 사이
 - (ㄴ) 재조사청구 조정결정 통지를 받은 개별공시지가결정과 과세처분 사이에는 하자승계를 부정하였다.

(2) 예외

- ① (그러나) 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 **수인한도**를 넘는 가혹함을 가져오고, 그 당사자에게 **예측가능**한 것이 아니라면 선행처분의 구속력을 인정할 수 없다고 하여 하자승계를 긍정하였다.
- ② (ㄱ) 개별통지가 없는 개별공시지가결정과 과세처분
 - (ㄴ) 표준지공시지가결정과 재결(보상금증감청구소송)은 별개의 법적효과를 목적으로 함에도 불구하고, 예측가능성이 없고, 수인한도를 넘는 경우에는 하자승계를 긍정한 바 있다.

3) 검토

- ① 하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다.
- ② 따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계여부를 개별적·구체적으로 판단함에 타당하다.

04 하자승계에 대한 판례정리

1) 하자승계를 인정한 판례

① 대집행절차상 각 행위

대판 1996.2.9. 95누12507

대집행의 계고, 대집행영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 대집행에 요한 비용의 납부명령 등은, (중략) 동일한 행정목적 달성을 위하여 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여지는 것으로서 서로 결합하여 하나의 법률효과를 발생시키는 것이므로 (중략) 선행처분인 계고처분이 하자가 있는 위법한 처분이라면 (중략) 후행처분인 대집행영장발부통보처분 자체에는 아무런 하자가 없다고 하더라도, 후행처분인 대집행영장발부통보처분의 취소를 구하는 청구소송에서 청구원인으로 선행처분인 계고처분이 위법한 것이기 때문에 그 계고처분을 전제로 행하여진 대집행영장발부통보처분도 위법한 것이라는 주장을 할 수 있다.

② (개별통지가 없는) 개별공시지가와 과세처분

대판 1994.1.25. 93누8542

개별공시지가는 이를 토지소유자나 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 토지소유자 등이 개별공시지가 결정 내용을 알고 있었다고 전제하기도 곤란할 뿐만 아니라 결정된 개별공시지가가 자신에게 유리하게 작용될 것인지 또는 불이익하게 작용될 것인지 여부를 쉽사리 예견할 수 있는 것도 아니며 (중략) 선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우에는 국민의 재판받을 권리를 보장하고 있는 헌법의 이념에 비추어 선행처분의 후행처분에 대한 구속력은 인정될 수 없다.

③ 표준지공시지가와 수용재결 (보증소)

대판 2008.8.21. 2007두13845

표준지공시지가결정은 이를 기초로 한 수용재결 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하지만, 표준지공시지가는 이를 인근 토지의 소유자나 기타 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 인근 토지의 소유자 등이 표준지공시지가결정 내용을 알고 있었다고 전제하기가 곤란할 뿐만 아니라, (중략) 위법한 표준지공시지가결정에 대하여 그 정해진 시정절차를 통하여 시정하도록 요구하지 않았다는 이유로 위법한 표준지공시지가를 기초로 한 수용재결 등 후행 행정처분에서 표준지 공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인한도를 넘는 불이익을 강요하는 것으로서 국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에도 부합하는 것이 아니다.

따라서 표준지공시지가결정이 위법한 경우에는 그 자체를 행정소송의 대상이 되는 행정처분으로 보아 그 위법 여부를 다룰 수 있음은 물론, 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 선행처분으로서 그 수용대상 토지가격산정의 기초가 된 비교표준지공시지가결정의 위법을 독립한 사유로 주장할 수 있다.

2) 하자승계를 부정한 판례

① 표준지공시지가와 개별공시지가

대판 1996.9.20. 95누11931

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 대하여 불복하기 위하여는 (구)지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청을 상대로 그 공시지가결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하고, 그러한 절차를 밟지 아니한 채 개별토지가격결정의 효력을 다투는 소송에서 그 개별토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가의 위법성을 다툴 수는 없다.

② 표준지공시지가의 조세부과처분

대판 1997.2.28. 96누10225

표준지로 선정된 토지의 공시지가에 불복하기 위하여는 (구)지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률 제8조 제1항 소정의 이의절차를 거쳐 처분청인 건설부장관을 상대로 그 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 하는 것이지 그러한 절차를 밟지 아니한 채 그 표준지에 대한 조세부과처분의 취소를 구하는 소송에서 그 공시지가의 위법성을 다툴 수는 없다.

(개별토지가격에 대한 불복방법과는 달리 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 위와 같이 제한하고 있는 것은 표준지의 공시지가와 개별토지가격은 그 목적·대상·결정기관·결정절차·금액 등 여러 가지면에서 서로 다른 성질의 것이라는 점을 고려한 것이므로, 이러한 차이점에 근거하여 표준지의 공시지가에 대한 불복방법을 개별토지가격에 대한 불복방법과 달리 인정한다고 하여 그것이 헌법상 평등의 원칙, 재판권 보장의 원칙에 위반된다고 볼 수는 없다고 할 것이다. 1997.9.26.선고96누7649)

③ 건물철거명령과 대집행 계고

대판 1998.9.8. 97누20502

건물철거명령이 당연히무효가 아닌 이상 행정심판이나 소송을 제기하여 그 위법함을 소구하는 절차를 거치지 아니하였다면 위 선행행위인 건물철거명령은 적법한 것으로 확정되었다고 할 것이므로 후행행위인 대집행계고처분에서는 그 건물이 무허가건물이 아닌 적법한 건축물이라는 주장이나 그러한 사실인정을 하지 못한다.

④ 사업인정과 수용재결 사이

대판 1992.3.13. 91누4324

사업인정처분 자체의 위법은 사업인정단계에서 다투어야 하고 이미 그 쟁송기간이 도과한 수용재결단계에서는 사업인정처분이 당연히 무효라고 볼 만한 특단의 사정이 없는 한 그 위법을 이유로 재결의 취소를 구할 수는 없다.

⑤ (재조사청구에 따른 조정결정을 통지받은) 개별공시지가와 과세처분 사이

대법원 1998. 3. 13. 선고 96누6059

개별토지가격 결정에 대한 재조사 청구에 따른 감액조정에 대하여 더 이상 불복하지 아니한 경우, 이를 기초로 한 양도소득세 부과처분 취소소송에서 다시 개별토지가격 결정의 위법을 당해 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 한 사례

⑥ 기타

- 1) 도시관리계획의 결정 및 고시, 사업시행자지정고시, 사업실시계획인가고시, 수용재결 등 도시계획시설사업의 각 처분사이 (현재 2010.12.28. 2009헌바429)
- 2) 도시계획결정과 수용재결 사이 (대판 1990.1.23. 87누947)
- 3) 조합설립추진위원회구성승인과 조합설립인가 사이 (대판 2013.12.26. 2011두8291)
- 4) [도시 및 주거환경정비법]상 주택재건축조합의 사업시행계획과 관리처분계획 사이 (대판 2012.8.23. 2010두13463)
- 5) 택지개발계획승인처분과 수용재결 사이 (대판 1996.4.26. 95누13241)
- 6) 택지개발예정지구지정과 택지개발계획승인처분 사이 (대판 1996.12.6. 95누8409)
- 7) 재개발사업시행인가처분과 토지수용재결처분 사이 (대판 1992.12.11. 92누5584)
- 8) 도시군계획시설결정과 실시계획 인가처분 사이 (대판 2017.7.18. 2016두49938)

I

행정행위의 직권취소

CASE

국도교통부장관 乙은 감정평가법인 甲이 거짓으로 정관을 작성하는 등 부정한 방법으로 감정평가법인 인가를 받은 경우, 국도교통부장관 乙이 직권으로 해당 인가를 취소할 수 있는지 여부를 설명하시오.

01 의의 및 근거

- ① 행정행위의 취소(직권취소)란 일단 유효하게 성립한 행정행위를 그 성립에 있어서 위법 또는 부당한 하자가 있음을 이유로, 그 효력의 전부 또는 일부를 소멸시키는 행정청의 의사표시를 말한다.
- ② 취소는 독립된 새로운 행정행위이며, 성립 이후의 하자를 이유로 하는 철회와 구별된다.
- ③ 행정기본법 제18조에 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제18조 (위법 또는 부당한 처분의 취소)

- ① 행정청은 위법 또는 부당한 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다. 다만, 당사자의 신뢰를 보호할 가치가 있는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 장래를 향하여 취소할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따라 당사자에게 권리나 이익을 부여하는 처분을 취소하려는 경우에는 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 공익과 비교·형량(衡量)하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 처분을 받은 경우
 2. 당사자가 처분의 위법성을 알고 있었거나 중대한 과실로 알지 못한 경우

대법원 1995. 9. 15. 선고 95누6311 판결

개별토지에 대한 가격결정도 행정처분에 해당하며, 원래 행정처분을 한 처분청은 그 행위에 하자가 있는 경우에는 원칙적으로 별도의 법적 근거가 없더라도 스스로 이를 직권으로 취소할 수 있다.

02 직권취소의 제한

1) 침익적 행정행위의 경우

침익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 이익을 주므로 침익적 행정행위의 취소권 행사는 원칙적으로 자유롭다.

2) 수익적 행정행위의 경우

- ① 수익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 침익적 행위가 되므로 수익적 행정행위의 취소권 행사는 제한을 받는다.(행정기본법 제18조 제2항)
- ② 적법상태의 실현에 대한 공익과 개인의 기득권에 대한 신뢰보호를 비교·형량하여 취소여부를 결정하여야 한다는 것이 학설과 판례의 태도이다.

- ③ 따라서 수익적 행정행위의 취소는 비례의 원칙, 신뢰보호의 원칙, 실권의 법리 등에 의해 제한받는다.
- ④ 처분의 하자가 수익자의 책임 있는 사유에 기인하는 경우에는 신뢰의 보호가치가 부정되어 취소가 제한되지 않는다.(행정기본법 제18조 제2항 단서)

3) 복효적 행정행위의 경우

위법한 복효적 행정행위의 직권취소의 경우 취소로 인한 상대방의 이익 또는 불이익과 함께 제3자의 이익 또는 불이익도 고려하여 취소여부를 결정해야 하므로 취소가 제한된다.

03 직권취소의 효과

1) 침익적 행정행위의 경우

소급효를 인정해도 일반적으로 상대방의 신뢰를 해치지 않기 때문에 **소급효가 원칙**이다.

2) 수익적 행정행위의 경우

- ① 상대방에게 귀책사유가 없는 한 취소의 효과가 **소급하지 않는 것이 원칙**이다.
- ② 그러나 상대방에게 귀책사유가 있거나 취소의 소급효를 인정하지 않으면 심히 공익에 반하는 경우에는 소급효 있는 취소가 가능하다.

3) 복효적 행정행위의 경우

행정행위의 상대방 및 제3자의 이익 및 귀책사유에 따라 취소의 소급효 여부 및 정도가 결정된다.

04 직권취소의 취소

1) 문제점

- ① 직권취소도 하나의 행정행위로서 그 직권취소에 하자가 있는 경우 해당 취소처분을 취소함으로써 원래의 행정행위의 효력을 회복시킬 수 있는지가 문제 된다.
- ② 직권취소에 무효사유의 하자가 있는 경우 그 취소처분은 무효이므로 당연히 원래의 행정행위는 그대로 존속한다.
- ③ 따라서 직권취소의 하자가 **취소사유일 때 문제**된다.

2) 학설

- ① 취소의 취소도 행정행위인 바 원행정행위가 소생된다는 <긍정설>
- ② 취소로 인해 해당 행위의 효력이 확정적으로 소멸하므로 명문의 규정이 없는 한 동일한 처분을 하여야 한다는 <부정설>
- ③ 원칙적으로 취소의 취소는 불가하지만, 수익적 행정행위의 취소는 위법한 취소를 취소하여 원상회복시킬 필요가 있으므로 취소의 취소를 인정하여야 한다는 <절충설>

3) 판례

부담적 행정행위의 경우에는 상대방의 신뢰보호이익을 위해 취소의 취소를 부정하고, 수익적 행정행위의 경우에는 제3자의 이해관계가 개입되지 않은 경우에 한하여 취소의 취소가 가능하다고 하여, **절충설**의 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.

01 의의 및 근거

- ① 적법하게 성립한 행정행위에 대해 그 효력을 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생하였음을 이유로 장래에 향하여 그의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다.
- ② 행정기본법 제19조에서 철회의 근거를 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제19조 (적법한 처분의 철회)

- ① 행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다.
 1. 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우
 2. 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우
 3. 중대한 공익을 위하여 필요한 경우
- ② 행정청은 제1항에 따라 처분을 철회하려는 경우에는 철회로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 철회로 달성되는 공익과 비교·형량하여야 한다.

02 철회의 사유

1) 행정기본법 상의 철회사유

- ① 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우
- ② 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우
- ③ 중대한 공익을 위하여 필요한 경우

2) 학설과 판례상 철회사유

- ① 상대방의 법령위반이나 의무위반이 있는 경우(예) 불법영업으로 인한 영업취소)
- ② 부담 불이행의 경우(예) 점용료 미납으로 인한 도로점용허가취소)
- ③ 철회권이 부관으로 유보된 경우 등

03 철회의 제한

1) 침익적 행정행위의 철회

침익적 행정행위의 철회는 상대방에게 이익을 가져다주므로 별다른 제한을 받지 않고 자유롭게 할 수 있음이 원칙이다.

2) 수익적 행정행위의 철회

- ① 수익적 행정행위의 철회는 상대방의 신뢰와 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 철회사유가 발생한 경우에도 철회를 하여야 하는 공익상의 필요, 상대방의 신뢰, 기득권 보호, 법적 안정성의 유지 등 관련된 모든 이익을 비교·형량하여 철회 여부를 결정하여야 한다.
- ② 따라서 직권취소와 마찬가지로 비례의 원칙이나 신뢰보호의 원칙 등을 위배하여 행한 철회는 위법한 처분이 된다.

04 철회의 효과

- ① 행정기본법 제19조 제1항에서 '행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다'고 규정하고 있다.
- ② 따라서 철회의 효과는 **장래에 향하여** 발생하는 것이 원칙이다.

05 철회의 취소

- ① 철회에 하자가 있는 경우 이를 취소하여 본래의 행정행위를 소생시킬 수 있는지가 문제된다.
- ② 이는 <하자 있는 취소의 취소>와 동일한 논리가 적용된다.
- ③ 판례는 침익적 행정행위의 철회의 취소는 인정하지 않지만, 수익적 행정행위의 철회의 취소는 가능한 것으로 본다.

III 행정행위의 실효

01 의미

- ① 행정행위의 실효란 유효한 행정행위의 효력이 행정청의 의사표시에 의하지 않고 **일정한 사실의 발생**으로 장래에 향하여 당연히 그 효력이 소멸되는 것을 말한다.
- ② 취소와 철회는 행정청의 의사표시가 필요하나, 실효는 **행정청의 의사표시와 무관하게** 당연히 효력이 소멸한다는 점에서 차이가 있다.
- ③ 실효사유가 발생하면, 그 행정행위는 행정청의 특별한 의사표시 없이 장래를 향해 당연히 소멸된다.

「토지보상법」 제23조의 사업인정의 실효

사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내 재결신청 하지 않는 경우 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

02 실효의 사유

- ① 행정행위 대상의 소멸(예) 위법건축물의 화재로 철거명령의 소멸)
- ② 해제조건의 성취 또는 종기의 도래
- ③ 목적의 달성 또는 목적 달성의 불가능(예) 위법건축물의 철거로 철거명령의 실효)

03 실효의 효과

실효사유가 발생하면 행정청의 특별한 의사표시 없이 그때부터 **장래를 향하여** 당연히 효력이 소멸된다.

CASE

국토교통부장관은 폐기물처리사업자인 A가 제출한 사업인정신청에 대하여, 전체 사업부지의 50%를 녹지로 조성하여 국가에 기부채납할 것을 조건(강학상 부담)으로 사업인정을 하였다. 이와 관련하여, 사업시행자인 A가 '녹지 50% 기부채납' 조건만의 취소를 구할 수 있는지 검토하시오.

01 의미 및 구별개념

1) 의미

- ① 부관이란 주된 행정행위의 효과를 제한하거나 요건을 충족시키기 위하여 부가된 종된 규율을 말한다.
- ② 부관은 학문상 개념이고 실정법에서는 주로 조건으로 표시되고 있다.
- ③ 부관은 행정청으로 하여금 구체적인 사정에 적합한 행정을 할 수 있도록 행정의 유연성과 탄력성, 상황적합성을 부여해주는 기능을 한다.
- ④ 부관은 주된 행정행위에 의존(부종성)하는 것으로, 특별한 규정이나 약정이 없는 한 주된 행정행위가 효력을 상실하면 부관도 그 효력을 상실한다.

2) 법정부관과의 구별

- ① 법령이 직접 행정행위의 조건, 기한 등을 정하는 경우와 같이 법령의 규정에 의해 직접 부가된 부관을 법정부관이라 한다.
- ② 법정부관은 행정청이 스스로의 의사로 붙이는 것이 아닌 법령의 규정에 의해 부가된 것이므로 법규의 실질을 가진다.
- ③ 따라서 법정부관에 대해서 다투려는 경우에는 법령에 대한 규범통제제도에 의해 통제된다.

02 법적근거

행정기본법 제17조가 행정행위의 부관에 대한 일반법적 근거가 되며 부관의 요건 및 한계를 명문화하고 있다.

[행정기본법] 제17조 (부관)

- ① 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.
- ② 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.

03 부관의 종류

1) 조건

- ① 조건이란 행정행위의 효과의 발생 또는 소멸을 장래에 발생 여부가 불확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다.
- ② 조건이 성취되어야 행정행위의 효력이 발생하는 정지조건과 조건이 성취되면 행정행위의 효력이 소멸하는 해제조건이 있다.

2) 기한

(1) 의의

기한이란 행정행위의 효과의 발생 또는 소멸을 장래에 발생 여부가 확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다.

(2) 종류

기한이 도래함으로써 행정행위의 효력이 발생하는 기한을 시기라 하고, 행정행위의 효력이 상실되는 기한을 종기라 한다.

(3) 종기의 해석

행정행위가 그 내용상 장기간에 걸쳐 계속될 것이 예상되는데, 그 유효기간이 허가 또는 특허된 사업의 성질상 부당하게 단기로 붙여진 경우, 그 유효기간은 당해 행정행위의 존속기간이 아니라 행정행위의 조건의 갱신기간으로 보는 것이 판례의 입장이다.

3) 부담

(1) 의의

- ① 부담이란 행정행위의 주된 내용에 부수하여 상대방에게 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 부과하는 부관을 말한다.
- ② 부담은 그 자체가 행정행위이므로, 독립하여 항고소송의 대상이 된다.

(2) 조건과의 구별

- ① 정지조건부 행정행위는 일정한 사실의 성취가 있어야 효력이 발생하는 반면, 부담부 행정행위는 처음부터 효력이 발생한다는 점에서 차이점이 있다.
- ② 해제조건부 행정행위는 일정한 사실의 성취에 의하여 당연히 효력이 소멸되는데 반하여 부담은 이를 이행하지 않더라도 당연히 효력이 소멸되지 않는다는 점(단지 철회사유가 된다.)에서 차이점이 있다.
- ③ 양자의 구별에는 행정청의 객관적인 의사가 중요하며, 부담과 조건의 구별이 애매한 경우에는 상대방에게 유리한 부담으로 추정한다.

(3) 기한과의 구별

기한은 그 도래에 의해 주된 행정행위의 효력을 발생 또는 실효시키지만, 부담의 경우는 의무기한의 도래로 의무불이행이 되어 철회사유가 될 뿐이다.

(4) 부담의 불이행 문제

- ① 부담불이행시 부담부 행정행위가 당연히 효력을 상실하는 것이 아니라, 부담부 행정행위의 **철회사유**가 될 뿐이다. (예) 점용료 미납부시 도로점용허가 철회)
- ② 철회시에는 철회의 일반이론에 따라 이익형량 원칙이 적용된다.
- ③ 부담의 불이행은 위와 같은 철회에 이르지 않더라도 독립하여 행정상의 **강제집행**이나 제재의 대상의 된다. (예) 점용료 미납부시 점용료 강제징수)

4) 철회권 유보

(1) 의의

- ① 철회권 유보란 일정한 경우에 행정행위를 철회하여 행정행위의 효력을 소멸시킬 수 있는 권한을 유보하는 부관을 말한다.
- ② 철회권의 유보는 행정의 상대방에게 철회의 가능성을 미리 주지시킴으로써 철회시 상대방의 **신뢰보호원칙** 주장을 제한하고 공익침해를 방지한다.

(2) 법적근거

- ① 별도의 법적근거가 없더라도 행정청은 부관으로 철회권을 유보할 수 있다.
- ② 법령에 철회사유가 명시되어 있는 경우에 법령에 규정된 명시적인 사유 이외의 사유를 들어 철회권을 유보할 수 있다.

5) 법률효과의 일부배제

- ① 법률효과의 일부배제란 법령이 행정행위에 부여하는 효과의 일부를 배제하는 내용의 부관을 말한다. (예) 공유수면매립지 일부의 국가귀속)
- ② 법률의 근거가 있는 경우에만 허용된다.
- ③ 판례와 다수설은 법률효과 일부배제를 부관으로 보고 있다.

6) 수정부담

- ① 의의 : 수정부담이란 상대방이 신청한 것과는 다르게 행정행위의 내용을 정하는 것을 말한다.
- ② 법적성질 : 수정부담은 신청한 내용의 처분을 거부하고 다른 내용의 처분을 하는 것이므로 **변경처분**에 해당한다는 것이 통설적 견해이다.
- ③ 권리구제 : 수정된 내용의 행정행위에 대한 취소소송을 제기할 것이 아니라, 신청한 내용에 대한 의무이행심판이나 거부처분취소소송을 제기해야 한다.

CASE

다음 부관이 어떠한 부관에 해당하는지 검토하시오.

A : 환경영향평가가 통과될 경우에 한하여 사업인정 효력 발생한다.

B : 사업부지 중 20%를 공원으로 조성하여 기부채납한다.

C : 공익상 필요하다고 인정되는 사유가 발생하면 사업인정을 철회할 수 있다

D : 2025년 12월 31일까지 사업 미착수시 효력을 상실한다.

답 : A(조건), B(부담), C(철회권유보), D(기한)

04 부관의 가능성

- ① 종래 기속행위에는 불가능하고 재량행위에는 가능하다는 견해가 지배적이었다.
- ② 그러나 최근에는 기속행위라도 요건충족적 부관이 가능하고, 재량행위라도 귀화허가(신분설정행위)와 같은 부관의 부칙이 금지되는 경우가 있으므로 개별적, 구체적으로 검토해야 한다.

[행정기본법] 제17조 (부관)

- ① 행정청은 처분에 재량이 있는 경우에는 부관(조건, 기한, 부담, 철회권의 유보 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 붙일 수 있다.
- ② 행정청은 처분에 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에 부관을 붙일 수 있다.

05 부관의 한계

1) 시간적 한계

- ① 행정행위를 발령한 후에 부관을 새로이 부칙(사후부관)하거나 변경(사후변경)할 수 있는지가 부관의 시간적 한계로서 문제가 된다.
- ② 행정기본법 제17조 제3항이 정하는 사유 외에 판례는 사후변경이 미리 유보된 경우에도 부관의 사후변경이 가능하다고 본다.

[행정기본법] 제17조 (부관) [법동사]

- ③ 행정청은 부관을 붙일 수 있는 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분을 한 후에도 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경할 수 있다.
 1. 법률에 근거가 있는 경우
 2. 당사자의 동의가 있는 경우
 3. 사정이 변경되어 부관을 새로 붙이거나 종전의 부관을 변경하지 아니하면 해당 처분의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

2) 내용상 한계 [목실취]

(1) 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것

주된 행정행위의 목적에 반하거나 그 본질적 효력을 해하지 않아야 한다.

(2) 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것

부관이 주된 행정행위와 실질적 관련성이 없는 경우에는 부당결부금지의 원칙에 위반된다.

(3) 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것

주된 행정행위의 효과를 무의미하게 만드는 경우라면 그러한 부관은 비례원칙에 위반된다.

[행정기본법] 제17조 (부관) [목실취]

- ④ 부관은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.
 1. 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것
 2. 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것
 3. 해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것

06 위법한 부관에 대한 행정쟁송

1) 부관의 독립쟁송가능성 (대상적격)

(1) 문제점

주된 행정행위와 분리하여 부관만을 소송대상으로 삼을 수 있는지가 문제된다.

(2) 학설 [부분전]

- ① 부담은 그 자체가 독립된 행정행위이므로 **부담만이 독립적으로 행정쟁송 제기가 가능**하고, 그 외의 부관은 부관부행정행위 전체를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <부담·기타부관 구별설>이 있다.(다수설, 판례)
- ② 독립쟁송가능의 문제는 부관의 독립 취소가능성 문제의 전제조건이므로 독립취소가 인정될 수 있을 정도로 주된 행정행위와의 **분리가능성**을 가지는 부관이라면, 부관만 독립하여 다룰 수 있다고 보는 <분리가능성설>
- ③ 부관의 분리가능성은 본안의 문제이며, 소송요건의 문제는 아니기 때문에 모든 부관은 **소의 이익이 있는 한** 독립하여 취소쟁송의 대상이 된다고 보는 <전부가능성설>등이 있다.

(3) 판례

- ① 대법원은 일관되게 **부담만이** 항고소송의 대상이 될 수 있다고 보며, 기타 부관은 독립하여 항고소송의 대상이 될 수 없다는 입장이다.
- ② 따라서 부담이 아닌 부관만의 취소를 구하는 소송이 제기된 경우에 법원은 각하판결을 하여야 한다고 본다.

대법원 1992. 1. 21. 선고 91누1264 판결

행정행위의 부관은 행정행위의 일반적인 효력이나 효과를 제한하기 위하여 의사표시의 주된 내용에 부가되는 종된 의사표시이지 그 자체로서 직접 법적 효과를 발생하는 독립된 처분이 아니므로 현행 행정쟁송제도 아래서는 부관 그 자체만을 독립된 쟁송의 대상으로 할 수 없는 것이 원칙이나 행정행위의 부관 중에서도 행정행위에 부수하여 그 행정행위의 상대방에게 일정한 의무를 부과하는 행정청의 의사표시인 부담의 경우에는 다른 부관과는 달리 행정행위의 불가분적인 요소가 아니고 그 존속이 본체인 행정행위의 존재를 전제로 하는 것일 뿐이므로 부담 그 자체로서 행정쟁송의 대상이 될 수 있다.

대법원 1986. 8. 19. 선고 86누202 판결

어업면허처분을 함에 있어 그 면허의 유효기간을 1년으로 정한 경우, 위 면허의 유효기간은 행정청이 위 어업면허처분의 효력을 제한하기 위한 행정행위의 부관이라 할 것이고 이러한 행정행위의 부관은 독립하여 행정소송의 대상이 될 수 없는 것이므로 위 어업면허처분 중 그 면허유효기간만의 취소를 구하는 청구는 허용될 수 없다.

(4) 검토

- ① 본안의 문제인 독립취소가능성과 소송요건의 문제인 독립쟁송가능성은 구분하는 것이 타당하고, 위법한 행정작용의 통제를 위해 가능한 쟁송가능성을 넓히는 것이 타당하므로 <전부가능성설>이 타당하다.
- ② 부관의 주된 행정행위로부터의 분리가능성은 독립취소가능성의 문제로 보아야 한다.

2) 쟁송의 형태

(1) 학설

학설은 대체로 부담에 대하여는 진정일부취소소송을, 부담 이외의 부관에 대해서는 부진정일부취소소송의 형식으로 다룰 수 있다고 본다.

※ 보충자료

- ① 진정일부취소소송 : 형식(대상적격)과 내용(본안판단) 모두 부관만의 취소를 구하는 소송
- ② 부진정일부취소소송 : 형식은 부관부 행정행위 전체의 취소를 구하나 내용은 부관만의 취소를 구하는 소송

(2) 판례

- ① 판례는 부진정일부취소소송을 인정하지 않으므로, **부담만이 독립쟁송가능하며 진정일부취소소송**으로 다룰 수 있다고 본다.
- ② 따라서 기타 부관은 부관부 행정행위 전체의 취소를 구하거나, 행정청에 부관이 없는 처분으로 변경을 청구한 후 그것이 거부된 경우 비로소 거부처분취소소송을 제기하여야 한다는 입장이다.

3) 부관의 독립취소가능성 (본안 문제)

(1) 문제점

원고가 부관만의 취소를 구하는 경우에 법원이 그 부관이 위법하다고 판단하여 부관만을 독립하여 취소할 수 있는지 아니면 부관부 행정행위 전체를 취소해야 하는지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 기속행위는 부관의 취소가 가능하고, 재량행위는 부관만의 취소는 인정되지 않는다고 한다.
(재량·기속행위 구별설)
- ② 부관이 주된 행정행위의 중요하고 **본질적 요소**라면 부관만의 취소는 인정되지 않고 부관부행정행위 전체를 취소해야 한다고 한다. 이때 부관이 본질적인 부분인지 여부는 행정청이 부관이 없이는 당해 행정행위를 하지 않았을 것이라고 해석되는지를 행정청의 객관적인 의사를 기준으로 판단해야 한다.(중요성 기준설)
- ③ 취소소송의 소송물이 부관 자체의 위법성이므로 **부관이 위법하면 부관만을 취소**할 수 있다고 한다.
(부관의 위법성 기준설)

(3) 판례

판례는 부담의 독립취소가능성은 인정하고 있으나, 부진정일부취소소송을 인정하지 않으므로 부담 이외 부관은 부정하는 입장이다.

(4) 검토

부관이 본질적임에도 부관만의 취소를 인정하는 것은 행정청의 의사에 반하여 **부관없는 행정행위를 강요**하는 것이 되므로, 국민의 권익구제와 행정목적의 실현을 적절히 조절하는 <중요성 기준설>이 타당하다.

제1절

단계적 행정결정

I

단계적 행정결정

01 단계적 행정결정의 의미

- ① 행정청의 결정이 여러 단계의 행정결정을 통하여 연계적으로 이루어지는 것을 말한다.
- ② 단계적 행정결정의 예로는 확약, 가행정행위, 사전결정 및 부분허가 등이 있다.

02 단계적 행정결정의 필요성

- ① 종국적인 행정결정에 오랜 기간을 요하는 경우가 많아, 당사자에게 본 처분의 가부에 대한 예측가능성이 필요하다.
- ② 또한 오랜 공사기간이 필요한 경우 일부 공사를 미리 시행하는 것이 필요한 경우가 있다.

II

확약

CASE

A도 B군 군수 乙은 대형마트를 유치하기 위하여 대규모점포 개설등록하면 법률상 재량을 행사하여 일체의 영업시간 제한이나 의무휴업일 지정하지 않겠다고 甲에게 약속하였다. 이 말을 믿은 甲은 乙에게 대규모점포의 개설등록을 신청하였고, 개설등록이 되었다. 그런데 개설등록 이후 오전0시부터 오전8시까지 영업시간을 제한하고 매월 둘째 주 일요일을 의무휴업일로 지정한 내용의 처분(제1차 처분)을 하였다.

1. 乙의 사전약속이 확약에 해당하는지 설명하시오.
2. 乙의 사전약속 위반된 처분이 신뢰보호의 원칙에 위반되는지 설명하시오. (2017 사시 변형)

01 의미

- ① 장래 일정한 행정행위를 하거나 하지 아니할 것을 약속하는 의사표시를 말한다.
- ② 확약은 신뢰보호 또는 금반언의 법리를 바탕으로 인정되는 행정청의 행위형식의 하나이다.

02 법적근거

- ① 행정절차법 제40조의2 제1항에서는 신청에 따른 확약의 법적근거를 규정하고 있다.
- ② 학설은 대체로 행정청의 처분권한에 확약의 권한도 포함되어 있다고 본다.

제40조의2 (확약)

- ① 법령등에서 당사자가 신청할 수 있는 처분을 규정하고 있는 경우 행정청은 당사자의 신청에 따라 장래에 어떤 처분을 하거나 하지 아니할 것을 내용으로 하는 의사표시(이하 “확약”이라 한다)를 할 수 있다.
- ② 확약은 문서로 하여야 한다.
- ③ 행정청은 다른 행정청과의 협의 등의 절차를 거쳐야 하는 처분에 대하여 확약을 하려는 경우에는 확약을 하기 전에 그 절차를 거쳐야 한다.

03 법적성질

1) 학설

- ① 확약이 행정청에 대하여 확약의 내용대로 이행할 법적 의무를 발생시킨다는 점에 비추어 확약의 처분성을 인정하는 견해(긍정설)
- ② 확약은 사정변경에 의해 변경될 수 있으므로 종국적 규율성을 가지지 못한다는 점을 근거로 처분성을 부정하는 견해(부정설)

2) 판례

판례는 어업권 우선순위결정을 확약으로 보면서 이는 행정처분이 아니므로 공정력, 불가쟁력 등과 같은 효력이 인정되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다. 그러나 일부 판례에서는 내인가취소를 거부처분으로 보아 처분성을 인정한 사례도 있다.

3) 검토

확약으로 행정청에게 확약을 준수할 의무가 발생하는 점, 확약의 처분성을 인정함으로써 조기에 권리구제를 도모할 수 있다는 점을 고려하여 확약의 처분성을 인정하는 것이 타당하다.

04 확약의 효과

1) 구속력

- ① 행정청이 확약의 내용대로 행위를 하여야 할 법적의무를 지며 상대방에게는 행정청에 대한 확약내용의 이행청구권이 인정된다.
- ② 단, 확약을 한 후에 확약의 내용을 이행할 수 없을 정도로 법령 등이나 사정이 변경된 경우, 확약이 위법한 경우에는 확약에 기속되지 아니한다.

제40조의2 (확약)

- ④ 행정청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 확약에 기속되지 아니한다.
 - 1. 확약을 한 후에 확약의 내용을 이행할 수 없을 정도로 법령등이나 사정이 변경된 경우
 - 2. 확약이 위법한 경우
- ⑤ 행정청은 확약이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하여 확약을 이행할 수 없는 경우에는 지체 없이 당사자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

2) 확약의 실효

확약이 있는 후에 사실적·법률적 상태의 변경이 있는 경우 행정청의 별다른 의사표시가 없더라도 확약은 실효된다는 것이 통설·판례의 태도이다.

05 권리구제

- ① 확약의 처분성을 인정하는 경우 항고소송의 대상이 된다. 그러나, 판례는 확약의 처분성을 부인하고 있다.
- ② 확약한 사항을 이행할 것을 신청하였으나 행정청이 이에 대해 거부하거나 부작위하는 경우에는, 거부처분 취소심판, 의무이행심판, 부작위위법확인소송 또는 거부처분취소소송이 가능할 것이다.

Ⅲ 가행정행위

01 의미

- ① 사실관계와 법률관계의 계속적인 심사를 유보한 상태에서 당해 행정법관계의 권리와 의무의 전부 또는 일부에 대해 **잠정적으로 확정**하는 행위를 의미한다.
- ② 가행정행위는 본행정행위가 있기까지 **잠정적**으로 행정행위로서의 **구속력**을 가지는 행정의 행위형식을 말한다.
(예 잠정세액)

02 법적성질

가행정행위가 전형적인 행정행위라는 입장과 행정행위의 특수한 행위형식으로 보는 입장으로 나누어져 있다.

03 본 행정행위와의 관계

- ① 가행정행위는 잠정적이기는 하지만 행정행위로서 직접 법적 효력을 발생시킨다.
- ② 가행정행위는 본행정행위에 대해 구속력을 미치지 않는다.
- ③ 가행정행위에 대한 신뢰도 인정되지 않는다.
- ④ 가행정행위는 본행정행위가 있게 되면 본행정행위에 의해 **대체**되고 효력을 상실한다.

CASE

甲은 세계품물 야외전시장을 포함하는 미술품 전시시설을 건립하고자 한다. 甲은 자신이 계획하고 있는 시설이 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법') 제4조 제4호의 '미술관'에 해당하는지에 관하여 국토교통부장관에게 서면으로 질의하였다. 이에 대하여 국토교통부장관은 甲의 시설이 토지보상법 제4조 제4호에 열거된 '미술관'에 속한다고 서면으로 통보하였다. 그 후 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 이러한 경우 국토교통부장관은 사업인정을 해주어야 하는가? (17회 문1)

01 의의

최종적인 행정결정을 내리기 전에 사전적인 단계에서 최종적 행정결정의 **요건 중 일부**에 대해 **종국적인 판단**으로서 내려지는 결정을 의미한다.

[건축법] 제10조 (건축 관련 입지와 규모의 사전결정)

- ① 제11조에 따른 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 그 건축물의 건축에 관한 다음 각 호의 사항에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.
1. 해당 대지에 건축하는 것이 이 법이나 관계 법령에서 허용되는지 여부
 2. 이 법 또는 관계 법령에 따른 건축기준 및 건축제한, 그 완화에 관한 사항 등을 고려하여 해당 대지에 건축 가능한 건축물의 규모
 3. 건축허가를 받기 위하여 신청자가 고려하여야 할 사항

02 법적 성질

- ① 사전결정은 그 자체가 하나의 행정행위이다.
- ② 최종처분이 기속행위인 경우 사전결정도 기속행위이다.
- ③ 최종처분이 재량행위인 경우에 사전결정이 재량행위인지 여부는 최종처분의 재량판단 부분이 사전결정의 대상이 되는지에 의해 결정된다.

03 법적 근거

사전결정권은 본처분권에 포함되므로 법규상의 특별한 근거규정이 없이도 사전결정을 행할 수 있다.

04 효력(구속력)과 그 한계

1) 학설

- ① <구속력 긍정설>은 행정청은 최종행정결정에서 사전결정된 것은 그대로 인정하고, 사전결정되지 않은 부분만을 결정한다고 본다.
- ② <구속력 부정설>은 사전결정에 구속력을 인정하지 않고, 신뢰의 이익만을 인정하는 견해이다. 이 견해에 따르면 사정변경이 없는 경우에도 공익이 신뢰이익보다 큰 경우 사전결정에 배치되는 결정을 할 수 있는 것으로 본다.

2) 판례

판례는 사전결정의 구속력을 인정하지 않고, 사전결정시 재량권을 행사하였더라도 최종처분시 다시 재량권을 행사할 수 있다고 본다.

3) 검토

사전결정은 종국적 판단으로서 내려지는 결정이므로 구속력의 예외가 인정되는 경우를 제외하고는 후행 최종행정 결정에 대해 구속력을 미친다고 보아야 한다.

V 부분허가

01 의미

- ① 원자력발전소와 같이 그 건설에 비교적 장기간의 시간을 요하는 경우, 단계적으로 시설의 일부분에 대하여 부여하는 허가를 의미한다.
- ② 시설물 중 일부의 건설 및 운전에 대하여 **확정적인 허가**를 발급하는 것으로 부분허가가 수차례에 걸쳐 이루어짐으로써 시설 전체의 건설이 완성되어 운전에 이르게 되는 방식을 말한다.

02 법적근거

부분허가처분권은 허가처분권에 포함되는 것이므로 허가에 법적근거가 있으면 부분허가는 별도의 법적 근거가 필요 없다.

03 법적성질

- ① 부분허가는 그 자체가 규율하는 내용에 대한 종국적 결정인 행정행위이다.
- ② 따라서 선행 부분허가는 후속하는 최종적 결정에 구속력을 미친다.

I

행정계획 개관

CASE

【문제 1】甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2001년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

- 1) 甲은 乙이 2010년 3월 그의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정한 것은 신뢰보호의 원칙에 위배될 뿐만 아니라, 당해 토지 일대의 이용상황을 고려하지 아니한 결정이었다고 주장하며, 녹지지역 지정을 해제할 것을 요구하고자 한다. 甲의 주장이 법적으로 관철될 수 있는가에 대하여 논하시오. (24회 1번 변형)

01 행정계획의 의미

행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현하기 위한 활동기준으로 설정된 것이다. (판례)

02 종류

1) 구속적 행정계획

- ① 대외적으로 국민에 대하여 일정한 법적 효과를 발생시키는 행정계획을 말한다.
- ② 예를 들어, 도시·군관리계획이 결정·고시되어 효력을 발생하면 당해 계획으로 정하여진 용도지역·용도지구 및 용도구역 안에서의 건축이 제한된다.

2) 비구속적 행정계획

행정기관의 내부지침에 불과하여 국민이나 행정기관 어느 쪽에도 구속력을 갖지 않는 행정계획을 말한다.

(예 도시기본계획)

03 법적 성질

1) 학설

- ① 행정계획은 일반적·추상적 규율로서 입법의 성질을 가진다고 보는 <입법행위설>.
- ② 특정인의 권리나 법률상 이익에 개별적이고 구체적인 변동을 초래하므로 행정행위의 성질을 가진다고 보는 <행정행위설>.
- ③ 행정계획은 그 종류가 다양하고 형태도 여러 가지이므로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 <개별검토설>.
- ④ 행정계획은 규범도 아니고 행정행위도 아닌 독자적인 성질을 가진다고 보는 <독자성설>이 있다.

2) 판례

- ① 행정조직 내부의 추상적인 계획에 불과하거나 행정활동의 지침으로서의 성격만을 가지는 비구속적 행정계획 또는 행정기관만에 대하여 구속력을 갖는 행정계획은 원칙상 처분성이 부정되지만, **국민에 대하여 구속력을 갖는 행정계획이 국민의 권리·의무에 구체적으로 직접 영향을 미친다면 처분성이 인정된다고 보고 있다.**
- ② 예를 들어, 도시·군기본계획에 대해서는 처분성을 부정하였으나, 도시·군관리계획과 주택재건축정비사업조합의 사업시행계획이나 관리처분계획의 처분성은 인정하였다.
- ③ 또한 최근 <4대강 살리기 마스터플랜>등은 4대강 살리기 사업의 기본방향을 제시하는 계획으로서, 행정처분에 해당하지 않는다고 하였다.

3) 검토

행정계획은 그 종류와 내용이 매우 다양하고 상이하므로, 행정계획의 법적 성질은 각 계획이 갖는 목적과 내용을 기준으로 개별적으로 검토하여야 할 것이다.

04 행정계획과 법률유보

1) 구속적 행정계획

구속적 행정계획은 개인의 권리상태에 영향을 줄 수 있기 때문에, 법적근거를 요한다.

2) 비구속적 행정계획

단순히 행정에 대한 지침과 국민에 대하여 정보를 제공하는데 그치기 때문에 법적근거는 필요하지 않다.

01 의미

- ① 계획재량이란 행정주체(계획청)가 행정계획의 수립·변경과정에서 갖게 되는 광범위한 형성의 자유를 의미한다.
- ② 계획재량은 행정목표의 설정이나 행정목표를 효과적으로 달성할 수 있는 수단의 선택 및 조정에 있어서 인정된다.

대법원 2000. 3. 23. 선고 98두2768 판결

행정계획이라 함은 행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 도시의 건설·정비·개량 등과 같은 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현하기 위한 활동기준으로 설정된 것으로서, 도시계획법 등 관계 법령에는 추상적인 행정목표와 절차만이 규정되어 있을 뿐 행정계획의 내용에 대하여는 별다른 규정을 두고 있지 아니하므로 행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가진다.

02 행정재량과의 구분

1) 학설

- ① 계획재량은 목적과 수단으로 구성되었으나 행정재량은 요건과 효과로 구성되어 양자는 규범구조가 서로 다르고, 계획재량에는 형량명령이라는 고유한 하자이론이 존재하여 질적 차이가 있다고 보는 <구별긍정설, 다수설>
- ② 규범구조의 차이는 본질적인 것이 아니고, 형량명령도 비례의 원칙의 내용에 해당하는 법원리라고 보아 질적 차이를 부정하고 양적 차이만을 인정하는 <구별부정설>이 있다.

2) 판례

- ① 종래에는 계획재량에 하자와 관련하여 재량권의 일탈·남용으로 사안을 해결하였는데,
- ② 최근에는 <형량하자>라는 용어를 사용하여 계획재량의 독자성을 나타내는 경향을 보이고 있다.

2005두1893 판결

행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가지는 것이지만, 행정주체가 가지는 이와 같은 형성의 자유는 무제한적인 것이 아니라 그 행정계획에 관련되는 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론이고 공익 상호간과 사익 상호간에도 정당하게 비교교량하여야 한다는 제한이 있으므로, 행정주체가 행정계획을 입안·결정함에 있어서 이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우에는 그 행정계획결정은 형량에 하자가 있어 위법하게 된다.

3) 검토

- ① 계획재량은 행정재량에 비해 비교적 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 보는 것이 일반적이다.
- ② 또한 양자는 규범구조 및 하자이론의 구성에 있어서 차이가 있기 때문에, 양자를 구별하는 것이 타당하다.

03 계획재량의 통제

1) 계획재량의 한계

- ① 행정계획을 수립함에 있어서는 계획청에게 계획재량이 인정되는데, 이러한 계획재량은 무제한적인 것이 아니라 일정한 한계를 가진다.
- ② 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며,
- ③ 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다.
- ④ 또한 필요한 수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다(형량명령).

2) 형량명령의 준수

- ① 형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙으로서 계획재량의 통제이론이다.
- ② 행정계획결정이 형량명령의 내용에 반하는 경우에는 형량하자가 있게 된다.
- ③ 형량하자가 발생한 경우 당해 행정계획은 위법하게 된다.

- 형량을 전혀 하지 않은 경우(형량의 해태)
- 형량의 대상에 마땅히 포함되어야 할 사항을 빠뜨린 경우(형량의 흠결)
- 관련된 공익과 사익의 가치를 잘못 평가한 경우(평가의 과오)
- 이익형량을 행하긴 하였으나 그것이 객관성·비례성을 결하는 경우(오형량)

[행정절차법] 제40조의4 (행정계획)

행정청은 행정청이 수립하는 계획 중 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 계획을 수립하거나 변경·폐지할 때에는 관련된 여러 이익을 정당하게 형량하여야 한다.

01 의미

- ① 계획보장청구권이란 기존 행정계획에 대한 관계 국민의 신뢰를 보호하기 위하여 관계 국민에 대하여 인정된 행정계획 주체에 대한 권리를 총칭하는 개념이다.
- ② 계획보장청구권은 단일한 청구권이 아니라 그 내용상 여러 가지 청구권을 포함하고 있다.

02 내용

1) 계획존속청구권

(1) 의미

계획존속청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지에 대해 계획의 존속을 주장하는 권리이다.

(2) 인정여부

- ① 계획의 존속을 청구하는 자의 개인적 이익이 계획법규에 의해 보호되고 있어야 하고, 행정청에게 **계획존속의무**가 있어야 한다.
- ② 계획의 변경 또는 폐지로 인한 이익보다 상대방의 신뢰보호의 이익이 더 커야 계획존속의무가 인정될 것이다.
- ③ 그러나 대부분 개인의 신뢰이익이 계획의 변경을 필요로 하는 공익보다 우월하다고 볼 수 없어 계획존속청구권은 인정되기 어렵다.

2) 계획이행청구권

(1) 의미

계획이행청구권이란 확정된 계획을 행정주체로 하여금 이행하도록 요구하는 권리를 말한다.

(2) 인정여부

- ① 계획의 이행을 청구하는 자의 개인적 이익이 계획법규에 의해 보호되고 있어야 하고, 행정청에게 계획이행의무가 있어야 한다.
- ② 그러나 대부분 계획이행으로 인한 이익이 계획을 이행하지 않음으로 인하여 달성되는 공익보다 크다고 보기 어려워 인정되기 어렵다.

3) 경과조치청구권

- ① 경과조치청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지로 인하여 불이익을 받는 것을 방지하기 위해 행정청에 경과조치나 적응조치를 요구할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 이는 명시적인 법률의 근거가 있는 경우에만 인정될 수 있다.

4) 손해전보청구권

계획보장청구권이 성립되면 피해를 입은 상대방은 계획의 변경이나 폐지로 인해 입은 피해의 보상을 청구할 수 있다.

IV

계획변경청구권

01 의미

계획이 확정된 후 사정변경 및 관련 개인의 권익침해 등을 이유로 하여 그 계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 의미한다.

02 인정여부

- ① 계획법규는 원칙상 공익의 보호를 목적으로 하는 것이며 사익의 보호를 목적으로 하지 않기 때문에, 이러한 계획변경청구권은 일반적으로 인정되지 않는다.
- ② 그러나, 예외적으로 법규상 또는 조리상 계획변경신청권이 인정되는 경우에는 해당 계획의 변경을 청구할 수 있을 것이다.

03 판례

- ① 판례는 과거 계획변경청구권을 일반적으로 인정하지 않았으나, 최근에는 긍정적인 입장을 취하고 있다.
- ② 폐기물처리사업계획의 적정통보를 받은 자의 국토이용계획변경신청(용도지역 변경)을 거부하는 것이 실질적으로 폐기물처리업 허가 자체를 거부하는 결과가 되는 경우, 예외적으로 그 신청인에게 법규상 또는 조리상 행정계획 변경을 신청할 권리를 인정하여 신청거부행위의 처분성을 긍정하였다.
- ③ 또한 도시계획구역 내 토지 등을 소유하고 있는 사람과 같이 도시계획 시설결정에 이해관계가 있는 주민으로서는 도시시설계획의 입안권자 내지 결정권자에게 도시시설계획의 입안 내지 변경을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있고, 이러한 신청에 대한 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 판시하였다.
(대판 2015. 3. 26. 2014두42742)

V

권리구제

01 항고소송

- ① 구속적 행정계획 중 행정계획으로 인하여 국민의 권리에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 처분성이 인정되어 항고소송을 제기할 수 있다.
- ② 다만, 본안판단에서 계획청에게는 폭넓은 재량이 인정되므로 행정계획의 위법성이 인정되기 어려울 것이다.

02 헌법소원

- ① 국민에게 구속력을 갖는 행정계획은 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 있다.
- ② 비구속적 행정계획은 원칙적으로 공권력의 행사에 해당하지 아니하나, 예외적으로 국민의 기본권에 직접적으로 영향을 끼치고 그대로 실시될 것이 틀림없을 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있다고 본다.

03 손해전보

- ① 위법한 행정계획으로 인하여 손해를 받은 자는 국가배상을 청구할 수 있을 것이다.
- ② 적법한 행정계획으로 특별한 희생을 받은 경우 손실보상을 청구할 수 있을 것이다.

CASE

A군의 군수(이하 'A군수')는 甲주식회사에게 「중소기업창업 지원법」 제33조 및 제35조에 따라 관할행정청과의 협의를 거쳐 산지전용허가 등이 의제되는 사업계획을 승인하였다. 산지전용허가가 의제되는 부지 인근에 거주하고 있는 주민乙은 해당 사업이 실시될 경우 산에서 내려오는 물의 흐름이 막혀 지반이 약한 부분에서 토사유출 및 산사태 위험이 있다며 해당 산지전용허가에 반대하고 있다.

관할행정청은 이후 「산지관리법」 제37조에 따라 재해위험지역 일체점검을 하던 중 甲의 시설공사장에서 토사유출로 인한 산사태 위험을 확인하고, 甲에게 통지된 관할행정청의 처분서에는 甲이 충분히 알 수 있도록 처분의 사유와 근거가 구체적으로 명시되지는 않았다. (총 50점)

1) 甲의 신청이 산지전용허가요건을 완비하지 못한 경우에도, A 군수가 사업계획승인을 할 수 있는지를 검토하시오. (15점) (2021년 5급 공채 기출)

01 의의 및 취지 (「행정기본법」 제24조)

- ① 하나의 인허가(주된 인허가)를 받으면 법률에서 정하는 바에 따라 그와 관련된 다른 인허가(관련 인허가)를 받은 것으로 보는 것을 말한다.
- ② 예를 들어 건축법 제11조 제5항 제9호에 따라서 건축허가를 받으면 도로법 제61조에 따른 도로의 점용 허가를 받은 것으로 본다고 규정하는데, 이와 같이 주된 인허가(건축허가)를 받으면 관련 인허가(도로점용허가)도 받은 것으로 보는 것을 인허가의제라 한다.
- ③ 무용한 행정절차의 반복을 피하고 절차를 간소화하여 신속하고 편리한 사무처리를 할 수 있도록 함에 그 취지가 있다.

[건축법] 제11조 (건축허가)

- ⑤ 제1항에 따른 건축허가를 받으면 다음 각 호의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2와 제14조에 따라 관련 법률의 인·허가등이나 허가 등을 받은 것으로 본다.
 1. 제20조 제3항에 따른 공사용 가설건축물의 축조신고
 2. 제83조에 따른 공작물의 축조신고
 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가
 4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조 제5항에 따른 시행자의 지정과 같은 법 제88조 제2항에 따른 실시계획의 인가
 5. 「산지관리법」 제14조와제15조에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고. 다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.
 6. 「사도법」 제4조에 따른 사도(私道)개설허가
 7. 「농지법」 제34조, 제35조및제43조에 따른 농지전용허가·신고 및 협의
 8. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조 제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결 허가
 9. 「도로법」 제61조에 따른 도로의 점용 허가

02 인허가 등의 신청

- ① 인허가의제를 받으려면 주된 인허가를 신청할 때 관련 인허가에 필요한 서류를 함께 제출하여야 한다.
- ② 다만, 불가피한 사유로 함께 제출할 수 없는 경우에는 주된 인허가 행정청이 별도로 정하는 기한까지 제출할 수 있다.

03 관련 인허가 행정청과 협의

[행정기본법] 제24조 (인허가의제의 기준)

- ③ 주된 인허가 행정청은 주된 인허가를 하기 전에 관련 인허가에 관하여 미리 관련 인허가 행정청과 협의하여야 한다.
- ④ 관련 인허가 행정청은 제3항에 따른 협의를 요청받으면 그 요청을 받은 날부터 20일 이내(제5항 단서에 따른 절차에 걸리는 기간은 제외한다)에 의견을 제출하여야 한다. 이 경우 전단에서 정한 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 의견을 제출하여야 하는 기간을 연장한 경우에는 그 연장한 기간을 말한다) 내에 협의 여부에 관하여 의견을 제출하지 아니하면 협의가 된 것으로 본다.

04 인허가의제의 요건

1) 절차적 요건

- ① 신청된 주된 인허가의 절차만 거치면 되고, 관련 인허가의 절차까지 거칠 필요는 없다.(절차집중공정)
- ② 예를 들어, 건축허가시 토지형질변경허가가 의제되는데, 이때 주된 인허가인 건축허가의 절차만 거치면 될 뿐, 관련 인허가인 형질변경허가의 절차는 별도로 거칠 필요가 없다.

[행정기본법] 제24조 (인허가의제의 기준)

- ⑤ 제3항에 따라 협의를 요청받은 관련 인허가 행정청은 해당 법령을 위반하여 협의에 응해서는 아니 된다.
다만, 관련 인허가에 필요한 심의, 의견 청취 등 절차에 관하여는 법률에 인허가의제 시에도 해당 절차를 거친다는 명시적인 규정이 있는 경우에만 이를 거친다.

2) 실체적 요건

- ① 주된 인허가의 요건 뿐만 아니라 관련 인허가의 요건도 갖추어야 한다.(실체집중부정)
- ② 주된 인허가의 요건을 갖추어도 관련 인허가의 요건을 갖추지 못하면 인허가가 거부된다.

05 인허가의 결정

- ① 주된 인허가기관에서 인허가 여부를 결정한다.
- ② 의제되는 인허가 중 일부에 대해서만 협의가 완료된 경우에도 신청인의 요청이 있으면 주된 인허가를 할 수 있고, 이 경우 협의가 완료된 일부 인허가만 의제된다.(부분 인허가의제)

06 인허가의제의 효과

- ① 협의가 완료된 인허가만이 의제된다.
- ② 관련 인허가의 효력은 주된 인허가 발급시점에 함께 발생한다.
- ③ 인허가의제의 효과는 주된 인허가의 해당 법률에 규정된 관련 인허가에 한정된다.

[행정기본법] 제25조 (인허가의제의 효과)

- ① 제24조 제3항 · 제4항에 따라 협의가 된 사항에 대해서는 주된 인허가를 받았을 때 관련 인허가를 받은 것으로 본다.
- ② 인허가의제의 효과는 주된 인허가의 해당 법률에 규정된 관련 인허가에 한정된다.

01 의미

공법상 계약이란 공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 복수당사자 사이의 서로 반대 방향의 의사표시의 합치에 의하여 성립되는 공법행위를 말한다.

02 구별개념

1) 사법상 계약과 구별

- ① 공법상 계약은 계약의 일방 당사자가 행정주체이며, 공법적 효과를 발생시키는 계약이다.
- ② 공법상 계약에 관한 소송은 공법상 당사자소송에 의한다.

2) 행정행위와의 구별

- ① 공법상 계약은 양 당사자의 합의에 의하여 성립되는 반면, 행정행위는 행정청에 의하여 일방적으로 결정된다.
- ② 공법상 계약은 비권력적 성질을 가지므로 행정행위에게 인정되는 공정력·자력집행력·존속력 등이 인정되지 않는다.

구 분	행정행위	공법상 계약
처분성	○	×
분쟁해결절차	항고소송	당사자소송, 민사상 손해배상
위법한 경우	무효와 취소 모두 가능	무효만 가능 (취소는 법률에 규정이 있는 경우에만 가능)
법률유보	○	×
법률우위	○	○
공정력·불가쟁력·불가변력	○	×
행정청의 강제집행	○	×
행정주체의 우월성	○	×

03 공법상 계약의 종류

1) 행정주체 상호간의 공법상 계약(예시)

- ① 지방자치단체 간의 교육사무위탁
- ② 지방자치단체 간의 도로·하천의 경비분담 협의

2) 행정주체와 사인 간의 공법상 계약(예시)

- ① 공공용도의 기부채납
- ② 전문직 공무원 채용계약
- ③ 시립무용단원 위촉계약

3) 사인 상호간의 공법상 계약

- ① 행정주체로부터 그 사무를 위임받은 공무수탁사인이 행정의 상대방인 사인과 체결하는 계약을 말한다.
- ② 사례 : 토지보상법상 사업시행자와 토지소유자 사이의 협의취득계약

04 공법상 계약의 성립요건과 적법요건

1) 성립요건

- ① 공법상 계약은 사법상의 계약과 마찬가지로 양 당사자의 청약과 승낙이라는 의사표시의 합치에 의해 성립된다.
- ② 공법상 계약에서 계약당사자의 일방은 행정주체이어야 하며, 행정주체에는 공무수탁사인도 포함된다.

2) 적법요건

(1) 주체에 관한 요건

- ① 행정주체가 공법상 계약의 주체가 된다.
- ② 그런데 행정기본법은 행정청을 공법상 계약의 당사자로 규정하고 있다.
- ③ 이것은 행정청이 행정주체를 대표하여 공법상 계약을 체결하는 것으로 보아야 한다.

(2) 내용에 관한 요건

- ① 공법상 계약도 공행정작용이므로 법률우위의 원칙이 적용된다.
- ② 따라서 헌법을 포함한 행정법의 일반원칙에 위배되어서는 안된다.

(3) 형식에 관한 요건

계약의 목적 및 내용을 명확하게 적은 계약서를 작성하여야 한다.(문서)

(4) 절차에 관한 요건

- ① 공법상 계약의 절차를 일반적으로 규율하는 법령은 존재하지 않는다.
- ② 공법상 계약에는 행정절차법이 적용되지 않는다.

[행정기본법] 제27조 (공법상 계약의 체결)

- ① 행정청은 법령등을 위반하지 아니하는 범위에서 행정목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 공법상 법률관계에 관한 계약(이하 “공법상 계약”이라 한다)을 체결할 수 있다. 이 경우 계약의 목적 및 내용을 명확하게 적은 계약서를 작성하여야 한다.
- ② 행정청은 공법상 계약의 상대방을 선정하고 계약 내용을 정할 때 공법상 계약의 공공성과 제3자의 이해관계를 고려하여야 한다.

05 하자있는 공법상 계약의 효과

공법상 계약은 행정행위와 달리 공정력이 인정되지 않으므로 취소는 존재할 수 없고, **무효**만이 존재한다는 견해가 다수설이다.

06 쟁송절차

1) 공법상 당사자소송

공법상 계약에 관한 소송은 민사소송이 아니라 공법상 당사자소송에 의한다.

2) 국가배상소송

- ① 공법상 계약에 따른 의무의 불이행 또는 공법상 계약의 체결 및 집행상의 불법행위로 인한 손해에 대한 국가배상청구는 공법상 당사자소송에 의하는 것이 이론상 타당하다.
- ② 그러나 실무상으로는 이를 민사소송으로 해결하고 있다.

01 의미

사실행위란 일정한 법적 효과의 발생을 직접적 목적으로 하는 행위가 아니라, 일정한 사실상의 결과발생만을 목적으로 하는 행정주체의 일체의 행위를 말한다.

02 사실행위의 종류

1) 권력적 사실행위

- ① 행정주체가 우월적 지위를 가지고 하는 사실행위로, **공권력 행사**의 실체를 가지는 사실행위를 말한다.
- ② 사례 : 행정대집행의 실행, 행정상 즉시강제, 권력적 행정조사 등

2) 비권력적 사실행위

- ① 공권력 행사의 실체를 갖지 않는 사실행위를 말한다.
- ② 사례 : 상담, 안내, 행정지도, 여론조사 등

03 권리구제

1) 항고쟁송

(1) 비권력적 사실행위

처분성이 결여되어 원칙적으로 항고쟁송의 대상이 되지 않는다.

(2) 권력적 사실행위

- ① 권력적 사실행위는 일반적으로 처분성이 인정된다고 본다.
- ② 그러나 권력적 사실행위의 대부분은 단기간에 집행이 종료되는 경우가 보통이므로 행정쟁송이 제기되더라도 권리보호의 필요(협약의 소익)이 결여되어 각하재결이나 각하판결을 받게 될 가능성이 높다.
- ③ 반면, 계속적 성질을 갖는 권력적 사실행위(예 전염병 환자의 강제격리)는 권리보호의 필요가 인정되면 본안판단에서 위법성여부에 대한 판단이 가능할 것이다.
- ④ 판례 : 계속적 성질을 갖는 권력적 사실행위로 볼 수 있는 단수조치, 교도소 재소자의 이송조치 등에 대해서 처분성을 인정하였다.

2) 헌법소원

(1) 비권력적 사실행위

- ① 비권력적 사실행위는 공권력의 행사에 해당하지 않아 원칙적으로 헌법소원제기가 불가하다.
- ② 다만, 예외적으로 비권력적 사실행위가 국민의 기본권에 직접 영향을 미치는 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있을 것이다.

(2) 권력적 사실행위

현재는 권력적 사실행위의 처분성을 인정하면서도 권력적 사실행위가 소의 이익이 없어 법원에 의한 구제를 받을 수 없을 경우 보충성 원칙에 대한 예외에 해당하여 헌법소원의 대상이 된다고 보고 있다.

04 행정상의 손해전보와 결과제거청구

1) 손해배상청구

위법한 사실행위로 인하여 손해가 발생한 경우 국가배상청구가 가능하다.

2) 결과제거청구

행정상 사실행위로 위법한 상태가 초래되어 권리가 침해되는 경우에는 행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 당사자소송에 의해 결과제거청구를 할 수 있다.

3) 손실보상청구

적법한 사실행위로 인하여 개인의 재산권에 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상을 청구할 수 있다.

01 의미

행정기관이 그 소관 사무의 범위에서 일정한 행정목적을 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 아니하도록 지도, 권고, 조언 등을 하는 행정작용을 말한다.(행정절차법 제2조 제3호)

02 법적성질

행정지도는 일정한 법적 효과의 발생을 목적으로 하는 의사표시가 아니라 상대방인 국민의 임의적 협력을 전제로 하는 비권력적 사실행위이다.

03 행정지도의 원칙

1) 비례의 원칙

행정지도는 그 목적 달성에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

2) 부당강요금지의 원칙

행정지도는 상대방의 의사에 반하여 부당하게 강요해서는 아니 된다.

3) 불이익조치금지의 원칙

행정기관은 행정지도의 상대방이 행정지도에 따르지 아니하였다는 것을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 안된다.

04 행정지도의 방식

1) 명확성의 원칙과 실명제

행정지도를 하는 자는 그 상대방에게 그 행정지도의 취지 및 내용과 신분을 밝혀야 한다.

2) 서면교부청구권

행정지도의 형식은 따로 정해진 것이 없으나, 그 상대방이 행정지도의 취지 및 내용과 신분에 관한 사항을 적은 서면의 교부를 요구하면 이를 교부하여야 한다.

1) 행정쟁송

행정지도는 비권력적 사실행위에 지나지 않기 때문에 일반적으로 처분성이 인정되지 않는다.

2) 헌법소원

- ① 행정지도는 공권력의 행사에 해당하지 않아 헌법소원 제기가 불가하다.
- ② 그러나 예외적으로 행정지도가 상대방에게 **사실상 강제적 효과**를 발생하는 경우에는 헌법소원의 대상이 될 수 있을 것이다.

3) 국가배상청구

- ① 위법한 행정지도로 손해를 입은 국민은 국가배상을 청구할 수 있다.
- ② 다만 행정지도는 상대방의 임의적인 동의나 협력을 전제로 하는 것이므로 행정지도와 손해발생 사이에 인과관계가 인정되기 어려울 것이다.
- ③ 그러나 예외적으로 행정지도가 사실상 강제력을 갖는 경우에는 인과관계가 인정될 수 있을 것이다.

4) 손실보상

- ① 행정지도는 상대방의 임의적 협력을 전제로 하기 때문에, 원칙적으로 손실보상이 어렵다.
- ② 그러나 예외적으로 행정지도의 사실상 강제로 인하여 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상청구가 가능할 것이다.

PART 03

행정절차와 실효성 확보수단

Chapter 01 행정절차

Chapter 02 행정의 실효성 확보수단

제1절

행정절차 일반론

01 개념

(협의의) 행정절차란 행정청이 행정작용을 할 때 대외적으로 거쳐야 하는 사전절차를 의미한다.

02 법적 근거

1) 헌법적 근거

- ① <적법절차의 원칙>이라 함은 국가권력이 개인의 권익을 제한하는 경우에는 개인의 권익을 보호하기 위한 적절한 절차를 거쳐야 하는 원칙을 말한다.
- ② 헌법 제12조 제1항에서 규정하고 있는 적법절차의 원칙은 형사소송절차에 국한되지 아니하고 **모든 국가작용 전반에 대하여 적용된다.**

[헌법] 제12조

- ① 모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포 · 구속 · 압수 · 수색 또는 심문을 받지 아니하며, 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌 · 보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다.

2) 법령상 근거

행정절차법 제3조 제1항에서 <행정절차에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다>고 규정하고 있어 행정절차법은 행정절차에 관한 **일반법적 지위**를 갖는다.

[행정절차법] 제3조 (적용범위)

- ① 처분, 신고, 확약, 위반사실 등의 공표, 행정계획, 행정상 입법예고, 행정예고 및 행정지도의 절차(이하 “행정절차”라 한다)에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

03 행정절차법의 구성

- 1) **처분의 공통절차** : 처분기준의 설정·공표, **처분이유의 제시**, 처분의 방식, 처분의 정정 및 불복의 고지 등에 관한 규정
- 2) **수익적 처분의 절차** : 처분의 신청, 처분의 처리기간 등
- 3) **침익적 처분의 절차** : **사전통지**, **의견청취절차**

I 처분기준의 설정·공표

01 의의 및 취지

처분기준의 설정·공표는 행정청의 자의적인 권한행사를 방지하고 행정의 통일성을 기하며, 처분의 상대방에게 예측 가능성을 부여하기 위하여 요청된다.

02 처분기준의 설정·공표의무

- ① 행정청은 필요한 처분기준을 해당 처분의 성질에 비추어 되도록 구체적으로 정하여 공표하여야 한다. 처분기준을 변경하는 경우에도 또한 같다.
- ② 행정청이 처분기준을 미리 공표하지 아니한 기준을 적용하여 처분을 하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 해당 처분에 취소사유에 이를 정도의 흠이 존재한다고 볼 수는 없다.

II 이유제시 [★★★★]

CASE

국토교통부장관 乙이 감정평가사 甲의 등록을 거부하는 처분을 하면서 행정절차법상 이유제시를 하지 않은 경우, 이는 절차상 하자에 해당하는지 설명하시오.

01 의의

이유제시란 행정청이 처분을 할 때에 당사자에게 그 근거와 이유를 알려주는 것을 말한다.

02 기능

이유제시는 행정이 보다 신중하고 공정하게 행해지도록 하기 위한 것이고, 다른 한편으로는 상대방에게 쟁송제기 여부의 판단 및 쟁송준비에 편의를 제공하기 위한 것이다.

03 이유제시 생략사유

[행정절차법] 제23조 (처분의 이유 제시) [그명간]

- ① 행정청은 처분을 할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.
 1. 신청 내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우
 2. 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우
 3. 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
- ② 행정청은 제1항 제2호 및 제3호의 경우에 처분 후 당사자가 요청하는 경우에는 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

04 이유제시의 정도

- ① 이유제시는 당사자가 당해 처분의 근거법령과 처분사유를 이해할 수 있을 정도로 구체적이고 상세하게 적시되어야 한다.
- ② 면허취소와 같은 적극적 처분의 경우에는 처분의 법률적 근거와 사실상의 이유를 상대방이 이해할 수 있을 정도로 구체적이고 명확하게 제시할 것이 요구된다.
- ③ 반면, 인허가 등을 거부하는 소극적 처분의 경우에는 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우라면, 구체적인 법조항 및 내용까지 명시하지 않더라도 위법하지 않다는 것이 판례의 입장이다.

대법원 2002. 5. 17. 선고 2000두8912 판결

행정절차법 제23조 제1항은 행정청은 처분을 하는 때에는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다고 규정하고 있는바, 일반적으로 당사자가 근거규정 등을 명시하여 신청하는 인허가 등을 거부하는 처분을 함에 있어 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우에는 당해 처분의 근거 및 이유를 구체적 조항 및 내용까지 명시하지 않았더라도 그로 말미암아 그 처분이 위법한 것이 된다고 할 수 없다.

대법원 2013. 11. 14. 선고 2011두18571 판결

행정절차법 제23조 제1항은 행정청이 처분을 하는 때에는 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하도록 규정하고 있고, 이는 행정청의 자의적 결정을 배제하고 당사자로 하여금 행정구제절차에서 적절히 대처할 수 있도록 하는 데 그 취지가 있다. 따라서 처분서에 기재된 내용과 관계 법령 및 당해 처분에 이르기까지 전체적인 과정 등을 종합적으로 고려하여, 처분 당시 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있어서 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데에 별다른 지장이 없었던 것으로 인정되는 경우에는 처분서에 처분의 근거와 이유가 구체적으로 명시되어 있지 않았다고 하더라도 그로 말미암아 그 처분이 위법한 것으로 된다고 할 수는 없다.

05 이유제시의 방식 및 시기

이유제시의 방식도 원칙적으로 문서로서 **처분시**에 이루어져야 한다.

06 이유제시의 하자과 치유

1) 이유제시의 하자

행정처분의 이유제시가 없거나, 불충분한 이유제시가 있는 경우를 말하며, 취소사유에 해당한다.

2) 하자의 치유

〈하자의 치유〉부분 참고

Ⅲ 처분의 정정 및 불복의 고지

01 처분의 정정

[행정절차법] 제25조 (처분의 정정)

행정청은 처분에 오기, 오산 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다.

02 불복의 고지

[행정절차법] 제26조 (고지)

행정청이 처분을 할 때에는 당사자에게 그 처분에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다.

01 처분의 신청

1) 신청의 방식

행정청에 처분을 구하는 신청은 **문서**로 해야 한다.(원칙)

2) 신청의 의사표시

신청의 의사표시는 명시적이고 확정적이어야 하므로, 신청에 앞서 허가 담당자에게 신청서의 검토를 요청한 것만으로는 신청이 있었다고 볼 수 없다.

02 신청의 접수 및 신청서의 보완

- ① 행정청은 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체없이 신청인에게 보완을 요구하여야 한다.
- ② 신청인은 처분이 있기 전에는 그 신청의 내용을 보완·변경하거나 취하할 수 있다.

03 신청의 처리

- ① 행정청은 신청인의 편의를 위하여 처분의 처리기간을 종류별로 미리 정하여 공표하여야 한다.
- ② 행정청이 정당한 처리기간 내에 처리하지 아니하였을 때에는 신청인은 해당 행정청 또는 그 감독 행정청에 신속한 처리를 요청할 수 있다.
- ③ 행정기관의 장은 접수된 민원에 대한 처리를 완료한 때에는 그 결과를 민원인에게 문서로 통지해야 한다.

I

사전 통지 [★★★★]

CASE

감정평가사 甲은 국토교통부장관에게 감정평가사 갱신등록을 신청하였으나 거부처분을 받았다. 그런데 甲은 갱신등록 거부처분에 앞서 거부사유, 법적 근거, 의견제출의 가능성 등에 대한 통지를 받지 못하였다. 이 경우, 해당 거부처분이 행정절차법상 사전통지 대상에 해당하는지 설명하시오.

01 의의 및 취지 (행정절차법 제21조)

- ① 사전통지란 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전에 통지하는 것을 말한다.(수익적 행정행위 X)
- ② 사전통지는 의견진술의 전치절차로서, 당사자에게 불이익처분을 하기 전에 의견제출의 기회를 주려는데 의의가 있다.

[행정절차법] 제21조 (처분의 사전 통지)

- ① 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 다음 각 호의 사항을 당사자 등에게 통지하여야 한다.
 1. 처분의 제목
 2. 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
 3. 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거
 4. 제3호에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
 5. 의견제출기관의 명칭과 주소
 6. 의견제출기한
 7. 그 밖에 필요한 사항

02 생략사유 (「행정절차법」 제21조 제4항) [긴객곤]

[행정절차법] 제21조 (처분의 사전 통지)

- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 통지를 하지 아니할 수 있다.
 1. 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
 2. 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우
 3. 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우
- ⑤ 처분의 전제가 되는 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우 등 제4항에 따른 사전 통지를 하지 아니할 수 있는 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

03 사전통지기간

행정청은 의견제출의 준비에 필요한 기간을 10일 이상으로 주어 통지하여야 한다.(행정절차법 제21조 제3항)

04 사전통지의 상대방

- ① 행정절차법 제21조 제1항은 사전통지를 <당사자등>에게 하여야 한다고 규정하고 있다.
- ② <당사자등>이란 행정청의 처분에 대하여 직접 그 상대가 되는 당사자와 행정청이 직권 또는 신청에 따라 행정절차에 참여하게 한 이해관계인을 말한다.
- ③ 따라서 제3자호 행정행위에서 제3자는 행정절차법상 사전통지·의견제출의 대상이 되지 않는다.

05 거부처분의 사전통지 [★★]

1) 문제점

- ① 행정절차법 제21조 제1항에서는 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전통지를 하도록 규정하고 있다.
- ② 이에 사전통지의 적용 범위와 관련하여 수익적 행정처분의 신청을 거부하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인가가 문제 된다.

2) 학설

- ① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 그 거부하는 권익을 제한하는 처분이 아니므로 사전통지가 불필요하다고 보는 <부정설>.
- ② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부는 기대이익을 제한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <긍정설>
- ③ 원칙적으로는 부정하나, 인허가에 부가된 갱신기간의 경우는 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 것으로 보아 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그 거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

대법원 2003. 11. 28. 선고 2003두674 판결

신청에 따른 처분이 이루어지지 아니한 경우에는 아직 당사자에게 권익이 부과되지 아니하였으므로 특별한 사정이 없는 한 신청에 대한 거부처분이라고 하더라도 직접 당사자의 권익을 제한하는 것은 아니어서 신청에 대한 거부처분을 여기에서 말하는 '당사자의 권익을 제한하는 처분'에 해당한다고 할 수 없는 것이어서 처분의 사전통지대상이 된다고 할 수 없다.

4) 검토

- ① 원칙적으로 신청의 거부는 권익제한이 아니라고 판단된다.
- ② 다만, 인허가 갱신의 경우는 갱신에 의해 종전의 허가효과가 유지되는 바, 갱신신청의 거부는 권익 제한에 해당한다고 볼 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다고 본다.

II 의견청취(의견진술) [★★★★]

CASE

국토교통부장관 乙은 감정평가사 甲이 감정평가 수주의 대가로 금품을 제공한 사실을 이유로 감정평가법 제39조에 따라 자격취소(징계) 처분을 하였다. 그런데 감정평가법 제45조(청문)에 감정평가법 제39조에 따른 자격취소가 청문사유로 명확히 규정되어 있지 않다는 이유로 청문 절차를 생략한 경우, 이는 절차상 하자에 해당하는지 검토하시오. (33회 문3번)

「감정평가법」 제45조 (청문)

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

01 의의 및 취지 (「행정절차법」 제22조)

- ① 의견청취절차는 사전통지된 내용에 따라 행정처분의 상대방 또는 이해관계인에게 자신의 의견을 진술하며 스스로 방어할 수 있는 기회를 부여하는 절차를 말한다.
- ② 의견청취는 행정처분을 함에 있어 당사자의 절차적 참여를 보장하고, 의견제출의 기회를 부여하여 국민의 방어권을 보호함에 그 취지가 인정된다.

02 유형

1) 청문

행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자들의 **의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차**를 말한다.

2) 공청회

공청회란 행정청이 공개적인 토론을 통하여 어떠한 행정작용에 대하여 당사자등, 전문지식과 경험을 가진 사람, 그 밖의 일반인으로부터 의견을 널리 수렴하는 절차를 말한다.

[행정절차법] 제22조 (의견청취) [법광큰]

- ② 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공청회를 개최한다.
1. 다른 법령등에서 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우
 2. 해당 처분의 영향이 광범위하여 널리 의견을 수렴할 필요가 있다고 행정청이 인정하는 경우
 3. 국민생활에 큰 영향을 미치는 처분으로서 대통령령으로 정하는 처분에 대하여 대통령령으로 정하는 수 이상의 당사자등이 공청회 개최를 요구하는 경우

3) 의견제출

- ① 행정청이 어떠한 행정작용을 하기 전에 당사자등이 의견을 제시하는 절차로서 청문이나 공청회에 해당하지 아니하는 절차를 말한다.
- ② 불이익 처분시 관련 법령상 청문이나 공청회에 관한 규정이 없더라도 의견제출절차는 반드시 거쳐야 한다.

[행정절차법] 제22조 (의견청취)

- ③ 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 할 때 제1항 또는 제2항의 경우 외에는 당사자 등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다.

03 의견청취 생략사유

1) 행정절차법 규정

[행정절차법] 제22조 (의견청취)

- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 제21조 제4항(사전통지 생략사유, 긴급권) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 의견청취를 하지 아니할 수 있다.

2) 관련 판례

- ① 처분의 성질에 비추어 판단

대법원 2016. 10. 27. 선고 2016두41811 판결

‘의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우’에 해당하는지는 해당 행정처분의 성질에 비추어 판단하여야 하며, 처분상대방이 이미 행정청에 위반사실을 시인하였다거나 처분의 사전통지 이전에 의견을 진술할 기회가 있었다는 사정을 고려하여 판단할 것은 아니다.

- ② 청문을 실시하지 않으면 위법

대법원 2001. 4. 13. 선고 2003두3337 판결

행정처분의 상대방이 통지된 청문일시에 불출석하였다는 이유만으로 행정청이 관계 법령상 그 실시가 요구되는 청문을 실시하지 아니한 채 침해적 행정처분을 할 수는 없을 것이므로, 행정처분의 상대방에 대한 청문통지서가 반송되었다거나, 행정처분의 상대방이 청문일시에 불출석하였다는 이유로 청문을 실시하지 아니하고 한 침해적 행정처분은 위법하다.

③ 협약으로 의견청취절차 배제 불가

대법원 2004. 7. 8. 선고 2002두8350 판결

행정청이 당사자와 사이에 도시계획사업의 시행과 관련한 **협약을 체결하면서** 관계 법령 및 행정절차법에 규정된 청문의 실시 등 **의견청취절차를 배제하는 조항을 두었다고 하더라도**, 국민의 행정참여를 도모함으로써 행정의 공정성·투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호한다는 행정절차법의 목적 및 청문제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 위와 같은 협약의 체결로 청문의 실시에 관한 규정의 적용을 배제할 수 있다고 볼 만한 법령상의 규정이 없는 한, 이러한 협약이 체결되었다고 하여 청문의 실시에 관한 규정의 적용이 배제된다거나 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당한다고 할 수 없다.

04 청문절차

1) 청문의 실시요건

[행정절차법] 제22조 (의견청취) **[법필취]**

① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.

1. 다른 **법령** 등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
2. 행정청이 **필요**하다고 인정하는 경우
3. 다음 각 목의 처분을 하는 경우
 - 가. 인허가 등의 **취소**
 - 나. 신분·자격의 박탈
 - 다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소

2) 청문의 사전통지

행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 **10일 전까지** 제1항 각 호의 사항(처분의 사전통지)을 당사자등에게 통지하여야 한다.

3) 청문의 진행

[행정절차법] 제31조 (청문의 진행)

- ① 청문 주재자가 청문을 시작할 때에는 먼저 예정된 처분의 내용, 그 원인이 되는 사실 및 법적 근거 등을 설명하여야 한다.
- ② 당사자등은 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있으며, 참고인이나 감정인 등에게 질문할 수 있다.
- ③ 당사자등이 의견서를 제출한 경우에는 그 내용을 출석하여 진술한 것으로 본다.
- ④ 청문 주재자는 청문의 신속한 진행과 질서유지를 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.

4) 청문의 종결

[행정절차법] 제35조 (청문의 종결)

- ① 청문 주재자는 해당 사건에 대하여 당사자등의 의견진술, 증거조사가 충분히 이루어졌다고 인정하는 경우에는 청문을 마칠 수 있다.
- ② 청문 주재자는 당사자등의 전부 또는 일부가 **정당한 사유 없이** 청문기일에 출석하지 아니하거나 제31조 제3항에 따른 의견서를 제출하지 아니한 경우에는 이들에게 다시 의견진술 및 증거제출의 기회를 주지 아니하고 청문을 마칠 수 있다.
- ③ 청문 주재자는 당사자등의 전부 또는 일부가 **정당한 사유로** 청문기일에 출석하지 못하거나 제31조 제3항에 따른 의견서를 제출하지 못한 경우에는 10일 이상의 기간을 정하여 이들에게 의견진술 및 증거제출을 요구하여야 하며, 해당 기간이 지났을 때에 청문을 마칠 수 있다.

5) 청문결과의 반영

[행정절차법] 제35조의2 (청문결과의 반영)

행정청은 처분을 할 때에 제35조 제4항에 따라 받은 청문조서, 청문 주재자의 의견서, 그 밖의 관계 서류 등을 충분히 검토하고 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 청문결과를 반영하여야 한다.

01 문제점

실체법상 적법함에도 불구하고 절차상 하자를 독자적 위법사유로 삼을 수 있는지 문제된다.

02 학설

- ① 적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 **기속력**을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 <긍정설>
- ② 행정절차는 적정한 행정결정을 위한 수단에 불과하고, 절차상 하자를 이유로 취소하더라도 행정청을 그 적정한 절차를 거쳐 동일한 처분을 할 수 있으므로 소송경제상 부정하는 <부정설>
- ③ 재량행위는 적법절차를 거쳤을 때, 행정청이 다른 내용의 처분을 할 수도 있으므로 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법한 것은 아니라고 보는 <절충설>이 있다.

03 판례

- ① 판례는 재량행위나 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자를 독자적 취소사유로 보는 **긍정설**의 입장이다.
- ② 재량행위인 식품위생법상 영업정지처분에 절차상 하자가 있는 경우 위법하다고 판시하였다.
- ③ **기속행위**인 과세처분 또한 절차상 하자가 있으면 위법하다고 판시하였다.

04 검토

- ① 행정작용은 법률적합성의 원칙에 따라 그 내용(실체)뿐 아니라 절차도 적법하여야 한다.
- ② 또한, 행정소송법 제30조 제3항에서 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 판례와 같이 긍정설이 타당하다.

[행정소송법] 제30조 (취소판결등의 기속력)

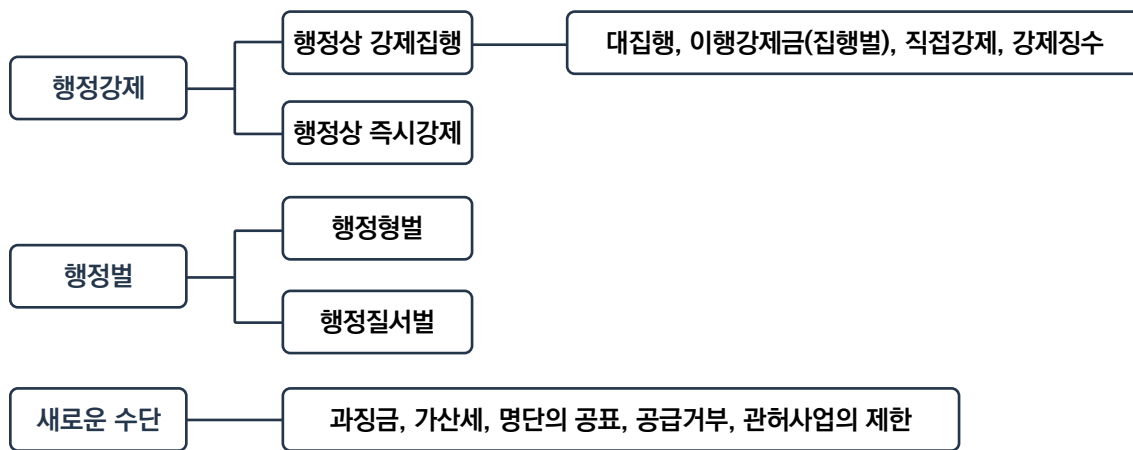
- ③ 제2항의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다.

제1절

행정강제

01 개념

- ① 행정청이 공익을 목적으로 국민에게 작위·부작위 등 의무를 부과하였으나, 이를 이행하지 않는 경우 행정청이 행정목적 달성을 위하여 취하는 여러 가지 법적 수단을 행정의 실효성 확보수단이라고 한다.
- ② 그 중 행정강제란 행정목적 실현하기 위하여 개인의 신체 또는 재산에 실력을 가함으로써 행정권이 직접 행정상 필요한 상태를 실현하는 권력적 행위이다.



[행정기본법] 제30조 (행정상 강제)

- ① 행정청은 행정목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 법률로 정하는 바에 따라 필요한 최소한의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.
1. 행정대집행 : 의무자가 행정상 의무(법령등에서 직접 부과하거나 행정청이 법령등에 따라 부과한 의무를 말한다. 이하 이 절에서 같다)로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 의무를 이행하지 아니하는 경우 법률로 정하는 다른 수단으로는 그 이행을 확보하기 곤란하고 그 불이행을 방지하면 공익을 크게 해칠 것으로 인정될 때에 행정청이 의무자가 하여야 할 행위를 스스로 하거나 제3자에게 하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것
 2. 이행강제금의 부과 : 의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 적절한 이행기간을 부여하고, 그 기간까지 행정상 의무를 이행하지 아니하면 금전급부 의무를 부과하는 것
 3. 직접강제 : 의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 신체나 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하는 것
 4. 강제징수 : 의무자가 행정상 의무 중 금전급부 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무가 실현된 것과 같은 상태를 실현하는 것
 5. 즉시강제 : 현재의 급박한 행정상의 장애를 제거하기 위한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 행정청이 곧바로 국민의 신체 또는 재산에 실력을 행사하여 행정목적 달성을 하는 것

02 행정상 강제집행

1) 의의

행정법상의 의무불이행이 있는 경우에 행정기관이 의무자의 신체 또는 재산에 실력을 가하여 장래를 향하여 그 의무를 이행하게 하거나 이행된 것과 같은 상태를 실현하는 행정작용을 말한다.

2) 구별개념

(1) 행정상 즉시강제와의 구별

행정상 강제집행은 의무의 존재 및 그 불이행을 전제로 하는 점에서 이를 전제로 하지 않고 즉시 행해지는 행정상 즉시강제와 구별된다.

(2) 행정벌과의 구별

행정상 강제집행은 불이행한 의무를 장래를 향해 실현시키는 것을 목적으로 한다는 점에서 과거의 의무위반에 대한 제재로서 가하는 행정벌과 구별된다.

3) 행정대집행(별도 서술)

4) 이행강제금

(1) 의의

- ① 의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 적절한 이행기간을 부여하고, 그 기한까지 행정상 의무를 이행하지 아니하면 금전금부 의무를 부과하는 것을 말한다.
- ② 집행벌이라고도 한다.

(2) 대집행과의 관계

- ① 대체적 작위의무의 불이행에 대하여 대집행이라는 수단이 있음에도 불구하고, 이행강제금을 부과할 수 있는지가 문제된다.
- ② 대집행에 많은 비용이 들거나 전문적인 기술이 필요한 경우, 의무자에게 금전적인 제재를 가하는 이행강제금이 효과적인 강제수단이 될 수 있다.
- ③ 이에 관한 판례는 없으나, 헌법재판소는 대체적 작위의무의 위반이 있는 경우 행정청은 대집행과 이행강제금을 합리적 재량에 의해 선택적으로 활용할 수 있다는 입장이다.

(3) 행정벌과의 관계

- ① 이행강제금은 장래를 향하여 의무이행을 확보하는 수단이라는 점에서 과거의 의무불이행에 대한 제재인 행정벌과는 구분된다.
- ② 따라서 이행강제금은 과태료나 벌금과 같은 행정벌과 병과될 수 있다.

5) 직접강제

(1) 의의

의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 신체나 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하는 것이다.

(2) 사례

영업장의 폐쇄, 외국인의 강제퇴거, 실력에 의한 예방접종, 강제해산 등

(3) 대집행과의 구별

- ① 대집행은 대체적 작위의무에 대한 강제수단인 반면, 직접강제는 일체의 의무불이행에 대해 가능하다.
- ② 직접강제는 의무자에게 직접 물리력을 행사하는 점에서 그렇지 않은 대집행과 구별된다.
- ③ 건물인도(명도)는 직접강제를 통해 가능하고, 건물철거는 대집행을 통해 가능하다.

(4) 한계

강제집행 수단 중 가장 강력한 강제집행 수단이므로, 다른 방법으로 의무이행을 강제할 수 없을 때 최후의 수단으로 행사되어야 한다.

6) 강제징수

(1) 의의

의무자가 행정상 의무 중 금전금부 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무가 실현된 것과 같은 상태를 실현하는 것이다.

(2) 법적근거

[국세징수법]이 일반법적 지위를 가진다.

(3) 절차

독촉, 재산의 압류, 압류재산의 매각, 청산의 단계로 이루어진다.

※ 보충자료 - 내용정리

종 류	적용 가능한 의무	일반법
대집행	대체적 작위의무	행정대집행법
이행강제금	작위의무, 부작위의무, 수인의무	각 개별법
직접강제	작위의무, 부작위의무, 수인의무	각 개별법
강제징수	금전금부 의무	국세징수법

03 행정상 즉시강제

1) 의의

현재의 급박한 행정상의 장애를 제거하기 위한 경우에, 행정청이 곧바로 국민의 신체 또는 재산에 실력을 행사하여 행정목적의 달성을 꾀하는 것이다.

[행정기본법] 제30조 (행정상 강제)

5. 즉시강제 : 현재의 급박한 행정상의 장애를 제거하기 위한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 행정청이 곧바로 국민의 신체 또는 재산에 실력을 행사하여 행정목적의 달성을 꾀하는 것
- 가. 행정청이 미리 행정상 의무 이행을 명할 시간적 여유가 없는 경우
 - 나. 그 성질상 행정상 의무의 이행을 명하는 것만으로는 행정목적 달성이 곤란한 경우

2) 사례

주차위반 차량의 견인, 감염병 환자의 강제입원, 소방장애물의 제거 등

3) 구별개념

(1) 행정상 강제집행과의 구별

양자는 행정상 필요한 상태를 실현시키는 강제행위라는 점은 동일하나, 행정상 즉시강제는 선행하는 의무부과와 그 불이행을 전제로 하지 않는다는 점에서 행정상 강제집행과 구별된다.

(2) 행정벌과의 구별

행정상 즉시강제는 장래에 대하여 행정상 필요한 상태의 실현을 목적으로 하지만, 행정벌은 과거의 의무위반에 대해 가해지는 제재라는 점에서 구별된다.

CASE

A시는 시가지 철도이설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의 취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. (22회 문3)

01 의의 및 근거

- ① 공법상 대체적 작위의무(타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무)의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다.
- ② 대집행의 일반법으로 행정대집행법이 있으며 토지보상법 제89조에도 대집행에 대한 규정이 있다.

02 요건 (『행정대집행법』 제2조) [공대다방]

[행정대집행법] 제2조 (대집행과 그 비용징수)

법률(법률의 위임에 의한 명령, 지방자치단체의 조례를 포함한다. 이하 같다)에 의하여 직접명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 그 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

1) 공법상 의무의 불이행

- ① 대집행의 대상이 되는 의무는 공법상의 의무이다.
- ② 사법상의 의무는 법령에 특별한 규정이 없는 한 대집행의 대상이 되지 않는다.

대법원 2006. 10. 13. 선고, 2006두7096

토지 등의 협의취득은 공공사업에 필요한 토지 등을 그 소유자와의 협의에 의하여 취득하는 것으로서 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 매매 내지 사법상 계약의 실질을 가지는 것이므로, 그 협의취득시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다.

2) 대체적 작위의무의 불이행

- ① 대체적 작위의무란 누구나 이행이 가능하여 타인이 대신 행할 수 있는 의무를 말한다
- ② 토지·건물의 인도 의무에서 사람이 그 인도·이전을 거부한다면 이는 사람을 실력으로 배제해야 하는 것이므로 (대체적 작위의무가 아님) 대집행의 대상이 될 수 없다.

구 분	대체적 작위의무	비대체적 작위의무
개 념	타인이 대신 행할 수 있는 의무	타인이 대신 행할 수 없는 의무
사 례	건물의 철거의무, 토지형질의 원상회복의무 등	토지·건물의 인도(명도)의무, 국유지로부터 퇴거의무, 의사의 진료의무 등
해 결 방 안	대집행 가능	직접강제

대법원 1998. 10. 23. 선고 97누157

도시공원시설인 매점의 관리청이 그 공동점유자 중의 1인에 대하여 소정의 기간 내에 위 매점으로부터 퇴거하고 이에 부수하여 그 판매 시설물 및 상품을 반출하지 아니할 때에는 이를 대집행하겠다는 내용의 계고처분은 그 주된 목적이 매점의 원형을 보존하기 위하여 점유자가 설치한 불법 시설물을 철거하고자 하는 것이 아니라, **매점에 대한 점유자의 점유를 배제하고 그 점유이전을 받는 데 있다고 할 것인데**, 이러한 의무는 그것을 강제적으로 실현함에 있어 직접적인 실행행사가 필요한 것이지 **대체적 작위의무에 해당하는 것은 아니어서** 직접강제의 방법에 의하는 것은 별론으로 하고 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되는 것은 아니다.

3) 다른 수단으로 그 이행을 확보하기가 곤란할 것 (보충성)

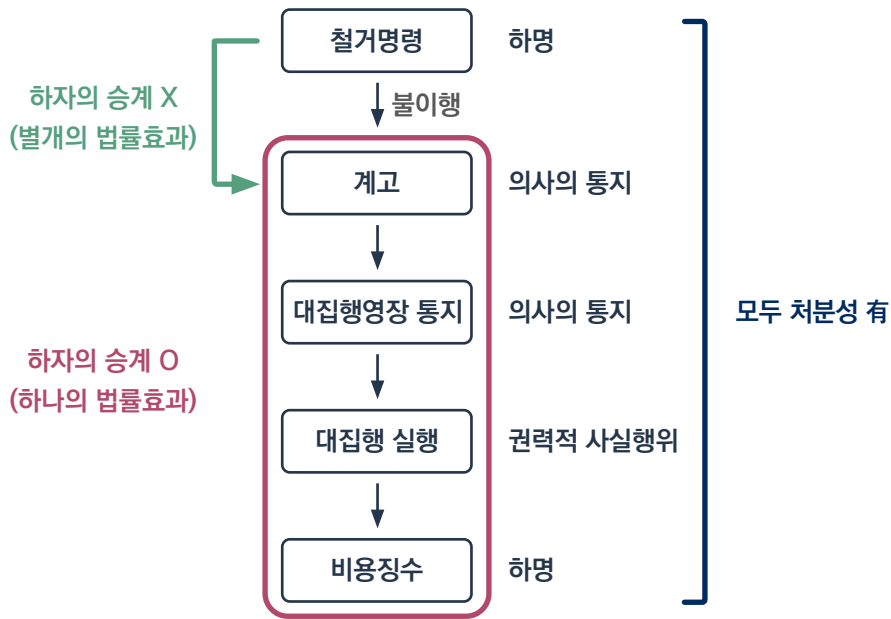
- ① 행정지도 등 의무이행을 확보할 수 있는 다른 수단이 있는 경우에는 대집행이 허용되지 않는다.
- ② 여기에서 다른 수단이란 비례의 원칙이 적용되는 것으로 대집행보다 경미한 수단을 의미한다.

4) 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것

- ① 이는 비례의 원칙 중 협의의 비례의 원칙을 의미하는 것으로, 구체적 상황 등을 고려하여 개별적으로 판단해야 한다.
- ② 이 요건에 대한 판단은 계고처분 당시를 기준으로 판단한다.

대법원 1983. 7. 12. 선고 83누150

철거계고처분을 받은 건물과 지방문화재인 용건능보호구역 경계사이에는 노폭 8m의 도로가 있고 위 건물을 그대로 두어도 용건능의 보존관리상 아무런 지장이 없으며 위 보호구역 내에는 다른 건물이 있는 것을 고려하면 위 건물에 대한 건축허가가 취소되었다는 사유만으로 위 건물을 방치함이 심히 공익을 해한다고 볼 수 없으므로 위 건물에 대한 계고처분은 위법하다.



1) 계고

(1) 의의 및 법적성질

- ① 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 한다는 뜻을 문서로써 알리는 행위를 말한다.
- ② 계고는 준법률행위적 행정행위로서 **통지**에 해당하며 항고소송의 대상이 된다.

[행정대집행법] 제3조 (대집행의 절차)

- ① 전조의 규정에 의한 처분(이하 대집행이라 한다)을 하려함에 있어서는 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 대집행을 한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.
이 경우 행정청은 상당한 이행기한을 정함에 있어 의무의 성질·내용 등을 고려하여 사회통념상 해당 의무를 이행하는 데 필요한 기간이 확보되도록 하여야 한다.
- ② 의무자가 전항의 계고를 받고 지정기한까지 그 의무를 이행하지 아니할 때에는 당해 행정청은 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행을 시키기 위하여 파견하는 집행책임자의 성명과 대집행에 요하는 비용의 개산에 의한 견적액을 의무자에게 통지하여야 한다.
- ③ 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 있어서 당해 행위의 급속한 실시를 요하여 전2항에 규정한 수속을 취할 여유가 없을 때에는 그 수속을 거치지 아니하고 대집행을 할 수 있다.

(2) 생략가능성 (「행정대집행법」 제3조 제3항)

비상시 또는 위험이 절박한 경우에 계고절차를 거치지 않고 대집행을 할 수 있다.

(3) 관련 판례

① 상당한 기간 위반한 계고처분은 위법

대법원 1990. 9. 14. 선고 90누2048

행정대집행법 제3조 제1항은 행정청이 의무자에게 대집행영장으로써 대집행할 시기 등을 통지하기 위하여는 그 전제로서 대집행계고처분을 함에 있어서 의무이행을 할 수 있는 상당한 기간을 부여할 것을 요구하고 있으므로, 행정청인 피고가 의무이행기한이 1988.5.24.까지로 된 이 사건 대집행계고서를 5.19. 원고에게 발송하여 원고가 그 이행종기인 5.24. 이를 수령하였다면, 설사 피고가 대집행영장으로써 대집행의 시기를 1988.5.27 15:00로 늦추었다하더라도 위 대집행계고처분은 상당한 이행기한을 정하여 한 것이 아니어서 대집행의 적법절차에 위배한 것으로 위법한 처분이라고 할 것이다.

판례는 상당한 기간을 부여하지 않은 경우 대집행영장으로 대집행의 시기를 늦추었다고 하더라도, 계고처분은 적법절차에 위배되어 위법하다고 보았다.

② 반복된 계고처분시 2·3차 계고의 처분성 부정

대법원 1994. 10. 28. 선고 94누5144

건물의 소유자에게 위법건축물을 일정기간까지 철거할 것을 명함과 아울러 불이행할 때에는 대집행한다는 내용의 철거대집행 계고처분을 고지한 후 이에 불응하자 다시 제2차, 제3차 계고서를 발송하여 일정기간까지의 자진철거를 촉구하고 불이행하면 대집행을 한다는 뜻을 고지하였다면 행정대집행법상의 건물철거의무는 제1차 철거명령 및 계고처분으로서 발생하였고 제2차, 제3차의 계고처분은 새로운 철거의무를 부과한 것이 아니고 다만 대집행기한의 연기통지에 불과하므로 행정처분이 아니다.

③ 철거명령과 계고처분의 결합 긍정

대법원 1992. 6. 12. 선고 91누13564

계고서라는 명칭의 1장의 문서로서 일정기간 내에 위법건축물의 자진철거를 명함과 동시에 그 소정기한내에 자진 철거를 하지 아니할 때에는 대집행할 뜻을 미리 계고한 경우라도 위 건축법에 의한 철거명령과 행정대집행법에 의한 계고처분은 독립하여 있는 것으로서 각 그 요건이 충족되었다고 볼 것이고, 이 경우 철거명령에서 주어진 일정기간이 자진철거에 필요한 상당한 기간이라면 그 기간속에는 계고시에 필요한 '상당한 이행기간'도 포함되어 있다고 보아야 할 것이다.

2) 대집행 영장에 의한 통지

(1) 의의 및 법적성질

- ① 의무자가 계고를 받고도 지정된 기한까지 그 의무를 이행하지 않을 때, 당해 행정청이 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행책임자의 성명 및 대집행비용의 개산액을 의무자에게 알리는 것을 말한다.
- ② 이는 준법률행위적 행정행위인 통지로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.

(2) 생략가능성 (「행정대집행법」 제3조 제3항)

계고와 마찬가지로 비상시 또는 위험이 절박한 경우에 통지 절차를 생략할 수 있다.

3) 대집행의 실행

(1) 의의 및 성질

- ① 의무자가 지정된 기한까지 의무를 이행하지 않는 경우에 당해 행정청 스스로 또는 제3자로 하여금 그 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다.
- ② 이는 수인하명(건물철거행위를 참고 받아 들어야 하는 의무를 부과)과 사실행위(철거행위)가 결합된 합성행위의 성질을 가지는 **권력적 사실행위**로서 행정처분에 해당한다.

[행정대집행법] 제4조 (대집행의 실행 등)

- ① 행정청(제2조에 따라 대집행을 실행하는 제3자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에는 대집행을 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 의무자가 동의한 경우
 2. 해가 지기 전에 대집행을 착수한 경우
 3. 해가 뜬 후부터 해가 지기 전까지 대집행을 하는 경우에는 대집행의 목적 달성이 불가능한 경우
 4. 그 밖에 비상사 또는 위험이 절박한 경우
- ② 행정청은 대집행을 할 때 대집행 과정에서의 안전 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 현장에 긴급 의료장비나 시설을 갖추는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 대집행을 하기 위하여 현장에 파견되는 집행책임자는 그가 집행책임자라는 것을 표시한 증표를 휴대하여 대집행시에 이해관계인에게 제시하여야 한다.

(2) 실행가능성

a. 문제점

대집행 실행에서 의무자가 수인의무(하명)를 위반하여 저항하는 경우 행정청이 실력으로 이를 배제할 수 있는지와 관련하여 명문의 규정이 없어 문제가 된다.

b. 학설

- ① 대집행에 필요한 최소한의 한도 내에서 부득이한 경우에 실력으로 그 저항을 배제할 수 있다고 보는 <긍정설>과
- ② 저항을 실력으로 배제하는 것은 대집행에 내재하는 당연한 권능으로 볼 수 없으므로 실행행사를 위해서는 법적 근거가 있어야 한다는 보는 <부정설>이 있다.

c. 판례

판례는 건물철거의무에 퇴거의무도 포함되어 있다고 보아 건물철거 대집행 과정에서 부수적으로 건물의 점유자들에 대한 퇴거 조치를 할 수 있고, 점유자들이 적법한 행정대집행을 위력으로 방해하는 경우 공무집행방해죄가 성립하므로 **경찰의 도움**을 받을 수 있다고 본다.

대법원 2017. 4. 28. 선고 2016다213916

건물의 점유자가 철거의무자일 때에는 건물철거의무에 퇴거의무도 포함되어 있는 것이어서 별도로 퇴거를 명하는 집행권원이 필요하지 않다. 따라서 행정청이 행정대집행의 방법으로 건물철거의무의 이행을 실현할 수 있는 경우에는 건물철거 대집행 과정에서 부수적으로 그 건물의 점유자들에 대한 퇴거 조치를 할 수 있는 것이고, 그 점유자들이 적법한 행정대집행을 위력을 행사하여 방해하는 경우 형법상 공무집행방해죄가 성립하므로, 필요한 경우에는 「경찰관 직무집행법」에 근거한 위험발생 방지조치 또는 형법상 공무집행방해죄의 범행방지 내지 현행범체포의 차원에서 경찰의 도움을 받을 수도 있다.

d. 검토

신체에 대한 실력행사는 명문에 근거가 있어야 하고, 경찰관직무집행법 등에 따른 경찰권의 발동으로 저항이 배제될 수 있으므로 <부정설>이 타당하다.

4) 비용징수

- ① 대집행에 소요된 비용을 의무자에게 명령하여 징수하는 절차이다.
- ② 비용납부명령은 급부하명이며 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 된다.
- ③ 의무자가 비용을 납부하지 않는 경우에는 국세징수법에 따라 강제징수 할 수 있다.

[행정대집행법] 제6조 (비용징수)

- ① 대집행에 요한 비용은 국세징수법의 예에 의하여 징수할 수 있다.
- ② 대집행에 요한 비용에 대하여서는 행정청은 사무비의 소속에 따라 국세에 다음가는 순위의 선취특권을 가진다.
- ③ 대집행에 요한 비용을 징수하였을 때에는 그 징수금은 사무비의 소속에 따라 국고 또는 지방자치단체의 수입으로 한다.

04 대집행에 대한 권리구제

1) 행정쟁송

- ① 대집행의 절차상 모든 행위는 처분성이 인정되므로, 행정심판 또는 행정소송의 제기가 가능하다.
- ② 다만, 대집행 실행이 완료된 경우에는 소의 이익이 없어 항고소송을 제기할 수 없으므로, 항고소송을 제기하면서 집행정지를 신청하여 대집행의 실행을 정지시킬 필요가 있다.

대법원 1967. 10. 23. 선고 67누115

행정대집행법 제2조에 의하여 의무자에게 명령된 행위에 관하여, 동법 제3조의 계고와 대집행영장에 의한 통지 절차를 거쳐서 이미 그 대집행이 사실행위로서 실행이 완료된 이후에 있어서는 그 행위의 위법을 이유로 하는 손해배상 또는 원상회복의 청구를 하는 것은 몰라도, 그 처분의 취소를 구함은, 권리보호의 이익이 없는 것이라 할 것인바, ... (중략) ...

대집행 실행에 의하여 철거되었음에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없는바이니, 앞서 설명한 바에 의하여 본건 계고처분의 취소를 구할 권리보호의 이익은 이미 상실되었다고 할 것이어서 본건 소송은 결국 소송요건 흠결로 인하여 소 각하를 면할 수 없을 것이다.

2) 손해배상 및 결과제거청구

- ① 위법한 대집행에 의하여 손해를 입은 자는 국가나 지방자치단체를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.
- ② 또한 대집행 이후에 위법의 상태가 계속된다면 결과제거청구를 주장할 수도 있다.

05 기타 논점

1) 하자의 승계 가능성

- ① 건축법상 철거명령과 행정대집행법상 대집행의 절차상 각 행위는 별개의 법적효과를 목적으로 하므로 하자의 승계가 부정된다.
- ② 반면에 대집행의 절차인 계고, 통지, 실행 및 비용징수는 하나의 법적효과를 목적으로 하여 각각 하자의 승계가 인정된다는 것이 통설·판례의 태도이다.

대법원 1993. 11. 9. 선고 93누14271

대집행의 계고·대집행명령에 의한 통지·대집행의 실행·대집행에 요한 비용의 납부명령 등은, 타인이 대신하여 행할 수 있는 행정의무의 이행을 의무자의 비용부담하에 확보하고자 하는, 동일한 행정목적 달성을 위하여 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여지는 것으로서, 서로 결합하여 하나의 법률효과를 발생시키는 것이므로, 선행처분인 계고처분이 하자가 있는 위법한 처분이라면, 비록 하자가 중대하고도 명백한 것이 아니어서 당면무효의 처분이라고 볼 수 없고 대집행의 실행이 이미 사실행위로서 완료되어 계고처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없게 되었으며, 또 대집행비용납부명령 자체에는 아무런 하자가 없다 하더라도, 후행처분인 대집행비용납부명령의 취소를 청구하는 소송에서 청구원인으로 선행처분인 계고처분이 위법한 것이기 때문에 그 계고처분을 전제로 행하여진 대집행비용납부명령도 위법한 것이라는 주장을 할 수 있다.

2) 이행강제금과의 관계

건축법에서는 행정상 강제집행수단으로 대집행과 이행강제금 모두를 규정하고 있다.

이와 관련하여 헌법재판소는 양자를 **선택적으로** 활용할 수 있으며, 이를 중첩적 제재에 해당한다고 보지는 않는다.

3) 「토지보상법」의 인도·이전의무의 대집행 가능성 [★★★]

(1) 문제점

- ① 토지·물건의 인도·이전은 대체적 작위의무가 아니므로 행정대집행의 대상이 되지 못한다.
- ② 그런데 토지보상법 제89조에서는 대집행을 규정하고 있어, 해당 규정을 토지·물건의 인도·이전에 대해 대집행을 인정하는 특별규정으로 보아야 하는지 견해가 대립한다.

[토지보상법] 제89조 (대집행)

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다. 이 경우 신청을 받은 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

[토지보상법] 제43조 (토지 또는 물건의 인도 등)

토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다.

(2) 학설

- ① 대집행이 불가능하다고 보는 것은 토지보상법 제89조를 무의미 하게 하는 것이므로 해당 규정을 합리적·합목적적으로 해석하여 대집행이 가능하다고 보는 <긍정설>
- ② 인도의무는 실력으로 점유를 배제시키는 직접강제에 해당한다고 보아 대집행을 부정하는 <부정설>이 대립한다.

(3) 판례

인도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실행행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것은 아니라고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

대법원 2005. 8. 19. 선고 2004다2809

'인도'에는 명도도 포함되는 것으로 보아야 하고, 이러한 명도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실행행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니다.

(4) 검토

토지보상법상 해당 규정을 행정대집행법의 특례 규정으로 보기 어렵고, 인도 의무는 직접적인 실행행사가 필요하므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 없다고 보는 <부정설>이 타당하다.

01 의미

- ① 행정벌이란 행정법상의 의무위반에 대한 제재로서 국가의 일반통치권에 의하여 과하는 처벌을 말한다.
- ② 행정벌은 직접적으로는 과거의 의무위반에 대한 제재로서의 의미를 가지는 것이나 간접적으로는 의무자에게 심리적인 압박을 가함으로써 의무이행을 촉진시키는 수단으로서의 의미도 갖는다.

02 종류

1) 행정형벌

(1) 의미

행정법상 의무를 위반한 자에게 [형법]에 정해진 형벌(사형·징역·금고·자격상실·벌금 등)을 과하는 행정벌을 말한다.

[감정평가법] 제49조 (벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
2. 감정평가법인이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
3. 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신등록을 한 사람(이하 생략)

(2) 적용법률

원칙적으로 형법총칙이 적용되며, 과벌절차도 형사소송법에 의한 것이 원칙이다.

(3) 대상인 행위

행정형벌은 행정법상 의무위반에 의하여 직접 행정목적과 사회공익이 침해되는 경우에 과하여지며, 법률에서 규정하고 있는 대부분의 행정벌이 행정형벌에 속한다.

2) 행정질서벌

(1) 의미

행정질서벌이란 행정법상의 의무위반에 대하여 [형법]상의 형벌이 아닌 **과태료**가 과하여지는 행정벌을 말한다.

[감정평가법] 제52조 (과태료)

- ① 제24조 제1항을 위반하여 사무직원을 둔 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 400만원 이하의 과태료를 부과한다.
 5. 제28조 제2항을 위반하여 보험 또는 협회가 운영하는 공제사업에의 가입 등 필요한 조치를 하지 아니한 사람
 7. 제47조에 따른 업무에 관한 보고, 자료 제출, 명령 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 국토교통부장관에게 거짓으로 보고한 자

(2) 적용법률

행정질서법은 형벌이 아니므로 형법총칙이 적용되지 않으며, 과태료의 부과절차인 [질서위반규제법]에 의한다.

(3) 대상인 행위

- ① 행정질서법인 과태료는 신고·등록·서류비치 등의 의무를 태만히 하는 것과 같이 간접적으로 행정상 질서에 장애를 줄 위험성이 있는 경미한 법법행위에 대한 제재로서 과하여지는 것이 보통이다.
- ② 헌법재판소는 행정법상의 의무위반행위에 대하여 행정형벌을 과할 것인지, 행정질서법을 과할 것인지는 입법권자의 입법재량에 속한다고 보고 있다.

03 병과가능성

1) 학설

- ① 행정형벌과 행정질서벌은 그 보호법익과 목적이나 성질이 다르므로 과태료 부과처분 후에 행정형벌을 부과하여도 일사부재리의 원칙에 반하지 않는다는 <긍정설>
- ② 양자는 모두 행정벌이므로 동일 법규 위반행위에 대하여 병과할 수 없다는 <부정설>

2) 판례

대법원은 긍정설을 헌법재판소는 부정설의 입장을 따르고 있다.

3) 검토

- ① 양자는 서로 목적·기능이 중복되는 면이 없지 않으므로, 기본적 사실관계가 동일한 의무위반행위에 대해서 행정질서벌과 행정벌을 병과하는 것은 이중처벌금지원칙의 기본정신에 배치될 여지가 있다.
- ② 다만, 기본적 사실관계가 다른 의무위반행위에 대해서는 병과가 가능할 것이다.
 - 예 건축물의 무단용도변경행위에 대해서는 행정형벌을, 시정명령 불이행에 대해서는 행정질서벌을 부과하는 것)

I

과징금 [★★]

CASE

국토교통부장관은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제6조(감정평가서)에 반하는 감정평가서를 작성·발급하였다는 이유로 감정평가사 甲에게 3월의 업무정지처분을 하였다.

(물음) 국토교통부장관은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」상 업무정지처분을 갈음하여 과징금을 부과할 수 있는지, 그리고 甲이 과징금 납부 의무를 불이행한 경우 국토교통부장관은 어떠한 조치를 할 수 있는지 검토하시오. (10점) (36회 문3 변형)

01 의미 및 근거

- ① 과징금이란 행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 **경제적 이익의 박탈을 위하여** 부과·징수하는 금전을 말한다.
- ② 행정기본법 제28조에 근거가 있으며, 감정평가법 제41조 내지 제44조 등 개별법에서 그 근거를 두고 있다.

[행정기본법] 제28조 (과징금의 기준)

- ① 행정청은 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 법률로 정하는 바에 따라 그 위반행위에 대한 제재로서 과징금을 부과할 수 있다.

02 종류

1) 본래적 과징금

- ① 본래적 의미의 과징금은 행정법상의 의무위반으로 인하여 얻은 경제적 이익을 박탈하는 금전적 제재를 말한다.
- ② 따라서 과징금 액수는 이득액의 규모 등과 상호 균형을 이룰 것이 요구된다는 것이 판례의 입장이다.

2) 변형된 과징금

- ① 변형된 과징금이란 **영업정지 등에 갈음하여** 과징금을 부과하는 것을 말한다.
- ② 즉, 의무위반행위가 사업의 인허가 등을 철회하거나 정지시킬 사유에 해당하지만, 그 사업을 철회·정지시킬 경우 초래되는 공익 또는 사익의 침해를 이유로 정지 등의 처분 대신에 과징금을 부과하는 것을 말한다.
- ③ 감정평가법 제41조의 과징금이 여기에 해당한다.

[감정평가법] 제41조 (과징금의 부과)

- ① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조에 따른 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 전액을 일시에 납부하기 어렵다고 인정될 때에는 그 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정할 때에는 담보를 제공하게 할 수 있다.

03 법적성질 (처분, 재량행위)

- ① 과징금부과행위는 행정행위로서 **급부하명**의 성격을 가지며 행정소송의 대상이 되는 처분이다.
- ② 영업정지처분을 할 것인지 과징금을 부과할 것인지는 행정청의 재량에 속하는 것으로 본다.
- ③ 감정평가법 제41조 제1항에서도 '~부과할 수 있다'고 규정하여 문언상 **재량행위**로 볼 수 있다.

04 다수의 위반행위에 대한 과징금 액수 산정 방법

1) 여러 위반행위를 일괄하여 제재 원칙

관할 행정청이 여러 가지 위반행위를 인지하였다면 명문의 규정이 없더라도 그 위반행위의 전부에 대하여 일괄하여 하나의 제재처분을 하는 것이 원칙이다.(판례)

2) 일괄 제재시 과징금을 한도로 할 것

- ① 어떤 과징금 부과처분을 한 후, 그 과징금 부과처분 이전에 있었던 다른 과징금 부과 사유를 인지한 경우, 별개의 처분으로 과징금을 부과하더라도 일괄하여 하나의 처분으로 하는 경우의 액수를 총 한도로 하여야 한다는 것이 판례의 입장이다.
- ② 이는 행정청이 언제 과징금 부과 사유를 인지하였느냐는 사정에 따라 과징금 액수가 달라지는 것을 막기 위함이다.

대판 2021.2.4. 2020두48390

[1] 위반행위가 여러 가지인 경우에 행정처분의 방식과 한계를 정한 관련 규정들의 내용과 취지에다가, 여객자동차운수사업자가 범한 여러 가지 위반행위에 대하여 관할 행정청이 구 여객자동차 운수사업법(2020. 3. 24. 법률 제17091호로 개정되기 전의 것) 제85조 제1항 제12호에 근거하여 사업정지처분을 하기로 선택한 이상 각 위반행위의 종류와 위반 정도를 불문하고 사업정지처분의 기간은 6개월을 초과할 수 없는 점을 종합하면, 관할 행정청이 사업정지처분을 갈음하는 과징금 부과처분을 하기로 선택하는 경우에도 사업정지처분의 경우와 마찬가지로 여러 가지 위반행위에 대하여 1회에 부과할 수 있는 과징금 총액의 최고한도액은 5,000만 원이라고 보는 것이 타당하다.

관할 행정청이 여객자동차운수사업자의 여러 가지 위반행위를 인지하였다면 전부에 대하여 일괄하여 5,000만 원의 최고한도 내에서 하나의 과징금 부과처분을 하는 것이 원칙이고, 인지한 여러 가지 위반행위 중 일부에 대해서만 우선 과징금 부과처분을 하고 나머지에 대해서는 차후에 별도의 과징금 부과처분을 하는 것은 다른 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다.

만약 행정청이 여러 가지 위반행위를 인지하여 그 전부에 대하여 일괄하여 하나의 과징금 부과처분을 하는 것이 가능하였음에도 임의로 몇 가지로 구분하여 각각 별도의 과징금 부과처분을 할 수 있다고 보게 되면, 행정청이 여러 가지 위반행위에 대하여 부과할 수 있는 과징금의 최고한도액을 정한 구 여객자동차 운수사업법 시행령(2018. 4. 10. 대통령령 제28793호로 개정되기 전의 것) 제46조 제2항의 적용을 회피하는 수단으로 악용될 수 있기 때문이다.

[2] 관할 행정청이 여객자동차운송사업자가 범한 여러 가지 위반행위 중 일부만 인지하여 과징금 부과처분을 하였는데 그 후 과징금 부과처분 시점 이전에 이루어진 다른 위반행위를 인지하여 이에 대하여 별도의 과징금 부과처분을 하게 되는 경우에도 종전 과징금 부과처분의 대상이 된 위반행위와 추가 과징금 부과처분의 대상이 된 위반행위에 대하여 일괄하여 하나의 과징금 부과처분을 하는 경우와의 형평을 고려하여 추가 과징금 부과처분의 처분양정이 이루어져야 한다.

다시 말해, 행정청이 전체 위반행위에 대하여 하나의 과징금 부과처분을 할 경우에 산정되었을 정당한 과징금액에서 이미 부과된 과징금액을 뺀 나머지 금액을 한도로 하여서만 추가 과징금 부과처분을 할 수 있다.

행정청이 여러 가지 위반행위를 언제 인지하였느냐는 우연한 사정에 따라 처분상대방에게 부과되는 과징금의 총액이 달라지는 것은 그 자체로 불합리하기 때문이다.

05 행정벌과 중복 부과 가능성

CASE

감정평가법인 A에게 과징금과 행정 벌금을 중복 부과한 것이 헌법 제13조의 이중처벌금지의 원칙에 반하는지 여부를 검토하십시오.

1) 문제점

- ① 헌법 제13조 제1항에서는 ‘~동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다’고 규정하고 있다.
- ② 동일한 위반행위에 대해 행정벌과 과징금을 병과하는 것이 이중처벌금지 원칙에 반하는 것이 아닌지가 문제 된다.

[헌법] 제13조

- ① 모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다.

2) 학설

- ① 행정벌과 과징금은 그 성질과 목적에 차이가 있어 병과가 이중처벌금지 원칙에 반하는 것은 아니라고 보는 견해와
- ② 동일한 위반행위에 대한 제재로 보아 과징금 등이 다른 법적 형식을 취하고 있더라도 병과가 불가능하다고 보는 견해가 있다.

3) 판례

부당내부거래에 대한 과징금은 형사처벌과 아울러 병과가 가능하며 이중처벌금지원칙에 위반되지 않는다고 판시하였다.

4) 검토

과징금은 행정상 제재금이고, 범죄에 대한 국가의 형벌권의 실행으로서의 과벌이 아니므로 양자는 병과가 가능하다고 보는 것이 타당하다.

06 과징금 납부의무 불이행시

1) 강제징수

과징금 부과처분을 받은 자가 납부의무를 불이행한 경우에는 [국세징수법] 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 강제징수할 수 있다.

2) 가산금 징수

가산금이란 행정법상 급부의무 불이행에 대하여 과해지는 금전상의 제재이다.

[감정평가법] 44조 (과징금의 징수와 체납처분)

- ① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 **가산금을 징수**할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 제1항에 따른 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 과징금의 징수와 체납처분 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

07 위법한 과징금에 대한 구제

1) 행정쟁송

과징금 부과행위는 침익적 행정행위(급부하명)으로서 행정쟁송법상의 처분에 해당하므로 행정심판이나 행정소송을 제기하여 그 취소를 구할 수 있다.

2) 국가배상

위법한 과징금부과처분으로서 인해 손해를 입은 자는 국가를 상대로 손해배상청구를 할 수 있으므로, 과징금이 법률상 원인 없이 징수된 경우 공법상의 부당이득반환청구를 행사할 수 있다.

CASE

감정평가사 甲이 국토교통부장관으로부터 징계처분을 받았다. 국토교통부장관은 감정평가사 甲의 생년월일, 소속 감정평가법인의 명칭 및 주소, 징계의 종류·내용 등을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 공고하고자 한다.

이 경우 위와 같은 징계정보의 공고가 감정평가사 甲에게 법적 불이익을 가져오는 행정처분(처분성)에 해당하는지 검토하시오.

01 의미

명단의 공표란 행정법상의 의무 위반 또는 의무불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가함으로써 심리적인 압박을 가하여 행정법상의 의무이행을 확보하는 간접강제수단을 말한다.

02 법적 근거

- ① 행정법상의 의무위반자의 명단을 공표하는 것은 그의 명예, 신용 또는 프라이버시에 대한 침해를 초래하므로 명시적인 법적근거가 요구된다.
- ② 감정평가법 제39조의2에서 징계의 공고가 명단의 공표에 해당한다.

[감정평가법] 제39조의2 (징계의 공고)

- ① 국토교통부장관은 제39조제1항 및 제2항에 따라 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.
- ② 협회는 제1항에 따라 통보받은 내용을 협회가 운영하는 인터넷 홈페이지에 3개월 이상 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.
- ③ 협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

03 법적성질

1) 학설

- ① 명단공표는 수인의무를 수반하지 않으므로 비권력적 사실행위라고 보는 견해이다.(비권력적 사실행위설, 다수설)
- ② 공표행위는 일방적으로 행해지고 그로 인하여 명예, 신용 등이 침해되므로 권력적 사실행위로 보는 견해이다.(권력적 사실행위설)
- ③ 공표에 앞서 공표결정이 통보되는 경우에는 공표결정통보는 행정처분의 성격을 갖고 공표 자체는 사실행위의 성격을 갖는 반면, 공표에 앞서 공표결정이 통보되지 않는 경우에는 공표는 권력적 사실행위라고 보는 견해가 있다.

2) 판례

판례는 병무청장이 병역의무 기피자의 인적사항 등을 인터넷 홈페이지에 게시한 것을 항고소송의 대상인 행정처분으로 판시하였다.

3) 검토

- ① 원칙적으로 명단을 공개하는 행위 그 자체는 순수한 사실행위일 뿐이므로 처분성이 부정된다.
- ② 그러나 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정하여 행정쟁송으로 다룰 수 있게 함이 타당하다.

04 권리구제

1) 행정쟁송 (처분성 여부)

명단공표의 처분성이 인정되는 경우 항고소송을 통해 다룰 수 있을 것이다.

2) 손해배상청구 등

위법한 공표에 대해 손해배상청구가 가능하며, 손해배상청구는 명단공표에 대한 취소소송과 관련 청구소송으로서 병합하여 제기할 수 있다(행정소송법 제10조 제2항).

3) 결과제거청구

위법한 명단공표로 인하여 피해를 입은 자는 결과제거청구권을 행사하여 공표의 철회나 정정을 요구할 수 있을 것이다.

III 기타

01 가산세

「국세기본법」 및 「세법」에서 규정하는 신고 등 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 그 법에 따라 산출된 세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.

02 공급거부

행정부상 의무를 위반하거나 불이행한 자에 대하여 행정상의 서비스나 재화의 공급을 거부하는 행위를 말한다.

03 관허사업의 제한

행정부상 의무를 위반하거나 불이행한 자에 대하여 각종 인허가를 거부, 정지, 철회함으로써 행정법상 의무준수 또는 의무이행을 간접적으로 강제하는 것을 말한다.

CASE

「토지보상법」 제9조에서는 “사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다”고 규정한다. 타인토지출입의 법적 성질에 대하여 설명하시오.

01 의미

- ① 행정기관이 행정작용을 위해 필요한 정보나 자료 등을 수집하는 일체의 행정활동으로서 행정상 즉시강제와 구별된다.
- ② (ㄱ) 행정기관의 일방적인 명령·강제를 수단으로 하는 권력적 행정조사와
(ㄴ) 명령·강제를 수반하지 않는 비권력적 행정조사로 구분된다.

02 법적성질 및 법적 근거

1) 법적 성질

- ① 행정조사에는 보고서요구명령, 장부서류제출명령, 출두명령 등 **행정행위의 형식**을 취하는 것과
- ② 질문, 출입검사, 실시조사, 진찰, 검진, 앙케트 조사 등 **사실행위의 형식**을 취하는 것이 있다.

2) 행정조사의 법적 근거

- ① 권력적 행정조사는 반드시 법적근거가 요구된다.
- ② 그러나 비권력적 행정조사는 반드시 법적근거를 요하는 것은 아니다.

03 실효행사 가능성

1) 문제점

비권력적 조사의 경우 실효행사가 부정되나, 권력적 행정조사를 함에 있어 상대방이 조사를 거부하거나 방해하는 경우에 당해 공무원이 실력으로 이를 억압하고 강제 조사를 할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 조사의 거부·방해가 있는 경우에 대한 제재 규정이 있는 것은 거부·방해 등이 위법하다는 것을 전제한 것이므로 비례의 원칙 내에서 실효행사가 가능하다고 보는 <긍정설>
- ② 제재규정은 간접적인 실효성 확보 수단에 불과하므로 실효행사는 허용되지 않는다고 보는 <부정설>
- ③ 원칙적으로는 허용되지 않으나 예외적으로 행정조사의 필요성이 긴급하고, 다른 수단이 없는 경우에 한하여 허용된다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 검토

국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 것은 명문의 근거가 없는 한 법치주의 관점에서 인정될 수 없으므로 <부정설>이 타당하다.

CASE

타인토지출입시 토지보상법 제10조의 통지의무를 거치지 않고 수집된 조서에 기초하여 사업인정(행정행위)를 한 경우, 사업인정이 위법한지 서술하시오.

[토지보상법] 제10조 (출입의 통지)

- ① 제9조제2항에 따라 타인이 점유하는 토지에 출입하려는 자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게 통지하여야 한다.

1) 문제점

- ① 행정조사가 위법한 경우에 그 행정조사에 의해 수집된 정보에 기초하여 내려진 행정결정이 위법하게 되는지 문제된다.
- ② 행정조사를 통하여 획득한 정보가 정확하지 않은 경우, 그 정보에 기초하여 내려진 행정행위는 사실오인의 흠이 있는 행정행위이므로 당연히 위법하다.
- ③ 따라서 문제가 되는 경우는 행정조사의 **내용은 정확**하지만 실체법상 또는 절차법상 위법한 경우이다.

2) 학설

- ① 적법절차의 원칙에 비춰 위법한 행정조사에 기초한 행정행위는 위법하다고 보는 <적극설>
- ② 행정조사와 행정행위는 서로 별개의 제도이므로 조사의 위법이 곧바로 행정행위를 위법하게 만들지는 않는다고 보는 <소극설>
- ③ 행정조사에 중대한 위법사유가 있다면 행정행위도 위법하다고 보는 <절충설>이 있다.

3) 판례

판례는 **적극설**에 따라 위법한 세무조사에 기한 과세처분은 위법하다고 하였다.
다만, 행정조사의 하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본 판례도 있다.

4) 검토

- ① 적법절차의 원칙에 따라 행정결정은 적법하고 정당한 절차를 거쳐야 한다.
- ② 따라서 위법한 행정조사에 기초한 행정결정은 위법하다고 보는 <적극설>이 타당하다.

PART 04

행정쟁송

Chapter 01 행정심판

Chapter 02 취소소송

제1절 행정구제의 체계

01 행정구제의 개념

행정권의 행사에 의해 침해된 국민의 권익을 구제해 주는 것을 말한다.

02 행정구제의 방법

1) 개요

- ① 행정구제의 방법에는 원상회복적인 것과 금전에 의한 보상이 있다.
- ② 전자로는 행정쟁송, 헌법소원과 공법상 결과제거청구권이 있다.
- ③ 후자로는 행정상 손해배상과 행정상 손실보상이 있다.

2) 행정쟁송

- ① 행정법관계에 있어서의 법적 분쟁을 당사자의 청구에 의하여 심리·판정하는 심판절차를 말한다.
- ② 오늘날 행정쟁송은 행정소송과 행정심판을 총칭하는 개념으로 사용하는 것이 타당하다.

3) 손해전보

- ① 행정작용으로 인해 발생한 국민의 재산상 손해 또는 손실을 보전하는 제도를 말한다.
- ② 그 원인행위의 형태에 따라 크게 손해배상(국가배상)과 손실보상으로 구분할 수 있다.

행정쟁송	행정심판		취소심판	
			무효등확인심판	
			의무이행심판	
	행정소송	항고소송	취소소송	
			무효등확인소송	
			부작위위법확인소송	
			무명항고소송	의무이행소송
			예방적부작위소송	
		당사자소송	실질적 당사자소송	
			형식적 당사자소송	
		객관적 소송	민중소송	
			기관소송	
		헌법소원		
손해전보	손해배상			
	손실보상			

01 행정심판의 의의

행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분 또는 부작위로 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고 아울러 행정의 적정한 운영을 도모하기 위해 행정기관에 의한 심판절차로서, 사법절차가 준용되는 불복절차를 말한다.

02 법적근거

행정심판을 규율하는 일반법으로 [행정심판법]이 있고, 각 개별법률에서 [행정심판법]에 대한 특칙을 규정하고 있다.

(예 토지보상법상 이의신청 등)

03 행정심판의 기능

- ① 행정소송보다 약식으로 진행되므로 신속·경제적인 권익구제가 가능하다.
- ② 법원에서 행정처분의 하자에 대해 위법성 심사를 하기 전에 행정청에게 스스로 반성할 기회를 주어 자율적으로 시정할 수 있다.
- ③ 행정청은 법원보다 해당 분야에 대한 전문지식이 풍부하므로 이를 이용할 수 있는 장점이 있다.
- ④ 행정소송의 제기 없이 행정심판 과정에서 법률관계가 확정된다면 법원의 부담이 경감되는 장점이 있다.

04 다른 행정상 불복제도와의 구별

1) 이의신청

(1) 의의

- ① 이의신청이란 위법·부당한 행정작용으로 인해 권리가 침해된 자가 처분청에 대하여 그러한 행위의 시정을 구하는 절차를 말한다.
- ② 강학상 이의신청은 행정불복 중 행정심판이 아닌 것, 달리 말하면 준사법적 절차가 아닌 행정불복을 말한다.

(2) 법적근거

- ① [행정기본법]은 처분에 대한 이의신청을 일반적으로 규정하고 있다.
- ② 그외 각 개별법에서 이의신청을 규정하고 있다.
각 개별법에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 [행정기본법]에 따른다.

[행정기본법] 제36조 (처분에 대한 이의신청)

- ① 행정청의 처분(「행정심판법」 제3조에 따라같은 법에 따른 행정심판의 대상이 되는 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 14일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 14일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 10일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 이의신청을 한 경우에도 그 이의신청과 관계없이「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.
- ④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날(제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 같은 항에 따른 통지기간이 만료되는 날의 다음 날을 말한다)부터 90일 이내에 제1항의 처분(이의신청 결과 처분이 변경된 경우에는 변경된 처분으로 한다)에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.
- ⑤ 다른 법률에서 이의신청과 이에 준하는 절차에 대하여 정하고 있는 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 조에서 정하는 바에 따른다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 이의신청의 방법 및 절차 등에 관한 사항은대통령령으로 정한다.

(3) 이의신청권자

처분에 이의가 있는 **처분의 상대방**만이 신청권자가 된다.

(4) 행정쟁송과의 관계

- ① 이의신청은 **임의적 절차**이다.
- ② 따라서 이의신청을 한 경우에도 그 이의신청과 관계없이 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있다.
- ③ 이의신청결과에 불복하고자 하는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 **90일 이내**에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

(5) 행정심판과의 구별

CASE

개별공시지가에 불복하는 甲은 부동산 가격공시에 관한 법률 제11조에 따라 X시장에게 B토지의 개별공시지가에 대한 이의를 신청하였으나 기각되었다. 이 경우 甲이 기각결정에 불복하여 행정심판법상의 행정심판을 제기할 수 있는지 설명하시오. (33회 문2 변형)

a. 문제점

- ① 이의신청이 강학상 이의신청에 불과한지 아니면 그 명칭에도 불구하고 실질적으로 행정심판에 해당하는지 문제된다.
- ② 개별법상 이의신청이 행정심판의 성질을 가지는 경우, 이의신청을 거친 후에 다시 행정심판을 제기할 수 없다.(행정심판법 제51조)

b. 구별기준

- ① 심판기관기준설 : 행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.
- ② 불복절차기준설 : 준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.
- ③ 판례 : 국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.
- ④ 검토 : 헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

c. 개별법상 이의신청의 성격

- ① 토지보상법상 이의신청 : 이의신청에 대한 재결이 확정된 때에는 [민사소송법]상의 확정판결이 있는 것으로 보는 규정을 고려할 때, [토지보상법]상의 이의신청은 특별법상의 행정심판으로 보는 것이 일반적인 견해이다.

대판 1992.6.9. 92누565

토지수용위원회의 수용재결에 대한 이의절차는 실질적으로 행정심판의 성질을 갖는 것이므로 토지수용법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 행정심판법의 규정이 적용된다고 할 것이다.

- ② 공시지가에 대한 이의신청 : 판례는 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

2) 처분의 재심사

[행정기본법] 제37조 (처분의 재심사)

- ① 당사자는 처분(제재처분 및 행정상 강제)은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)이 행정심판, 행정소송 및 그 밖의 쟁송을 통하여 다룰 수 없게 된 경우(법원의 확정판결이 있는 경우는 제외한다)라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 처분을 한 행정청에 처분을 취소·철회하거나 변경하여 줄 것을 신청할 수 있다.
 - 1. 처분의 근거가 된 사실관계 또는 법률관계가 추후에 당사자에게 유리하게 바뀐 경우
 - 2. 당사자에게 유리한 결정을 가져다주었을 새로운 증거가 있는 경우
 - 3. 「민사소송법」 제451조에 따른 재심사유에 준하는 사유가 발생한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우
- ② 제1항에 따른 신청은 해당 처분의 절차, 행정심판, 행정소송 및 그 밖의 쟁송에서 당사자가 중대한 과실 없이 제1항 각 호의 사유를 주장하지 못한 경우에만 할 수 있다.

05 고지제도

1) 의의

- ① 행정청이 처분을 할 때에 상대방 등에게 해당 처분에 대하여 행정심판을 제기할 수 있는지 여부 등을 미리 알려주는 제도를 말한다.
- ② 국민에게 행정심판제기와 관련된 정보를 제공하여 행정심판제도의 이용기회를 보장하려는 데 그 취지가 있다.

[행정심판법] 제58조 (행정심판의 고지)

- ① 행정청이 처분을 할 때에는 처분의 상대방에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.
 - 1. 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지
 - 2. 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구 기간
- ② 행정청은 이해관계인이 요구하면 다음 각 호의 사항을 지체 없이 알려 주어야 한다. 이 경우 서면으로 알려 줄 것을 요구받으면 서면으로 알려 주어야 한다.
 - 1. 해당 처분이 행정심판의 대상이 되는 처분인지
 - 2. 행정심판의 대상이 되는 경우 소관 위원회 및 심판청구 기간

2) 법적성질

행정심판에 관한 사항을 알리는데 불과하므로 비권력적 사실행위이다.

3) 고지의무위반의 효과

- ① 고지제도는 행정심판제기에 대한 정보를 제공할 뿐이므로, 행정청이 고지의무를 이행하지 않거나(불고지), 잘못된 고지(오고지)를 하였다 하더라도 당해 처분이 위법하게 되는 것은 아니다.(판례)
- ② 불고지·오고지가 있는 경우 심판청구기간은 <청구요건>에서 후술함

01 일반행정심판과 특별행정심판

1) 일반행정심판

- ① 일반행정심판이란 [행정심판법]에 의한 행정심판을 말한다.
- ② 행정심판법 제4조 제2항은 “다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다.”고 하여, [행정심판법]이 일반법임을 명시하고 있다.

2) 특별행정심판

- ① 사안의 전문성·특수성을 살리기 위하여 각 개별법에서 따로 정한 행정심판을 말한다.
- ② 사례 : 토지보상법상 토지수용재결에 대한 이의신청

02 일반행정심판의 종류

1) 개요

- ① 행정심판법에서 규정하는 행정심판은 모두 행정청의 처분 또는 부작위를 대상으로 하는 항고심판이다.
- ② 당사자심판에 대해서는 규정하고 있지 않으므로, 공법상 법률관계에 대한 분쟁은 당사자소송을 제기해야 한다.
- ③ 행정소송에서는 부작위위법확인소송이 인정되나, 행정심판에서는 부작위위법확인심판이 인정되지 않고, 그 대신 위법 또는 부당한 부작위에 대하여 적극적인 처분을 구하는 **의무이행심판 제기가 가능하다**.

[행정심판법] 제5조 (행정심판의 종류)

행정심판의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 취소심판 : 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판
2. 무효등확인심판 : 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판
3. 의무이행심판 : 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판

2) 취소심판

(1) 의의

취소심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판을 말한다.

(2) 특징

- ① 심판청구기간에 제한이 있고(행정심판법 제27조)
- ② 집행부정지가 원칙이며(행정심판법 제30조 제1항)
- ③ 사정재결(행정심판법 제44조) 등이 적용된다.

3) 무효등확인심판

(1) 의의

- ① 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판을 말한다.
- ② 무효확인심판, 유효확인심판, 실효확인심판, 존재확인심판, 부존재확인심판이 있다.

(2) 특징

- ① 취소심판과 달리 청구기간의 제한이 없고
- ② 사정재결에 관한 규정이 적용되지 않는다.

4) 의무이행심판

(1) 의의

- ① 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다.
- ② 의무이행심판은 거부처분이나 부작위와 같은 소극적인 행위로 인한 권익침해에 대한 권리구제수단이라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

(2) 특징

- ① 거부처분에 대한 의무이행심판에는 청구기간의 제한이 있지만(안 날 90일, 있은 날 180일), 부작위에 대해서는 청구기간의 제한이 없다.
- ② 취소심판과 같이 사정재결에 대한 규정이 적용된다.
- ③ 의무이행심판에는 성질상 집행정지에 관한 규정이 적용되지 않고, 임시처분이 가능하다.

01 청구인

1) 의의

- ① 청구인이란 행정심판을 청구하는 자를 말한다.
- ② 처분의 상대방뿐만 아니라 제3자도 행정심판의 청구인이 될 수 있다.

2) 청구인적격

- ① 청구인적격이란 행정심판을 청구할 자격이 있는 자를 말하며, 이는 항고소송의 원고적격에 대응되는 개념이다.
- ② 취소심판은 처분의 취소 또는 변경을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다.
(법률상 이익의 의미는 행정소송에서 후술함)

02 피청구인

1) 의의

피청구인이란 심판청구를 제기 받은 상대방인 당사자를 말하고, 이는 행정소송의 피고에 대응되는 개념이다.

2) 피청구인적격

행정심판은 처분을 한 행정청을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.

03 행정심판의 대상

1) 개요

행정심판의 대상인 처분 또는 부작위는 기본적으로 행정소송의 대상인 처분 또는 부작위와 동일하다.

2) 심판유형별 대상

- ① 취소심판·무효등확인심판 : 위법 또는 부당한 처분(거부처분 포함)
- ② 의무이행심판 : 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위

04 행정심판기관

1) 의의

행정심판청구를 심리·재결하는 권한을 가진 행정기관을 말한다.

2) 행정심판위원회

(1) 의의

행정청의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구를 심리·의결하고 그 판단에 따라 재결하는 합의제 행정청이다.

(2) 종류

- ① 행정심판법에 의해 설치되는 일반행정심판위원회와 개별법에 의해 설치되는 특별행정심판위원회가 있다.
- ② 일반행정심판위원회 : 국토교통부장관의 처분에 대한 행정심판을 심리·재결한다.
- ③ 특별행정심판위원회 : [토지보상법]상 중앙토지수용위원회 등

3) 행정심판위원회의 권한

(1) 심리권

행정심판위원회는 심판 청구된 사건을 심리하는 권한을 가진다.

(2) 재결권

- ① 행정심판위원회는 심리를 마치고 난 후 심판청구에 대한 법적 판단을 할 수 있는 권한, 즉 재결할 권한을 가진다.
- ② 행정심판위원회는 처분에 대한 집행정지결정 및 집행정지취소결정, 임시처분결정, 그리고 사정재결을 할 수 있다.

(3) 불합리한 법령 등의 시정조치요구권

중앙행정심판위원회는 심판청구를 심리·재결할 때에 처분 또는 부작위의 근거가 되는 명령 등 (법규명령·행정규칙 등)이 법령에 근거가 없거나 상위 법령에 위배되거나 국민에게 과도한 부담을 주는 등 크게 불합리하면 관계 행정기관에 그 명령 등의 개정·폐지 등 적절한 시정조치를 요청할 수 있다.

05 청구기간

1) 개요

- ① 행정심판은 법정 청구기간 내에 제기하여야 한다.
- ② 심판청구기간은 취소심판과 거부처분에 대한 의무이행심판에만 적용되고, 무효등확인심판이나 부작위에 대한 의무이행심판에는 적용되지 않는다.

2) 심판청구기간

(1) 행정심판법상 심판청구기간

처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 하고, 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다.

(2) 특별법상의 심판청구기간

[토지보상법]상 이의신청기간은 재결서의 정본을 받은 날로부터 30일 이내로 규정되어 있다.

3) 오고지·불고지의 경우

(1) 오고지의 효과

심판청구기간을 <처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내>보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우, 그 잘못 고지된 기간 내에 심판청구할 수 있다.(짧게 알린 경우에는 원래의 기간 동안 청구가능, 또한 행정소송에는 적용되지 않는다.)

(2) 불고지의 경우

처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구할 수 있다.

[행정심판법] 제27조 (심판청구의 기간)

- ① 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다.
- ② 청구인이 천재지변, 전쟁, 사변, 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 한다.
- ③ 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항과 제2항의 기간은 불변기간으로 한다.
- ⑤ 행정청이 심판청구 기간을 제1항에 규정된 기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 본다.
- ⑥ 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간에 심판청구를 할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정은 무효등확인심판청구와 부작위에 대한 의무이행심판청구에는 적용하지 아니한다.

01 개요

- ① 행정심판의 가구제수단으로는 집행정지제도와 임시처분제도가 있다.
- ② 임시처분제도는 집행정지가 인정되지 않는 거부처분이나 부작위의 경우에도 당사자의 임시적인 권리보호를 위해 인정된다.
- ③ 집행정지는 [행정심판법]이나 [행정소송법]에 모두 규정되어 있지만, 임시처분은 [행정심판법]에만 규정되어 있다.

02 집행정지

1) 의의

- ① 집행정지란 위원회가 다툼의 대상이 된 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행을 정지시키는 것을 말한다.
- ② [행정심판법]은 집행부정지를 원칙으로 하면서도, 처분의 집행으로 중대한 손해가 생기는 것을 예방하기 위하여 일정한 경우 예외적으로 집행정지를 인정하고 있다.

[행정심판법] 제30조 (집행정지)

- ① 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ② 위원회는 처분, 처분의 집행 또는 절차의 속행 때문에 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요성이 긴급하다고 인정할 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지(이하 “집행정지”라 한다)를 결정할 수 있다. 다만, 처분의 효력정지는 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 때에는 허용되지 아니한다.
- ③ 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.
- ④ 위원회는 집행정지를 결정한 후에 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 정지사유가 없어진 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 집행정지 결정을 취소할 수 있다.

03 임시처분

1) 의의

- ① 행정청의 처분이나 부작위 때문에 발생할 수 있는 당사자의 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위해 당사자에게 임시지위를 부여하는 행정심판위원회의 결정을 말한다.
- ② 행정심판에서는 의무이행심판이 인정되기 때문에 임시처분이 가능하다.

[행정심판법] 제31조 (임시처분)

- ① 위원회는 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우로서 처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위하여 임시지위를 정하여야 할 필요가 있는 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 임시처분에 관하여는 제30조 제3항부터 제7항까지를 준용한다. 이 경우 같은 조 제6항전단 중 “중대한 손해가 생길 우려”는 “중대한 불이익이나 급박한 위험이 생길 우려”로 본다.
- ③ 제1항에 따른 임시처분은 제30조 제2항에 따른 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.

2) 요건

(1) 적극적 요건

- (ㄱ) 심판청구가 계속 중일 것,
- (ㄴ) 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우일 것,
- (ㄷ) 처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위한 것일 것,
- (ㄹ) 이를 막기 위하여 임시지위를 정해야 할 필요가 있어야 한다.

(2) 소극적 요건

임시처분이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것을 요건으로 한다.

3) 임시처분의 보충성

임시처분은 집행정지와의 관계에서 **보충적 구제제도**이므로, 임시처분은 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다.

4) 임시처분의 결정 및 취소

- ① 위원회는 직권 및 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다.
- ② 위원회는 임시처분을 결정한 후에 임시처분이 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 처분사유가 없어진 경우에는 직권 또는 신청에 의하여 임시처분 결정을 취소할 수 있다.

01 심리

1) 심리의 의의

재결의 기초가 되는 사실관계 및 법률관계를 명확히 하기 위해 행정심판위원회가 당사자나 관계인의 주장과 반대주장을 듣고 각종의 증거·자료를 수집·조사하는 일련의 절차를 말한다.

2) 심리의 원칙

(1) 불고불리의 원칙

행정심판위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 재결하지 못한다.

(2) 불이익변경금지의 원칙

심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리하게 재결을 하지 못한다.

[행정심판법] 제47조 (재결의 범위)

- ① 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 재결하지 못한다.
- ② 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다.

3) 처분사유의 추가·변경

항고소송에서의 처분사유 추가·변경의 법리는 행정심판단계에서도 동일하게 적용된다.(후술)

02 행정심판의 조정

조정은 양 당사자 간의 합의가 가능한 사건인 경우, 행정심판위원회가 개입·조정하는 절차를 통하여 갈등을 조기에 해결하는 제도이다.

03 행정심판의 재결

1) 재결의 의의

- ① 재결이란 행정심판청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 법적 판단을 말한다.
- ② 재결은 다툼이 있는 행정법상의 사실관계 또는 법률관계를 일정한 절차를 거쳐 판단·확정하는 행위이므로 준법률행위적 행정행위인 **확인행위**에 해당한다.

2) 재결기간

- ① 재결은 [행정심판법] 제23조에 따라 피청구인 또는 위원회가 심판청구서를 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다.
- ② 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 30일을 연장할 수 있다.

3) 재결의 송달과 효력발생

- ① 위원회는 재결을 한 경우 지체 없이 당사자에게 재결서의 정본을 송달하여야 한다.
- ② 재결은 재결서의 정본이 청구인에게 송달되었을 때에 그 효력이 생긴다.

4) 재결의 종류

(1) 각하재결

청구인의 심판청구가 제기요건에 흠결이 있는 부적법한 심판청구인 경우, 본안심리 자체를 거절하는 재결을 말한다.

(2) 기각재결

- ① 본안심리를 한 결과, 청구가 이유 없다고 인정하여 청구를 배척하고 원처분을 지지하는 재결을 말한다.
- ② 기각재결이 있는 후에도, 처분청은 당해 처분을 직권으로 취소·변경할 수 있다.

(3) 인용재결

본안심리를 한 결과, 청구가 이유 있다고 인정하여 청구인의 청구취지를 받아들이는 재결을 말한다.
(상세한 내용 별도 목차로 서술)

(4) 사정재결

- ① 위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 **공공복리에 크게 위배된다고** 인정하면 그 심판청구를 **기각**하는 재결을 말한다.
- ② 취소심판과 의무이행심판에서만 인정된다.(무효등확인심판에서는 인정되지 않음)

[행정심판법] 제44조 (사정재결)

- ① 위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하면 그 심판청구를 기각하는 재결을 할 수 있다. 이 경우 위원회는 재결의 주문에서 그 처분 또는 부작위가 위법하거나 부당하다는 것을 구체적으로 밝혀야 한다.
- ② 위원회는 제1항에 따른 재결을 할 때에는 청구인에 대하여 상당한 구제방법을 취하거나 상당한 구제방법을 취할 것을 피청구인에게 명할 수 있다.
- ③ 제1항과 제2항은 무효등확인심판에는 적용하지 아니한다.

04 인용재결의 종류

1) 취소·변경재결

(1) 종류

- ① 처분취소재결 : 처분을 직접 취소하는 재결
- ② 처분변경재결 : 처분을 직접 변경하는 재결
- ③ 처분취소명령재결 : 현재 삭제되어 없음.
- ④ 처분변경명령재결 : 행정청에게 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 명령하는 재결

(2) 취소의 의미

〈취소〉는 당해 처분의 전부를 취소하는 것을 의미한다.

(3) 변경의 의미

〈변경〉은 (ㄱ) 소극적 변경(일부취소)(예) 위법한 과세액의 일부취소)뿐만 아니라 취소소송과 달리 (ㄴ) 적극적 변경(예) 업무정지처분을 과징금처분으로 변경)도 포함한다.

2) 무효등확인재결

- ① 처분무효확인재결
- ② 처분유효확인재결
- ③ 처분존재확인재결
- ④ 처분부존재확인재결
- ⑤ 처분실효확인재결(명문규정 없지만 통설 인정)

3) 의무이행재결

(1) 의의

청구가 이유 있다고 인정할 때에 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나(처분재결) 처분청에게 그 신청에 따른 처분을 할 것을 명하는 재결(처분명령재결)을 말한다.

(2) 종류

- ① 처분재결 : 신청에 따른 처분을 하는 재결
- ② 처분명령재결 : 행정청에게 처분을 할 것을 명하는 재결(실무적으로 대부분)

[행정심판법] 제43조 (재결의 구분)

- ① 위원회는 심판청구가 적법하지 아니하면 그 심판청구를 각하한다.
- ② 위원회는 심판청구가 이유가 없다고 인정하면 그 심판청구를 기각한다.
- ③ 위원회는 취소심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분을 취소 또는 다른 처분으로 변경하거나 처분을 다른 처분으로 변경할 것을 피청구인에게 명한다.
- ④ 위원회는 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 처분의 존재 여부를 확인한다.
- ⑤ 위원회는 의무이행심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 지체 없이 신청에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 피청구인에게 명한다.

05 재결의 효력

1) 불가쟁력

재결에 대하여는 다시 심판청구를 제기하지 못하고, 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 불가변력

재결이 비록 위법 또는 부당하더라도 행정심판위원회가 스스로 그 재결을 취소·변경할 수 없는데, 이를 재결의 불가변력이라고 한다.

3) 형성력

- ① 재결의 내용에 따라 새로운 법률관계의 발생이나 기존의 법률관계에 변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다.
- ② 이러한 형성력은 **형성재결**(취소재결, 변경재결, 처분재결)에서만 발생하고, **이행재결**(변경명령재결, 처분명령재결)에서는 발생하지 않는다.

4) 기속력

(1) 의의

피청구인인 행정청이나 관계행정청이 인용재결의 취지에 따르도록 구속하는 효력을 말한다.

(2) 반복금지의무

인용재결이 있으면 행정청은 동일한 사정 아래에서 같은 사유로 동일인에게 같은 내용의 처분을 반복할 수 없는 반복금지의무가 발생한다.

(3) 재처분의무

거부처분에 대한 취소재결이나 무효확인재결이 있으면, 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.

5) 재처분의무 불이행시 실효성 확보수단

(1) 직접처분

[행정심판법] 제50조 (위원회의 직접 처분)

- ① 위원회는 피청구인이 제49조 제3항에도 불구하고 처분을 하지 아니하는 경우에는 당사자가 신청하면 기간을 정하여 서면으로 시정을 명하고 그 기간에 이행하지 아니하면 직접 처분을 할 수 있다. 다만, 그 처분의 성질이나 그 밖의 불가피한 사유로 위원회가 직접 처분을 할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 간접강제

[행정심판법] 제50조의2 (위원회의 간접강제)

- ① 위원회는 피청구인이 제49조 제2항(제49조 제4항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제3항에 따른 처분을 하지 아니하면 청구인의 신청에 의하여 결정으로 상당한 기간을 정하고 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나 즉시 배상을 할 것을 명할 수 있다.

06 재결에 대한 불복

- ① 재심판청구의 금지
- ② 재결에 대한 행정소송 제기

제1절

행정소송의 개요

01 행정소송의 의미

행정청의 공권력 행사에 대한 불복 및 기타 행정법상의 법률관계에 관한 분쟁에 대하여 법원에 정식의 소송절차를 거쳐 행하는 행정쟁송절차를 말한다.

02 행정소송의 종류

1) 행정소송법상 종류

- ① 행정소송은 크게 개인의 권리구제를 주된 목적으로 하는 **주관소송**과 행정작용의 적법성 또는 공익실현을 직접 목적으로 하는 **객관소송**으로 나눌 수 있다.
- ② 항고소송과 당사자소송은 주관소송이고, 민중소송과 기관소송은 객관소송이다.

[행정소송법] 제3조 (행정소송의 종류) 행정소송은 다음의 네 가지로 구분한다.

1. 항고소송 : 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송
2. 당사자소송 : 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송
3. 민중소송 : 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송
4. 기관소송 : 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송

(2) 항고소송의 종류

[행정소송법] 제4조(항고소송) 항고소송은 다음과 같이 구분한다.

1. 취소소송 : 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송
2. 무효등 확인소송 : 행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재여부를 확인하는 소송
3. 부작위위법확인소송 : 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송

03 무명항고소송의 인정여부

1) 문제점

- ① 행정소송은 사법부에 의한 사법작용이기 때문에 권력분립의 원칙상 사법부가 행정부의 고유한 권한을 침해할 수 없다는 한계가 있다.
- ② 이와 관련하여 [행정소송법]에서 규정된 소송형태 외에 다른 항고소송을 인정할 수 있는지가 문제된다.

2) 의무이행소송의 인정여부

CASE

국토교통부장관은 <OO공구사업>에 대해서 사업시행자를 <A공사>로 하는 사업인정을 고시하였다. 이에 A공사는 토지소유자와 협의매수를 위한 협의를 시작하였다. 그런데 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 토지소유자 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 소송상의 불복방법에 관하여 검토하십시오. (32회 문제1 변형)

(1) 의의

의무이행소송이란 행정청의 거부처분 또는 부작위에 대하여 법상의 **작위의무의 이행**을 청구하는 소송을 말한다.

(2) 인정여부

- ① 행정소송법 제4조를 제한적으로 해석하고, 권력분립의 원칙상 법원이 행정청에 대하여 어떠한 처분을 명하는 것은 행정청의 1차적 판단권을 침해한다고 보는 <부정설>
- ② 행정소송법 제4조를 예시적으로 해석하고, 거부처분이나 부작위를 행정청의 1차적 판단권의 행사로 볼 수 있으므로 의무이행소송의 인정이 권력분립원칙에 반하지 않는다고 보는 <긍정설>
- ③ 원칙적으로 부정하나 예외적으로 현행 항고소송만으로는 실효적인 권리구제가 불가능한 경우에는 인정된다는 <절충설>이 있다.
- ④ 판례는 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장이다.
- ⑤ 검토 : 거부처분은 행정청의 1차적 판단이 행사된 것이고, 부작위도 처분에 필요한 상당한 기간이 지났음에도 거부처분을 하지 않은 것이므로 행정청의 판단권의 행사에 준하는 것으로 볼 수 있으므로, 국민의 권익구제를 위하여 **절충설이 타당**하다.

대판 1997.9.30. 97누3200

현행 행정소송법상 행정청으로 하여금 일정한 행정처분을 하도록 명하는 이행판결을 구하는 소송이나 법원으로 하여금 행정청이 일정한 행정처분을 행한 것과 같은 효과가 있는 행정처분을 직접 행하도록 하는 형성판결을 구하는 소송은 허용되지 아니한다.

3) 예방적 부작위소송의 인정여부

CASE

사업시행자인 Y는 정비사업을 추진하는 과정에서 이에 반대하는 토지 등 소유자인 乙 등의 토지와 주택을 취득하려 했으나, 「토지보상법」에 따른 협의가 성립되지 않아 관할 지방토지수용위원회에 수용재결을 신청하였다. 만약 재결의 절차가 진행중인 상태에서 乙 은 토지수용위원회를 상대로 “지방토지수용위원회에 수용재결을 하여서는 아니 된다”라는 판결을 구하는 행정소송을 관할 법원에 제기하였다면 이러한 소송이 현행 행정소송법상 허용될 수 있는가? (2012년 변시 변형)

(1) 의의

행정청의 공권력 행사에 의해 국민의 권익이 침해될 것이 예상되는 경우에 미리 그 예상되는 침익적 처분을 저지하는 것을 목적으로 제기하는 소송을 말한다.

(2) 인정여부

- ① 행정소송법에 규정이 없고, 행정청의 1차적 판단권이 행하여지지 않은 상태에서의 사전적 통제제도이기 때문에 권력분립의 원칙상 허용되지 않는다는 <부정설>
- ② 기본 법정 항고소송만으로는 국민의 권익이 구제되지 못하는 경우가 있고, 특정의 권익침해가 예상되고 또한 임박한 경우에는 행정청의 1차적 판단권이 행사된 것에 준하는 것으로 볼 수 있어 허용된다는 <긍정설>이 있다.
- ③ 판례는 의무이행소송과 마찬가지로 <부정설>을 취하고 있다.
- ④ 검토 : 국민의 권리구제를 위하여 예방적 금지소송이 필요한 경우가 있고, 허용범위를 제한하여 인정하면 행정청의 일차적 판단권을 거의 침해하지 않을 수 있으므로 <긍정설>이 타당하다.

4) 작위의무확인소송 인정여부

행정청에 대해 일정한 작위의무가 있음을 확인해줄 것을 청구하는 소송인 작위의무확인소송 역시 인정되지 않는다.

04 취소소송

1) 의의

행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송을 말한다.

2) 종류

- ① 취소소송의 대상인 처분등은 처분과 재결을 의미한다.
- ② 따라서 처분취소소송, 처분변경소송, 재결취소소송, 재결변경소송 그리고 판례상 인정되는 무효선언을 구하는 의미의 취소소송이 있다.

3) 성질

취소소송의 성질에 대해 확인소송설, 형성소송설 등의 견해가 있으나, 취소소송은 법률관계를 변경 또는 소멸시키는 것으로 **형성소송**으로 보는 것이 통설·판례의 태도이다.

01 소송요건

- ① 소송요건이란 본안판단의 전제요건으로서 본안심리를 받기 위한 요건을 말한다.
- ② 소송요건은 불필요한 소송을 각하시켜 법원의 부담을 경감시키고, 적법한 소송에 대하여 충실한 심판이 이루어질 수 있도록 요구되는 요건이다.
- ③ 소송요건은 법원의 직권심사사항이며, 소송요건이 결여되면 법원은 각하판결을 한다.
- ④ 소송요건이 갖추어지면 본안심리로 넘어가므로 소송요건을 본안심판요건이라고도 하고, **소의 적법요건**이라고도 한다.

대상적격 (제19조)	소송의 대상이 될 수 있는 자격을 말하며, 취소소송은 처분등 을 대상으로 한다.
원고적격 (제12조 전문)	행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말하며, 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자 가 제기할 수 있다.
협의의 소의 (제12조 후문)	원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성 이라고도 한다.
제소기간 (제20조)	소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 또는 처분등이 있는 날부터 1년 이내 에 제기하여야 한다.
행정심판의 전치 (제18조)	행정소송을 제기하기 전에 행정심판법상 행정심판을 거치는 것을 말한다. 취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다고 하여 임의적 전치주의 를 취한다.
피고적격 (제13조)	소송이 올바른 피고를 상대방으로 제기되는 것을 말한다. 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.
재판관할 (제9조)	어떤 법원에 소를 제기하여야 하는지에 관한 것으로, 취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지 를 관할하는 행정법원으로 한다.

02 제소기간 (『행정소송법』 제20조) [★]

1) 의의

- ① 제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다.
- ② 제소기간은 행정의 안정성과 국민의 재판청구권의 조화를 고려해 입법 정책적으로 규정하며, 제소기간의 준수 여부는 법원의 직권조사사항이다.

[행정소송법] 제20조 (제소기간)

- ① 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 다만, 제18조제1항 단서에 규정한 경우와 그 밖에 행정심판청구를 할 수 있는 경우 또는 행정청이 행정심판청구를 할 수 있다고 잘못 알린 경우에 행정심판청구가 있는 때의 기간은 재결서의 정보를 송달받은 날부터 기산한다.
- ② 취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년(제1항 단서의 경우는 재결이 있는 날부터 1년)을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 기간은 불변기간으로 한다.

2) 안 날부터 90일

(1) 행정심판을 거치지 않은 경우

- ① 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는데, <처분 등이 있음을 안 날>이란 통지, 공고, 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미한다.
- ② 상대방이 있는 행정처분의 경우에는 행정처분이 상대방에게 고지되어 상대방이 이러한 사실을 인식함으로써 행정처분이 있다는 사실을 현실적으로 알았을 때를 의미한다.
- ③ 일반적으로 처분에 관한 서류가 당사자의 주소지에 송달되는 등 사회통념상 처분이 있음을 당사자가 알 수 있는 상태에 놓여진 때에는 반증이 없는 한 그 처분이 있음을 알았다고 추정할 수 있다.
- ④ 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고, 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되어야 하므로 고시 또는 공고의 효력발생일을 <처분 등이 있음을 안 날>로 보아 제소기간을 기산하여야 한다고 본다.

(2) 행정심판을 거친 경우

행정심판을 거친 경우는 행정심판에 대한 재결서 정보를 송달받은 날부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 한다.

3) 있는 날부터 1년

(1) 행정심판을 거치지 않은 경우

- ① 취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년을 경과하면 제기하지 못한다. 즉, 처분이 있는 날로부터 1년 내에 취소소송을 제기하여야 한다.
- ② <처분이 있는 날>이란 행정처분이 상대방에게 도달되어 효력이 발생한 날이라는 것이 통설·판례의 입장이다.

(2) 행정심판을 거친 경우

- ① 행정소송법 제20조 제2항 본문에서 <취소소송은 처분등이 있는 날부터 1년>이라고 규정하고 있는데, 이 처분등에는 행정심판에 따른 재결도 포함된다.
- ② 따라서 재결이 있는 날부터 1년 이내에 취소소송을 제기하여야 한다.

(3) 정당한 사유

- ① 행정소송법 제20조 제2항 단서에서는 정당한 사유가 있는 때에는 처분등이 있는 날부터 1년이 경과하여도 제소할 수 있다고 규정하고 있다.
- ② 여기서 정당한 사유란 사회통념에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 보는 것이 판례의 태도이다.
- ③ 또한, 제3자요 행정행위에서 처분의 상대방이 아닌 제3자는 특별한 사정이 없는 한 정당한 사유가 있는 경우에 해당하여 행정소송법 제20조 제2항 본문의 취소소송 제소기간을 배제할 수 있다고 본다.

4) 안 날과 있는 날의 관계

- ① 처분이 있음을 안 날과 처분이 있는 날 중 어느 하나의 기간이라도 경과하면 제소할 수 없다.
- ② 즉, 양자 중 먼저 경과하는 날을 기준으로 제소기간은 종료된다.

5) (단순) 이의신청을 거친 경우

[행정기본법] 제36조 (처분에 대한 이의신청)

- ④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날(제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 같은 항에 따른 통지기간이 만료되는 날의 다음 날을 말한다) 부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

03 행정심판의 전치 (『행정소송법』 제18조)

- ① 행정심판의 전치란 행정소송을 제기하기 전에 행정청에 먼저 행정심판을 청구하여 처분의 시정을 구하고, 그에 불복하는 경우에 비로소 소송을 제기하는 것을 말한다.
- ② 행정소송법은 행정심판 임의주의를 취하고 있다. 따라서 처분에 대해 행정심판을 거쳐서 취소소송을 제기할 수도 있고, 곧바로 취소소송을 제기할 수도 있다.
- ③ 만일 개별법에서 행정심판 전치주의를 규정하고 있다면, 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거쳐야 행정소송을 제기할 수 있다.

[행정소송법] 제18조 (행정심판과의 관계)

- ① 취소소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다. 다만, 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

04 피고적격 (『행정소송법』 제13조)

- ① 피고적격을 가진 자는 처분 등을 행한 행정청, 즉 처분청이 됨이 원칙이다(행정소송법 제13조).
- ② 또한, 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정을 통해 피고를 변경할 수 있다.

I 처분

01 대상적격 (「행정소송법」 제19조)

1) 개요

- ① 취소소송은 <처분등>을 대상으로 하며, <처분등>이란 처분과 행정심판의 재결을 말한다.
- ② 따라서 어떤 행정작용이 처분에 해당하는지가 문제된다.(재결에 대해서는 후술)
- ③ 행정청의 어떤 행위가 처분에 해당하는지의 문제는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우에 개별적으로 결정하여야 한다.

[행정소송법] 제2조 (정의)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “처분등”이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(이하 “처분”이라 한다) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

[행정소송법] 제19조 (취소소송의 대상)

취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

02 거부의 처분성 [★★★★]

CASE

甲은 2023. 8. 23. A광역시 B구 소재 토지를 증여받았고, 증여 당시 개별공시지가는 1㎡당 2,200,000원이었다. 甲은 개별공시지가에 오류가 있음을 발견해 B구청장 乙에게 정정을 신청했으나 정정불가 통보를 받았다. 물음 1) 甲이 乙의 정정불가 결정 통지를 대상으로 취소소송을 제기할 수 있는지를 설명하시오. (35회 문제 2번 변형)

1) 거부의 의의

행정청이 국민으로부터 어떤 신청을 받고서 그 신청에 따르는 행위를 하지 않을 뜻을 표시하는 행위를 말한다.

2) 부작위와 구별

거부는 신청에 대한 명백한 거절의 의사표시로서 행정청이 처음부터 아무런 의사표시를 하지 않은 부작위와 구별된다.

3) 거부행위가 처분이 되기 위한 요건

(1) 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용일 것

신청의 대상이 된 행위가 행정처분이어야 한다.

(2) 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떠한 변동을 일으킬 것

신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다.

(3) 법규상 또는 조리상의 신청권이 있을 것

- ① 행정청의 거부행위가 처분이 되기 위해서는 국민이 행정청에 대하여 그 신청에 따른 행정행위를 해줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다.
- ② 판례는 신청권의 존부에 대하여 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계 법규의 해석에 의하여 일반국민에게 그러한 권리가 인정되는지를 살펴 추상적으로 결정하고 있으며, 이러한 신청권은 단순한 응답을 받을 권리인 경우도 포함되나, 반드시 신청의 인용이라는 만족적 결과를 의미하는 것은 아니라고 보고 있다.

대법원 1998. 7. 10. 선고 96누14036

국민의 적극적 행위신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 것이라고 하려면, 그 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이어야 하고 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 하며, 그 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야만 한다.

4) 신청권 존부에 대한 견해의 대립

(1) 문제점

신청에 대한 거부가 처분이 되기 위해서 법규상·조리상 신청권이 필요한지가 문제 된다.

(2) 학설

- ① 신청권의 존부를 원고적격의 문제로 보는 <원고적격설>.
- ② 신청권의 존부는 본안에서 판단하여야 한다고 보는 <본안요건설> 및
- ③ 단순한 응답을 받을 권리로서 신청권이 필요하다고 보는 <대상적격설>이 있다.

(3) 판례

판례는 신청권이란 신청인이 누구인가를 고려하지 않고, 단순한 응답받을 권리를 의미한다고 보았으며, 어떤 개인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 있다면 그 거부행위는 항고소송의 대상인 처분으로 보아야 한다고 판시하여 대상적격설을 취하고 있다.

(4) 검토

현행 행정소송법은 신청권에 대응하는 처분의무를 부작위의 요소로 규정하고 있고, 거부처분 개념은 부작위개념과 연결되어 있으므로 현행 행정소송법하에서는 신청권을 거부처분의 요건으로 보는 것이 타당하다.

5) 반복된 거부처분

- ① 판례는 거부처분은 관할행정청이 국민의 신청에 대해 거절의 의사표시를 함으로써 성립되고, 그 이후 동일한 내용의 새로운 신청에 대하여 다시 거절의 의사표시를 한 경우에는 **새로운 거부처분(각각 독립된 처분)**이 있는 것으로 보아야 한다고 판시한 바 있다.
- ② 이 경우 판례는 행정심판 및 행정소송의 제기간은 각 **새로운 거부처분**을 기준으로 진행된다고 보고 있다.
(단, 비판의견 있음)

대법원 2022. 3. 17. 선고 2021두53894

수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있은 후 당사자가 다시 신청을 한 경우에는 신청의 제목 여하에 불구하고 그 내용이 새로운 신청을 하는 취지라면 관할 행정청이 이를 다시 거절하는 것은 새로운 거부처분이라고 보아야 한다. 나아가 어떠한 처분이 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 아니라고 하더라도, 해당 처분에 대한 이의신청의 내용이 새로운 신청을 하는 취지로 볼 수 있는 경우에는, 그 이의신청에 대한 결정의 통보를 새로운 처분으로 볼 수 있다.

03 신고의 수리거부

1) 신고의 의의

- ① 신고란 사인이 공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체에 대하여 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다.
- ② 아무런 법적 효과를 가져오지 않는 신고는 단순한 사실로서의 신고일 뿐이고, 사인의 공법행위로서의 신고에 해당하지 않는다.

2) 종류

(1) 자기관결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)

- ① 신고의 요건을 갖춘 신고만 하면 신고의무를 이행한 것이 되는 신고를 말한다.
- ② 자기관결적 신고의 **수리**는 단순한 접수행위이므로 법적 효과를 발생시키지 않는 **사실행위**이다.

[행정절차법] 제40조 (신고)

- ① 법령등에서 행정청에 일정한 사항을 통지함으로써 의무가 끝나는 신고를 규정하고 있는 경우 신고를 관장하는 행정청은 신고에 필요한 구비서류, 접수기관, 그 밖에 법령등에 따른 신고에 필요한 사항을 게시(인터넷 등을 통한 게시를 포함한다)하거나 이에 대한 편람을 갖추어 두고 누구나 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 신고가 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우에는 신고서가 접수기관에 도달된 때에 신고 의무가 이행된 것으로 본다.
 1. 신고서의 기재사항에 흠이 없을 것
 2. 필요한 구비서류가 첨부되어 있을 것
 3. 그 밖에 법령등에 규정된 형식상의 요건에 적합할 것
- ③ 행정청은 제2항 각 호의 요건을 갖추지 못한 신고서가 제출된 경우에는 지체 없이 상당한 기간을 정하여 신고인에게 보완을 요구하여야 한다.
- ④ 행정청은 신고인이 제3항에 따른 기간 내에 보완을 하지 아니하였을 때에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 해당 신고서를 되돌려 보내야 한다.

(2) 행위요건적 신고 (수리를 요하는 신고)

- ① 행정청에 대하여 일정한 사항을 통지하고 행정청이 이를 수리함으로써 법적효과가 발생하는 신고를 말한다.
- ② 신고의 요건을 갖춘 신고가 있었다 하더라도 수리되지 않으면 신고가 되지 않는 것으로 보는 것이 통설 및 판례의 입장이다.
- ③ 따라서, 수리거부는 거부처분에 해당하며 이는 항고소송의 대상이 된다.

[행정기본법] 제34조 (수리 여부에 따른 신고의 효력)

법령등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우(행정기관의 내부 업무 처리 절차로서 수리를 규정한 경우는 제외한다)에는 행정청이 수리하여야 효력이 발생한다.

3) 구별기준

(1) 관련 규정

관련 법령에서 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있으면 수리를 요하는 신고로 보고, 그렇지 않으면 수리를 요하지 않는 신고로 본다.

(2) 구별이 명확하지 않은 경우

a. 학설

- ① 신고 요건이 형식적 요건만을 요구하는 경우에는 자기완결적 신고로 보고, 신고요건이 형식적 요건 뿐만 아니라 실질적 요건도 포함하는 경우에는 실질적 요건의 충족여부에 대한 실질적 심사까지 해야 하므로 원칙상 수리를 요하는 신고로 보아야 한다.〈신고요건 및 심사방식기준설〉
- ② 입법자의 객관적 의사 즉 당해 법령의 목적과 당해 법령에서 나타나고 있는 관련 조문에 관한 합리적이고 유기적인 해석을 통해 구별해야한다는 견해인 〈입법자의사설〉
- ③ 일반적인 구별기준은 관련 법규정에 의해 추론되는 입법자의 객관적 의사라고 보면서도 복수의 구체적인 구별기준을 유형화하여 제시하는 견해인 〈복수기준설〉 등이 있다.

b. 판례

- ① 판례는 관련 법규정에 따르되 기본적으로 신고요건 및 심사방식을 기준으로 자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고를 구별하고 있다고 보는 것이 타당하다.
- ② 구체적으로 건축신고는 자기완결적 신고로 보나, 인허가의제 효과를 수반하는 건축신고에 대해서는 인허가의 실체적 요건에 관한 수리를 결정하여야 하므로 수리를 요하는 신고로 보았다.

c. 검토

- ① 형식적 신고요건에 대해서 형식적 심사를 행하면 자기완결적 신고이고, 신고요건에 실질적 요건도 포함될 뿐만 아니라 행정청이 실질적 심사를 할 수 있는 경우에는 수리를 요하는 신고로 보는 것이 타당하다.
- ② 따라서, 소속 감정평가사의 고용신고는 동법 제17조상의 등록과 달리 등록거부사유에 해당하는지 확인없이, 형식적 요건만을 요구하므로 〈자기완결적 신고〉에 해당한다.
- ③ 사무직원의 고용신고는 국토교통부장관이 결격사유에 해당하는지 여부를 확인하므로, 실질적인 요건까지 충족시켜야 하는 〈수리를 요하는 신고〉로 본다.

[감정평가법] 제17조 (등록 및 갱신등록)

- ① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 제10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

[감정평가법] 제21조의2 (고용인의 신고)

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

[감정평가법상 신고의 종류 정리]

구 분	신고의 명칭	관련 법조문	법적성질
1	감정평가사 등록	제17조	수리를 요하는 신고
2	고용인의 신고(감정평가사)	제21조의 2	자기완결적 신고
3	고용인의 신고(사무직원)	제21조의 2	수리를 요하는 신고
4	법인의 정관변경신고	제29조(설립 등)	수리를 요하는 신고
5	법인의 해산신고	제30조(해산)	수리를 요하는 신고

4) 적법한 신고의 효과발생

(1) 자기완결적 신고의 경우

- ① 신고서가 접수기관에 도달된 때에(행정청의 수리여부와 관계없이) 신고의 의무가 이행된 것으로 보고, 신고의 효력이 발생한다.
- ② 따라서 행정청이 적법한 신고서를 접수하지 않고 반려하여도 신고의무는 이행된 것으로 본다.

(2) 수리를 요하는 신고의 경우

- ① 행정청이 수리함으로써 신고의 효과가 발생한다.
- ② 적법한 신고가 있는 경우 행정청은 그 신고를 수리하여야 한다.(원칙적으로 기속행위)
- ③ 따라서 법령이 정한 요건을 구비한 적법한 신고가 있으면 행정청은 원칙적으로 수리하여야 하며, 법령에 없는 사유를 들어 수리를 거부할 수 없다.

5) 부적법한 신고의 효과

(1) 자기완결적 신고의 경우

부적법한 신고가 있었다면 행정청이 수리하였다고 하여도 신고의 효과가 발생하지 아니한다.

(2) 수리를 요하는 신고의 경우

- ① 부적법한 신고에 대해서 행정청이 이를 수리하였다면, 그 수리행위는 위법한 수리행위가 된다.
- ② 수리행위가 무효인 경우에는 신고의 효과가 발생하지 않지만, 취소할 수 있는 사유인 경우에는 수리행위가 취소될 때까지는 신고의 효과가 발생한다.

6) 자기 완결적 신고의 수리거부의 처분성 [★★★★]

CASE

감정평가사무소를 운영하는 甲은 감정평가사 乙을 채용하여 고용신고를 한 뒤 감정평가업무를 수행하도록 지시하였다. 국토교통부장관은 乙이 결격사유에 해당한다는 이유로 해당 고용신고의 수리를 거부하였다. 이로 인해 甲은 소속 감정평가사가 아닌 자를 통하여 감정평가 업무를 수행한 것으로 간주되어 벌금이 부과될 가능성이 있다. 이러한 경우, 국토교통부장관의 고용신고 수리 거부가 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지 여부를 논하시오.

(1) 문제점

- ① 감정평가사법 제21조의 2에서 규정하는 소속 감정평가사의 고용신고는 형식적 요건만을 요구하고, 사무직원의 고용신고와는 달리 결격사유에 해당하는지 여부 등에 대한 확인이 없으므로 자기완결적 신고라고 본다.
- ② 따라서 행정청이 자기완결적 신고의 수리를 거부하는 경우, 그 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 거부처분에 해당하는지 문제된다.

(2) 학설

- ① 신고의 법적성질에 따라 구분하는 견해로서 자기완결적 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 되지 않고, 수리를 요하는 신고의 수리거부는 항고소송의 대상이 된다고 보는 견해와
- ② 신고의 법적성질과 관계 없이 수리가 반려될 경우 **신고인이 불이익을 받을 위험** 등 법적 지위가 불안정하게 될 수 있는지 여부를 기준으로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 견해가 있다.

(3) 판례

종래에는 신고의 법적성질을 기준으로 수리를 요하는 신고의 수리거부만이 항고소송의 대상이 된다고 보았으나, 최근 「건축법상」 신고와 관련하여 **건축신고를 자기완결적 신고로 보면서도**, 건축신고가 반려될 경우 당사자에게 **제재적 처분이 내려질 우려**가 있어 불안정한 지위에 놓이게 된다고 보아, 건축신고 반려행위를 항고소송의 대상이 되는 **처분**으로 보아 개별적으로 검토하는 견해를 취하고 있다.

대법원 2010. 11. 18. 선고 2008두167 전원합의체

건축신고가 반려될 경우 당해 건축물의 건축을 개시하면 시정명령, 이행강제금, 벌금의 대상이 되거나 당해 건축물을 사용하여 행할 행위의 허가가 거부될 우려가 있어 불안정한 지위에 놓이게 된다.

따라서 건축신고 반려행위가 이루어진 단계에서 당사자로 하여금 반려행위의 적법성을 다투어 그 법적 불안을 해소한 다음 건축행위에 나아가도록 함으로써 장차 있을지도 모르는 위험에서 미리 벗어날 수 있도록 길을 열어 주고, 위법한 건축물의 양산과 그 철거를 둘러싼 분쟁을 조기에 근본적으로 해결할 수 있게 하는 것이 법치행정의 원리에 부합한다. 그러므로 건축신고 반려행위는 항고소송의 대상이 된다고 보는 것이 옳다.

(4) 검토

신고의 법적성질을 기준으로 하는 견해는 국민의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 미신고행위에 대한 **제재규정이 있다면** 이는 사인에게 신고의무를 지우는 것으로서 그러한 신고에 대한 수리거부의 **처분성을 긍정함이 타당하다**.

CASE

감정평가사 甲은 「감정평가법」을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2021. 4. 1. 甲과 乙에게 업무정지처분을 갈음하여 각 3천만원의 과징금을 부과하였다.

물음1) 甲은 부과된 과징금이 지나치게 과중하다는 이유로 국토교통부장관에게 이의신청을 하였고, 이에 대해서 국토교통부장관은 2021. 4. 30. 甲에 대하여 과징금을 2천만원으로 감액하는 결정을 하였다.

甲은 감액된 2천만원의 과징금도 과중하다고 생각하여 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하고자 한다.

이 경우 甲이 취소를 구하여야 하는 대상은 무엇인지 검토하십시오. (32회 문3번)

1) 문제점

- ① 행정청이 금전관련처분(예 조세처분 등)을 한 후에 당초처분을 시정하기 위하여 이를 감액하거나 증액하는 처분(경정처분)을 하는 경우가 있다.
- ② 처분이 있는 후 처분청이 처분을 변경한 경우에 당초처분과 경정처분 중 무엇을 대상으로 행정소송을 제기해야 하는지가 문제된다.

2) 학설

- ① 당초처분은 경정처분에 흡수되어 소멸하고, 경정처분만이 효력을 가지고 소송의 대상이 된다는 견해(흡수설)
- ② 경정처분은 당초처분에 흡수되어 경정처분에 의하여 수정된 당초처분이 소송의 대상이 된다는 견해(역흡수설) 등이 있다.
- ③ 당초처분과 경정처분은 독립된 처분으로 별개의 소송대상이라는 견해(병존설)

3) 판례

(1) 감액경정처분의 경우

- ① 감액경정처분은 당초처분의 전부를 취소한 다음 새로이 처분을 한 것이 아니라, 당초처분의 일부취소에 불과하므로, 경정처분에 의하여 감액되고 남아 있는 당초처분이 항고소송의 대상이 된다.(역흡수설)
- ② 이 경우 제소기간의 준수여부도 당초처분을 기준으로 판단한다.

(2) 증액경정처분의 경우

- ① 당초처분은 증액처분에 흡수되어 소멸되므로 증액경정처분이 항고소송의 대상이 된다.(흡수설)
- ② 이 경우 제소기간의 준수여부도 증액경정처분을 기준으로 판단한다.

4) 검토

- ① 감액경정처분의 경우에는 경정처분에 의하여 수정된 당초처분을 소의 대상으로 하는 것이 당초처분의 연속성 측면에서 타당하고,
- ② 증액경정처분의 경우에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액경정처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

05 변경처분

1) 문제의 소재

- ① 처분청은 직권으로 당초처분을 변경할 수 있다.
- ② 변경처분이 이루어질 경우, 처분의 상대방은 종전처분(선행처분)과 후속처분(후행처분) 중 무엇을 대상으로 행정소송을 제기해야 하는지가 문제된다.

2) 판례

(1) 적극적(실질적) 변경처분

- ① 후속처분이 종전처분의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 경우, 종전처분은 그때부터 효력을 상실하므로 후속처분만이 항고소송의 대상이 된다.
- ② 이 경우 변경취소소송의 제소기간의 준수여부는 변경처분시를 기준으로 한다.

대판 2012.3.29. 2010두7765

[도시 및 주거환경정비법] 관련 규정의 내용, 형식 및 취지 등에 비추어 보면, 당초 관리처분계획의 경미한 사항을 변경하는 경우와 달리 관리처분계획의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용으로 새로운 관리처분계획을 수립하여 시장·군수의 인가를 받은 경우에는, 당초 관리처분계획은 달리 특별한 사정이 없는 한 효력을 상실한다.

(2) 소극적(일부) 변경처분

후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고, 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다.

대판 2010.12.9. 2009두4555

재개발조합설립 인가신청에 대한 행정청의 조합설립인가처분 후 (구)[도시 및 주거환경정비법 시행령] 제27조 각 호에서 정한 경미한 사항의 변경에 대하여 행정청이 변경인가처분을 한 경우, 당초의 조합설립인가처분은 변경인가처분에 흡수되지 않는다.

대판 2015.11.19. 2015두295

기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전 처분을 완전히 대체하는 것이거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다.

II 재결

01 원처분주의와 재결주의 [★★★]

CASE

국토교통부장관은 「감정평가법」 제6조(감정평가서)에 반하는 감정평가서를 작성·발급하였다는 이유로 감정평가사 甲에게 3월의 업무정지처분을 하였다. 甲은 위 처분에 대하여 행정심판을 청구하였고, 행정심판위원회는 “국토교통부장관은 甲에게 한 3월의 업무정지처분을 2월의 업무정지처분으로 변경하라”는 재결을 하였다. 국토교통부장관은 위 재결취지에 따라 “3월의 업무정지처분을 2월의 업무정지처분으로 변경한다”는 후속 변경처분을 하였다.

물음 1) 甲이 후속 변경처분을 받은 후에 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분을 대상으로 하는지 검토하시오.
(36회 문3번)

1) 문제점

행정부의 처분에 대하여 행정심판의 재결을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우 (ㄱ) 원처분을 대상으로 해야 하는지, (ㄴ) 재결을 대상으로 해야 하는 것인지가 문제된다.

2) 의의

(1) 원처분주의

원처분과 재결 모두 취소소송의 대상이 될 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분취소소송에서만 주장할 수 있고, 재결취소소송에서는 원처분의 위법은 주장할 수 없고, 재결 자체의 고유한 위법만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

(2) 재결주의

원처분에 대해서는 소송을 제기할 수 없고, 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 하되, 재결 자체의 위법뿐만 아니라 원처분의 위법도 재결취소소송에서 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

3) 현행법상 태도

행정소송법 제19조는 원처분주의를 택하고 있다.

「행정소송법」 제19조 (취소소송의 대상)

취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

4) 재결 자체의 고유한 위법의 인정범위

(1) 재결자체의 고유한 위법의 의미

원처분에는 없고 재결 자체에만 존재하는 위법을 의미하는 것으로 재결 자체의 주체·내용·절차·형식의 위법이 있는 경우를 말한다.

(2) 재결의 주체에 관한 위법

권한이 없는 행정심판위원회가 재결을 하거나 행정심판위원회의 구성상 하자가 있는 경우 등이 있다.

(3) 재결의 절차에 관한 위법

- ① 행정심판법상의 심판절차를 준수하지 않은 경우를 그 예로 들 수 있다.
- ② 다만, 행정심판법 제45조에서 규정하고 있는 재결기간(60일 이내)은 훈시규정으로 해석되므로 재결기간을 넘긴 경우에도 그것만으로는 절차의 위법이 있다고 볼 수 없다.

(4) 재결의 형식에 관한 위법

문서에 의하지 아니한 재결, 재결에 주문만 기재되고 이유가 전혀 기재되어 있지 않거나 이유가 불충분한 경우, 재결서에 기명날인을 하지 아니한 경우 등을 그 예로 들 수 있다.

(5) 재결의 내용에 관한 위법

- ① 위법·부당하게 각하재결, 기각재결, 인용재결을 한 경우를 말한다.
- ② 여기에 대해서는 별도로 서술한다.

02 재결자체의 내용상 위법이 있는 경우

1) 각하재결

판례는 행정심판청구가 부적법하지 않음에도 불구하고 각하한 재결은 실체심리를 받을 권리를 박탈한 것으로서 원처분에 없는 고유한 하자이므로 재결소송의 대상이 된다고 판시한 바 있다.

2) 기각재결

- ① 원처분이 정당하다고 하면서 심판청구를 기각한 재결에 대해서는 원칙적으로 내용상의 위법을 주장하여 제소할 수 없다.
- ② 판례도 원처분과 동일한 이유로 원처분을 유지한 경우에는 고유한 하자가 존재하지 않는다고 판시한 바 있다.
- ③ 다만, 불고불리의 원칙, 불이익변경금지의 원칙을 벗어난 재결을 한 경우, 사정재결을 함에 있어 사정재결의 요건을 잘못 판단한 경우에는 내용상 위법이 인정된다.

3) 인용재결

- ① 인용재결은 청구인의 주장을 받아들이는 것이므로 원칙적으로 청구인은 인용재결에 대해서 불복할 이유가 없다.
- ② 그러나 일정한 경우에는 인용재결의 경우에도 <재결의 고유한 위법>이 인정되는 경우가 있다.(별도 목차로 후술)

03 인용재결에 고유한 위법이 있는 경우

1) 제3자요 행정행위에 대한 인용재결인 경우

CASE

사업시행자 Y는 정비사업을 실시함에 있어 이 사업에 반대하는 토지등소유자 乙 등의 토지와 주택을 취득하기 위하여 「토지보상법」에 의거한 乙 등과 협의가 성립되지 않아 지방토지수용위원회의 수용재결을 거쳤는데, 이 수용재결에 불복하여 Y가 중앙토지수용위원회에 이의재결(특별법상 행정심판)을 신청하여 인용재결을 받았다.
이 경우 乙등이 이 재결에 대해 항고소송을 제기한다면 소송의 대상은 무엇인가. (25회 문1 변형)

(1) 문제점

인용재결로 비로소 권리가 침해된 자가 인용재결을 다투고자 하는 경우, 인용재결을 제3자의 입장에서

① 재결자체의 고유한 위법이 있는 것으로 볼지 ② 원처분으로 볼지 문제된다.

㉠ 사업인정에 대하여 토지소유자가 취소심판을 청구하여 이를 취소하는 인용재결이 있는 경우, 사업시행자가 인용재결을 다투고자 할 때 그 인용재결이 사업시행자(제3자)의 입장에서 재결 자체의 고유한 위법인지, 아니면 최초의 침익적 원처분인지)

(2) 학설

① 제3자요 행정행위에서 인용재결로 권익을 침해당한 자가 인용재결의 당부를 다투는 것은 재결 자체의 고유한 하자를 주장하는 것이라는 견해와(행정소송법 제19조 단서설)

② 해당 인용재결은 형식상으로는 재결이나, 실질적으로는 권익을 침해당한 자에 대한 별도의 새로운 처분이므로 인용재결이 최초의 처분이라는 견해가 있다.(행정소송법 제19조 본문설)

(3) 판례

① 대법원은 제3자요를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다투는 필요가 있고,

② 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다고 판시하였다.

[대법원 2001. 5. 29. 선고 99두10292 판결]

(4) 검토

① 인용재결로 비로소 권익을 침해받게 되는 자는 인용재결을 대상으로 소를 제기할 수 있다.

② 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 이는 재결 고유의 하자를 주장하는 것으로 보는 것이 타당하다.

2) 부적법한 인용재결이 있는 경우

① 행정심판의 제기요건을 결여하였음에도 불구하고 각하하지 아니하고 인용재결을 한 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 해당하므로 제3자는 인용재결을 다투 수 있다.

② 판례로 자기완결적 신고의 수리는 처분성이 없으므로 수리처분의 취소를 구하는 행정심판청구는 부적법 각하해야 함에도 불구하고 인용재결한 경우에는 인용재결에 고유한 하자가 있으므로 인용재결이 행정소송의 대상이 된다고 보았다.

04 인용재결의 경우 소의 대상

1) 적극적·소극적(일부취소) 변경재결의 경우

(1) 문제점

변경재결이 있는 경우 당사자는 원처분과 재결 중 어느 것을 소송의 대상으로 해야 하는지가 문제된다.

(2) 학설

a. 변경된 원처분설

일부취소재결과 변경재결을 구별하지 않고 원처분주의 원칙상 재결은 소송의 대상이 되지 못하고 재결로 인하여 일부취소하고 남은 원처분, 또는 변경된 원처분이 소송의 대상이 된다는 견해이다.

b. 변경재결설

행정심판위원회의 변경재결은 원처분을 대체하는 새로운 처분이므로 재결이 소의 대상이 된다는 견해이다.

c. 일부취소와 적극적 변경재결 구별설

일부취소재결의 경우에는 남은 원처분이 소송의 대상이 되나, 적극적 변경재결의 경우에는 당초처분을 변경하는 새로운 처분이므로 적극적 변경재결을 소의 대상으로 하여야 한다는 견해이다.

(3) 판례

판례는 일부취소 또는 적극적 변경재결로 인하여 **감경되고 남은 원처분**을 대상으로 원처분청을 피고로 하여 소송을 제기하여야 하는 것으로 보고 있다.

(4) 검토

행정소송법 제19조 단서는 재결 자체의 고유한 위법이 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 해야 한다고 규정하고 있는 바, 변경재결 자체에 고유한 위법이 없다면 일부취소 또는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 보는 것이 타당하다.

2) 변경명령재결(변경명령재결에 따른 변경처분)의 경우

(1) 문제점

행정심판위원회의 변경명령재결이 있고 이에 따라 처분청이 재결의 취지에 따라(행정심판법 제49조) 변경처분을 한 경우 변경처분과 원처분 중 어느 것이 소의 대상이 되는지가 문제 된다.

(2) 학설

a. 변경된 원처분설

변경처분은 원처분에 흡수되므로 변경된 원처분만이 소송의 대상이 된다는 견해이다.

b. 변경처분설

명령재결에 따른 변경처분은 원처분을 대체하는 새로운 처분으로 보고 변경처분을 대상으로 취소소송을 제기하는 것이 타당하다는 견해이다.

(3) 판례

판례는 일부인용의 처분명령재결에 따라 당초처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 그 취소소송의 대상은 <변경된 내용의 당초처분>이라고 판시한 바 있다.

대법원 2007. 4. 27. 선고 2004두9302

행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 (처분명령재결에 따라) 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 변경처분에 의하여 당초 처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로, 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분이지 변경처분은 아니고, 제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초 처분을 기준으로 판단하여야 한다.

(4) 검토

행정소송법 제19조 단서는 재결 자체의 고유한 위법이 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 해야 한다고 규정하고 있는 바, 변경재결 자체에 고유한 위법이 없다면 일부취소 또는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 보는 것이 타당하다.

CASE

甲은 P토지의 표준지공시지가 처분의 상대방은 아니지만, 표준지공시지가에 따라 자신이 받을 보상액이 달라질 수 있다. 甲에게 P토지의 표준지공시지가 처분에 불복하여 취소소송을 다룰 법률상 이익이 있는지 여부를 검토하시오.
(25회 문2번 변형)

01 원고적격의 의미

원고적격이란 원고로서 소송을 수행하여 본안판결을 받을 수 있는 자격을 말한다.

02 법률상 이익의 의미

1) 관련규정

- ① 「행정소송법」 제12조에서 원고적격과 관련하여 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있다.
- ② 따라서 법률상 이익이 무엇을 의미하는지 문제된다.

[행정소송법] 제12조 (원고적격)

취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.

2) 학설 [권법보적]

- ① 위법한 처분으로 권리를 침해당한 자만이 원고적격을 갖는다는 <권리구제설>.
- ② 위법한 처분으로 인하여 근거법규 및 관계법규에 의하여 보호되는 이익이 침해된 자에게 당해 처분을 취소할 원고적격이 인정된다고 보는 <법률상 보호이익구제설>(통설·판례)
- ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 실질적으로 재판상 보호할 가치가 있는 이익이 침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치이익구제설>
- ④ 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성 보장설> 등이 있다.

3) 판례 [개직구]

법률상 보호되는 이익이라 함은 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익을 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익과 같이 사실적·경제적 이해 관계를 갖는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않는다고 판시하고 있다.[대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결]

4) 검토

- ① 권리구제설은 원고적격의 인정 범위가 너무 좁고
- ② 보호가치이익구제설은 보호가치 판단기준이 모호한 점
- ③ 적법성보장설은 취소소송을 객관화하는 문제점이 있다.
- ④ 따라서 국민의 권익구제 및 남소방지 등 관점에서 <법률상 보호이익구제설>이 타당하다.

03 법률의 범위

1) 문제점

법률상 보호이익구제설에 따라 법률이 보호하는 개별적·직접적·구체적 이익이라고 할 때, 법률의 범위를 어떻게 이해할 것인가에 따라 법률상 이익의 인정범위가 달라진다.

2) 학설

- ① 당해 처분의 근거법규에 한정된다는 견해와
- ② 근거법규 외에 관계법규에 의해 보호되는 이익도 포함된다는 견해,
- ③ 헌법상의 기본권까지 포함된다는 견해가 있다.

3) 판례

- ① 법률상 이익이란 근거법규 및 관계법규에 의해 보호되는 이익이라고 하면서도, 그 인정범위를 넓혀 가는 경향에 있다.
- ② 다만, **헌법상 기본권**이 원고적격의 요건인 법률상 이익이 될 수 있는지에 관하여 아직 이를 적극적으로 인정하고 있는 대법원 판례는 없고, 추상적 기본권의 침해만으로는 원고적격을 인정할 수 없다는 대법원 판례가 있을 뿐이다.
- ③ 반면, 헌법재판소는 국세청장의 납세병마개 제조자 지정처분에 대한 헌법소원사건에서 **헌법상 기본권인 경쟁의 자유**가 법률상 이익이 된다고 결정한 바 있다.

헌재결 1998.4.30., 97헌마141

설사 국세청장의 지정행위의 근거법규인 이 사건 조항들이 단지 공익만을 추구할 뿐 청구인 개인의 이익을 보호하려는 것이 아니라는 이유로 청구인에게 취소소송을 제기할 법률상 이익을 부정한다고 하더라도, 국세청장의 지정행위는 행정청이 병마개 제조업자들 사이에 특혜에 따른 차별을 통하여 사경제 주체간의 경쟁조건에 영향을 미치고 이로써 기업의 경쟁의 자유를 제한하는 것임이 명백한 경우에는 국세청장의 지정행위로 말미암아 기업의 경쟁의 자유를 제한받게 된 자들은 적어도 보충적으로 기본권에 의한 보호가 필요하다. 따라서 일반법규에서 경쟁자를 보호하는 규정을 별도로 두고 있지 않은 경우에도 기본권인 경쟁의 자유가 바로 행정청의 지정행위의 취소를 구할 법률상의 이익이 된다 할 것이다.

04 제3자의 원고적격

1) 문제점

- ① 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자에게 원고적격이 인정될 수 있는지 문제된다.
- ② 일반적으로 제3자의 경우 간접적·반사적 이익의 침해에 불과하다고 보아 원고적격이 부정되는 것이 일반적이다.
- ③ 다만, 행정처분의 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 그 처분 등으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 취소소송을 제기할 자격이 인정될 수 있다.

2) 영업자 소송

(1) 의의

여러 영업자가 경쟁관계에 있는 경우에 경쟁관계에 있는 영업자에 대한 처분 또는 부작위를 경쟁관계에 있는 다른 영업자가 다투는 소송을 말한다.

(2) 판례

- ① 판례는 일반적으로 기존업자가 **특허**를 받은 경우 그 특허로 받은 이익은 **법률상 이익**이라고 보아 원고적격을 인정하고, 기존업자가 **허가**를 받은 경우 허가로 인하여 받은 이익은 반사적 이익에 불과한 것으로 보아 원고적격을 부정하는 경향이 있다.
- ② 다만, 〈허가와 특허의 구별 없이〉 처분의 근거가 되는 법률이 해당 업자들 사이의 **과당경쟁으로 인한 경영의 불합리를 방지**하는 것도 그 목적으로 하고 있는 경우, 기존 업자에게 신규인·허가에 대한 취소를 구할 원고적격을 인정하고 있다.

3) 경원자 소송

(1) 의의

수인의 신청을 받아 일부에 대하여만 인허가 등의 수익적 행정처분을 할 수 있는 경우에 인허가 등을 받지 못한 자가 타인이 받은 인허가처분에 대하여 제기하는 소송을 말한다.

(2) 판례

경원관계가 존재하는 경우 일방에 대한 인·허가처분이 타방에 대한 불허가처분(거부처분)이 될 수밖에 없는 경우에 불허가처분을 받은 경원자에게 법률상의 이익이 있다고 보고 있다.

4) 인인소송 (인근주민소송)

(1) 의의

어떠한 시설의 설치를 허가하는 처분 등에 대하여 당해 시설의 인근주민이 다투는 소송을 말한다.

(2) 판례

당해 처분의 근거법규 및 관계법규가 공익 뿐만 아니라 **인근주민의 개인적 이익도 보호하고 있다고 해석**되는 경우에는 인근주민에게 원고적격이 인정된다고 판시하였다.

(3) 환경영향평가법령과 원고적격 인정기준

a. 환경영향평가 대상지역 안의 주민의 원고적격

환경영향평가 대상지역 안의 주민이 갖는 환경상의 이익은 **직접적·구체적 이익**으로서 그들에 대한 특단의 사정이 없는 한 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 **사실상 추정**되어 원고적격이 인정된다.

b. 환경영향평가 대상지역 밖의 주민의 원고적격

환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라고 할지라도 처분 등으로 인하여 처분 전과 비교하여 **수인한도를 넘는 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려**가 있다는 것을 **입증**함으로써 원고적격을 인정받을 수 있다고 판시한 바 있다.

CASE

국토교통부장관은 감정평가법인등 甲이 감정평가법 제10조에 따른 업무범위를 위반하여 업무를 행하였다는 이유로 甲에게 3개월 업무정지처분을 하였다. 甲은 이러한 처분에 불복하여 취소소송을 제기하였으나 소송계속 중 3개월의 정지기간이 경과되었다. 감정평가법 제32조 제5항에 근거하여 제정된 감정평가법 시행령 제29조 [별표 3] '감정평가법인등의 설립인가의 취소와 업무의 정지에 관한 기준'에 따르면, 위 위반행위의 경우 위반횟수에따라 가중처분을 하도록 규정하고 있다(1차 위반 시 업무정지 3개월, 2차 위반 시 업무정지 6개월, 3차 위반 시 업무정지 1년). 甲은 업무정지처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는가? (27회 문제4 현행법으로 변경)

01 의의 및 근거

1) 의의

원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 권리보호의 필요성이라고도 한다.

2) 근거

[행정소송법] 제12조의 해석과 관련하여 다수설과 판례는 전문은 원고적격에 관한 규정이나, 후문은 협회의 소익에 관한 규정으로 본다.

[행정소송법] 제12조 (원고적격)

취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다. 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.

02 회복되는 법률상 이익의 범위

1) 논의 실익

「행정소송법」 제12조 제2문의 회복되는 <법률상 이익>의 해석과 관련하여 전문의 법률상 이익과 동일하게 해석할 것인지 아니면 부수적 이익도 포함된다고 보는 것인지 견해가 대립한다.

2) 학설

- ① [행정소송법] 제12조 후문의 <법률상 이익>은 취소소송을 통하여 구제되는 기본적인 법률상의 이익뿐만 아니라 <부수적 이익>도 포함한다는 점에서 원고적격에서의 <법률상 이익>보다 넓게 보는 것이 다수견해이다.
- ② 다만, 이러한 <부수적 이익>에 어디까지 포함될 것인가에 대하여
 - (ㄱ) 명예·신용의 이익은 포함되지 않는다는 견해,
 - (ㄴ) 명예나 신용의 이익도 경우에 따라서는 포함된다는 견해,
 - (ㄷ) 경제적·정신적 이익까지 포함된다고 보는 견해가 있다.

3) 판례

- ① 판례는 전문과 후문의 <법률상 이익>을 동일하게 보고, <당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익>이라고 해석하고, 간접적이거나 사실적·경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 <법률상 이익>에 해당되지 않는다고 본다.
- ② 다만 최근에는 위법한 처분이 반복될 위험성이 있어 행정처분의 위법성 확인 내지 불분명한 법률문제에 대한 해명이 필요하다고 인정되는 경우에 소의 이익을 긍정하여 소의 이익을 넓히고 있다.

대법원 1995. 10. 17. 선고 94누14148 전원합의체

항고소송에 있어서 소의 이익이 인정되기 위하여는 행정소송법 제12조 소정의 "법률상 이익"이 있어야 하는바, 그 법률상 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우를 말하고 간접적이거나 사실적, 경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 여기에 해당되지 아니한다.

4) 검토

「행정소송법」 제12조 제2문은 협의의 소익에 대한 근거 조항으로 전문의 법률상 이익과 후문의 회복되는 법률상 이익을 일치시킬 필요가 없으며, 국민의 권리구제 확대를 위해 전문의 법률상 이익보다 넓게 보아, 명예 신용 등 인격적 이익도 포함된다고 보는 것이 타당하다.

03 구체적인 사례에서 소의 이익 유무

1) 소의 이익이 인정되지 않는 경우

(1) 처분의 효력이 소멸한 경우

- ① 처분의 효력이 소멸한 경우에는 해당 처분의 취소를 통하여 회복할 법률상 이익이 없는 것이 원칙이다.
- ② 예를 들어, 영업정지처분의 효력기간이 정하여져 있는데, 소송 도중 그 기간이 경과하였다면 소의 이익이 인정되지 않는다.(가장 중요, 후술)
- ③ 또한 취소소송 중 처분이 취소*철회된 경우, 다른 처분으로 대체되어 처분이 소멸한 경우 등이 있다.

(2) 원상회복이 불가능한 경우

- ① 취소소송의 인용판결을 받아 처분이 취소되더라도 원상회복이 불가능한 경우에는 원칙적으로 소의 이익이 부정된다.
- ② 예를 들어, 건물철거명령에 대한 취소소송 도중 이미 건물이 철거된 경우

(3) 처분 후의 사정변경에 의해 이익침해가 해소된 경우

- ① 처분 후 사정변경에 의해 권익의 침해 등이 해소된 경우에는 처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다.
- ② 예를 들어, 시험에 불합격 후 소송 진행 중에 새로 실시된 시험에 합격한 경우

(4) 보다 실효적인 구제수단이 있는 경우

취소소송을 제기하는 것보다 직접적인 구제수단이 있음에도 처분 등의 취소를 구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 분쟁해결의 유효적절한 수단이라고 할 수 없어 소의 이익이 부정된다.

2) 소의 이익이 인정되는 경우 (가중처벌 규정이 있는 경우)

(1) 문제점

제재적 처분이 효력을 상실하였더라도, 법령 등에 제재처분의 전력이 장래의 제재처분의 **가중요건 또는 전제요건**으로 규정되어 있는 경우, 제재처분의 취소를 구할 협의의 소익이 있는지가 문제 된다.

(2) 가중요건이 법적 구속력 있는 법령으로 규정되어 있는 경우

가중요건 등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 제재처분의 취소를 구할 협의의 소익이 인정된다.

(3) 가중요건이 부령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우

- ① 부정설로는 부령형식의 행정규칙은 행정규칙에 불과하여 행정청에 대해 법적 구속력을 미치지 않으므로 소의 이익을 부정하는 견해(변경전 판례의 견해)가 있다.
- ② 긍정설로는 (ㄱ)부령형식의 행정규칙을 행정규칙으로 보면서도 소의 이익을 인정하는 견해,
(ㄴ)부령형식의 행정규칙의 법규성 여부를 묻지 않고 소의 이익을 인정하는 견해(대법원 다수견해),
(ㄷ)부령형식의 행정규칙을 법규명령으로 보면서 소의 이익을 인정하는 견해(대법원 별개의견) 등이 있다.

(4) 가중요건이 행정규칙으로 규정되어 있는 경우

담당 공무원은 행정규칙도 준수하여야 하므로 가중요건이 행정규칙에 규정된 경우에도, 취소소송을 통해 장래의 불이익을 제거할 현실적 필요성이 있다고 보는 것이 타당하다. 최근 판례도 같은 입장이다.

대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후56

중앙해양안전심판원의 '해양사고관련자 징계양정 지침'에 의하면, 해양사고와 관련하여 징계를 받은 날로부터 1년 이내에 다시 해양사고를 일으킨 경우 징계량의 2배 범위 내에서 징계량을 가중할 수 있고, 또 해양사고방지를 위하여 특히 필요한 경우에는 면허를 취소할 수 있다고 규정하고 있으며, 이 사건 징계집행일로부터 1년이 경과하지 않았는바, 이와 같이 제재적 행정처분의 가중사유나 전제요건에 관한 규정이 법령이 아닌 **행정규칙의 형식으로 되어 있다 하더라도** 관할 행정청이나 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있으므로, 이 사건 재결의 존재로 인해 적어도 이 사건 징계집행일로부터 1년 이내에는 원고가 가중된 징계량을 받을 수 있는 위험이 구체적이고 현실적인 것이어서 이 사건 재결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

(5) 판례

- ① 종래에는 가중요건이 법률이나 대통령령에 규정되어 있는 경우에는 소의 이익을 긍정한 반면, 부령형식에 규정된 제재적 처분기준을 행정규칙에 불과한 것으로 보아 소의 이익을 부정했었다.
- ② 그러나 최근 대법원은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제요건을 규정하고 있다면, **그 기준의 법적성질에 상관없이** 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 **긍정**하는 입장이다.
- ③ 다만, 변경된 판례에서 대법원 **다수의견**은 부령형식의 제재적 처분기준의 법적성질에 대해서 명확히 밝히지 않았지만 대법원 **별개의견**은 이를 **법규명령**으로 보았다.

제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분을 하도록 정하고 있는 경우,

제재적 행정처분의 가중사유나 전제요건에 관한 규정이 법령이 아니라 규칙의 형식으로 되어 있다고 하더라도, 그러한 규칙이 법령에 근거를 두고 있는 이상 **그 법적 성질이 대외적·일반적 구속력을 갖는 법규명령인지 여부와는 상관없이**, 관할 행정청이나 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있으므로 이들이 그 규칙에 정해진 바에 따라 행정작용을 할 것이 당연히 예견되고, 그 결과 행정작용의 상대방인 국민으로서는 그 규칙의 영향을 받을 수밖에 없다.

따라서 그러한 규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 받은 상대방이 그 처분의 존재로 인하여 장래에 받을 불이익, 즉 후행처분의 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로, 상대방에게는 선행처분의 취소소송을 통하여 그 불이익을 제거할 필요가 있다.

(6) 소결

- ① 가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 법률이나 법규명령에 규정된 경우 뿐만 아니라 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다.
- ② 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익을 인정하는 것이 타당하다.

01 가구제

- ① 가구제란 소송의 본안판결이 확정되기 전에 원고의 권리보호를 위해 잠정적으로 행해지는 수단을 말한다.
- ② 소송의 실효성 확보를 위한 가구제로는 집행정지제도와 가처분이 있는데, 행정소송법에서는 집행정지만을 규정하고 있어 민사집행법상의 가처분을 행정소송에서도 준용할 수 있는지가 문제 된다.

02 집행정지 [★★]

1) 집행부정지 원칙과 집행정지(예외) (「행정소송법」 제23조)

- ① 행정소송법 제23조 제1항은 **집행부정지**를 원칙으로 규정하고 있다.
- ② 소송이 길어지면 승소판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다.
- ③ 따라서 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다.

[행정소송법] 제23조 (집행정지)

- ① 취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ② 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다.
다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다.
- ③ 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다.
- ④ 제2항의 규정에 의한 집행정지의 결정을 신청함에 있어서는 그 이유에 대한 소명이 있어야 한다.
- ⑤ 제2항의 규정에 의한 집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다.
이 경우 집행정지의 결정에 대한 즉시항고에는 결정의 집행을 정지하는 효력이 없다.
- ⑥ 제30조제1항의 규정은 제2항의 규정에 의한 집행정지의 결정에 이를 준용한다.

2) 요건

(1) 적극적 요건

a. 적법한 본안소송의 계속

- ① 민사집행법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다.
- ② 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

b. 처분 등의 존재

- ① 집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다.
- ② 따라서 **부작위**에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다.
- ③ **거부처분**에 대해서 집행정지가 허용되는지 견해의 대립이 있는데, 통설과 판례는 집행정지의 대상이 되지 않는다고 본다.(후술)

c. 회복하기 어려운 손해발생의 우려

회복하기 어려운 손해란 특별한 사정이 없는 한 **금전으로 보상할 수 없는 손해**로서 금전보상이 불능인 경우 뿐만 아니라 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜 수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유·무형의 손해를 말한다.

대법원 2003. 4. 25.자 2003무2 결정

행정소송법 제23조 제2항에 정하고 있는 행정처분 등의 집행정지 요건인 '회복하기 어려운 손해'라 함은 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 이는 금전보상이 불능인 경우 내지는 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 당사자가 참고 견딜 수 없거나 또는 참고 견디기가 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 일컫는다.

당사자가 행정처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 재산상의 손해를 입거나 기업 이미지 및 신용이 훼손당하였다고 주장하는 경우에 그 손해가 금전으로 보상할 수 없어 '회복하기 어려운 손해'에 해당한다고 하기 위해서는, 그 경제적 손실이나 기업 이미지 및 신용의 훼손으로 인하여 사업자의 자금사정이나 경영 전반에 미치는 파급효과가 매우 중대하여 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 등의 사정이 존재하여야 한다.

d. 긴급한 필요

- ① <긴급한 필요>란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다.
- ② 판례는 긴급한 필요가 있는지 여부는 처분의 성질, 양태와 내용, 처분상대방이 입는 손해의 성질·내용과 정도, 원상회복·금전배상의 방법과 난이도 등은 물론 본안청구의 승소가능성 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 보았다.

(2) 소극적 요건

a. 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것

행정소송법 제23조 제3항에 의거 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다.

b. 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

- ① 행정소송법상 명문으로 규정된 요건은 아니지만 <본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것>이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다.
- ② 이에 대해 본안에서 승소가능성이 전혀 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 **취지에 반하며**, 집행정지신청의 **남용을 방지**할 필요도 있으므로 본 요건이 요구된다고 보는 것이 일반적 견해이다.

3) 내용

(1) 처분의 효력정지

- ① 처분의 효력정지란 처분의 내용에 따르는 공정력·구속력·집행력 등을 잠정적으로 정지시킴으로써, 정지 결정 이후부터 처분이 존재하지 않는 상태에 두는 것을 말한다. (예) 영업정지처분의 효력정지 등)
- ② 다만, 처분의 효력정지는 처분등의 집행 또는 절차의 속행을 정지함으로써 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다(행정소송법 제23조 제2항 단서).

(2) 처분의 집행정지

처분의 집행정지는 처분의 내용을 강제적으로 실현하는 집행력의 행사를 정지시키는 것으로서 처분의 내용이 실현되지 않은 상태로 두는 것을 말한다. (예) 철거명령을 강제집행하기 위한 대집행을 정지하는 것)

(3) 절차의 속행정지

절차의 속행정지는 심판대상인 처분에 따르는 후속처분을 정지시키는 것을 말한다.

(예) 대집행계고에 대한 집행정지신청에서 대집행영장의 통지나 대집행 실시 등 절차의 속행정지)

4) 불복 및 취소

(1) 집행정지결정에 대한 불복

행정소송법 제23조 제5항에 의거 집행정지의 결정 또는 기각의 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다.

(2) 집행정지결정의 취소

집행정지의 결정이 확정된 후 집행정지가 공공복리에 중대한 영향을 미치거나 그 정지사유가 없어진 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 집행정지의 결정을 취소할 수 있다(행정소송법 제24조 제1항).

5) 집행정지의 효과

- ① 집행정지결정은 취소판결의 효력에 준하여 당사자인 행정청 뿐만 아니라 관계행정청도 기속한다.
(행소법 제23조 제6항)
- ② 집행정지결정이 있으면 신청인 및 피신청인에게 효력이 미치며, 제3자에게도 효력이 미친다.
(행소법 제29조 제2항)
- ③ 본안소송에서 패소확정판결을 받았더라도 집행정지결정의 효력이 소급하여 소멸하지 않는다.
(즉, 집행정지기간 중의 영업이 위법하게 되는 것은 아니다.)

[행정소송법] 제29조 (취소판결등의 효력)

- ① 처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다.
- ② 제1항의 규정은 제23조의 규정에 의한 집행정지의 결정 또는 제24조의 규정에 의한 그 집행정지결정의 취소결정에 준용한다.

03 거부처분의 집행정지 가능성 [★★]

1) 문제점

- ① 집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 종전의 상태로 회복시키는 소극적인 조치일뿐 종전 상태를 변경시키는 적극적인 조치는 아니다.
- ② 따라서 거부처분취소소송에서 거부처분이 집행정지의 대상이 될 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 집행정지결정은 행정청에 사실상의 구속력을 가진다고 보아 긍정하는 <긍정설>.
- ② 집행정지는 처분이 없었던 것과 같은 상태를 만드는 것일 뿐이며, 행정소송법 제23조 제6항은 집행정지결정의 구속력과 관련하여 행정소송법 제30조 제1항만을 준용하고, 재처분의무를 규정한 동조 제2항(재처분의무)을 준용하지 아니하므로 거부처분의 집행정지를 부정하는 <부정설>
- ③ 원칙적으로는 거부처분의 집행정지를 부정하나, 예외적으로 갱신허가의 거부와 같이 신청인에게 어떠한 법적 이익이 있다고 인정되는 경우에는 집행정지를 인정할 실익이 있으므로 제한적으로 긍정하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

[행정소송법] 제30조 (취소판결등의 구속력)

- ① 처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 구속한다.
- ② 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다.

3) 판례

판례는 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 없었던 것과 같은 즉, 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고, 행정청에게 신청에 따른 처분을 할 의무가 생기는 것은 아니므로 부정하는 <부정설>의 입장을 취한다.

대법원 1995. 6. 21.자 95두26 결정

신청에 대한 거부처분의 효력을 정지하더라도 거부처분이 없었던 것과 같은 상태, 즉 거부처분이 있기 전의 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고 행정청에게 신청에 따른 처분을 하여야 할 의무가 생기는 것이 아니므로, 거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데 아무런 보탬이 되지 아니하여 그 효력정지를 구할 이익이 없다.

4) 소결

- ① 갱신허가 신청에 대한 거부처분과 같이 거부처분이 없었던 상태로 돌아가는 경우 이전 권리가 계속 존속될 수 있는 경우라면, 신청인에게 법적 이익이 인정될 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다.
- ② 예를 들어, (ㄱ) 인허가 등에 붙여진 기간이 갱신기간이라고 볼 수 있는 경우, (ㄴ) 외국인의 체류갱신허가의 거부처분 등을 들 수 있다.

04 가처분 가능성

1) 문제점

- ① 가처분이란 확정판결이 있을 때까지 발생할 수 있는 현저한 손해나 급박한 위험 등을 막기 위해 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하는 것을 목적으로 하는 가구제 수단을 말한다([민사집행법] 제300조).
- ② 행정소송법에는 가처분에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않아 민사집행법의 가처분에 관한 규정을 **준용**할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① [행정소송법]에 가처분에 관한 명문의 규정이 없고, 집행정지제도는 민사집행법의 가처분에 대한 **특별규정**에 해당하며, 현행 우리 법제하에서 **의무이행소송**이 인정되지 않으므로 준용할 수 없다는 <부정설>
- ② 실효성 있는 국민의 권리구제를 도모하고, [행정소송법] 제8조 제2항에 의하여 준용할 수 있다는 <긍정설>
- ③ 수익적 행정행위에 대한 거부처분의 효력을 잠정적으로 배제할 필요가 있는 경우와 같이 집행정지제도를 통해서 실효적인 권리구제가 되지 않는 예외적인 경우에는 준용할 수 있다는 <절충설>이 있다.

[행정소송법] 제8조 (법적용예)

- ② 행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 [법원조직법]과 [민사소송법] 및 [민사집행법]의 규정을 준용한다.

3) 판례

판례는 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

4) 소결

- ① 행정소송법에서 가구제 수단으로서 집행정지제도를 규정하고 있는데, 이는 민사집행법상의 가처분제도를 배제하는 특별 규정으로 볼 수 있다.
- ② 또한 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하지 않은 상태를 고려할 때 부정설이 타당하다.
- ③ 다만, 국민의 권리보호 확대를 위해 입법론적으로는 가처분제도의 도입이 필요하다.

CASE

甲은 2014. 3월경 감정평가사 자격을 취득한 후, 2015. 9. 2.부터 2017. 8. 3.까지 '乙감정평가법인'의 소속 감정평가사였다. 또한 甲은 2015. 7. 7.부터 2017. 4. 30.까지 '수산업협동조합 중앙회(이하 '수협'이라 함)'에서 상근 계약직으로 근무하였다. 관할 행정청인 국토교통부장관 A는 甲이 위와 같이 수협에 근무하면서 일정기간 동안 동시에 乙감정평가법인에 등록하여 소속을 유지하는 방법으로 감정평가사 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다고 봄이 상당하여, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 '감정평가법'이라 함) 제27조가 규정하는 명의대여 등의 금지 또는 자격증 부당행사 금지에 위반하였다는 것을 이유로 국토교통부장관 A는 甲에 대하여 3개월간의 업무정지 징계 처분을 하였고, 甲은 당해 처분이 위법하다고 보고 관할법원에 취소소송을 제기하였다.

물음) 이 취소소송의 계속 중 국토교통부장관 A는 당해 징계처분의 사유로 감정평가법 제27조의 위반사유 이외에, 징계처분 당시 甲이 국토교통부 장관에게 등록을 하지 아니하고 감정평가업무를 수행하였다는 동법 제17조의 위반사유를 추가하는 것이 허용되는가? [29회 문1]

01 의의

- ① 처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상 근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다.
- ② 처분사유의 추가·변경은 **소송경제 및 분쟁의 일회적 해결**을 위해 그 취지가 인정되며, 원고의 방어권 보장과 이유제시제도의 취지를 고려하여 일정한 한계 내에서 이루어진다.
- ③ 행정소송법에 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 인정되며, **대법원규칙**(법규명령)에 규정되어 있다.

02 구별개념

- ① 처분사유의 추가·변경은 처분의 동일성(소송물)을 전제로 하므로 처분변경으로 인한 소의 변경(행정소송법 제22조)과도 다르다.
- ② 처분사유의 추가·변경은 처분시에 이유제시가 되었으나 소송계속 중에 처분시에 이미 존재하였지만 처분사유로 하지 않았던 처분사유를 추가·변경하는 것이라는 점에서, 처분시에 이유제시가 되지 않았거나 불충분하여 이를 사후에 보완함으로써 그 하자를 치유하는 처분이유의 사후제시와는 구별된다.

03 인정 여부

1) 문제점

행정소송법은 처분사유의 추가·변경에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않아 행정소송 계속 중에 처분사유의 추가·변경이 인정될 수 있는지에 대한 견해가 대립한다.

2) 학설

- ① 처분사유의 추가·변경을 거부하여도 행정청은 새로운 사유를 들어 새로운 처분을 할 수 있으므로 분쟁의 일회적 해결과 소송경제 측면에서 추가·변경을 인정하는 <긍정설>
- ② 처분사유의 추가·변경을 인정하면 처분의 상대방은 예기치 않은 불이익을 받을 수 있으므로 부정하는 <부정설>
- ③ 소송경제와 원고의 방어권 보장을 조화시켜 제한적으로 허용하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

- ① 판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.
- ② 다만, 처분상대방이 명시적으로 동의한 경우에는 기본적 사실관계의 동일성과 무관하게 허용된다고 보았다.

대법원 1992. 2. 14. 선고 91누3895

행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있을 뿐, 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로서 주장함은 허용되지 아니한다.

4) 소결

- ① 처분사유의 추가·변경을 부정하면 당해 처분이 취소되더라도 처분청은 다른 사유를 들어 새로운 재처분을 할 수 있으므로 소송경제 측면에서 타당하지 않다.
- ② 따라서 소송경제와 원고의 방어권을 보장을 조화시켜 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 제한적으로 처분사유의 추가·변경을 긍정함이 타당하다.

04 인정 요건

1) 시간적 범위

(1) 추가·변경사유의 기준시

- ① 취소소송에서 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 <처분시설>에 따르면 처분시에 객관적으로 존재하였던 사유만이 처분사유의 추가·변경의 대상이 된다.
- ② 다만, 판결시설에 따르면 판결시까지의 사유도 처분사유의 추가·변경의 대상이 될 수 있다고 볼 수 있으나, 이는 판결의 지체 여부에 따라서 판결의 내용이 달라질 수 있다는 문제가 있다.

(2) 추가·변경사유의 허용시점

처분사유의 추가·변경은 **사실심 변론종결시**까지만 허용된다.

대법원 1999. 8. 20. 선고 98두17043

행정청은 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 처분사유를 추가, 변경할 수 있다고 할 것이나 이는 사실심 변론종결시까지만 허용된다.

2) 객관적 범위

- ① 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위 내에서만 가능하다.
- ② 판례는 기본적 **사실관계가 동일**하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다고 보았다.
- ③ 또한 판례는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없다고 보았다.

대법원 2003. 12. 11. 선고 2001두8827

행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서, 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있고, 여기서 기본적 사실관계의 동일성 유무는 **처분 사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일**한지 여부에 따라 결정되며 이와 같이 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장하는 것이 허용되지 않는다.

대법원 2011. 5. 26. 선고 2010두28106

행정처분이 적법한지는 특별한 사정이 없는 한 처분 당시 사유를 기준으로 판단하면 되고, 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없으므로 이와 같은 경우에는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실에 대하여 처분 후 추가·변경한 법령을 적용하여 처분의 적법 여부를 판단하여도 무방하다. 그러나 처분의 근거 법령을 변경하는 것이 종전 처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름없는 경우에는 허용될 수 없다.

기본적 사실관계의 동일성을 인정한 판례

대판 2008.2.28. 2007두13791

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 제1항 제12호 소정의 “담합을 주도하거나 담합하여 입찰을 방해하였다.”는 사유와, ② 같은 항 제7호 소정의 ‘특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자’에 해당한다는 사유

대판 2004.11.26. 2004두4482

① 주택신축을 위한 산림형질변경허가신청에 대한 거부처분의 근거로 제시된 ‘준농림지역에서의 행위제한’이라는 사유와, ② 나중에 거부처분의 근거로 추가한 ‘자연경관 및 생태계의 교란, 국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요’라는 사유

대판 2019.10.31. 2017두74320

① 건축신고수리 반려처분 취소소송에서 “위 토지가 건축법상 도로에 해당하여 건축을 허용할 수 없다.”는 사유와, ② “위 토지가 인근 주민들의 통행에 제공된 사실상의 도로인데, 주택을 건축하여 주민들의 통행을 막는 것은 사회공동체와 인근 주민들의 이익에 반하므로 甲의 주택 건축을 허용할 수 없다.”는 사유

기본적 사실관계의 동일성을 부정한 판례

대판 1992.8.18. 91누3659

① 토석채취허가신청에 대한 반려처분의 사유인 “인근주민의 동의서를 제출하지 않았다.”는 사유와, ② “자연 경관이 훼손된다.”는 사유

대판 1999.3.9. 98두18565

① 입찰참가자격을 제한시킨 당초의 처분 사유인 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않은 사실과, ② 항고소소에서 새로 주장한 계약의 이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 준 사실

대판 1995.11.21. 95누10952

① 중고자동차매매업 허가신청에 대한 불허가처분의 사유인 “기존의 다른 공동사업장과의 거리제한규정에 저촉된다.”는 사유와, ② “최소 주차용지에 미달한다.”는 사유

대판 1999.8.20. 98두17043

① 이주대책대상자 선정신청의 거부 사유로서 ‘당해 사업지구 내 가옥소유자가 아니’라는 사유와, ② ‘이주대책 실시기간을 도과하였다’는 사유

I

취소소송의 심리

01 심리의 의미

- ① 판결을 내리기 위해 법원이 사건의 사실관계와 법률관계를 조사하고 판단하는 절차를 의미한다.
- ② 법원은 당사자들이 제출한 소송자료를 바탕으로 증거를 조사하고, 주장된 사실을 확정하며, 관련 법규를 적용하여 사건을 판단한다.

02 심리의 원칙 (당사자주의 원칙)

1) 당사자주의와 직권주의

- ① 심리에 관한 기본원칙으로는 소송절차의 주도권이 누구에게 있는지에 따라 당사자가 소송을 주도하는 당사자주의와 법원이 주도하는 직권주의로 나뉜다.
- ② 당사자주의는 다시 처분권주의와 변론주의로 구분된다.

2) 처분권주의

- ① 처분권주의는 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 그리고 소송 절차의 종결에 대한 주도권을 당사자에게 부여하는 원칙이다.
- ② 법원은 당사자의 신청이 있어야만 소송을 시작하거나 특정 사항에 대해 판결할 수 있으며, 당사자가 신청한 범위를 넘어서 판결할 수 없다.

3) 변론주의

- ① 변론주의는 소송의 기초가 되는 소송자료(사실과 증거)의 수집 및 제출 책임을 당사자에게 부여하고, 법원은 당사자가 제출한 자료만을 재판의 기초로 삼아야 한다는 원칙이다.
- ② 즉, 당사자가 주장하지 않은 사실이나 제출하지 않은 증거는 판결의 근거가 될 수 없으며, 법원이 직권으로 소송자료를 수집하거나 당사자에게 소송자료 제출을 지시할 수 없다.

4) 당사자주의 원칙

당사자주의를 원칙으로 하되, 행정소송은 민사소송과 달리 그 결과가 공익실현과 밀접한 관련이 있으므로 [행정소송법] 제26조에서 직권심리주의를 보충적인 소송원칙으로 인정하고 있다.

[행정소송법] 제26조 (직권심리)

법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.

03 심리의 내용

1) 소송요건심리

(1) 의의

- ① 소송요건심리란 제기된 소가 소송요건을 갖춘 것인지의 여부를 심리하는 것을 말한다.
- ② 요건심리결과 소송요건을 갖추지 못하면 소송은 각하된다.

(2) 소송요건의 존부의 판단

- ① 소송요건의 구비 여부는 법원에 의한 직권조사사항으로 당사자의 자백에 구속되지 않는다.
- ② 따라서 당사자의 주장이 없다고 하더라도 그 존부에 관하여 의심이 있는 경우에 법원은 이를 직권으로 밝혀야 한다.
- ③ 소송요건은 사실심 변론종결시까지 구비되어야 하고, 사실심 변론종결시는 물론 상고심에서도 존속하여야 한다.

2) 본안심리

- ① 본안심리란 요건심리의 결과 소송요건이 구비된 경우, 사건의 본안(예. 취소소송에서 처분의 위법여부)에 대해 실체적 심사를 하는 것을 말한다.
- ② 본안심리결과 청구가 이유 있다고 인정되면 인용판결을 하고, 이유가 없다고 인정되면 기각판결을 한다.

04 심리의 범위

1) 불고불리의 원칙

[행정소송법]에도 민사소송에서와 같이 원칙적으로 불고불리의 원칙이 적용되어, 법원은 소송제기가 없는 사건에 대하여 심리·재판할 수 없고, 소제기가 있는 사건에 대해서도 당사자의 청구범위를 넘어서 심리·재판할 수 없다.

2) 법률문제와 사실문제

- ① 법원은 행정사건을 심리함에 있어 소송의 대상이 된 처분의 법률문제 뿐만 아니라 사실문제에 대하여도 심리할 수 있다.
- ② 단, 법률심인 상고심은 하급심이 인정한 사실관계를 전제로 법률문제만을 심리·판단한다.

05 주장책임과 입증책임

1) 주장책임

- ① 변론주의하에서는 법원은 당사자가 주장하지 않은 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다.
- ② 따라서 당사자가 분쟁의 대상이 되는 주요사실을 변론에서 주장하지 않으면 그러한 사실이 없는 것으로 취급되어 불이익을 받게 되는 바, 이를 주장책임이라고 한다.
- ③ 행정소송에서도 변론주의를 기본구조로 하고 있으므로, 당사자에게 주장책임이 있다.

2) 입증책임

(1) 의의

입증책임이란 소송상 일정한 사실의 존부가 확정되지 않은 경우에 불리한 법적 판단을 받게 되는 당사자 일방의 불이익 또는 불이익의 위험을 말한다.

(2) 소송요건의 입증책임

소송요건은 법원의 직권조사사항이지만, 그 존부가 불분명한 경우에는 부적합한 소로 취급되어 원고에게 불이익하므로, 이에 대한 입증책임은 원고가 부담한다.

(3) 본안사항의 입증책임

- ① 본안인 처분의 적법성에 대한 입증책임은 피고인 행정청이 부담한다.
- ② 반면, 적극적 처분의 경우 권한장애·소멸사실, 소극적 처분의 경우 권한발생사실에 대해서는 원고에게 입증책임이 있다.

01 취소소송의 판결의 종류

- ① 판결이란 법원이 변론을 거쳐 구체적 사건에 대한 법의 판단을 선언하는 행위를 말한다.
- ② 취소소송의 종국판결에는
 - (ㄱ) 소송요건의 결여로 본안심리를 거부하는 판결인 각하판결,
 - (ㄴ) 원고의 청구가 이유 없다고 판단되는 경우에 원고의 청구를 배척하는 기각판결 및
 - (ㄷ) 원고의 청구가 이유 있음을 인정하여 처분등을 취소·변경하는 인용판결이 있다.

02 사정판결

CASE

A구청장은 E구역에 대해 재개발사업 시행 인가처분을 하였다. 그러나 이 지역은 재개발조합 설립 및 사업시행 인가를 위한 법정 동의 요건을 충족하지 못한 곳이었다. 이에 해당 재개발구역 내 토지소유자들이 처분의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 법원은 이 처분이 위법하여 취소사유에 해당한다고 판단하였다.

다만, 만약 해당 지역의 주거환경이 매우 열악하고 전체 소유자의 90% 이상이 재개발사업의 진행을 원하며, 재개발 사업의 공익적 목적에 비추어 볼 때 처분의 취소가 현저히 공공복리에 부합하지 않는다고 인정되는 경우, 법원이 내릴 수 있는 판결에 대해 설명하시오.

1) 의의

- ① 사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다.
- ② 사정판결은 법률적합성의 원칙의 예외로서 판례는 공공복리를 위해 엄격한 요건 하에서 제한적으로 인정되어야 한다고 본다.

[행정소송법] 제28조 (사정판결)

- ① 원고의 청구가 이유있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다. 이 경우 법원은 그 판결의 주문에서 그 처분등이 위법함을 명시하여야 한다.

2) 요건

- ① 사정판결의 요건으로는 (ㄱ) 원고의 청구가 이유 있다고 인정될 것, (ㄴ) 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 않을 것이 있다.
- ② 판례는 <현저히 공공복리에 적합하지 아니한가 여부>는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 그 적용여부를 판단하여야 한다고 본다.

3) 심리

사정판결은 법률적합성의 원칙의 예외이므로 피고인인 행정청이 주장 및 입증책임을 부담한다고 보는 견해가 있으나, 판례는 행정소송법 제26조(직권심리)를 근거로 당사자의 주장이 없더라도 **직권**으로 사정판결이 가능하다고 본다.

4) 위법성과 필요성 판단의 기준

처분의 위법성 여부는 **처분시**를 기준으로 판단하고, 공공복리를 위한 사정판결의 필요성은 사실심 변론종결시 (**판결시**)를 기준으로 판단한다.

5) 효과

- ① 법원은 판결의 주문에 위법함을 명시하여야 하고(행정소송법 제28조 제1항 후문)
- ② 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도와 배상방법 그 밖의 사정을 조사하여야 하며(제2항)
- ③ 원고는 피고인 행정청이 속하는 국가 또는 공공단체를 상대로 손해배상, 제해시설의 설치 그밖에 적당한 구제방법의 청구를 당해 취소소송등이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다(제3항).

6) 무효등확인소송에서 사정판결 가능성

(1) 문제점

- ① 행정소송법 제38조 제1항은 무효등확인소송의 준용규정을 나열하고 있는데, 동법 제28조의 사정판결을 준용하고 있지 않다.
- ② 따라서 무효등확인소송에서 사정판결이 가능한지가 문제된다.

(2) 학설

- ① 무효나 취소는 하자의 정도의 차이에 불과하고 그 구별이 상대적이므로 공익성을 존중하여 사정판결을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과
- ② 법문언상 준용규정이 없으므로 인정될 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

(3) 판례

판례는 당연무효의 행정처분을 소송목적물로 하는 행정소송에서는 존치시킬 효력이 있는 행정행위가 없기 때문에 행정소송법 제28조 소정의 사정판결을 할 수 없다고 하여 **<부정설>**의 입장을 취한다.

(4) 소결

- ① 사정판결은 법치주의의 예외적 조치에 해당하므로 그 해석에 있어 엄격성이 요구된다.
- ② 따라서 준용 규정이 없음을 근거로 판례의 태도와 같이 무효등확인소송에서 사정판결은 부정함이 타당하다.

CASE

국토교통부장관은 감정평가사 甲에 대하여 업무정지 6개월의 징계처분을 하였다. 이에 불복한 甲이 징계처분취소 소송을 제기하였는바, 법원은 해당 징계처분을 업무정지 3개월의 징계처분으로 감경하는 판결을 할 수 있는지에 관하여 설명하시오. (35회 문3번 변형)

1) 문제점

- ① 행정소송법 제4조의 1호에서 취소소송을 <행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송>이라고 정의하고 있다.
- ② 이에 <변경>의 해석과 관련하여 법원이 일부취소판결을 할 수 있는지가 문제 된다.

2) 행정소송법 제4조 1호의 <변경>의 의미

(1) 학설

- ① 행정소송법 제4조 1호의 변경을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분등을 취소하고 새로운 처분을 내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과
- ② 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 변경은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 있다.

(2) 판례

판례는 <변경>을 소극적 변경, 즉 일부취소를 의미하는 것으로 보아 적극적으로 처분을 변경하는 판결은 인정되지 않는다고 본다.

(3) 검토

생각건대, 적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지 않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상 <변경>을 **소극적 변경**으로서 **일부취소**를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

3) 일부취소의 가능여부에 따른 판결

(1) 일부취소가 가능한 경우

- ① 처분의 일부취소가 가능한지 여부는 일부취소의 대상이 되는 부분의 **분리가능성**에 따라 결정된다.
- ② 외형상 하나의 행정처분에 해당하더라도 **가분성**이 있거나 그 처분 대상의 일부가 **특정**될 수 있다면 그 일부만의 취소가 가능하다.
- ③ 일부취소가 가능한 경우에는 법원은 원칙적으로 전부취소를 하여서는 안되며 일부취소를 하여야 한다.
- ④ 예를 들어, 조세부과처분과 같은 금전부과처분이 기속행위인 경우, 당사자가 제출한 자료에 의해 정당한 세액을 산출할 수 있는 경우에는 적법한 세액을 초과한 부분만의 취소가 가능하다.

과세처분취소소송의 처분의 적법 여부는 과세액이 정당한 세액을 초과하느냐의 여부에 따라 판단되는 것으로서 당사자는 사실심 변론종결시까지 객관적인 조세채무액을 뒷받침하는 주장과 자료를 제출할 수 있고, 이러한 자료에 의하여 적법하게 부과될 정당한 세액이 산출되는 때에는 그 정당한 세액을 초과하는 부분만 취소하여야 할 것이고 전부를 취소할 것은 아니다.

(2) 일부취소가 불가능한 경우(전부취소)

- ① 과징금부과처분과 같이 재량행위의 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로, 법원의 일부취소는 인정되지 않는다.
- ② 따라서 법원은 전부취소를 하여야 하고, 처분청은 재량권을 행사하여 다시 적정한 처분을 해야 한다.
- ③ 다만, 조세부과처분과 같은 금전부과처분이 기속행위라 할지라도 당사자가 제출한 자료에 의해 적법하게 부과될 부과금액을 산출할 수 없는 경우에는 법원이 처분청의 역할을 할 수 없으므로 금전부과처분의 일부취소가 인정되지 않는다.

행정청이 영업정지처분을 함에 있어서 그 정지기간을 어느 정도로 할 것인지는 행정청의 재량권에 속하는 사항인 것이며, 다만 그것이 공익의 원칙이나 평등의 원칙 또는 비례의 원칙등에 위반하여 재량권의 한계를 벗어난 재량권 남용에 해당하는 경우에만 위법한 처분으로서 사법심사의 대상이 되는 것이나, 법원으로서의 영업정지처분이 재량권 남용이라고 판단될 때에는 위법한 처분으로서 그 처분의 취소를 명할 수 있을 뿐이고, 재량권의 한계내에서 어느 정도가 적정한 영업정지 기간인지를 가리는 일은 사법심사의 범위를 벗어난다.

01 기판력 (실질적 확정력) [★★]

CASE

국토교통부장관은 감정평가업자 甲에 대하여 법령상 의무 위반을 이유로 6월의 업무정지처분을 하였다.
 甲은 업무정지처분취소소송을 제기하였으나 기각되었고 동 기각판결은 확정되었다.
 이에 甲은 위 처분의 위법을 계속 주장하면서 이로 인한 재산상 손해에 대해 국가배상청구소송을 제기하였다.
 이 경우 업무정지처분취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는 영향을 설명하시오. (22회 문2 변형)

1) 의의

기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고, 법원도 이에 모순*저촉되는 판단을 할 수 없는 판결의 구속력을 말한다.

2) 취지

기판력은 소송절차의 반복과 모순된 재판의 방지라는 법적 안정성의 요청에 따라 일반적으로 인정되고 있는 판결의 효력이다.

3) 근거

[행정소송법]은 기판력에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않지만, [행정소송법] 제8조 제2항에 의하여 [민사소송법]의 관련 규정이 준용된다.

4) 적용 판결

기판력은 인용판결뿐만 아니라 기각판결에도 인정된다.

5) 효력범위

(1) 주관적 범위

- ① 기판력은 당해 소송의 당사자 및 당사자와 동일시할 수 있는 승계인, 소송에 참가한 제3자에게 미친다.
- ② 그러나 당해 소송과 관계없는 제3자에게는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- ① 기판력은 판결의 주문에 표시된 <소송물>에 관한 판단에만 미치고, 판결이유에서 제시된 구체적인 위법사유에 관한 판단에는 미치지 않는다.
- ② 취소소송의 소송물을 통설 및 판례와 같이 <위법성 일반>으로 보게 되면, 취소소송의 기판력은 인용판결의 경우에는 당해 처분이 위법하다는 점에, 기각판결의 경우에는 당해 처분이 적법하다는 점에 미친다.
- ③ 다만, 사정판결은 기각판결의 일종이지만, 처분의 위법성을 주문에 명시하므로 당해 처분이 위법하다는 점에 기판력이 생긴다.

※ 보충자료 - 소송물의 개념

1. 소송물의 의의

- ① 소송물이란 **심판의 대상**이 되는 **소송상의 청구**를 말한다.
- ② 소송물은 소송의 기본단위로서 소의 병합, 처분사유의 추가*변경, 소의 변경을 결정하는 경우와 기판력의 **객관적 범위**를 정함 등에 있어서 의미를 갖는다.
- ③ 취소소송의 소송물을 어떻게 바라보는가에 대해 이견이 있다.

2. 학설

1) 처분의 위법성 일반으로 보는 견해 (다수설, 판례)

- ① 취소소송의 소송물을 처분의 **위법성 일반**으로 보는 견해이다.
- ② 이 견해에 의하면 개개의 위법사유에 관한 주장은 단순한 공격방어권에 지나지 않는다고 보며, 취소소송에서 판결의 기판력은 처분의 위법 또는 적법 일반에 대하여 미친다고 한다.
- ③ 이 견해에 의하면 취소소송에서 기각판결을 받은 경우 다른 위법사유를 들어 취소소송을 제기할 수 없을 뿐만 아니라 다른 위법사유를 들어 국가배상청구소송을 제기할 수 없게 된다.

2) 처분의 개개의 위법사유라고 보는 견해

- ① 이 견해에 의하면 취소소송의 판결의 기판력은 **개개의 위법사유**에 한정된다.
- ② 따라서 청구기각판결의 경우에 원고는 후소에서 전소에서 주장한 것과 다른 위법사유를 주장할 수 있게 된다.
- ③ 이 견해에 대해서는 분쟁의 일회적 해결을 기할 수 없다는 비판이 제기된다.

3) 주관소송적 관점설

취소소송의 소송물을 <대상이 되는 처분을 통하여 자신의 권리가 침해되었다는 원고의 법적 권리주장>이라고 보는 견해이다.

4) 형성소송적 관점설

취소소송의 형성소송적 성격을 강조하면서 소송물을 <행정처분으로 인하여 생긴 위법상태의 배제를 구하는 원고의 주장>으로 보는 견해이다.

3. 판례

판례는 행정소송의 기판력은 행정처분의 위법·적법에 미친다고 하였다.

4. 검토

생각건대, 분쟁의 일회적 해결 측면에서 행정행위 **위법성 일반**을 소송물로 보는 다수의 견해와 판례 입장이 타당하다고 본다.

(3) 시간적 범위

- ① 기판력은 **사실심 변론종결시**를 기준으로 발생한다.
- ② 따라서 사실심 변론종결시까지 제출할 수 있었던 공격방어 방법은 후소에서 제출불가하나, 변론종결 후 새로운 사유가 발생한 경우에는 기판력이 미치지 않는다.

6) 기판력이 작용하는 사례

(1) 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우

동일한 처분에 대하여 **절차적 하자**를 이유로 취소소송을 제기하였으나 기각당한 후 **내용상 위법**을 이유로 다시 취소소송을 제기하는 경우

(2) 전소와 후소가 모순되는 관계인 경우

취소소송이 기각 확정되어 처분의 적법성에 기판력이 발생하였는데, 처분의 위법을 주장하며 다시 **무효확인소송**을 제기한 경우

(3) 전소가 후소의 선결문제인 경우

- ① 행정처분에 대한 **취소소송**이 확정되고, 동 처분의 위법을 전제로 **국가배상청구소송**을 제기한 경우(후술)
- ② 과세처분에 대한 **취소소송**이 확정되고, 동 처분의 무효를 전제로 **부당이득반환청구소송**을 제기한 경우

7) 취소소송의 기판력이 국가배상청구에 미치는지 여부

(1) 문제점

- ① 취소소송의 기판력이 그 후에 제기된 국가배상청구소송에 미치는지가 문제된다.
- ② 이는 취소소송의 위법성 개념이 국가배상청구소송과 동일한지 여부와 관련이 있다.

(2) 학설

a. 기판력 부정설

양 소송의 위법성은 서로 다른 개념이므로 취소소송의 판결의 기판력은 국가배상청구소송에 영향을 미치지 않는다는 견해이다.

b. 기판력 긍정설

양 소송의 위법성은 동일하므로 취소소송의 판결의 기판력은 국가배상청구소송에 영향을 미친다고 보는 견해이다.

c. 제한적 긍정설

국가배상청구소송의 위법개념을 취소소송의 위법개념보다 넓은 개념으로 보면서, 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치지만, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 본다.

(3) 판례

- ① 취소소송의 확정판결의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 여부와 관련하여 판례의 입장은 분명하지 않다.
- ② 다만, 대법원은 처분등이 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의해 당해 처분 등이 곧바로 불법행위를 구성하는 것이 아니라고 본다.

(4) 검토

국가배상청구소송의 목적은 위법한 공무원의 행위로 인한 국민의 손해를 금전적으로 배상하는데 있으므로 국가배상청구소송에서의 위법성을 취소소송보다 넓게 보는 제한적 기판력 긍정설이 타당하다.

CASE

A도 B시에 위치한 X산과 Y호수 일대는 수려한 자연경관을 자랑하고 있어 많은 사람들이 방문하는 명소이다. 甲은 X산과 Y호수의 자연경관을 누릴 목적으로 그 인근으로 최근 이주한 주민으로서 이 일대를 공원으로 조성할 것을 내용으로 하는 도시관리계획의 입안을 B시장에게 제안하였다. B시장은 甲의 제안을 거부하는 통보를 하였다. 이에 甲은 도시관리계획 입안 제안에 대한 B시장의 거부처분 취소를 구하는 행정소송을 제기하였고, 법원은 이익형량에 하자가 있어 위법하다고 판단하여 인용 판결을 내렸다. 이후 B시장이 새로운 이익형량을 하여 甲의 제안을 다시 거부할 경우, 이러한 재처분이 기속력에 반하는지 여부를 검토하시오. (2024년 변시 변형)

1) 의의 및 취지

- ① 기속력이란 **확정판결의 취지**에 따라 행동하도록 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 구속하는 효력을 말한다.
- ② 행정청이 판결에 따르지 않고 동일한 행위를 반복하거나 거부처분이 취소된 경우에도 판결의 취지에 따르는 처분을 하지 않는 경우에는 **판결의 실효성을 확보**할 수 없으므로, 행정소송법은 기속력을 규정하여 행정청에게 판결의 취지에 따라야 할 실체법상의 의무를 인정한 것이다.

[행정소송법] 제30조 (취소판결등의 기속력)

- ① 처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.
- ② 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다.

2) 적용판결

- ① 기속력은 **인용판결**에 한하여 인정된다.
- ② 따라서 취소소송의 기각판결이 있는 후에도 처분청은 당해 처분을 직권으로 취소할 수 있다.

3) 법적성질

- ① 기속력의 법적성질을 (ㄱ)기판력과 동일하다고 보는 <기판력설>이 있으나, (ㄴ)기속력은 취소판결의 실효성을 확보하기 위해 행정소송법에서 특별히 인정하는 효력이라고 보는 <특수효력설>이 통설 및 판례의 입장이다.
- ② 판례는 과거 기속력과 기판력이라는 용어를 구별하지 않고 사용한 판례도 있었으나, 최근에는 양자를 명확히 구별하고 있다.
- ③ 생각건대, 기판력은 모든 본안판결의 효력이며 소송법상 효력이나, 기속력은 취소판결(인용판결)에서의 효력이며 실체법상 효력이므로 양자를 다르게 보는 <특수효력설>이 타당하다.

4) 범위

(1) 주관적 범위

- ① 기속력은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다(행정소송법 제30조 제1항).
- ② 여기서 <관계 행정청>이란 당해 판결에 의해 취소되는 처분등을 기초로 하여 그와 관련되는 처분이나 부수되는 행위를 할 수 있는 모든 행정청을 말한다.

(2) 객관적 범위

- ① 기속력은 주로 판결의 실효성 확보를 위하여 인정되는 효력으로서 판결의 주문뿐만 아니라 판결이유 중 설시된 **개개의 위법사유**에 미친다.
- ② 기본적 사실관계가 다른 처분사유에 대해서는 기속력이 미치지 않는다.
- ③ 따라서 행정청이 기본적 사실관계가 동일하지 않은 별도의 새로운 사유를 들어 동일한 내용의 처분을 다시 하는 것은 허용된다.

(3) 시간적 범위

- ① 기속력의 시간적 범위는 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 처분시설에 따라 **처분시**에 존재하던 사유에만 기속력이 미친다고 보는 것이 통설 및 판례의 태도이다.
- ② 따라서 처분의 취소판결이 있은 후 새로운 처분사유(법령 및 사실상태)에 의해 동일한 내용의 처분을 하더라도 이는 기속력에 반하지 않는다.

대법원 1998. 1. 7.자 97두22 결정

행정처분의 적법 여부는 그 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우에는 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있으며 그러한 처분도 행정소송법 제30조 제2항에 규정된 재처분에 해당된다.

대판 2016.03.24., 2015두48235

확정판결의 당사자인 처분 행정청은 종전 처분 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 처분을 할 수 있고, 새로운 처분의 처분사유가 종전 처분의 처분사유와 기본적 사실관계에서 동일하지 않은 다른 사유에 해당하는 이상, 처분사유가 종전 처분 당시 이미 존재하고 있었고 당사자가 이를 알고 있었더라도 이를 내세워 새로이 처분을 하는 것은 확정판결의 기속력에 저촉되지 않는다.

5) 내용

(1) 반복금지의무 (「행정소송법」 제30조 제1항)

- ① 반복금지효란 취소판결이 확정되면 행정청 및 관계행정청은 판결의 취지에 저촉되는 처분을 하여서는 안된다는 구속을 받는 것을 말한다.
- ② 즉, 행정청은 동일한 사실관계 하에서 동일한 당사자에 대하여 동일한 내용의 처분등을 반복해서는 안 되며, 이를 위반한 처분은 하자가 중대하고 명백하여 **당연무효**가 된다.
- ③ 다만, 취소된 처분의 취소사유와 **기본적 사실관계의 동일성**이 없는 다른 처분사유를 들어 동일한 내용의 처분을 하여도 이는 동일한 처분이 아니므로 기속력에 반하지 않는다.
- ④ 또한, 판례는 **절차나 형식의 위법**을 이유로 처분등이 취소되는 판결이 확정된 경우에는 행정청이 판결에 적시된 절차나 형식의 위법사유를 보완하여 다시 새로운 처분을 하더라도 이는 기속력에 저촉되지 않는다고 본다.

(2) 재처분의무 (「행정소송법」 제30조 제2항)

- ① 행정소송법 제30조 제2항에 의거 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.
- ② 재처분의무는 판결의 취지를 존중하면 되는 것이므로 **반드시 원고가 신청한 내용대로 재처분을 해야 하는 것은 아니다**.
- ③ 재처분의무는 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다(동조 제3항).

(3) 결과제거의무 (원상회복의무)

- ① 취소판결이 확정되면 행정청은 취소된 처분으로 인해 초래된 위법상태를 제거해야 할 결과제거의무(원상회복의무)를 진다.
- ② 결과제거의무에 대한 명문의 규정은 없지만 일반적으로 행정소송법 제30조 제1항의 해석상 인정된다고 본다.

구 분	기속력	기판력
규정	[행정소송법] 제30조	[민사소송법]규정을 준용
취지	판결의 실효성 확보	법적 안정성 확보
적용 판결	인용판결에서만 인정	모든 판결
주관적 범위	처분청 및 관계행정청	전소의 당사자, 후소법원
객관적 범위	주문 및 이유 (후속처분에도 작용) (개개의 위법사유까지 미침)	주문 (당해 처분에 한정) (처분의 위법성 일반에 미침)
시간적 범위	처분시까지 존재하였던 사유에 대해서만 발생	사실심 변론종결시를 표준
위반효과	기속력을 위반한 후속처분은 무효 (간접강제의 대상)	기판력을 위반한 판결을 위법 (상소사유)

03 기타의 효력

1) 불가변력

판결이 일단 확정되면 법원 자신도 이를 취소·변경할 수 없게 되는데, 이를 판결의 불가변력이라 한다.

2) 불가쟁력 (형식적 확정력)

불가쟁력이란 당사자가 상소를 포기하거나, 상소제기기간의 경과 또는 모든 심급을 거친 경우 등으로 인해 판결에 불복하는 자가 더 이상 판결을 다룰 수 없게 되는 구속력을 의미한다.

3) 형성력

- ① 판결의 형성력이란 법원의 판결에 따라 법률관계의 발생·변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다.
- ② 취소판결의 형성력은 형성효, 소급효 및 대세효로 이루어진다. 즉, 취소판결은 계쟁처분의 효력을 소급적으로 상실시키며 제3자(대세효)에 대하여도 효력이 있다.
- ③ 처분등에 대한 취소판결이 확정되면 처분청의 별도의 취소를 기다릴 것 없이 처분등이 당연히 <소급적>으로 효력을 상실하게 된다.
- ④ 형성력은 행정처분을 취소하는 인용판결에만 인정되고, 기각판결에는 인정되지 않는다.
- ⑤ 행정소송법 제29조 제1항의 해석에 의해 인정된다고 본다.

[행정소송법] 제29조 (취소판결등의 효력)

- ① 처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다.

4) 대세효 (제3자효)

- ① 취소판결의 취소의 효력은 소송에 관여하지 않은 제3자에 대하여도 미치는데 이를 <대세효>라고 한다.
- ② 대세효를 인정한 취지는 행정상 법률관계를 통일적으로 규율하고자 하는데 그 기본적인 취지가 있다.
- ③ 취소판결의 효력이 제3자에게도 미침으로 인하여 제3자가 불측의 손해를 입을 수 있으므로 행정소송법은 <제3자의 소송참가(제16조)>와 <재심청구제도(제31조)>를 인정하고 있다.

CASE

사업시행자 A는 토지보상법 4조에 따른 학교건립사업을 하기 위해 국토교통부장관에게 토지보상법상 사업인정요건을 갖춰 사업인정 신청을 하였으나 국토교통부장관은 공공성이 없다는 사유로 거부하였다. 이에 A는 거부처분 취소소송을 제기하였고, 인용판결을 받았다. 그러나 상당한 기간이 지나도록 국토교통부장관이 사업인정을 해주지 않고 있다. 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 판결의 실효성 확보를 위한 행정소송법상 제도에 대해 설명하시오.

01 의미 및 취지

- ① 간접강제란 행정청이 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 법원이 일정한 절차에 따라 행정청에게 배상을 명하는 제도를 말한다.
- ② 간접강제는 판결의 **실효성 확보**에 그 취지가 인정된다.

[행정소송법] 제34조 (거부처분취소판결의 간접강제)

- ① 행정청이 제30조제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니하는 때에는 제1심 수소법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다.

02 요건

- ① 간접강제의 요건으로는 (ㄱ) 거부처분에 대한 취소판결이 확정될 것과 (ㄴ) 처분청이 거부처분취소판결의 취지에 따른 재처분을 하지 않을 것이 있다.
- ② 여기에서 <재처분을 하지 않은 것>에는 아무런 재처분을 하지 않은 것뿐만 아니라, 재처분이 기속력에 반하여 당연무효가 된 것도 포함된다.

03 절차

- ① 간접강제는 (ㄱ) 당사자가 제1심 수소법원에 간접강제를 신청하고, (ㄴ) 법원은 간접강제의 신청이 이유 있다고 인정함으로써 간접강제결정을 한다.
- ② 간접강제결정으로써 법원은 상당 기간을 정하고 그 기간 내에 이행하지 아니하면 지연기간에 따라 일정한 배상을 명하거나, 즉시 손해배상 할 것을 명할 수 있다.

04 배상금의 성질 (심리적 강제수단)

- ① 판례는 간접강제는 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서 재처분 지연에 대한 제재나 손해배상은 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것이라고 보았다.
- ② 따라서 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다고 본다.

05 무효등확인판결에서 간접강제 가능성

1) 문제점

- ① 간접강제는 거부처분취소소송에서 인정되고 있고, 부작위위법확인소송에 준용되고 있다.
- ② 그러나 무효등확인판결의 경우 간접강제를 준용하는 규정이 없어 간접강제가 적용될 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 간접강제를 준용하는 규정이 없으므로 부정하는 <부정설>
- ② 행정소송법 제34조 제1항에서 <제30조 제2항의 규정에 의한 처분을 하지 아니하는 때>라고 규정하고 있음을 근거로 거부처분이 당연무효인 경우에도 간접강제가 허용된다고 보는 <긍정설>이 있다.

3) 판례

판례는 무효등확인판결이 간접강제를 준용하지 않으므로 부정하는 입장에 있다.

4) 소결

무효등확인소송에서도 행정청의 재처분의무 위반에 대한 실효성 확보를 위해 간접강제가 적용될 수 있다고 보는 것이 타당하다.

01 관련청구소송의 병합**[행정소송법] 제10조 (관련청구소송의 이송 및 병합)**

- ① 취소소송과 다음 각 호의 1에 해당하는 소송(이하 “관련청구소송”이라 한다)이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우에 관련청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다.
1. 당해 처분등과 관련되는 손해배상·부당이득반환·원상회복등 청구소송
 2. 당해 처분등과 관련되는 취소소송
- ② 취소소송에는 사실심의 변론종결시까지 관련청구소송을 병합하거나 피고외의 자를 상대로 한 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다.

1) 의의 및 취지

- ① [행정소송법]상 관련청구소송의 병합이란 취소소송, 무효등확인소송, 부작위위법확인소송, 당사자소송(이하 취소소송 등)에 당해 취소소송 등과 관련이 있는 청구소송을 병합하여 제기하는 것을 말한다.
- ② 관련청구소송의 병합은 **소송경제**·**도모**와 **판결간 모순방지** 등에 취지가 있으며, 행정소송법 제10조, 민사소송법 제253조(소의 객관적 병합) 등에 근거가 있다.

2) 병합의 종류**(1) 주관적·객관적 병합**

- ① 소의 병합에는 주관적 병합과 객관적 병합이 있다.
- ② 주관적 병합이란 공동소송을 말하고, 객관적 병합은 청구의 병합이라고도 한다.

(2) 청구의 병합의 종류

청구의 병합의 종류에는

- (ㄱ) 양립하는 여러 개의 청구를 병렬적으로 병합하는 **단순병합**(모든 청구에 대해 법원의 판결이 필요),
- (ㄴ) 여러 개의 청구 가운데 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판을 바라지 않은 형태의 **선택적 병합** 및
- (ㄷ) 양립되지 않는 청구를 주위적·예비적으로 병합하는 **예비적 병합**이 있다.

대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두6773

잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없는 관계에 있어 선택적 병합이 불가능한데 원심이 위 두 청구의 선택적 병합 청구를 허가한 것 또한 잘못이다.

3) 요건

- (ㄱ) 취소소송 등에 병합할 것,
- (ㄴ) 각 청구소송이 적법할 것,
- (ㄷ) 관련청구소송이 병합될 것,
- (ㄹ) 주된 취소소송 등이 사실심 계속 중일 것,
- (ㄴ) 병합의 형태가 소송법상 허용되어야 한다.

CASE

A시에서는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한다는 방침을 결정하고, A시 시장은 X, Y, W토지의 개별공시지가 산정의 기초가 된 P토지의 표준지공시지가와 지가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준 가격을 내부적으로 결정하고 중앙부처와 협의 중이다. X토지 소유자인 甲은 더 많은 보상금을 받기 위해 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 당해 국토교통부장관을 피고로 취소소송을 제기하였다. 이 취소소송에 P토지 소유자인 丙이 소송에 참가할 수 있는지 검토하시오. (25회 문2 변형)

1) 의의

- ① 행정소송법 제29조는 처분등을 취소하는 **확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있다**고 규정한다.
- ② 소송참가란 타인간 소송 계속 중 당사자가 아닌 제3자가 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 지위에 영향이 미치게 될 경우, 자신의 이익을 위하여 소송절차에 참가하는 것을 말한다.

2) 제3자의 소송참가

[행정소송법] 제16조 (제3자의 소송참가)

- ① 법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에는 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제3자를 소송에 참가시킬 수 있다.
- ② 법원이 제1항의 규정에 의한 결정을 하고자 할 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 신청을 한 제3자는 그 신청을 각하한 결정에 대하여 즉시항고할 수 있다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 소송에 참가한 제3자에 대하여는 민사소송법 제67조의 규정을 준용한다.

(1) 의의 및 취지

- ① 제3자의 소송참가란 소송의 결과에 의해 권익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 그 제3자를 소송에 참가시키는 제도를 말한다.
- ② **제3자의 권익을 보호**하려는 데 그 취지가 인정된다.

(2) 요건과 절차

- ① 제3자의 소송참가의 요건으로는 (ㄱ) 타인간의 취소소송 등이 계속 중일 것, (ㄴ) 소송결과에 따라 **법률상 이익의 침해**를 받을 제3자일 것이 있다.
- ② 여기에서 <제3자>란 소송당사자 이외의 자를 말하고, <이익의 침해>는 법률상 이익을 말하며, 단순한 사실상의 이익이나 경제상의 이익은 포함되지 않는다.
- ③ 법원은 소송의 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의해 참가결정을 하고, 법원이 결정을 하는 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을 들어야 한다.
- ④ 제3자는 각하결정에 대해 즉시항고를 할 수 있다.

(3) 소송참가인의 지위

- ① 참가인에게는 민사소송법 제67조를 준용하므로 참가인의 지위는 **공동소송적 보조참가인**과 유사한 지위를 가진다는 것이 일반적인 견해이다.
- ② 따라서 소송행위 중 참가인과 피참가인에게 **유리한 행위(예 상소)**는 1인이 하여도 전원에 대하여 효력이 생기는 반면, **불리한 행위(예 상소포기)**는 전원이 함께 하지 않는 한 효력이 없다.
- ③ 참가인은 현실적으로 소송행위를 하였는지 여부에 관계없이 **판결의 효력을 받는다**.

(4) 제3자의 재심청구(행정소송법 제31조)

a. 의의

처분 등을 취소하는 판결에 의하여 권리 또는 이익의 침해 받은 제3자가 자기에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못함으로써 판결의 결과에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법을 제출하지 못한 때에는 이를 이유로 확정된 종국판결에 대하여 재심의 청구를 하는 것을 말한다.

b. 요건

- ① 제3자의 의한 재심청구는 확정판결이 있음을 안 날로부터 30일 이내, 판결이 확정된 날로부터 1년 이내에 제기하여야 한다.(제31조 제2항)
- ② 재심청구기간은 불변기간이다.(제31조 제3항)
- ③ 행정소송법 제31조의 해석상 소송참가를 한 제3자는 판결 확정 후 행정소송법 제31조에 의한 재심의 소를 제기할 수 없다.

3) 행정청의 소송참가

[행정소송법] 제17조 (행정청의 소송참가)

- ① 법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다.

(1) 의의 및 취지

- ① 행정청의 소송참가란 **관계 행정청**이 다른 행정청의 행정소송에 참가하는 것을 말한다.
- ② 행정소송법 제17조에서 법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의해 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다고 규정하고 있다.
- ③ 처분청 외에 관계 행정청을 소송에 참여시켜 공격·방어방법을 제출할 수 있도록 함으로서 적정한 재판을 도모하는데 그 취지가 있다.

(2) 요건과 절차

- ① 행정청의 소송참가의 요건으로는 (ㄱ) 타인의 취소소송이 계속 중일 것, (ㄴ) 처분등과 관계있는 다른 행정청일 것 및 (ㄷ) 참가의 필요성이 있다.
- ② 행정청의 소송참가는 법원의 직권, 당사자 또는 당해 행정청의 신청에 의하여, 법원은 참가 여부를 결정하기 전에 당사자 및 행정청의 의견을 들어야 한다.

(3) 참가인의 지위

- ① 행정청의 소송참가는 민사소송법 제76조가 준용되므로 참가행정청은 **단순한 보조참가인**에 준하는 지위에서 소송을 수행하게 된다.
- ② 다만, 참가행정청은 피참가인의 소송행위와 저촉되는 소송행위는 할 수 없다.(보조역할에 불과)

03 소의 변경

1) 의의

- ① 소의 변경이란 소송 중에 원고가 소송의 대상인 청구를 변경하는 것을 말하며, **청구의 변경**이라고도 한다.
- ② 소의 변경 후에도 변경 전의 소송절차는 그대로 유지된다.

2) 종류

- ① [행정소송법]은 소의 변경과 관련하여 (ㄱ) 소 종류의 변경(제21조)과 (ㄴ) 처분변경으로 인한 소의 변경(제22조)의 두 가지를 규정하고 있다.
- ② [행정소송법] 제8조 제2항에 따라 [민사소송법]이 준용되므로 명문규정은 없으나 [민사소송법]에 따른 소변경도 가능하다.

3) 소 종류의 변경(제21조)

(1) 의의 및 취지

- ① 소의 종류의 변경이란 행정소송 사이에서 소의 종류 자체를 변경하는 것을 말한다.
- ② 이는 행정소송의 종류를 잘못 선택해서 초래되는 불이익으로부터 원고를 보호하며, 기존의 소송과정에서 얻은 자료를 새로운 소송에서 그대로 사용하게 하여 소송경제를 도모하는데 의미가 있다.
- ③ 소의 종류의 변경은 항고소송 사이에서 뿐만 아니라 항고소송과 당사자소송 사이에서도 인정된다.

(2) 종류

a. 항고소송 간의 변경

취소소송을 취소소송 외의 항고소송으로, 무효등확인소송을 취소소송으로, 부작위위법확인소송을 취소소송으로 변경하는 것이 가능하다.

b. 항고소송과 당사자소송간의 변경

취소소송이나 무효등확인소송을 당해 처분등에 관계되는 사무가 귀속되는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송으로 변경하거나, 당사자소송을 항고소송으로 변경하는 것이 가능하다.

(3) 요건

- ① 청구의 기초에 변경이 없을 것
- ② 소를 변경하는 것이 상당하다고 인정될 것
- ③ 변경의 대상이 되는 소가 사실심에 계속되어 있고, 사실심 변론종결 전일 것
- ④ 새로운 소가 적법할 것
- ⑤ 원고의 신청이 있을 것

(4) 효과

소의 변경을 허가하는 결정이 있게 되면, 새로운 소송(신소)은 이전의 소송(구소)이 처음 제기된 때 제기된 것으로 보며, 이전의 소(구소)는 취하된 것으로 본다.

4) 처분변경으로 인한 소의 변경(제22조)

(1) 의의

- ① 행정청이 소송의 대상인 처분을 소가 제기된 후 변경한 때에는 원고의 신청에 의하여 법원의 허가를 받아 새로운 처분으로 소를 변경하는 것을 말한다.
- ② 이는 소의 각하나 새로운 소의 제기라는 무용한 절차의 반복을 배제하여 간편하고도 신속하게 개인의 권익구제를 확보하기 위해 인정되는 제도이다.

(2) 요건

- ① 소송의 대상인 처분이 소가 제기된 후 행정청에 의하여 변경되어야 한다. 이러한 변경에는 형식적 변경과 실질적 변경이 있다.
- ② 형식적 변경 : 구처분과 동일한 내용의 처분 또는 구처분과 기초를 같이 하는 다른 처분으로 변경하는 경우
(예) 업무정지처분을 절차상 하자를 이유로 직권취소한 이후 동일한 내용의 업무정지처분을 한 경우)
- ③ 실질적 변경 : 처분내용의 동일성이 없는 다른 처분으로 변경하는 경우
(예) 자격취소처분을 업무정지처분으로 변경)
- ④ 소 변경의 일반적 요건으로서 변경될 소가 계속되고 사실심 변론종결 전이어야 하며, 변경되는 새로운 소는 적법하여야 한다.

(3) 절차

처분변경으로 인한 소의 변경은 원고의 신청이 있어야 하고, 법원은 결정으로써 청구의 취지 또는 원인의 변경을 허가할 수 있다.

(4) 예외적 행정심판 전치주의

행정심판 전치주의가 적용되는 경우라도 변경전의 처분에 대하여 행정심판전치절차를 거쳤으면 새로운 처분에 대하여 별도의 행정심판을 거치지 않아도 된다.

(5) 효과

소의 변경을 허가하는 결정이 있게 되면, 새로운 소송은 이전의 소송(구소)이 제기된 때 제기된 것으로 보며, 구소는 취하된 것으로 본다.

5) [민사소송법]상의 소의 변경(생략)

CASE

감정평가법인A는 '업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 감정평가법 제10조의 업무를 하게 한 사유'로 업무정지처분을 받아야 하나, 표준지공시지가 업무를 수행하고 있는 법인으로서 업무정지처분에 갈음하여 동법 제41조 과징금 처분을 받았다. A법인은 과징금을 전액 납부하였다. 그런데 당해 과징금처분은 국토교통부장관이 아닌 권한 없는 행정청의 과징금 처분이었다. 그 사실을 안 A법인은 무효등확인소송을 제기하였다. A법인이 부당이득반환청구소송이라는 보다 실효적인 권리구제 수단이 있음에도 불구하고 무효등확인소송을 제기할 수 있는지 검토하시오.

01 의미 및 성질

- ① 무효등확인소송이란 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다.
- ② 여기에는 처분등의 무효확인소송, 존재확인소송, 부존재확인소송, 유효확인소송, 실효확인소송이 포함된다.
- ③ 무효등확인소송에서는 취소소송에 관한 규정 중 행정심판 전치주의(행소법 18조) 제소기간(행소법 제20조), 사정판결(행소법 제28조), 간접강제(행소법 제34조)에 관한 규정은 준용되지 않는다.
- ④ 무효등확인소송은 주관적 소송으로서 당해 처분등이 처음부터 무효임을 확인 선언하는 **확인소송**의 성질을 가진다.

[행정소송법] 제4조 (항고소송)

2. 무효등 확인소송: 행정청의 처분등의 효력 유무 또는 존재여부를 확인하는 소송

02 확인의 이익이 필요한지 여부

1) 문제점

- ① 무효등확인소송도 소의 이익이 요구된다. 이와 관련하여 민사소송에서의 확인의 이익(확인소송의 보충성)이 요구되는지 문제된다.
- ② 즉, 무효등확인소송보다 실효적인 권리구제수단이 가능한 경우에도 무효등확인소송이 허용되는지 견해의 대립이 있다.

※ 보충자료 - 확인소송의 보충성이란?

- ① 현존하는 원고의 불안이나 위험을 제거하기 위하여 확인판결을 받는 것이 유효적절한 수단인 경우에만 확인소송이 인정될 수 있고, 보다 실효적인 권리구제수단이 있다면 확인소송이 인정될 수 없는 것을 의미한다.
- ② 다른 유효적절한 권리구제수단이 없어서 확인소송을 제기하는 것이 가장 실효적인 권리구제수단이 될 때의 이익을 <확인의 이익>이라고 한다.

2) 학설

- ① 무효등확인소송에서 취소판결의 기속력(행정소송법 제30조) 규정을 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있어 확인소송의 보충성은 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>과
- ② 무효등확인소송은 확인소송의 성질을 가지고 있으므로 확인소송의 보충성이 필요하다고 보는 <보충설 필요설>이 대립한다.

3) 판례

종래에는 무효등확인소송에서 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보았으나, 최근에는

- (ㄱ) 행정소송은 민사소송과 목적, 취지, 기능 등을 달리하고,
- (ㄴ) 확정판결의 기속력에 의해 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있으며,
- (ㄷ) 외국과 달리 우리 행정소송법은 보충성을 규정하고 있지 않는다고 하여 불요설로 변경하였다.

대법원 2008. 3. 20. 선고 2007두6342 전원합의체 판결

행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다.

또한 행정소송법 제4조에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, 행정소송법 제38조 제1항에서는 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분의무에 관한 행정소송법 제30조를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다.

이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다.

4) 소결

- ① 무효등확인소송은 행정소송법 제30조를 준용하므로 무효확인판결의 기속력에 따라 무효판결만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있다.
- ② 따라서 확인소송의 보충성이 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>이 타당하다.

03 취소소송과의 관계 [★]

1) 무효사유에 대해 취소소송을 제기한 경우

- ① 당사자가 취소소송을 제기하였으나 법원의 심리결과 그 처분이 무효사유의 하자를 가지는 경우 법원은 어떠한 결정을 하여야 하는지가 문제된다.
- ② 이 경우 통설과 판례는 취소소송의 소송요건을 갖추었다면 무효선언적 의미의 취소판결을 할 수 있다는 입장이다.
- ③ 만약 취소소송의 소송요건을 충족하지 못한 경우에는 무효확인소송으로 소변경이 가능하다.
(소변경하지 않으면 각하판결)

2) 취소사유에 대해 무효확인소송을 제기한 경우

(1) 문제점

- ① 무효확인소송을 제기하였는데 그 처분의 하자가 취소사유에 불과한 경우, 취소소송의 제기요건을 갖추지 못했다면 법원은 기각판결을 하여야 한다.
- ② 그러나 당해 무효확인소송이 취소소송의 제기요건을 갖춘 경우, 법원이 어떠한 판결을 내려야 하는지가 문제된다.

(2) 학설

- ① 무효확인청구에 취소청구가 당연히 포함되어 있다고 볼 수는 없다고 하여 원고의 청구를 기각해야 한다고 보는 <청구기각판결설>
- ② 판결은 소송상 청구에 대해 내려지는 것이므로 법원은 석명권을 행사하여 무효확인소송을 취소소송으로 변경하도록 한 후 취소판결을 해야 한다고 보는 <소변경필요설>
- ③ 무효확인청구에는 원고의 명시적인 반대의사표시가 없는 한 취소청구도 당연히 포함된다고 보아 법원은 취소판결을 할 수 있다고 보는 <취소판결설>이 있다.

(3) 판례

판례는 일반적으로 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 원고가 그 처분의 취소를 구하지 아니한다고 밝히지 아니한 이상 그 처분이 만약 당연무효가 아니라면 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다고 하여 <취소판결설>의 입장을 취한다.

(4) 소결

처분이 무효라는 주장에는 취소를 구하는 뜻도 포함되어 있다고 볼 수 있으므로 판례와 같이 처분을 취소하는 판결을 할 수 있다고 보는 <취소판결설>이 타당하다.

CASE

국토부장관은 사업시행자를 A공사로, 사업시행지를 X시 일대로 ◇◇공구사업에 대하여 토지보상법에 따른 사업인정을 고시하였다. 甲은 ㉠토지 78,373㎡와 ㉡토지 2,334㎡를 소유하고 있는데, ㉠토지의 전부와 ㉡토지의 일부가 사업시행지에 포함되어 있다. 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 토지보상법에 따른 협의의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다.

협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (32회 문1번 변형)

01 의미 및 성질

- ① 부작위위법확인소송이란 행정청이 상대방의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않는 경우 이러한 부작위가 위법한 것임을 확인하는 소송을 말한다.
- ② 부작위위법확인소송에서는 취소소송에 관한 규정 중 처분변경으로 인한 소의 변경(행정소송법 제22조), 집행정지(행정소송법 제23조 제2항), 사정판결(행정소송법 제28조)에 관한 규정은 준용되지 않는다.
- ③ 부작위위법확인소송은 부작위의 위법에 대한 확인을 구하는 소송으로 확인소송의 성질을 가지며, 공권력에 대한 소송이므로 항고소송에 해당한다.

[행정소송법] 제4조 (항고소송)

3. 부작위위법확인소송: 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송

02 소송요건

1) 대상적격 (부작위)

(1) 의미

부작위라 함은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다(행정소송법 제2조 2호).

(2) 부작위 성립 요건

a. 당사자의 신청

- ① 부작위가 성립하기 위해서는 당사자의 신청이 있어야 하며, 이러한 신청이 반드시 적법할 필요는 없다.
- ② 신청권이 필요한지에 관해서는 견해가 대립하나, 판례는 당사자에게 법규상·조리상 신청권이 없는 경우 부작위위법확인소송은 부적법하다고 판시한바 있다.
- ③ 부작위가 되기 위해서는 원고가 신청한 행위가 [행정소송법]상의 처분이어야 한다.

b. 상당한 기간의 경과

부작위가 위법한 것이 되려면 당사자의 신청 후 상당한 기간이 경과하도록 행정청이 아무런 처분을 하지 않은 경우이어야 한다. 여기에서 <상당한 기간>이란 처분을 하기 위해서 통상 요구되는 기간을 의미하며, 처분의 성질·내용 등을 고려하여 판단하여야 한다.

c. 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있을 것

부작위가 되려면 행정청에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있어야 한다. <법률상 의무>에는 명문 규정에 의해 인정되는 경우뿐만 아니라, 조리상 인정되는 경우도 포함된다.

대법원 1991. 2. 12. 선고 90누5825

법령상 검사임용 신청 및 그 처리의 제도에 관한 명문 규정이 없다고 하여도 조리상 임용권자는 임용신청자들에게 전형의 결과인 임용 여부의 응답을 해줄 의무가 있다.

d. 아무런 처분을 하지 않을 것

- ① 부작위가 되려면 행정청이 아무런 처분도 하지 않아야 한다. 즉, 행정청이 거부처분을 하였다면 이는 취소소송을 제기하여야 하므로 부작위위법확인소송을 제기할 수 없다.
- ② 또한, 법령에서 일정기간 동안 아무런 처분이 없는 경우에 거부처분을 한 것으로 보는 간주거부조항이 있는 경우에도 부작위위법확인소송은 허용되지 않는다.

2) 원고적격

[행정소송법] 제36조 (부작위위법확인소송의 원고적격)

부작위위법확인소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다.

(1) 이익

부작위위법확인소송의 <법률상 이익>은 취소소송과 동일하게 <법률상 이익>을 의미한다. 다만, <처분의 신청을 한 자>의 의미가 무엇인지가 문제된다.

(2) 신청권의 요부

- ① 부작위위법확인소송에서 원고적격이 인정되기 위하여 (ㄱ) 단순히 신청한 것으로 족하다는 견해와 (ㄴ) 신청권이 있어야 한다고 보는 견해가 있다.
- ② 통설 및 판례는 부작위의 성립 요건으로 신청권을 요구하고 있으므로, 부작위가 있으면 신청권이 있는 자에게 원고적격이 인정된다고 본다.
- ③ 반면, 신청권을 요구하지 않는 견해에 의하면 신청권이 없이도 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있으면 원고적격이 인정된다.
- ④ 또한, 판례는 부작위의 직접상대방이 아닌 제3자라도 법률상 이익이 있는 한 원고적격이 인정된다고 판시한 바 있다.

3) 제소기간

(1) 문제점

- ① 행정청의 부작위에 대하여 행정심판을 거친 경우에는 취소소송의 제소기간인 [행정소송법] 제20조 (제소기간)를 따르면 된다.
- ② 그러나 행정심판을 거치지 않은 경우에는 제소기간이 문제된다.

(2) 학설

- ① 상당기간이 경과하면 처분이 있었던 것으로 보아, 행정소송법 제20조 제2항을 적용해 그 날로부터 1년 이내에 제소하여야 한다고 보는 견해와
- ② 부작위는 처분등이 없었던 것이므로 제소기간의 제한이 없다고 보는 견해가 대립한다.

(3) 판례

판례는 부작위가 계속되는 한 그 위법의 확인을 구할 이익이 있다고 보아 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다고 본다.

(4) 소결

행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판에 심판청구기간의 제한을 두고 있지 않고, 상당한 기간도 불확정적인 것으로 부작위의 종료시점을 정하기가 어려운 점을 고려하여 판례와 같이 제소기간의 제한이 없다고 보는 것이 타당하다.

03 심리의 범위

1) 문제점

부작위위법확인소송의 심리범위와 관련하여 부작위의 위법 여부만을 심리 할 수 있는지, 아니면 당사자가 신청한 처분의 실제적인 내용까지 심리할 수 있는지에 대하여 이견이 있다.

2) 학설

- ① 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법한 것임을 확인하는 소송이므로, 수소법원은 부작위의 위법 여부만을 심사할 수 있다고 보는 <절차적 심리설>
- ② 무용한 소송의 반복을 피하고 당사자의 실효적인 권리구제를 위해 신청에 따른 처분 의무가 있는지와 같은 실체적 내용도 심리할 수 있다고 보는 <실체적 심리설>이 대립한다.

3) 판례

판례는 부작위위법확인소송은 부작위의 위법을 확인하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 <절차적 심리설>의 입장을 취한다.

4) 소결

부작위위법확인소송은 부작위의 위법성을 확인하여 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 확인 소송인 점에서 판례와 같이 부작위의 위법한 여부만을 심리하는 <절차적 심리설>이 타당하다.

04 위법성 판단의 기준시점

부작위위법확인소송은 처분이 존재하지 않으므로, 위법성 판단은 <판결시>를 기준으로 하여야 한다.

05 거부처분취소소송으로 소변경 가능성

1) 문제점

- ① 부작위위법확인소송을 제기한 후 행정청이 거부처분을 한 경우에 행정소송법 제22조에 따라 처분변경으로 인한 소변경을 하여야 한다.
- ② 그러나 [행정소송법] 제37조(소의 변경)에서 동법 제21조(소의 변경)는 준용하나 제22조(처분변경으로 인한 소의 변경)에 대한 준용규정이 없어 거부처분취소소송으로 소송을 변경할 수 있는지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 행정소송법 제22조의 처분변경에 의한 소의 변경에 대한 준용규정을 두지 않은 것은 입법의 불비에 해당하므로, 행정소송법 제21조를 적용하여 소변경을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>
- ② 행정소송법 제22조를 준용하지 않으므로 처분변경으로 인한 소의 변경을 할 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

3) 판례

대법원은 부작위위법확인소송 제기 후 소극적 처분이 있어 취소소송으로 소를 변경한 사안에서 이를 인정한 바 있다.

4) 검토

- ① 부작위위법확인소송과 거부처분취소소송은 모두 일정한 처분을 받는 것을 목적으로 한다.
- ② 이에 양자의 청구의 기초에 변경이 없으므로 행정소송법 제21조를 준용하여 소의 변경이 가능하다고 보는 것이 타당하다.
- ③ 다만, 입법론적으로는 제22조에 대한 준용규정을 명확히 마련하는 것이 필요하다고 본다.

[행정소송법] 제3조 (행정소송의 종류)

2. 당사자소송 : 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송

01 의미

행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다.

02 항고소송과 구별**1) 문제의 소재**

판례상 항고소송과 당사자소송의 구별이 가장 문제되는 것은 국가를 상대로 하는 각종 급부청구의 경우인바, 금전지급신청에 대해 금전지급을 거부하는 행정청의 결정이 있는 경우에 항고소송으로 다투어야 하는지, 당사자소송으로 다투어야 하는지가 문제된다.

2) 판단기준

- ① 어떤 급부청구권이 행정청의 **인용결정**에 의하여 구체적인 권리가 비로소 발생하는 경우에는 신청에 대한 행정청의 지급결정이나 지급거부결정을 대상으로 **항고소송**을 제기하여야 한다.
- ② 반면, 행정청의 1차적 판단 없이 **법령에 의하여 곧바로 구체적인 청구권이 발생하는 경우에는** 행정청을 상대로 항고소송을 제기함 없이 곧바로 그 법률관계의 한쪽 당사자를 상대로 급부이행을 청구하는 **당사자소송**을 제기하여야 한다.

대판 2008.05.29. 2007다8129

- [1] **주거이전비**는 당해 공익사업 시행지구 안에 거주하는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원에서 지급되는 금원의 성격을 가지므로, 적법하게 시행된 공익사업으로 인하여 이주하게 된 주거용 건축물 세입자의 주거이전비 보상청구권은 **공법상의 권리**이고, 따라서 그 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 공법상의 법률관계를 대상으로 하는 **행정소송**에 의하여야 한다.
- [2] 세입자의 주거이전비 보상청구권의 형태에 관하여 보건대, 공익사업법 제78조 제5항, 제7항, 공익사업법 시행규칙 제54조 제2항 본문, 제3항의 각 조문을 종합하여 보면 위 주거이전비 보상청구권은 그 요건을 충족하는 경우에 **당연히 발생하는 것이므로**, 주거이전비 보상청구권은 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 **당사자소송**에 의하여야 할 것이다.

03 실질적 당사자소송

1) 의의

- ① 실질적 당사자소송이란 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다.
- ② 일반적으로 당사자소송이라함은 실질적 당사자소송을 의미한다.

2) 종류

(1) 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송

공법상의 부당이득반환청구소송, 공무원의 불법행위로 인한 국가배상청구소송 등이 있다.
(다만, 판례는 민사소송절차에 의하여 처리하고 있다.)

(2) 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송

공법상의 신분·지위 등의 확인소송, 공법상 금전지급청구소송, 공법상 계약에 관한 소송,
공법상 결과제거청구권, 토지보상법상 주거이전비 청구소송 등이 있다.

04 형식적 당사자소송

- ① 형식적 당사자소송이란 실질적으로는 행정청의 처분등을 다투는 것이나 형식적으로는 처분등으로 인해 형성된 법률관계를 다투기 위해 관련 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 당사자소송을 말한다.
- ② 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증액청구소송이 이에 해당한다. (개별법에서 후술)

PART 05

행정상 손해전보

Chapter 01 행정상 손해배상

제1절

행정상 손해배상(국가배상)

CASE

법원으로부터 근저당권에 근거한 경매를 위한 감정평가를 의뢰받은 감정평가사 乙이 감정평가 대상토지의 착오로 실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮게 감정평가액을 산정하였다. 토지소유자인 甲이 이에 대해 이의를 제기하였음에도 경매담당 법관 丙은 乙의 감정평가액을 최저입찰가격으로 정하여 경매절차를 진행하였으며, 대상토지는 원래의 가치보다 결국 낮게 丙에게 낙찰되어 甲은 손해를 입게 되었다. 甲이 법관의 과실을 이유로 국가배상을 청구한 경우, ① 이 청구가 인용될 가능성을 검토하고 ② 丙법관에 대한 배상 청구가 가능한지 논하시오. (25회 문3번 변형)

01 의미 및 유형

- ① 행정상 손해배상이란 공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위 또는 영조물의 하자로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배상을 해주는 제도를 말한다.
- ② 행정상 손해배상은 국가배상이라고도 하며, 국가배상법에서는 국가배상책임의 유형으로
 - (ㄱ) 공무원의 위법행위로 인한 배상책임(국가배상법 제2조)과
 - (ㄴ) 영조물의 설치·관리상의 하자로 인한 배상책임(동법 제5조)을 규정하고 있다.

02 법적성질

1) 국가배상청구권의 법적성질

(1) 학설

국가배상책임의 법적 성격에 대해 (ㄱ) 국가배상책임은 일반불법행위 책임의 한 유형에 불과한 것으로서, 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 <사권설>과 (ㄴ) 국가배상책임은 공법적 원인에 의해 발생한 것이므로 공권으로 보는 <공권설>이 대립한다.

(2) 판례

판례는 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 입장이다.

(3) 검토

생각건대, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으로 보고, 국가배상청구권의 법적 성격은 **공권**으로 보는 것이 타당하다.

2) 국가배상책임의 법적성질

(1) 문제점

[국가배상법] 제2조에서 직접적인 가해자는 공무원임에도 불구하고 피해자에 대한 배상책임은 국가 또는 지방자치단체가 부담하는 이유와 관련하여 국가배상책임의 법적성질에 대하여 대립이 있다.

(2) 학설

- ① 위법한 공무원의 행위는 국가등의 행위로 볼 수 없으므로, 공무원 자신이 배상책임을 져야 하나, 피해자 구제를 위하여 국가가 대신하여 책임을 지는 것으로 보는 <대위책임설>
- ② 공무원의 행위의 효과는 국가등의 행위로 귀속되므로 배상책임은 국가등의 자기책임이라고 보는 <자기책임설>
- ③ 공무원의 위법행위가 **경과실**인 경우에는 공무원의 행위는 국가 행위이므로 국가가 자기책임으로서 배상책임을 지지만, **고의 또는 중과실**에 의한 것일 때에는 기관의 행위로서 품격을 상실하므로 원칙적으로 공무원 개인의 책임이나, 피해자 구제를 위해 국가가 대신하여 책임지는 것이라고 보는 <절충설>이 있다.

(3) 판례

판례는 경과실의 경우에는 자기책임으로 보고, 고의*중과실인 경우에는 대위책임이라고 보아 <절충설>의 입장이다.

(4) 검토

- ① 위법행위가 공무원의 고의 또는 중과실에 기한 경우에 그 행위는 기관행위로서 품격을 상실하게 된다.
- ② 그러나 그 행위의 외관이 여전히 공무원의 직무행위로 보여진다면 피해자와의 관계에서는 기관의 행위로 인정하여야 하며, 피해자인 국민을 두텁게 보호하기 위해 국가가 **자기책임**으로 배상하는 것이 타당하다.

03 공무원의 배상책임 (피해자의 선택적 청구권)

1) 문제점

헌법 제29조 제1항 단서는 공무원 개인의 책임은 면제되지 않는다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 국가배상책임에서 가해 공무원 개인도 피해자에 대해서 배상책임을 지는지가 문제 된다.

[헌법] 제29조

- ① 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다.

2) 학설

- ① 국가배상책임을 **자기책임**으로 보는 입장에서 국가와 공무원 개인의 책임은 독립해서 성립되고, 피해자의 권리구제를 폭넓게 보장하기 위하여 선택적 청구권 행사를 긍정하는 <긍정설>
- ② 국가배상책임을 **대위책임**으로 보는 입장에서 공무원의 직접책임을 인정하는 것은 공무원의 직무집행을 위촉시킬 우려가 있으므로 선택적 청구권 행사를 부정하는 <부정설>
- ③ **경과실**에 기한 것인 경우는 여전히 기관행위이므로 국가만이 책임을 지고, **고의·중과실**인 경우에는 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권을 긍정하는 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

전원합의체 판례의 다수의견은 경과실의 경우에는 부정하고, 고의·중과실의 경우에는 공무원 개인의 책임을 긍정하여 **절충설**의 입장이다.

4) 소결

- ① 헌법 제29조 제1항 단서에서 공무원의 책임이 면제되지 않는다고 규정하고 있으나 구체적인 손해배상책임의 범위까지 규정하고 있지는 않고, 국가배상법은 공무원의 내부적 책임만 규정하고 있을 뿐 외부적 책임에 대해서는 규정한 바 없다.
- ② 따라서 양자를 조화롭게 해석하고 공무원의 직무집행행위를 위촉시키지 않기 위해서 고의·중과실의 경우에만 공무원 개인의 책임을 인정하는 <**제한적 긍정설**>이 타당하다.

04 공무원의 구상책임

- ① 국가나 지방자치단체가 국가배상책임을 지는 경우에 공무원에게 **고의 또는 중과실**이 있으면 국가나 지방자치단체는 공무원에게 구상할 수 있다.
- ② 경과실의 경우 공무원의 사기저하와 사무정체를 방지하기 위해 정책적 고려에서 구상을 인정하지 않고 있다.

[국가배상법] 제2조 (배상책임)

- ② 제1항 본문의 경우에 공무원에게 고의 또는 중대한 과실이 있으면 국가나 지방자치단체는 그 공무원에게 구상(求償)할 수 있다.

CASE

甲은 S시에 임야 30,000㎡를 소유하고 있다. S시장은 甲 소유의 토지에 대하여 토지의 이용상황을 실제 이용되고 있는 '자연림'으로 하여 개별공시지가를 산정한 다음 A감정평가법인에 검증을 의뢰하였는데, A감정평가법인이 그 토지의 이용상황을 '공업용'으로 잘못 정정하여 검증지가를 산정하고, 시 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의 하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다. 이에 따라 甲소유 토지의 개별공시지가가 적정가격 보다 훨씬 높은 가격으로 결정, 공시되었다 B은행은 S시의 공시지가를 신뢰하고, 甲에게 70억 원을 대출하였는데, 甲이 파산함에 따라 채권 회수에 실패하였다.

B은행은 S시를 대상으로 국가배상을 청구하였다. S시의 개별공시지가 결정행위가 국가배상법 제2조상의 위법행위에 해당하는가에 관하여 논하시오. (24회 문2번)

[국가배상법] 제2조 (배상책임)

- ① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 "공무원"이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다.(이하 생략)

01 공무원

- ① 국가배상법 제2조의 <공무원>은 행정부, 입법부, 사법부 소속의 공무원 및 지방자치단체의 공무원을 포함하며, 실질적으로 공무를 수행하는 <기능적 의미의 공무원>을 말한다.
- ② 판례는 공무를 위탁받은 사인인 공무수탁사인의 경우 공무의 위탁이 일시적이고 한정적인 경우에도 공무원에 해당한다고 판시한 바 있다.

02 직무행위

직무행위의 범위에 대해 견해 대립이 있으나, 판례는 국가배상청구의 요건인 <공무원의 직무>에는 권력적 작용만이 아니라 비권력적 작용도 포함되며 단지 행정주체가 사경제주체로서 하는 활동만 제외된다고 하여 광의설의 입장을 취한다.

03 직무를 집행하면서 행한 행위 (직무 관련성)

- ① 직무를 <집행하면서>는 단순한 직무 집행행위뿐만 아니라 널리 외형상 직무집행과 관련 있는 행위를 포함한다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다(외형설).
- ② 즉, 비록 실질적으로 직무행위가 아니거나 주관적으로 공무집행 의사가 없다고 하더라도 외관상 공무원의 집행행위로 보여진다면 <직무를 집행하면서>에 포함되는 것으로 보아야 한다.

04 고의 또는 과실

1) 과실책임주의

- ① (ㄱ) 고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고,
(ㄴ) 과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태 하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 의미한다.
- ② 과실에는 중과실과 경과실을 모두 포함한다.

2) 과실의 객관화 경향

- ① [국가배상법]상 과실을 행위자의 주관적 심리상태로 보는 것이 아니라, <당해 직무를 담당하는 평균적 공무원의 주의의무>를 기준으로 과실을 판단한다.
- ② 가해공무원의 특징이 필수적인 것은 아니며, 고의·과실의 입증책임은 원고가 부담한다.

3) 구체적인 검토

(1) 법령의 해석 및 적용

- ① 판례는 원칙적으로 공무원이 관계 법규를 알지 못하거나 필요한 지식을 갖추지 못해 법규의 해석을 그르친 경우에는 과실이 있다고 본다.
- ② 그러나 법령에 대한 해석이 명백하지 않은 등의 이유로 관계 공무원이 그 나름대로 신중을 다하여 합리적인 근거를 찾아 그 중 어느 한 견해를 따라 내린 해석이 후에 대법원의 입장과 달라 결과적으로 위법하게 된 경우까지 공무원의 과실을 인정할 수는 없다고 판시한 바 있다.

(2) 처분의 근거 법령의 위헌·위법선언과 공무원의 과실

- ① 처분의 근거가 된 법규가 나중에 위헌 또는 위법으로 된 경우에는 공무원에게 일반적으로 과실이 있다고 보기 어렵다.
- ② 왜냐하면, 공무원에게는 법률의 위헌여부를 심사할 권한이 없어서 명백한 무효가 아니라면 공무원으로서는 법률을 적용할 수밖에 없기 때문이다.

(3) 행정규칙에 따른 처분

행정규칙에 정해진 기준에 따른 처분이 나중에 위법한 처분임이 판명되어 취소되었다고 하더라도, 당해 공무원에게 직무상의 과실이 있다고 할 수 없다.

05 법령의 위반

1) 문제점

국가배상책임의 요건이 되는 <법령위반>을 어떻게 이해할 것인지에 대하여 견해의 대립이 있다.

2) 학설

- ① 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법과 동일하게 보아 행위 자체의 법령위반으로 파악하는 <협의의 행위위법설>
- ② 국가배상법상의 위법을 취소소송의 위법보다 넓게 보아 법령 위반 뿐만 아니라 널리 인권존중, 공서양속, 신의성실의 원칙의 위반 등도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>
- ③ 행위자체의 위법뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여 행위가 객관적으로 정당성을 결여하였는지 여부로 판단해야 한다고 보는 <상대적 위법성설>
- ④ 취소소송의 위법성과는 달리 피해의 결과에 따라 위법성을 판단하여, 손해가 수인한도를 넘으면 위법행위가 된다고 보는 <결과불법설> 등이 있다.

3) 판례

- ① 판례는 공무원의 직무집행이 법령이 정한 요건과 절차에 따라 이루어진 것이라면 특별한 사정이 없는 한 법령에 적합한 것이고, 그 과정에서 개인의 권리가 침해된다고 하여 법령적합성이 곧바로 부정되는 것은 아니라고 하여 결과불법설은 배척하고 행위위법성설에 입각한 판시도 한 바 있으며
- ② 최근 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위의 태양 및 원인, 손해의 정도 등 제반사정을 종합하여 객관적 정당성을 상실하였는지 여부를 기준으로 판단하여 상대적 위법성설을 따르는 듯한 판례도 있어, 판례의 입장은 명확하지 않다.

4) 소결

- ① 국가배상법이 법치주의의 요청에 따라 법규범을 위반한 직무행위에 의하여 발생된 손해에 대한 국가 등의 배상책임임을 인정하기 위하여 제정되었음을 볼 때, 기본적으로 행위위법설이 타당하다.
- ② 손해전보를 목적으로 하는 국가배상에서 반드시 항고소송의 위법과 동일하게 볼 필요는 없으며, 인권보장의 측면에서 볼 때, 공무원에게 직무상의 일반적 손해방지의무를 인정하는 것이 타당하므로 행위위법설 중에서도 광의의 행위위법설이 타당하다.

06 손해 및 인과관계

- ① 국가배상책임이 인정되기 위해서는 공무원의 불법행위로 인해 손해가 발생 되어야 한다.
- ② <손해>는 가해행위로 인해 발생한 일체의 손해로서 법률상 이익의 침해를 말하며, 반사적 이익의 침해는 해당되지 않는다.
- ③ 손해는 적극적·소극적 손해를 불문하고, 생명·신체·정신상의 손해도 포함된다.
- ④ 또한, 가해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데, <상당인과관계>의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

I

기판력과 국가배상청구소송

01 문제점

- ① 취소소송의 확정판결이 난 후, 국가배상청구소송을 제기했을 때 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 여부가 문제된다.
- ② 이는 취소소송에 있어서 위법과 국가배상청구소송에 있어서 위법이 동일한가 하는 문제와 관련이 있다.

02 학설

- ① 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 동일한 개념이라고 보아 취소소송의 확정판결의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <기판력 긍정설, 협의의 행위위법설>
- ② 국가배상청구소송의 위법의 범위가 취소소송의 위법보다 넓다고 보아 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치나, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 보는 <제한적 긍정설, 광의의 행위위법설>
- ③ 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 다른 개념으로 보고, 양자의 소송물이 달라 기판력이 미치지 않는다고 보는 <기판력 부정설, 결과불법설·상대적위법성설>

03 판례

판례는 어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없다고 보아, 이에 대한 판례의 입장은 명확하지 않다.

04 검토

- ① 취소소송과 국가배상청구소송의 위법의 개념을 어떻게 보는지에 따라 취소판결의 기판력이 미치는지 여부가 달라진다.
- ② 국가배상청구소송의 위법을 취소소송의 위법보다 더 넓게 보는 광의의 행위위법설에 따르면, 인용판결의 기판력만이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <제한적 긍정설>이 타당하다고 본다.

01 문제점

- ① 국가배상법 제2조의 <공무원>에 법관도 포함되고, 재판행위도 직무에 해당한다.
- ② 그러나 법관의 재판행위의 결과인 확정판결이 있으면 기판력이 발생 되므로 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능한지가 문제 된다.

02 학설

- ① 국가배상책임을 인정하여도 확정판결의 기판력을 침해하는 것은 아니라는 <국가배상청구 긍정설>
- ② 국가배상책임을 인정하는 것이 확정판결의 효력을 부정하는 것은 아니지만, 판결의 위법성이 인정되어야 하고, 이는 기판력을 침해하는 것이므로 부정하는 <국가배상청구 부정설>
- ③ 재판행위의 특수성을 고려하여 법적 안정성과 국민의 권리구제를 적절히 조화시켜 제한적으로 인정하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

03 판례

판례는 법관의 재판행위에 국가배상책임이 인정되려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였거나 법관이 그에게 부여된 권한의 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다고 하여 **제한적으로 인정**하고 있다.

04 소결

- ① 법관도 공무원이고 재판행위도 직무에 포함되므로 <국가배상청구 긍정설>에 따라 위법한 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능하다고 보는 것이 타당하다.
- ② 다만, 위법과 과실의 인정을 엄격히 하여 재판의 독립성이 침해되지 않도록 해야 할 것이다.

01 문제점

- ① 부작위에 의한 국가배상에서의 부작위는 신청을 전제로 하지 않는다. 따라서 [국가배상법]상 부작위는 행정권의 불행사를 의미한다.
- ② 부작위는 작위의무를 전제로 하므로
 - (ㄱ) 조리상 작위의무를 인정할 수 있는지의 문제,
 - (ㄴ) 재량행위에 있어 부작위의 위법성의 문제,
 - (ㄷ) 부작위에 의한 손해배상책임에 있어서 작위의무의 사익보호성이 요구되는가의 문제 등이 문제된다.

02 조리에 의한 작위의무의 인정여부

1) 문제점

작위의무가 법령에서 명문으로 규정되어 있지 않은 경우에도 조리상 작위의무를 인정할 수 있는지에 대해서 견해의 대립이 있다.

2) 학설

- ① 법률에 의한 행정의 원칙에 비추어 법률상의 근거가 없는 경우에는 작위의무를 인정할 수 없다는 부정설
- ② 국민의 생명과 재산을 보호하여야 한다는 국가의 임무에 비추어 위험방지 의무를 인정하는 긍정설이 대립하고 있다.

3) 판례

형식적 의미의 법령에 명시적으로 공무원의 작위의무가 규정되어 있지 않음에도 일정한 경우에 위험방지의무를 인정하고 있다.

4) 검토

피해자의 구제를 목적으로 하는 국가배상에 있어서 법률에 의한 행정의 원리를 강조하는 것은 타당하지 않으며, 법치행정의 목적도 인권보장이라는 점, 생명과 재산을 보호하여야 한다는 것이 국가의 기본권보호의무에 비추어 조리에 의한 위험방지의무를 인정하는 긍정설이 타당하다.

03 재량행위에 있어 부작위의 위법성 여부

- ① 재량행위의 경우 행정청은 권한 행사여부에 대한 독자적인 판단권이 있으므로 부작위는 원칙적으로 위법하지 않다.
- ② 그러나 재량이 영으로 수축되어 권한의 행사만이 합당한 경우에는 부작위는 위법한 것이 되어 그로 인하여 손해를 받은 자는 국가배상청구가 가능하다.
- ③ 판례는 권한의 불행사가 객관적 정당성을 상실하여 현저하게 합리성을 잃어 사회적 타당성을 잃은 경우에는 국가배상청구를 인정한다.

04 직무상 작위의무의 사익보호성 요부

1) 문제점

직무상 의무위반이 국가배상법상 위법이 되기 위해 직무상 사익보호성이 요구되는지에 관하여 견해의 대립이 있다.

2) 학설

- ① 공무원의 직무상 의무를 규율하는 법령이 공익뿐만 아니라 국민 개개인의 이익을 보호하는 것을 목적으로 할 때 국가배상법상의 위법성이 인정된다고 보는 견해(적극설)
- ② 직무의 사익보호성 여부와 관계없이 법령에 위반하면 모두 위법으로 보아야 한다는 견해(소극설)이 대립한다.

3) 판례

판례는 직무상 의무위반으로 인한 손해에 대하여 국가배상책임이 인정되기 위해서는 당해 직무상 의무가 공익뿐만 아니라 국민 개개인의 이익을 보호목적으로 하고 있어야 한다고 한다.

4) 소결

생각건대, 법령의 사익보호성이 인정되지 않는 경우에는 피해자인 사인과의 관계에서 위법하다고 보기 어려우므로 위법성의 문제로 보는 것이 타당하다.